2026

에듀랜드 공인중개사

제 37 회 공인중개사 시험대비 전면개정판

기본서 ❶ 민법 및 민사특별법

에듀랜드

CONTENTS

PART 01 민법총칙

CHAPTER 01 민법(民法)의 기초 9
제 1 절 권리의 변동(법률효과) 9
제 2 절 법률행위(法律行爲) 일반 12

CHAPTER 02 법률행위의 목적 16
제 1 절 목적의 확정・가능・적법 16
제 2 절 목적의 사회적 타당성(社會的 妥當性) 20

CHAPTER 03 의사표시(意思表示) 28
제 1 절 법률행위의 해석(解釋) 28
제 2 절 비정상적 의사표시 30
제 3 절 의사표시의 효력발생 44

CHAPTER 04 법률행위의 대리(代理) 47
제 1 절 서 설 47
제 2 절 대리의 3면관계 48
제 3 절 복대리(復代理) 55
제 4 절 무권대리(無權代理) 58

CHAPTER 05 법률행위의 무효와 취소 68
제 1 절 법률행위의 무효(無效) 68
제 2 절 법률행위의 취소(取消) 76

CHAPTER 06 조건과 기한 82
제 1 절 서 설 82
제 2 절 조건(條件) 82
제 3 절 기한(期限) 86

PART 02 물권법

CHAPTER 01	**물권법 총론(總論)**	**90**
제 1 절	물권의 의의 및 종류	90
제 2 절	물권의 효력	93
CHAPTER 02	**물권의 변동(變動)**	**96**
제 1 절	서 설	96
제 2 절	부동산물권변동	97
제 3 절	부동산물권의 공시방법(등기)	99
제 4 절	물권의 소멸	107
CHAPTER 03	**점유권(占有權)**	**110**
제 1 절	총 설	110
제 2 절	점유의 모습(점유의 태양)	112
제 3 절	점유의 승계	117
제 4 절	점유권의 효력	118
제 5 절	점유의 보호	122
CHAPTER 04	**소유권(所有權)**	**126**
제 1 절	소유권의 범위	126
제 2 절	소유권에 기한 물권적 청구권	132
제 3 절	소유권의 취득	135
제 4 절	공동소유(共同所有)	144
CHAPTER 05	**용익물권(用益物權)**	**156**
제 1 절	지상권(地上權)	156
제 2 절	지역권(地役權)	168
제 3 절	전세권(傳貰權)	172
CHAPTER 06	**담보물권(擔保物權)**	**181**
제 1 절	담보물권의 공통적 성질	181
제 2 절	유치권(留置權)	182
제 3 절	저당권(抵當權)	189

CONTENTS

PART 03 계약법

CHAPTER 01 계약법 총론(總論) 203
제 1 절 계약 일반 203
제 2 절 계약의 성립 206
제 3 절 계약의 효력 212
제 4 절 계약의 해제와 해지 220

CHAPTER 02 계약법 각론(各論) 228
제 1 절 매매(賣買) 228
제 2 절 교환(交換) 244
제 3 절 임대차(賃貸借) 246

PART 04 민사특별법

CHAPTER 01 주택임대차보호법 263
제 1 절 서 설 263
제 2 절 대항력 264
제 3 절 보증금의 회수 268
제 4 절 임차권등기명령 272
제 5 절 임대차기간 및 계약의 갱신 · 차임 · 기타 273

CHAPTER 02 상가건물임대차보호법 277
제 1 절 서 설 277
제 2 절 대항력(對抗力) 278
제 3 절 보증금의 회수 280
제 4 절 임차권등기명령 281
제 5 절 존속기간의 보장 282
제 6 절 권리금 284
제 7 절 기 타 286

CHAPTER 03 가등기담보 등에 관한 법률 287
제 1 절 가등기담보의 의의 및 성질 287
제 2 절 가등기담보법의 적용범위 288
제 3 절 가등기담보권의 실행 289

CHAPTER 04 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 294

CHAPTER 05 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 302
제 1 절 서 설 302
제 2 절 구분소유의 요건 302
제 3 절 집합건물의 구성요소 303
제 4 절 공용부분 305
제 5 절 구분소유자의 의무와 책임 308
제 6 절 담보책임 309
제 7 절 관리단 및 관리단의 기관 311
제 8 절 규약 및 집회 313
제 9 절 재건축 및 복구 315

PART 01

민법총칙

CHAPTER 01 민법(民法)의 기초

CHAPTER 02 법률행위의 목적

CHAPTER 03 의사표시(意思表示)

CHAPTER 04 법률행위의 대리(代理)

CHAPTER 05 법률행위의 무효와 취소

CHAPTER 06 조건과 기한

CHAPTER

01 민법(民法)의 기초

제 1 절 권리의 변동(법률효과)

Ⅰ 총설(總說)

1. 민법의 의의와 권리 · 의무

(1) **민법의 의의**

민법은 많은 법률관계 중에서도 이러한 '개인과 개인 사이의 법률관계(권리 · 의무관계)를 규율하는 법'이다.

(2) **권리와 의무**

① 권리란 일반적으로 '일정한 이익을 누릴 수 있도록 법이 인정한 힘'을 말하며, 의무란 '반드시 따라야 할 법률상의 구속' 을 말한다.

② 권리와 의무는 대체로 서로 대응하는 관계에 있으나, 민법은 권리 중심으로 구성되어 있으므로 권리 중심으로 공부한다.

(3) **물권과 채권**

① 물권이란 물건을 직접 지배하여 그로부터 발생하는 이익을 배타적으로 누릴 수 있는 권리를 말한다(소유권, 점유권, 지상권, 지역권, 전세권, 유치권, 저당권 등). 물권은 물건을 직접 지배하면서 누구에게나 주장할 수 있다는 점에서 절대권(絶對權) 또는 대세권(對世權)이라고도 한다.

② 채권이란 특정인(채권자)이 다른 특정인(채무자)에게 일정한 행위(급부)를 청구할 수 있는 권리를 말한다. 채권은 특정한 사람에 대한 권리이므로 이를 상대권(相對權) 또는 대인권(對人權)이라고도 한다.

2. 민법의 구조와 권리변동의 의의

(1) 법률관계는 고정되어있는 것이 아니라 끊임없이 변한다. 민법은 이러한 수많은 법률관계를 대체적으로 일정한 원인이 있으면 일정한 결과가 발생하는 모습으로 규정하고 있다. 일정한 결과로써 나타나는 것을 권리의 변동이라 하며, 이를 '법률효과'라 하고, 이러한 법률효과를 발생시키는 원인을 '법률요건'이라 한다.

(2) 즉, '권리의 변동'이란 법에서 인정하는 일정한 원인(법률요건)이 있을 때 결과로써 발생하는 법률효과로 '권리의 발생 · 변경 · 소멸'을 말하며, 이를 권리의 주체입장에서 본다면 '권리의 취득 · 변경 · 상실(득실변경)'으로 표현할 수 있다.

Ⅱ 권리변동의 모습

1. 권리의 발생(취득)

① 원시취득(原始取得, 절대적 발생)

㉠ 의의 : 타인의 권리에 기함이 없이 특정인이 어떤 권리를 새로이 취득하는 것을 말한다.

㉡ 종류 : 무주물선점, 유실물습득, 매장물발견, 시효취득, 선의취득, 첨부 등에 의한 소유권취득, 신축건물의 소유권취득 등이 원시취득에 해당한다.

② 승계취득(承繼取得, 상대적 발생)

㉠ 의의 : 승계취득이란 '타인의 권리에 기초하여 특정인이 권리를 승계적으로 취득하는 것'을 말한다. 이에는 '이전적 승계'와 '설정적 승계'가 있다.

㉡ 이전적(移轉的) 승계

전 권리자의 권리가 동일성을 유지하면서 새로운 권리자에게 이전되는 경우를 말한다. 권리의 주체가 바뀌는 것이다.

ⓐ 특정승계(特定承繼)

매매 · 교환 · 증여 · 사인증여 · 경락에 의한 권리취득처럼 개개의 취득원인에 의해 개개의 권리가 취득되는 경우이다.

ⓑ 포괄승계(包括承繼)

상속 · 포괄유증 · 회사합병에 의한 권리취득처럼 하나의 취득원인에 의해 다수의 권리가 일괄적으로 취득되는 경우이다.

㉢ 설정적(設定的) 승계

전 권리자는 그의 권리를 그대로 보유하면서 새로운 권리자가 전 권리자의 권리의 권능(내용) 중 '일부'를 취득하는 것을 말한다. 소유권에 대해 지상권 · 지역권 · 전세권 · 유치권 · 질권 · 저당권 등의 제한물권을 설정하는 경우가 이에 해당한다.

2. 권리의 변경

① 주체의 변경

권리의 이전적 승계가 있으면 권리주체가 변경된다.

② 내용의 변경

㉠ 질적 변경(성질적 변경)

물건인도청구권이 손해배상청구권으로 변경되는 경우 등을 말한다.

㉡ 양적 변경(수량적 변경)

소유권의 객체에 제한물권이 설정되는 경우 등을 말한다.

③ 작용(作用)의 변경

임차권이 등기에 의해 대항력을 가지게 되는 경우 등을 말한다.

3. 권리의 소멸

① 절대적 소멸(객관적 소멸)

권리 자체가 객관적으로 소멸하는 것으로서 목적물멸실 · 소멸시효 · 포기 · 변제 · 혼동 · 공용징수 · 몰수로 인한 권리의 소멸이 이에 해당한다.

② 상대적 소멸(주관적 소멸, 주체의 변경)

甲이 소유하는 가옥을 乙에게 매각하여 그 소유권이 상실하는 경우처럼 권리 자체는 소멸하지 않고 권리주체만 변경되는 것이다.

Ⅲ 권리변동의 원인(법률요건)

① 법률요건이란 법률효과를 발생하게 하는 원인 내지 법률관계변동의 원인을 말한다. 법률요건은 일정한 법률효과를 발생시키기 위해 필요한 모든 법률사실을 다 갖춘 상태에 해당한다.

② 법률요건은 행위자가 원하는 대로 법률효과가 발생하는 '법률행위(계약 등)'와 행위자가 원하든 원하지 않든 법률의 규정에 의하여 법률효과가 발생하는 '법률규정(상속, 판결, 경매 등)'으로 나뉜다.

제 2 절 법률행위(法律行爲) 일반

Ⅰ 법률행위의 의의

① 법률행위란 일정한 법률효과의 발생을 목적으로 하는 하나 또는 수개의 의사표시를 (필수)불가결의 요소로 하는 법률요건을 말한다.

② 의사표시는 법률행위의 필수불가결한 요소이지 유일한 요소인 것은 아니다. 즉, 법률행위는 경우에 따라 의사표시만으로 구성되어 있는 것은 아니고 의사표시 외의 다른 요소를 구성요소로 하는 경우도 있다.

Ⅱ 법률행위의 종류

1. 의사표시의 수와 방향에 따른 분류

(1) **단독행위**

① **의의** : 행위자의 한 개의 의사표시로 성립하는 법률행위이다.

② **종류**

㉠ **상대방 있는 단독행위** : 의사표시를 수령할 자가 특정되어 있고 상대방에게 의사표시가 도달해야 효력이 생기는 단독행위를 말한다. 동의 · 상계 · 대리권수여 · 채무면제 · 철회 · 취소 · 추인 · 해제 · 해지 · 시효이익의 포기 · 기한의 이익포기 등이 이에 해당한다.

㉡ **상대방 없는 단독행위** : 의사표시를 수령할 자가 특정되어 있지 않고, 상대방에게 도달할 필요 없이 의사표시의 성립과 동시에 효력이 생기는 단독행위를 말한다. 유언, 유증, 재단법인설립행위, 소유권의 포기, 점유권의 포기 등이 이에 해당한다.

③ **특징** : 일방적 의사표시에 의해 법률효과가 발생하므로 주로 법률에 규정이 있을 때에만 인정된다. 또한 단독행위에는 원칙적으로 조건이나 기한을 붙일 수 없다.

(2) **계 약**

① 계약이란 '서로 대립하는 두 개의 의사표시(청약과 승낙)의 합치에 의하여 성립하는 법률행위'를 말한다.

② 넓은 의미로는 채권계약, 물권계약, 가족법상 계약 등이 포함되지만, 좁은 의미로 계약이라고 할 경우에는 매매 · 교환 · 임대차 등 채권계약만을 가리킨다.

(3) **합동행위** : 합동행위는 2개 이상의 의사표시가 서로 같은 방향으로 합치하여 성립하는 법률행위이다. 사단법인의 설립행위 등이 이에 해당한다.

2. 이행의 문제 유무에 따른 분류

(1) 의무부담행위(채권행위)

① 의무부담행위란 당사자에게 일정한 채권 · 채무를 발생시키는 법률행위를 말하는데 언제나 이행의 문제를 남기는데 특색이 있다. 채권행위(매매, 교환, 임대차 등)가 이에 해당한다.

② 권리에 대한 처분권이 없는 무권리자도 부담행위는 할 수 있으므로 타인의 물건을 매매한 경우에 그 매매계약도 유효하다.

(2) 처분행위(물권행위 · 준물권행위)

① 의의

처분행위란 권리를 직접 이전 · 변경 · 소멸시키는 법률행위로서 이행의 문제를 남기지 않는다.

② 물권행위

직접 물권의 변동을 목적으로 하는 법률행위이다(소유권이전행위, 제한물권 설정행위 등).

③ 준물권행위

물권이외의 권리의 변동을 목적으로 하는 법률행위를 말한다(채권양도, 채무면제 등).

④ 처분행위의 특징

처분행위는 처분권 있는 자만이 할 수 있고, 처분권 없는 자가 한 처분행위는 무효이다.

3. 법률행위 방식에 따른 분류

(1) 요식행위(要式行爲)

요식행위란 일정한 방식에 따라 행해져야 효력이 인정되는 법률행위를 말한다. 이에는 혼인, 유언, 법인설립행위 등이 있다.

(2) 불요식행위(不要式行爲)

방식에 구애받지 않고 자유롭게 할 수 있는 법률행위를 말한다. 계약자유의 원칙상 법률행위는 불요식 행위가 원칙이다.

Ⅲ 법률행위의 요건

1. 의 의

법률행위가 완전 유효하게 법률효과를 발생하기 위해서는 일정한 요건을 갖추어야 한다. 첫째는 법률행위로서 성립하여 존재하기 위한 요건(성립요건)을 갖추어야 하고, 다음으로는 일단 성립한 법률행위가 무효나 취소가 되지 않고 완전 유효하기 위한 요건(유효요건, 효력요건)을 갖추어야 한다.

2. 법률행위의 성립요건

① 의의

어떤 행위가 법률행위로 인정될 수 있는 최소한의 형식적 요건을 말하며, 이는 법률행위의 효과를 주장하는 당사자가 그 입증책임을 부담한다.

② 일반적 성립요건

모든 법률행위의 성립에 필요한 공통적 요건으로서 법률행위의 당사자, 법률행위의 내용으로서 목적, 법률행위의 불가결의 요소로서 의사표시가 있어야 한다.

3. 법률행위의 효력(유효)요건

① 의의

법률행위로서의 형식적 요건을 갖춘 행위가 법률상 실질적으로 유효하기 위한 요건을 말하며, 이에 대해서는 법률행위의 무효를 주장하는 자가 그 부존재에 대하여 입증책임을 부담한다.

② 일반적 효력요건

㉠ 당사자가 권리능력 · 의사능력 · 행위능력을 가져야 한다. 권리능력 · 의사능력을 갖추지 못하면 그 법률행위는 무효가 되며, 행위능력을 갖추지 못한 제한능력자의 행위는 취소사유에 해당한다.

㉡ 법률행위의 목적(내용)이 확정할 수 있고, 실현가능하며, 적법하고, 사회적 타당성이 있어야 한다. 이 중 어느 하나라도 갖추지 못하면 그 법률행위는 무효이다.

㉢ 법률행위를 구성하는 의사표시에 관하여 의사와 표시가 일치하고, 의사표시에 하자가 없어야 한다.

보충학습 당사자의 능력

1. 권리능력
   ① 권리능력이란 법률상 권리와 의무의 주체가 될 수 있는 능력을 말한다.
   ② 권리능력자로 민법은 '자연인'과 '법인'을 두고 있다. 또한 민법 제3조는 "사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다." 라고 규정하고 있다.
2. 의사능력
   ① 의사능력이란 자기가 행하는 어떠한 행위의 의미나 결과를 판단할 수 있는 정상적인 능력을 말한다.
   ② 만취한 자나 유아 등은 의사능력이 없는 의사무능력자이고 의사무능력자의 법률행위는 무효이다.
3. 행위능력
   ① 행위능력이란 단독으로 유효한 법률행위를 할 수 있는 능력을 말한다.
   ② 행위능력이 제한받는 자를 제한능력자라고 한다. 미성년자(19세 미만), 피성년후견인(정신적 제약으로 사무처리능력이 지속적으로 결여된 자), 피한정후견인(정신적 제약으로 사무처리능력이 부족한 자)이 이에 해당한다.
   ③ 이러한 제한능력자의 법률행위는 취소할 수 있다.

③ 특별효력요건

㉠ 특별효력요건은 법률의 규정이나 당사자의 특약에 의하여 요구되는 것으로써 대리행위에 있어서 대리권의 존재, 토지거래허가제에 있어서 주무관청의 허가, 정지조건부 법률행위에 있어서 조건의 성취, 시기부 법률행위에 있어서 기한의 도래, 유언에 있어서 유언자의 사망 등이 있다.

㉡ 그러나 농지취득자격증명은 농지취득의 원인이 되는 법률행위(매매 등)의 효력을 발생시키는 요건은 아니다.

CHAPTER

02 법률행위의 목적

제 1 절 목적의 확정 · 가능 · 적법

Ⅰ 목적의 확정(確定)

① 법률행위의 목적은 확정할 수 있어야 하는데, 법률행위 당시에 확정되어 있어야 하는 것은 아니고 늦어도 법률행위 내용을 실현할 당시까지(이행기) 확정될 수 있으면 된다.

② 따라서 매매계약에 있어서 그 목적물과 대금은 반드시 계약체결 당시에 구체적으로 특정될 필요는 없고 이를 사후에라도 구체적으로 특정할 수 있는 방법과 기준이 정해져 있으면 족하다[96다26176].

Ⅱ 목적의 가능(可能)

1. 의 의

① 법률행위의 목적은 그 실현이 가능한 것이어야 한다. 법률행위 성립당시에 그 목적이 실현할 수 없는 것이면 무효이다.

② 법률행위의 내용이 실현가능한가 여부는 사회통념에 의해 결정된다. 따라서 물리적으로 불능의 경우는 물론, 비록 물리적으로는 가능하더라도 사회통념상 불가능한 경우에도 불능이다.

2. 불능의 종류

(1) 원시적 불능과 후발적 불능

① **원시적 불능** : 법률행위 성립 당시부터 그 실현이 불능인 경우를 말한다. 예컨데 매매계약체결 전에 이미 건물이 멸실된 경우와 같은 경우를 말하는데, 원시적 불능의 경우에 그 법률행위는 무효이고, 계약체결상의 과실책임(제533조)이 문제될 수 있다.

② **후발적 불능** : 법률행위 성립당시에는 실현이 가능하였으나 그 이행 전에 불능이 된 경우를 말한다. 예컨대, 매매계약체결 당시에는 건물이 존재하였으나 계약체결 후 이행하기 전에 건물이 멸실된 경우와 같은 경우로서 후발적 불능의 경우에는 법률행위 자체는 유효하고, 채무자의 귀책사유(고의 또는 과실) 유무에 따라 채무불이행(이행불능 제390조)이나 위험부담(제537조)의 문제가 발생한다.

(2) 전부불능과 일부불능

① 전부불능

법률행위 목적의 전부가 불능인 경우를 말한다. 원시적으로 전부불능이면 법률행위는 무효가 되고 계약체결상의 과실책임이 문제될 수 있으며, 후발적으로 전부불능이면 법률행위 자체는 유효하고, 채무불이행이나 위험부담의 문제가 발생한다.

② 일부불능

법률행위 목적의 일부만이 불능인 경우를 말한다. 유상계약의 경우 계약은 유효하고 담보책임이 문제된다(제574조).

Ⅲ 목적의 적법성(適法性)

1. 의 의

법률행위의 목적이 적법하여야 한다는 것은 법규정 중에 강행규정에 위반하지 않아야 한다는 것을 의미한다.

2. 강행규정과 임의규정

(1) 강행규정

① 강행규정이란 선량한 풍속 기타 사회질서에 관한 규정으로서 당사자의 의사에 의하여 이를 배제하거나 변경할 수 없는 규정을 말한다.

② 민법상 강행규정의 예로는 민법총칙상 권리능력 · 행위능력, 선량한 풍속 기타 사회질서에 관한 규정(제103조, 제104조)등이 있고, 물권법은 물권법정주의에 의해 대부분의 규정이 강행규정이다.

(2) 임의규정

임의규정은 선량한 풍속 기타 사회질서에 관계없는 규정으로서 당사자의 의사에 의하여 배제하거나 변경할 수 있는 규정을 말하며 법률행위가 이에 위반한다 할지라도 그 법률행위는 유효이며 적법하다.

3. 효력규정과 단속규정

(1) 효력규정

효력규정이란 '규정에 위반하면 행정상의 제재는 물론 사법상의 효력도 무효가 되는 규정'을 말한다. 일반적으로 강행규정이란 이러한 효력규정을 의미한다.

판 례

1. 구 부동산중개업법 및 같은 법 시행규칙 등 관련 법령에서 정한 한도를 초과하는 부동산 중개수수료 약정이 강행법규 위반으로 무효인지 여부(적극)

부동산 중개수수료에 관한 위와 같은 규정들은 중개수수료 약정 중 소정의 한도를 초과하는 부분에 대한 사법상의 효력을 제한하는 이른바 강행법규에 해당하고, 따라서 구 부동산중개업법 등 관련 법령에서 정한 한도를 초과하는 부동산 중개수수료 약정은 그 한도를 초과하는 범위 내에서 무효이다(대판 2005다32159).

2. 공인중개사 자격이 없는 자가 중개사무소 개설등록을 하지 아니한 채 부동산중개업을 하면서 체결한 중개수수료 지급약정의 효력(무효)

중개사무소 개설등록에 관한 구 부동산중개업법 관련 규정들은 공인중개사 자격이 없는 자가 중개사무소 개설등록을 하지 아니한 채 부동산중개업을 하면서 체결한 중개수수료 지급약정의 효력을 제한하는 이른바 강행법규에 해당한다(대판 2008다75119).

3. 공인중개사 자격이 없는 자가 거래행위를 중개하였으나 업으로 한 것이 아닌 경우, 그에 따른 중개수수료 지급약정이 무효인지 여부(소극)

공인중개사 자격이 없는 자가 우연한 기회에 단 1회 타인 간의 거래행위를 중개한 경우 등과 같이 '중개를 업으로 한' 것이 아니라면 그에 따른 중개수수료 지급약정이 강행법규에 위배되어 무효라고 할 것은 아니다(대판 2010다86525).

---

(2) 단속규정

① 단속규정이란 '일정한 행정목적을 달성하기 위하여 국가가 일정한 행위를 금지 · 제한하는 법규'를 말하며, 단속규정에 위반하는 경우 위반자는 일정한 처벌을 받으나 사법상의 효력은 유효이다.

② 예컨대, 무허가음식점의 영업행위, 무허가 숙박행위, 불합격농산물의 판매행위 등이 단속규정을 위반한 경우이다.

판 례

1. 미등기전매행위에 대하여 형사처벌을 규정한 부동산등기특별조치법 제2조 제2항 및 제8조 제1호가 중간생략등기 합의의 사법상 효력을 무효로 하는 취지인지 여부(소극)

부동산등기특별조치법상 조세포탈과 부동산투기 등을 방지하기 위하여 위 법률 제2조 제2항 및 제8조 제1호에서 등기하지 아니하고 제3자에게 전매하는 행위를 일정 목적범위 내에서 형사 처벌하도록 되어 있으나 이로써 순차매도한 당사자 사이의 중간생략등기 합의에 관한 사법상 효력까지 무효로 한다는 취지는 아니다(대판 92다39112).

2. **개업공인중개사 등이 중개의뢰인과 직접 거래를 하는 행위를 금지하는 공인중개사법 제33조 제6호의 규정 취지 및 법적 성질(=단속규정)**

개업공인중개사 등이 중개의뢰인과 직접 거래를 하는 행위를 금지하는 공인중개사법 제33조 제6호의 규정에 위반하여 한 거래행위가 사법상의 효력까지도 부인하지 않으면 안 될 정도로 현저히 반사회성, 반도덕성을 지닌 것이라고 할 수 없으므로, 위 규정은 강행규정이 아니라 단속규정이다(대판 2016다259677).

■ 단속규정과 효력규정의 예

단속규정	효력규정
1. 중간생략등기를 금지하는 부동산등기특별조치법 제2조 제2항 2. (구) 주택법 제39조 제1항의 전매금지규정 3. 개업공인중개사 등이 중개의뢰인과 직접 거래를 하는 행위를 금지하는 공인중개사법 제33조 제6호의 규정 4. 투자일임매매약정을 제한한 증권거래법 제107조	1. 부동산중개수수료 약정 중 (구) 부동산중개업법 및 동 시행규칙에 의한 한도를 초과하는 부분 2. 공인중개사 자격이 없는 자가 중개사무소 개설등록을 하지 아니한 채 부동산중개업을 하면서 체결한 중개수수료 지급약정의 효력(무효) 3. 허가구역 내의 토지에 관하여 관청의 허가를 받을 것을 요구하는 「부동산거래신고 등에 관한 법률」 제11조 4. 「공익법인의 설립 · 운영에 관한 법률」상 공익법인이 하는 기본재산의 처분에 주무관청의 허가를 요하는 규정 6. 증권회사와 고객 사이의 투자수익보장약정 7. 사립학교의 기본재산처분행위 등에 주무관청의 허가를 요구한 사립학교법 제28조. 8. 부동산실명법에 위반한 명의신탁(부동산 실권리자명의등기에 관한 법률 제4조)

3. 강행법규(효력규정) 위반의 효과

(1) 무 효

① 강행규정 위반으로 인한 무효는 절대적 무효이므로 선의의 제3자에게 대항할 수 있다.

② 강행법규를 위반한 자가 스스로 강행규정에 위반된 계약의 무효를 주장할 수 있다(신의칙에 위반되지 않는다).

(2) 부당이득반환청구 여부

강행법규인 효력규정을 위반하면 그 법률행위는 무효가 되므로 그 법률행위에 따른 의무를 이행할 필요가 없다. 만일 이행을 하였다면 강행규정 위반으로 무효인 법률행위가 제103조에 위반되지 않는 한 반환청구를 할 수 있다[99다70860].

제 2 절 목적의 사회적 타당성(社會的 妥當性)

Ⅰ 반사회질서의 법률행위(제103조)

제103조(반사회질서의 법률행위) 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위는 무효로 한다.

1. 제103조의 의의 및 판단시기

① 사회에서 행해지는 모든 법률행위를 예상해서 미리 개별적으로 모든 사항을 강행규정을 정해 둔다는 것은 입법기술상 불가능하다. 그래서 민법은 이와 같은 경우를 대비하여 103조라는 일반적 · 추상적 규정을 두어 법률행위의 목적이 개개의 강행법규에 위반하지 않더라도 '선량한 풍속 기타 사회질서에 위반하는 때, 즉 사회적 타당성이 없는 법률행위'는 무효로 한다.

② 어느 행위가 사회질서에 반하는지의 여부는 원칙적으로 '법률행위 당시'를 기준으로 한다. 따라서 매매계약체결 당시(법률행위시)에 정당한 대가를 지급하고 목적물을 매수하는 계약을 체결하였다면 비록 그 후 목적물이 범죄행위로 취득된 것을 알게 되었다고 하더라도 특별한 사정이 없는 한 민법 제103조에 반하는 행위라고 단정할 수 없다[2001다44987].

2. 반사회질서 법률행위의 유형

(1) 정의관념에 반하는 행위

① 범죄행위를 내용으로 하는 계약이나 범죄를 하지 않을 것을 조건으로 대가적 급부를 제공하는 계약, 밀수를 위한 자금대차계약

② 경매나 입찰의 담합행위

③ 노조간부의 부정한 청탁약정, 공무원의 직무에 관하여 특별한 청탁을 하고 이에 대하여 보수를 지급할 것을 내용으로 하는 약정

④ 증인이 증언을 조건으로 소송의 일방 당사자로부터 통상적으로 용인할 수 있는 수준을 넘은 대가를 제공받기로 약정한 경우

⑤ 수사기관에서 참고인으로 진술하면서 자신이 잘 알지 못하는 내용에 대하여 허위의 진술을 하고 대가를 받기로 하는 약정

⑥ 변호사 아닌 자가 승소를 조건으로 그 대가로 소송당사자로부터 소송물의 일부를 양도받기로 하는 약정

⑦ 형사사건에 관한 변호사의 성공보수약정. 다만, 민사소송에서의 성공보수약정은 반사회질서의 법률행위가 아니다.

⑧ 당초부터 오로지 보험사고를 가장하여 보험금을 취득할 목적으로 생명보험계약을 체결하는 경우 또는 보험계약자가 다수의 보험계약을 통하여 보험금을 부정취득할 목적으로 보험계약을 체결한 경우

⑨ 행정기관에 진정서를 제출하여 상대방을 궁지에 빠뜨린 다음 이를 취하하는 조건으로 거액의 급부를 제공받기로 약정

⑩ 전통사찰주지직의 매매(단, 거액의 대가로 주지직의 양도약정이 있음을 알고도 묵인한 상태에서 종교법인의 주지 임명행위는 유효)

⑪ 매도인의 배임행위에 매수인이 적극 가담하여 맺어진 부동산의 이중매매계약

⑫ 금전소비대차계약 시 당사자 사이의 경제력 차이로 인하여 사회통념상 허용되는 한도를 초과하는 현저하게 고율의 이자약정

(2) 인륜에 반하는 행위

① 첩계약은 처의 동의 여부에 상관없이 무효

② 부첩관계의 종료를 해제조건으로 하는 증여계약은 그 조건만이 무효인 것이 아니라 증여계약 자체가 무효

(3) 개인의 자유를 심하게 제한하는 행위

① 평생 혼인하지 않겠다는 계약이나 어떠한 일이 있어도 이혼하지 않겠다는 각서

② 혼인하면 퇴직하겠다는 각서

③ 위약벌의 약정이 그 의무의 강제에 의하여 얻어지는 채권자의 이익에 비하여 과도하게 무거운 경우

(4) 지나치게 사행적인 행위

① 도박자금을 대여하는 행위

② 도박채무를 변제하기로 하는 약정 이나 도박채무의 변제방법으로 토지를 양도하는 행위

(5) 생존의 기초가 되는 재산의 처분행위

① 사찰의 존립에 필수불가결한 재산인 임야를 증여하는 계약

② 장차 취득하는 전 재산을 양도한다는 계약

(6) 동기의 불법

① 동기(의사표시의 이유)의 불법이란 '법률행위 자체는 사회질서에 위배되지 않으나, 당사자가 그 의사표시를 하게 된 동기에 반사회성이 있는 경우'를 말한다(도박장을 개장하기 의하여 가옥을 임차하는 경우, 범행자금으로 사용하기 위해 자금을 차용하는 경우 등).

② 판례는 거래안전보호를 위하여 그 동기가 표시되거나 상대방에게 알려진 경우에는 반사회질서행위가 된다고 한다[2009다37251].

3. 반사회질서에 해당하지 않는 경우

① 부첩관계를 해소하기로 하면서 첩(위자료)과 두 딸(양육비)의 장래의 생활대책을 마련해 주기 위해 금전의 지급을 약정하는 것은 공서양속에 반한다고 할 수 없다[80다458].

② 부정행위를 용서받는 대가로 처에게 부동산을 양도하되, 부부관계가 유지되는 동안에는 처가 임의로 처분할 수 없다는 제한을 붙인 약정은 유효하다[92므204].

③ 투기의 목적으로 주택개량사업구역 내의 주택에 거주하는 세입자가 피분양권(이른바 세입자입주권)을 세입자들로부터 15매나 매수한 경우에도, 그것만으로는 그 피분양권 매매계약이 반사회질서의 법률행위로서 무효로 된다고 할 수 없다[90다19770].

④ 양도소득세의 일부를 회피할 목적으로 매매계약서에 낮은 금액을 매매대금으로 기재하였다 하여, 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효로 된다고 할 수는 없다[2007다3285].

⑤ 양도소득세를 부과받지 않게 할 목적으로 매매를 원인으로 한 소유권이전등기를 3년 후에 넘겨받기로 특약을 하였다 하여도, 그 특약 자체가 사회질서나 신의칙에 위반된 것이라고 할 수 없다[91다6627].

⑥ 반사회적 행위에 의하여 조성된 재산인 이른바 비자금을 소극적으로 은닉하기 위하여 임치한 것은 사회질서에 반하는 법률행위로 볼 수 없다[2000다49343].

⑦ 강제집행을 면할 목적으로 부동산에 허위의 근저당권설정등기를 경료하는 행위는 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위로 볼 수 없다[2003다70041].

⑧ 강박행위의 주체가 국가공권력이고 공권력행사의 내용이 기본권을 침해하는 것이라고 하여 그 강박에 의한 의사표시가 항상 반사회성을 띠게 되어 당연히 무효로 된다고는 볼 수 없다[95다40038].

⑨ 단지 법률행위의 성립과정에서 불법적 방법이 사용된 데 불과한 때에는, 그 불법이 의사표시의 형성에 영향을 미친 경우에는 의사표시의 하자를 이유로 그 효력을 논의할 수는 있을지언정 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 수는 없다[2002다21509].

⑩ 해외파견된 근로자가 귀국일로부터 일정기간 소속회사에 근무해야 한다는 사규나 약정, 일정기간 근무하지 않으면 해외파견 소요경비를 배상한다는 사규나 약정은 근로기준법 제21조에 위배하는 것도 아니다[82다카90].

⑪ 도박채무의 변제를 위하여 채무자가 채권자에게 부동산처분대리권의 수여행위까지 무효라고 볼 수는 없고, 대리권을 수여받은 채권자가 선의의 제3자와 체결한 매매행위도 무효가 되지는 않는다[94다40147].

4. 반사회질서 법률행위의 효과

(1) 무 효

① 사회질서에 반하는 법률행위는 무효이다. 이 무효는 절대적이므로 제3자에 대해서도 선의 · 악의를 불문하고 무효를 주장할 수 있다.

② 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위의 무효는 이를 주장할 이익이 있는 자는 누구든지 무효를 주장할 수 있다. 따라서 반사회질서 법률행위를 원인으로 하여 부동산에 관한 소유권이전등기를 마쳤더라도 그 등기는 원인무효로서 말소될 운명에 있으므로 등기명의자가 소유권에 기한 물권적 청구권을 행사하는 경우에, 권리 행사의 상대방은 법률행위의 무효를 항변으로서 주장할 수 있다(2015다11281).

(2) 부당이득반환청구 여부

사회질서에 반하는 법률행위는 무효이므로 이행 전 채무는 이행할 필요가 없다. 이행 후에는 불법원인급여가 되어 급여자는 부당이득을 원인으로 반환을 청구할 수 없고, 급여한 물건의 소유권이 여전히 자기에게 있다고 하여 소유권에 기한 반환청구도 할 수 없다. 따라서 급여한 물건의 소유권은 급여를 받은 상대방에게 귀속하게 된다(대판 79다483).

> **제746조(불법원인급여)** 불법의 원인으로 인하여 재산을 급여하거나 노무를 제공한 때에는 그 이익의 반환을 청구하지 못한다.

5. 부동산의 이중매매

(1) 의 의

甲(매도인)이 자기의 X부동산을 乙(제1매수인)에게 매도하는 계약을 체결하고 중도금까지 지급받은 후에 아직 소유권이전등기를 하지 않은 상태에서 甲이 다시 그 부동산을 丙(제2매수인)에게 매도하여 소유권이전등기를 해준 경우를 말한다.

(2) 원칙(유효)

① 부동산의 이중매매는 자유경쟁의 원리상 원칙적으로 유효하다.

② 이 경우 매도인이 丙(제2매수인)에게 소유권이전등기를 해 주었다면 丙은 소유권을 취득하고, 乙(제1매수인)에 대한 소유권이전의무는 채무불이행(이행불능)이 된다. 따라서 乙(제1매수인)은 매도인에 대하여 최고 없이 매매계약을 해제하고 손해배상을 청구할 수 있다.

(3) 예외(무효)

① 제2매수인이 매도인의 배임행위에 적극 가담하여 그에 따른 등기이전을 하였다면 제2의 매매행위는 정의관념에 반하므로 무효가 된다. 적극 가담하는 행위는 제2매수인이 다른

사람에게 목적물이 매도된 것을 안다는 것만으로는 부족하고 적어도 매도사실을 알고도 매도를 권유하거나 요청 · 유도하여 계약에 이르는 정도가 되어야 한다.

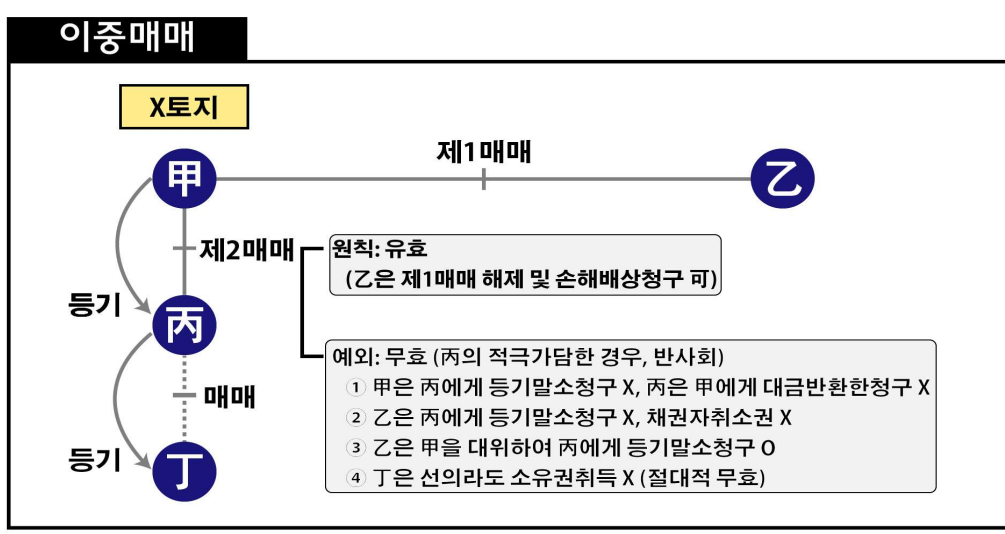
② 매도인 甲과 제2매수인 丙의 급부 상호 간은 불법원인급여에 해당하므로 매도인은 제2매수인에 대하여 부당이득반환청구권이나 소유권에 기한 물권적 청구권을 행사할 수 없고, 제2매수인도 매도인에 대해 대금지급반환 청구도 할 수 없다.

③ 제1매수인 乙은 제2매수인 丙에 대해 직접 소유권이전등기의 말소를 청구할 수 없고, 진정명의회복을 원인으로 자신 명의의 소유권이전등기를 청구할 수 없다[2000다36484].

④ 다만, 제1매수인은 매도인을 대위하여 제2매수인에게 등기말소를 청구할 수 있고, 불법행위로 인한 손해배상청구도 할 수 있다.

⑤ 제1매수인은 자신의 소유권이전등기청구권(특정채권)보전을 위해 채권자취소권을 행사할 수 없다[98다56690].

⑥ 부동산의 이중매매가 반사회적 법률행위에 해당되는 경우에는 이중매매는 절대적 무효이므로, 제2매수인 丙으로부터 당해 부동산을 취득한 제3자는 선의, 악의를 묻지 않고 소유권을 취득할 수 없다. 즉, 당해 부동산을 제2매수인 丙으로부터 다시 취득한 제3자는 선의라도 甲과 丙 사이의 이중매매계약이 유효하다고 주장할 수 없다[대판 96다29151].



Ⅳ 불공정한 법률행위(제104조)

제104조(불공정한 법률행위) 당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험으로 인하여 현저하게 공정을 잃은 법률행위는 무효로 한다.

1. 서 설

(1) 의 의

① 불공정한 법률행위란 '상대방의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용하여 자기의 급부에 비하여 현저히 균형을 잃은 반대급부를 하게 하여 부당하게 재산상의 이득을 취득하는 법률행위'를 말하며, 폭리행위(暴利行爲)라고도 한다.

② 민법 제104조는 불공정한 법률행위를 무효로 규정하고 있는데 이는 사회적 약자의 지위에 있는 자의 궁박 · 경솔 또는 무경험을 이용한 폭리행위를 규제하는 데 목적이 있다.

(2) 제103조와의 관계 : 제104조의 불공정한 법률행위는 제103조의 예시규정에 해당한다. 따라서 비록 제104조의 요건을 완전히 갖추고 있지 못한 경우에도 그 행위는 제103조에 의해 반사회적 행위로서 무효가 될 수 있다.

2. 불공정 법률행위의 요건

(1) 피해자의 궁박 · 경솔 또는 무경험이 있을 것

① '궁박'은 급박한 곤궁을 의미하고 경제적 궁박뿐만 아니라 정신적 · 심리적 궁박상태를 포함한다[98다58825].

② '경솔'은 의사를 결정할 때 행위결과에 대해 보통인이 베푸는 고려를 하지 않는 심리상태를 말한다.

③ '무경험'은 일반적인 생활체험의 부족을 의미하는 것으로서 어느 특정영역에 있어서의 경험부족이 아니라 거래일반에 대한 경험부족을 뜻한다[2002다38927].

④ 이러한 궁박 · 경솔 또는 무경험은 모두 구비하여야 하는 것이 아니고 그 중 어느 하나만 갖추어져도 충분하다.

⑤ 대리인이 법률행위를 한 경우 궁박은 본인을 기준으로 판단하고, 경솔 · 무경험은 대리인을 기준으로 판단하여야 한다[71다2255].

(2) 폭리자의 악의(이용의사)가 있을 것

폭리자에게 피해자측의 궁박 · 경솔 또는 무경험의 상태에 있는 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사, 즉 폭리행위의 악의가 없었다면 불공정한 법률행위는 성립하지 않는다[95다1460].

(3) 급부와 반대급부 사이의 현저한 불균형이 있을 것

① 현저히 공정을 잃은 법률행위란 자기의 급부에 비해 현저하게 균형을 잃은 반대급부를 하게 하여 부당한 재산적 이익을 얻는 행위를 말한다[92다 52238].

② 급부와 반대급부 사이의 '현저한 불균형'은 단순히 시가와의 차액 또는 시가와의 배율로 판단할 수 있는 것은 아니고, 구체적 · 개별적 사안에 있어서 일반인의 사회통념에 따라 결정하여야 한다. 그 판단에 있어서는 피해자의 궁박 · 경솔 · 무경험의 정도를 고려하여 당사자의 주관적 가치가 아닌 거래상의 객관적 가치에 의하여야 한다[2009다50308].

③ 불균형 여부의 판단 시기는 '법률행위시(계약체결 당시)'를 기준으로 한다. 따라서 계약 체결 당시를 기준으로 불공정한 것이 아니라면, 사후에 외부적 환경의 급격한 변화에 따라 계약당사자 일방에게 큰 손실이 발생하고 상대방에게는 그에 상응하는 큰 이익이 발생할 수 있는 구조라고 하여 그 계약이 당연히 불공정한 계약에 해당한다고 말할 수 없다[2011다53683].

(4) 입증책임

① 불공정한 법률행위로서 매매계약의 무효를 주장하려면 무효를 주장하는 자가 모든 요건을 주장 · 입증해야 한다[70다2065].

② 따라서 급부와 반대급부간의 현저한 불균형(객관적 요건)이 있다 하여 궁박 · 경솔 또는 무경험(주관적 요건)이 추정되지는 않는다[76다2179].

3. 효 과

(1) 무 효

① 불공정한 법률행위는 절대적 무효이므로 선의의 제3자에게도 대항할 수 있다.

② 어느 법률행위가 '불공정한 법률행위'에 해당하여 무효라고 한다면, 그 계약으로 인하여 불이익을 입는 당사자로 하여금 위와 같은 불공정성을 소송 등 사법적 구제수단을 통하여 주장하지 못하도록 하는 부제소합의 역시 다른 특별한 사정이 없는 한 무효이다.

③ 불공정한 법률행위로 무효인 경우, 추인에 의해 무효인 법률행위가 유효로 될 수 없으나, 무효행위의 전환에 관한 민법 제138조가 적용될 수 있다. 따라서 당사자 쌍방이 매매계약이 불공정한 행위로 무효임을 알았더라면 대금을 다른 액으로 정하여 매매계약에 합의하였을 것이라고 예외적으로 인정되는 경우에는, 그 대금액을 내용으로 하는 매매계약이 유효하게 성립한다[2009다50308].

(2) 부당이득반환 여부

① 불공정한 법률행위는 무효이므로 이행 전이라면 이행할 필요가 없다.

② 이미 이행하였다면 불법원인은 폭리자 쪽에만 있으므로 불법원인급여에 관한 제746조 본문에 따라 폭리자는 급부의 반환을 청구할 수 없고 피해자는 제746조 단서에 의해 급부의 반환을 청구할 수 있다.

4. 적용범위

(1) 단독행위

불공정한 법률행위는 단독행위에도 적용된다. 즉, 경험부족의 가정부인이 경제적 · 정신적 궁박상태에서 구속된 남편을 석방 · 구제하기 위해 '채권을 포기하는 행위(단독행위)'를 한 경우 이는 불공정한 법률행위에 해당한다[75다92].

(2) 무상행위

불공정한 법률행위가 성립하려면 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 있어야 하므로 기부행위, 증여계약과 같이 아무런 대가관계 없이 당사자 일방이 상대방에게 일방적인 급부를 하는 법률행위에는 제104조가 적용되지 않는다[99다56833].

(3) 경 매

당사자의 의사에 의하지 않은 경매에 의한 재산권의 이전에는 민법 제104조는 적용될 여지가 없다[80마77].

CHAPTER

03 의사표시(意思表示)

제 1 절 법률행위의 해석(解釋)

Ⅰ 서 설

1. 의 의

① 법률행위의 해석이란 법률행위의 내용(목적)을 명확하게 확정하는 것을 말한다. 그런데 법률행위는 의사표시를 핵심요소로 하므로 법률행위 해석은 결국 의사표시의 해석이라 할 수 있다.

② 의사표시의 존부가 명확하지 않은 경우, 의사와 표시가 일치하지 않는 경우, 표의자가 표시행위에 사용한 개념이 객관적인 문언의 의미와 다른 경우, 표시행위가 다의적인 경우 등에 있어서 해석을 행하게 된다.

2. 법률행위 해석의 주체와 대상

(1) **주체**

법률행위 해석의 주체는 궁극적으로 법원(판사)이다. 따라서 매매계약서에 계약사항에 대한 이의가 생겼을 때에는 매도인의 해석에 따른다는 조항은 법원의 법률행위해석권을 구속하지 않는다.

(2) **해석의 대상**

① 법률행위의 해석은 당사자의 내심적 의사여하에 관계없이 당사자가 그 표시행위에 부여한 객관적 의미를 합리적으로 해석하여야 한다.

② 또한 의사표시의 해석에 있어서 당사자의 진정한 의사를 알 수 없다면, 당사자의 내심의 의사보다는 외부로 표시된 행위에 의하여 추단되는 의사, 즉 표시상의 효과의사를 가지고 해석함이 상당하다[96다1320].

3. 법률행위 해석의 방법

(1) **자연적 해석**

① **의의** : 법률행위의 해석에 있어서 표현의 문자적 · 언어적 의미에 구속되지 않고 표의자의 실제적인 의사, 즉 내심적 효과의사를 추구하는 것을 말한다. 자연적 해석방법은 표의자의 입장에서 하는 해석방법이다.

② **오표시무해(誤表示無害)의 원칙**

㉠ 표의자 및 상대방이 의사표시를 잘못하였다 하여도 그 잘못된 표시의 진정한 의미를

인식할 수 있거나 이해한 때에는 법률행위는 표시된 대로 성립하는 것이 아니라 실제로 이해한 의미대로 성립한다는 원칙이다.

㉡ 즉, 매매계약에 있어 쌍방당사자가 모두 특정의 X토지를 계약목적물로 삼았으나 그 지번 등에 관해 착오를 일으켜 계약서에 그 목적물을 X토지와는 별개인 Y토지로 표시한 경우 X토지를 매매목적물로 한다는 쌍방당사자의 의사합치가 있은 이상 위 매매계약은 X토지에 관해 성립한 것으로 보아야 하고 매매계약을 착오를 이유로 취소할 수 없다. 따라서 매수인은 X토지의 소유권이전청구권을 행사할 수 있으며, 만일 위 매매계약을 원인으로 하여 Y토지에 관해 매수인명의로 소유권이전등기가 경료되었다면 이는 원인 없는 것으로서 무효이다[96다19581].

(2) 규범적 해석

① **의의** : 내심적 효과의사와 표시행위가 일치하지 않는 경우에 상대방의 신뢰보호를 위해 상대방의 시각에서 표시행위에 따라 표시행위의 객관적 의미를 탐구하여 법률행위의 성립을 인정하는 해석을 말한다.

② **규범적 해석에 따른 판례**

㉠ 임대차계약을 체결하면서 '모든 경우의 화재'에 대하여도 임차인이 그 손해를 부담하기로 특약을 하였을 경우 모든 경우라 함은 불가항력의 경우까지도 포함하는 뜻이다[79다508].

㉡ 어떠한 의무를 부담하는 내용의 기재가 있는 문면에 "최대한 노력하겠습니다"라고 기재되어 있는 경우, 특별한 사정이 없는 한 당사자가 그러한 의무를 법적으로는 부담할 수 없지만 사정이 허락하는 한 그 이행을 사실상 하겠다는 취지로 해석함이 상당하다[93다32668].

㉢ 임대인이 임대차계약서의 단서 조항에 '모든 권리금을 인정함'이라는 기재를 하였다고 하여 임대차 종료시 임차인에게 권리금을 반환하겠다고 약정하였다고 볼 수는 없다[2000다4517,4524].

(3) 보충적 해석

① **의의** : 보충적 해석은 법률행위의 내용(목적)에 공백(간극)이 있는 경우에 해석에 의하여 당사자의 가상적(가정적) 의사를 제3자의 시각에서 확정하여 공백을 보충하는 것을 말한다. 즉, 계약에서 당사자가 약정하지 않은 사항에 관하여 분쟁이 생기는 경우에 법원에서 제3자의 입장에서 합리적으로 해석하는 방법이다.

② **적용범위** : 보충적 해석은 특히 계약에서 큰 기능을 발휘 한다. 자연적 해석 또는 규범적 해석에 의하여 법률행위가 성립된 후에 보충적 해석을 하게되며, 당사자의 실제의사가 아니라 법률행위 당시 및 보충적 해석을 할 당시의 사정 · 거래관행에 의하여 인정되는 가상적 의사(假想的 意思)를 밝히는 것이다.

제 2 절 비정상적 의사표시

Ⅰ 서 설

법률행위가 유효하기 위해서는 의사와 표시가 일치하고 그 의사의 형성과정에 하자가 없어야 한다. 민법은 이러한 요건을 갖추지 못한 비정상적인 의사표시를 유형화 하여 먼저 의사와 표시가 불일치한 형태로 진의 아닌 의사표시(제107조), 통정허위표시(제108조), 착오로 인한 의사표시(제109조)를 규정하고, 다음으로 의사표시에 하자가 있는 경우로서 사기 · 강박에 의한 의사표시(제110조)를 규정하고 있다.

- 비정상적 의사표시
  - 의사와 표시의 불일치 (의사의 흠결)
    - 불일치를 표의자가 알고 있는 경우
      - 비진의표시(제107조)
      - 통정허위표시(제108조)
    - 불일치를 표의자가 모르고 있는 경우 – 착오(제109조)
  - 하자(瑕疵) 있는 의사표시의 – 사기 · 강박에 의한 의사표시(제110조)

Ⅱ 진의 아닌 의사표시(비진의표시)

1. 의 의

제107조(진의 아닌 의사표시) ① 의사표시는 표의자가 진의 아님을 알고 한 것이라도 그 효력이 있다. 그러나 상대방이 표의자의 진의 아님을 알았거나 이를 알 수 있었을 경우에는 무효로 한다.
② 진의 아닌 의사표시의 무효는 선의의 제3자에게 대항하지 못한다.

① 진의 아닌 의사표시란 '의사'와 '표시'가 일치하지 않는다는 것을 표의자 스스로 알면서 하는 의사표시 또는 표의자가 진의 아님을 알고 한 의사표시'를 말하며, 비진의표시(非眞意表示) 또는 심리유보(心理留保)라고도 한다. 예컨대, 甲이 증여의 의사가 없음에도 불구하고 자신의 부동산을 乙에게 증여한다고 약정한 경우이거나 사직의사 없는 근로자가 사용자의 지시 또는 회사의 경영방침에 따라 일괄하여 사직서를 작성 · 제출한 경우이다.

② 진의 아닌 의사표시는 의사의 의식적 흠결이라는 점에서 통정허위표시와 같으나, 상대방과 통정함이 없이 표의자가 단독으로 한다는 점에서 허위표시와 다르다.

2. 진의 아닌 의사표시 해당여부

(1) **'진의'의 의미** : 비진의 의사표시에 있어서의 '진의'란 특정한 내용의 의사표시를 하고자 하는 표의자의 생각을 말하는 것이지 표의자가 진정으로 마음 속에서 바라는 사항을 뜻하는 것을 말하는 것이 아니다.

(2) **진의 아닌 의사표시에 해당하는 경우**

① 사직의사 없는 사기업의 근로자가 회사에 사직서를 제출하는 경우에는 진의 아닌 의사표시에 해당한다.

② 근로자가 사용자의 '지시'에 좇아 일괄하여 사직서를 작성 제출할 당시 그 사직서에 기하여 의원면직처리될지 모른다는 점을 인식하였다고 하더라도 이것만으로 그의 내심에 사직의 의사가 있는 것이라고 할 수 없다[90다11554].

③ 근로자들이 일괄적으로 사직원을 제출할 때 근로계약관계를 종료시키고자 하는 내심의 의사가 없었고, 사용자 또한 이러한 사정을 알고서 사직원을 수리하였다면 위 근로자들의 사직의사표시는 진의 아닌 의사표시로 무효라고 할 것이다[92다21036].

(3) **진의 아닌 의사표시에 해당하지 않는 경우**

① 표의자가 의사표시의 내용을 진정으로 마음속에서 바라지는 않았다고 하더라도 당시의 상황에서는 그것을 최선이라고 판단하여 그 의사표시를 하였을 경우에는 이를 내심의 효과의사가 결여된 진의 아닌 의사표시라고 할 수 없다[99다34475].

② 표의자가 강박에 의해서나마 증여를 하기로 하고 그에 따른 증여의 의사표시를 한 이상 증여의 내심의 효과의사가 결여된 것이라고 할 수는 없다[92다41528].

③ 법률상 또는 사실상의 장애로 자기명의로 대출받을 수 없는 자 를 위해 대출금채무자로서의 명의를 빌려준 乙이 자기명의로 대출을 받아 그 자금을 甲이 사용하도록 한 경우 특별한 사정이 없는 한 乙의 의사는 채무부담의 의사가 없는 것이라고 할 수 없으므로 진의 없는 의사표시 또는 통정허위표시라고 할 수 없다. 따라서 명의대여자인 乙이 원칙적으로 대출금반환채무를 진다[97다8403].

3. 효 과

(1) **원칙적으로 유효**

① 비진의표시는 표시된 대로 효력이 발생한다(제107조 제1항 본문).

② 물의를 일으킨 사립 대학교 조교수가 사직원이 수리되지 않을 것이라고 믿고 사태수습을 위해 사직원을 제출하였던바, 의외로 이사회에서 사직원이 수리된 경우 위 조교수의 사직원은 그 의사표시에 따라 효력을 발생한다[79다2168].

(2) 예외적으로 무효

① 당사자 간의 효과

㉠ 상대방이 표의자의 진의 아님을 알았거나 알 수 있었을 경우에는 비진의표시를 무효로 한다(제107조 제1항 단서). 따라서 상대방이 선의 · 무과실인 경우에는 유효이다.

㉡ '알 수 있었을 경우'라고 함은 일반인의 주의를 기울이면 알 수 있었다는 것, 과실(過失)로 알지 못하였음을 말한다.

㉢ 상대방의 악의 또는 과실에 대한 입증책임은 의사표시의 무효를 주장하는 자(표의자)에게 있다[92다2295].

② 제3자에 대한 효과

㉠ 비진의표시의 무효로써 선의의 제3자에게 대항하지 못한다(제107조 제2항).

㉡ 여기에서 '제3자'는 비진의 의사표시의 당사자와 그 포괄승계인을 제외한 자로서 비진의 의사표시에 의해 외형상 형성된 법률관계를 토대로 새로운 법률상 이해관계를 맺은 자이다.

㉢ 여기서 '선의'는 당사자 간의 행위가 비진의표시임을 제3자가 모르는 것을 말한다. 그리고 제3자는 선의이기만 하면 되고 과실 유무는 묻지 않으며, 특별한 사정이 없는 한 제3자의 선의는 추정되므로 비진의표시의 무효를 주장하는 측에서 제3자가 악의라는 사실을 주장 · 입증해야 한다[92다2295].

㉣ 대항하지 못한다는 것은 비진의표시의 무효를 주장하지 못한다는 것을 의미한다. 따라서 선의의 제3자는 완전한 권리를 취득하게 되어 선의의 제3자로부터 전득한 전득자는 선의 · 악의를 불문하고 보호된다(엄폐물의 법칙).

4. 적용범위

(1) 적용되는 경우

① 진의 아닌 의사표시는 계약, 상대방 있는 단독행위(취소, 추인, 해제 등)뿐만 아니라 상대방 없는 단독행위에도 적용된다. 다만, 상대방 없는 단독행위의 경우는 상대방이 없기 때문에 제107조 제1항 단서가 적용될 여지가 없으므로 항상 유효이다.

② 대리인이 본인의 의사에 반하여 자기나 제3자의 이익을 위한 배임적 대리행위를 한 경우(대리권남용)에도 유추적용될 수 있다.

(2) 적용되지 않는 경우

① **가족법상 행위** : 혼인, 입양과 같이 당사자의 진의가 절대적으로 요구되는 가족법상의 행위에는 민법 제107조가 적용되지 않는다. 따라서 비진의표시의 신분행위는 언제나 무효이다.

② **소송행위** : 당사자의 소송행위는 일반 사법상의 행위와는 달리 내심의 의사보다 그 표시를 기준으로 하여 그 효력 유무를 판정할수 밖에 없으므로 소의 취하가 내심의 의사에 반한 것이라고 하더라도 이를 무효라고 볼 수는 없다[80다3251].

③ **공법상 행위** : 공무원이 사직의 의사표시와 같은 사인의 공법행위에는 진의 아닌 의사표시에 관한 제107조가 준용되지 아니하므로 그 의사가 외부에 표시된 이상 그 의사는 표시된 대로 효력을 발생한다[97누13962].

④ **강행규정에 위반한 행위** : 강행법규에 위반한 계약은 무효이므로 그 경우에 계약상대방이 선의·무과실이더라도 민법 제107조의 비진의표시의 법리 또는 표현대리 법리가 적용될 여지는 없다[2013다49381].

Ⅲ 통정허위표시(通情虛僞表示)

1. 의 의

제108조(통정한 허위의 의사표시) ① 상대방과 통정한 허위의 의사표시는 무효로 한다.
② 통정한 허위의 의사표시의 무효는 선의의 제3자에게 대항하지 못한다.

① **허위표시 또는 통정허위표시** : '상대방과 통정하여 하는 진의 아닌 의사표시'를 말한다(의사의 의식적 흠결). 여기서 '통정'이란 당사자가 의사와 표시의 불일치를 서로 짜고서 당해 법률행위를 가장행위로 한다는 점에 관한 양해(합의)를 의미한다. 예를 들어 채무자가 채권자의 강제집행을 피하기 위하여 자신소유 주택에 대해서 친구와 매매를 가장하여 친구 앞으로 소유권이전등기를 경료해 주는 경우를 말한다.

② 표의자의 '의사'와 '표시'의 불일치에 대하여 상대방이 알고 있는 것만으로는 부족하며 그에 관하여 상대방과의 사이에 의사의 합치(상대방의 양해)가 있어야 한다. 이점에서 상대방과의 통정이 없는 비진의표시와 차이가 있다.

③ 허위표시를 요소로 하는 법률행위를 가장행위(假裝行爲)라 하며, 허위표시는 상대방도 의사와 표시의 불일치를 알고 있다는 데에 특징이 있다.

보충학습 허위표시에 해당되는 경우

(1) 동일인에 대한 대출액 한도 제한을 회피하기 위하여 실질적인 주채무자가 제3자를 형식상의 주채무자로 내세웠고 금융기관도 이를 양해한 경우 제3자 명의로 되어 있는 대출약정은 통정허위표시에 해당하는 무효의 법률행위이다[96다18076].

(2) 채권자가 기존 채권을 우선변제받을 목적으로 주택임대차계약의 형식을 빌려 기존 채권을 임대차보증금으로 하기로 하고 주택의 인도와 주민등록을 마침으로써 주택임대차로서의 대항력을 취득한 것처럼 외관을 만들었을 뿐 실제 주택을 주거용으로 사용수익할 목적을 갖지 아니한 계약은 주택임대차계약으로서는 허위표시에 해당되어 무효라 할 것이므로 이에 주택임대차보호법상 대항력을 부여할 수 없다[2000다24184].

2. 효 과

(1) 당사자 사이의 효과

① 당사자 사이에는 언제나 무효이다. 따라서 권리, 의무가 발생하지 않으므로 이행 전에는 이행할 필요가 없다.

② 이행 한 경우 허위표시 자체가 반사회질서의 법률행위는 아니므로 불법원인급여에 해당하지 않고 당사자는 부당이득반환청구권 또는 소유권에 기한 반환청구권을 행사할 수 있다. 따라서 자력이 없는 채무자 甲이 채권자 A의 강제집행을 피하기 위하여 자신의 유일한 부동산을 乙에게 파는 것처럼 꾸미고 乙의 이름으로 소유권이전등기까지 한 경우에는, 甲은 乙에게 등기말소를 청구할 수 있다.

③ 허위표시가 채권자를 해할 목적으로 행하여진 경우에는, 채권자 A는 사해행위를 이유로 채권자취소권(제406조)을 행사할 수 있다[97다50985]. 즉, 통정허위표시도 채권자취소권의 대상이 될 수 있다.

④ 통정허위표시는 당사자 사이에서는 철회할 수 있으나 그 철회를 가지고 선의의 제3자에게 대항하지 못한다.

(2) 제3자에 대한 효과

① 상대적 무효

허위표시의 무효는 선의의 제3자에게 대항하지 못한다(제108조 제2항).

② 제3자

제3자는 허위표시의 당사자와 포괄승계인 이외의 자로서 그 허위표시에 의하여 외형상 형성된 법률관계를 토대로 실질적으로 새로운 법률상 이해관계를 맺은 자를 말한다. 여기에서 제3자는 허위표시의 당사자와 직접 법률상 이해관계를 가진 자 외에도, 그 법률상 이해관계를 바탕으로 하여 다시 새로이 법률상 이해관계를 가지게 된자(전득자)도 포함된다[2012다49292]. 따라서 허위표시의 당사자와 직접 이해관계를 가진 자가 악의더라도 전득자가 선의라면 전득자는 선의의 제3자로 보호받는다.

③ 선의

당해 의사표시가 허위표시임을 모르는 것을 말하며, 제3자는 선의이기만 하면 되고 무과실은 요건이 아니다[2003다70041]. 또한 제3자의 선의는 추정되므로 허위표시의 무효를 주장하는 측에서 제3자가 악의라는 사실을 주장 · 입증해야 한다[2002다1321].

④ 대항하지 못한다

선의의 제3자를 보호하기 위하여 당사자는 허위표시의 무효를 선의의 제3자에게 주장할 수 없다는 의미이다. 그러나 선의의 제3자가 무효를 주장하는 것은 무방하다.

■ 제3자에 해당여부

제3자에 해당하는 자	제3자에 해당되지 않는 자
① 가장매매의 매수인으로부터 그 목적물을 다시 매수한 자 ② 부동산가장매매의 매수인으로 부터 그 부동산에 저당권을 설정받은 자 또는 가등기를 취득한 자 ③ 가장매매의 매수인에 대한 가장매매목적물을 가압류한 자(가압류채권자),가장행위에 의한 채권을 가압류한자 ④ 가장저당권설정행위에 기한 저당권의 실행으로 경락받은 자 ⑤ 가장매매에 기한 대금채권을 양수한 자(양수인) ⑥ 가장채무를 보증하고 그 보증채무를 이행한 보증인 ⑦ 파산자가 상대방과 통정한 허위의 가장채권을 보유하고 있다가 파산이 선고된 경우의 파산관재인(다만, 선의, 악의는 총파산채권자를 기준으로 판단)	① 허위표시 당사자의 상속인 ② 대리인이 허위표시를 한 경우 본인 ③ 제3자를 위한 계약에서의 제3자(수익자) ④ 채권의 가장양도에 있어서 채무자 ⑤ 가장양수인의 일반채권자 ⑥ 저당권등 제한물권이 가장포기된 경우의 기존의 후순위 제한물권자 ⑦ 허위표시의 당사자로부터 계약상 지위를 이전받은 자(계약을 인수한 자) ⑧ 가장매매에 기인한 손해배상청구권의 양수인

(3) **은닉행위(隱匿行爲)**

① 甲이 乙에게 증여하면서 증여세를 면탈하기 위하여 서로 통모하여 매매계약서를 작성한 경우 매매는 가장행위이고 증여는 은닉행위이다.

② 이 경우 가장행위인 매매가 무효라고 해도 은닉행위인 증여가 증여로서의 요건을 갖추었다면 증여계약은 유효하다.

③ 따라서 甲에서 乙에게 마쳐진 소유권이전등기는 유효이고 乙은 완전한 소유권을 취득하므로 乙과 법률상 이해관계를 맺은 제3자는 선의 · 악의를 불문하고 권리를 취득한다.

4. 적용범위

① 계약뿐만 아니라 해제 · 취소 등 상대방 있는 단독행위에도 적용된다.

② 그러나 상대방 없는 단독행위나 합동행위, 가족법상의 법률행위(혼인 · 입양 등), 소송행위나 공법행위에는 허위표시에 관한 규정이 적용되지 않는다.

Ⅳ 착오(錯誤)로 인한 의사표시

1. 서 설

제109조(착오로 인한 의사표시) ① 의사표시는 법률행위의 내용의 중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다. 그러나 그 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 때에는 취소하지 못한다.
② 착오로 인한 의사표시의 취소는 선의의 제3자에게 대항하지 못한다.

(1) 의 의

① 착오에 의한 의사표시란 의사와 표시의 불일치를 표의자가 모르고서 하는 의사표시를 착오에 의한 의사표시라고 한다. 착오는 의사와 표시의 불일치를 표의자가 모른다는 점에서 불일치를 알고 있는 진의 아닌 의사표시나 허위표시와는 구별된다.

② 부동산의 양도가 있은 경우에 그에 대하여 부과될 양도소득세 등의 세액에 관한 착오가 미필적인 장래의 불확실한 사실에 관한 것이라도 착오에서 제외되는 것은 아니다[93다24810]. 그러나 표의자가 장래에 발생할 막연한 사정을 예상하거나 기대하고 법률행위를 하였으나 그러한 예상이나 기대와 다른 사정이 발생한 경우, 착오를 이유로 법률행위를 취소할 수 없다[2017다220058].

(2) 착오의 유형(類型)

① **표시상(表示上)의 착오** : 1000만원으로 적는다는 것을 100만원으로 잘못 적은 경우(오기(誤記)·오답(誤談)와 같이 표시행위 자체를 잘못한 경우를 말한다. 신원보증서류에 서명날인(署名捺印)한다는 착각에 빠진 상태로 연대보증의 서면에 서명날인한 경우, 결국 위와 같은 행위는 강학상 이른바 기명(서명)날인의 착오로서 표시상의 착오에 해당한다[2004다43824].

② **법률의 착오** : 법률의 착오란 법률의 존재 또는 효과에 대하여 인식을 잘못한 경우로 판례는 법률의 착오에 대해서도 제109조를 적용한다. 따라서 법률의 착오도 동기의 착오가 될 수도 있고 중요부분의 착오가 될 수도 있다.

③ **동기(動機)의 착오**

㉠ **의의** : 동기의 착오란 '의사표시를 하게 된 동기(연유)에 착오가 있는 경우'를 말한다. 예컨대, 전철역이 들어설 것이라고 오인하고서 토지를 고가로 매수하는 경우와 같이 표시에 대응하는 내심의 의사가 존재하지만 그 내심의 의사를 결정할 때의 동기 또는 의사를 결정하는 과정에 착오가 있는 경우이다.

㉡ **원칙** : 동기의 착오는 거래의 안전을 위하여 원칙적으로 법률행위의 착오가 아니므로 동기의 착오를 이유로 법률행위를 취소할 수 없다.

㉢ **예외** : 그러나 그 동기가 상대방에게 표시되어 상대방도 알면서 법률행위를 하고 그것이 중요한 부분에 관한 것이라면 법률행위를 취소할 수 있다[2000다12259]. 다만, 당사자들 사이에 별도로 그 동기를 의사표시의 내용으로 삼기로 하는 합의까지 이루어질 필요는 없다[97다26210].

㉣ **상대방으로부터 유발된 동기의 착오** : 동기의 착오가 상대방으로부터 유발된 경우에는 동기가 표시되지 않았다 하더라도 취소할 수 있다. 경계선을 침범하였다는 상대방의 강력한 주장에 의하여 착오로 그간의 경계침범에 대한 금원을 지급한 경우[97다6063], 담당공무원의 법령오해에 터잡아 토지소유자가 토지를 국가에 증여한 경우[90다카7460] 등은 상대방에 의하여 유발된 동기의 착오로서 취소할 수 있다.

2. 착오에 의한 취소요건

(1) 법률행위의 내용의 '중요부분'의 착오가 있을 것

① 중요부분의 의미

착오가 없었더라면 표의자(주관적 요건)가 그러한 의사표시를 하지 않았으리라고 인정될 정도로 착오가 중요한 부분에 관한 것이어야 하고 일반인(객관적 요건)도 표의자의 입장에 있었더라면 그러한 의사표시를 하지 않았으리라고 인정될 정도여야 한다[93다55487].

② 중요부분의 착오에 해당하는 경우

㉠ 토지의 현황 · 경계에 관한 착오는 성질의 착오로서 매매계약의 중요부분에 대한 착오이다. 답 1,389평을 전부 경작할 수 있는 농지인 줄 알고 매수하였으나 측량 결과 약 600평이 하천을 이루고 있는 경우[67다2160] 등은 법률행위 내용의 중요부분의 착오에 해당한다.

㉡ 甲이 채무자가 乙인 것으로 알고 근저당권설정자로 서명날인을 하였는데 그 후 채무자가 丙으로 되어 근저당권설정등기가 경료된 경우 법률행위내용의 중요부분에 관한 착오에 해당한다[95다37087].

㉢ 재건축아파트 설계용역에서 재건축조합이 건축사자격이 없이 건축연구소를 개설한 건축학교수에게 건축사자격이 있는 것으로 착각하여 설계용역계약을 체결한 경우는 중요 부분의 착오에 해당한다[2002다70884].

③ 중요부분의 착오가 아닌 경우

㉠ 계약의 내용이 건물 및 그 부지를 현 상태대로 매매한 것인 경우 위 부지(4평)에 관하여 0.211평(계산상 0.201평)에 해당하는 지분이 부족하다 하더라도 그러한 근소(미미)한 차이만으로써는 매매계약의 중요부분에 착오가 있었다거나 기망행위가 있었다고는 보기 어렵다[83다카1328].

㉡ 부동산 매매에 있어서 시가에 관한 착오는 동기의 착오에 불과할 뿐 법률행위의 중요부분에 관한 착오라고 할 수 없다[92다29337].

㉢ 특정 지번의 임야 전부에 관한 매매계약서에 표시된 지적이 실제 면적보다 작은 경우는 중요부분의 착오에 해당하지 않는다[69다196].

㉣ 착오로 인해 표의자가 경제적인 불이익을 입은 것이 아니라면 이를 법률행위내용의 중요부분의 착오라고 할 수 없다. 따라서 가압류등기가 없다고 믿고 보증하였더라도 그 가압류가 원인 무효인 것으로 밝혀진 경우, 가압류의 존재에 관하여 착오가 있었다고 하여 그로 인하여 무슨 경제적 불이익을 입은 것은 아니라고 할 것이므로 착오를 이유로 의사표시를 취소할 수 없다[98다23706].

(2) 표의자에게 중대한 과실이 없을 것

① 중대한 과실의 의의

㉠ 표의자의 직업 · 행위의 종류 · 목적 등에 비추어 보통 요구되는 주의를 현저히 결한 것을 의미한다[94다25964].

㉡ 중대한 과실의 유무는 구체적 사실관계에서 보통인이 베풀어야 할 주의를 표준으로 객관적으로 판단되어야 한다.

② 중대한 과실을 인정하여 취소권을 부정한 경우

㉠ 공인중개사를 통하지 않고 개인적으로 토지 거래를 하는 경우, 토지대장 등 공적장부를 확인하지 않아 매매계약 목적물에 착오가 있더라도 매수인은 중대한 과실이 있으므로 착오를 이유로 취소할 수 없다.

㉡ 공장을 경영하는 자가 공장을 설립할 목적으로 토지를 매수하면서 공장건축의 가능성을 관할관청에 알아보지 않은 것도 매수인에게 중대한 과실이 있는 것이다.

③ 중대한 과실이 없다고 하여 취소권을 인정한 경우

㉠ 부동산중개업자가 다른 점포를 매매 목적물로 잘못 소개하여 매수인이 매매 목적물에 관하여 착오를 일으킨 경우, 매수인에게 중대한 과실이 없다[97다32772, 32789].

㉡ 토지매매에 있어서 특별한 사정이 없는 한, 매수인이 측량을 통하여 매매목적물이 지적도상의 그것과 일치하는지 여부를 확인하지 않은 경우라도 매수인에게 그러한 주의의무가 있다고 볼 수 없으므로 중대한 과실이 인정되지 않는다[2019다288232].

(3) 입증책임

① **착오 및 중요부분에 관한 입증책임** : 착오를 이유로 의사표시를 취소하는 자(표의자)는 법률행위의 내용에 착오가 있었다는 사실과 함께 그 착오가 의사표시에 결정적인 영향을 미쳤다는 점, 즉 중요부분이라는 점을 증명하여야 한다[2007다74188].

② **중대한 과실에 대한 입증책임** : 표의자에게 중대한 과실이 있다는 사실의 입증책임은 상대방측, 즉 법률행위의 유효를 주장하는 자(취소를 저지하려는 자)가 부담한다.

3. 효 과

(1) 당사자 사이의 효과

① 중요부분의 착오이고 그 착오에 중대한 과실이 없는 경우에는 그 의사표시를 취소할 수 있다(제109조 제1항).

② 제109조는 임의규정이므로 표의자의 취소권을 배제하는 약정은 유효하다. 따라서 그러한 약정이 있는 경우에 표의자는 의사표시를 취소할 수 없다.

③ 표의자에게 중대한 과실이 있더라도 그 상대방이 표의자의 착오를 알고서 이용한 경우에는 표의자의 의사표시 취소가 허용된다[4288민상321].

④ 착오가 있다하더라도 상대방이 표의자의 진의에 동의한 경우에는 표의자의 진의대로 계약이 성립하므로 착오를 이유로 취소할 수 없다.

⑤ 법률행위 당시 착오가 있었더라도 그 후의 사정변경에 의하여 표의자에게 유리하게 되었고, 표의자의 착오 주장이 신의칙에 반하게 되는 경우에는 취소권이 배제된다[94다44620].

(2) **제3자에 대한 효력** : 착오로 인한 의사표시의 취소로써 선의의 제3자에게 대항하지 못한다(제109조 제2항).

(3) **표의자의 손해배상책임 여부** : 표의자에게 중과실은 없지만 경과실이 있을 경우에도 중요부분의 착오임을 이유로 취소할 수 있는데, 판례는 '착오를 이유로 의사표시를 취소하여 상대방이 손해를 입었더라도 착오에 빠진 것 자체가 위법하지는 않으므로 상대방은 불법행위를 이유로 손해배상을 청구할 수 없다'고 한다[97다카13023].

4. 적용범위

(1) **적용되는 경우** : 제109조는 원칙적으로 재산상 법률행위에 적용된다. 따라서 재산상의 계약, 단독행위 등에 적용된다.

(2) **적용되지 않는 경우**

① 당사자의 진의가 절대적으로 존중되는 가족법상의 법률행위에는 적용되지 않는다.

② 공법상 행위 또는 소송법상 행위에도 적용되지 않는다.

③ 따라서 소의 취하 등과 같은 소송행위의 경우에는 착오를 이유로 하는 취소가 허용되지 않는다. 다만, 소취하합의의 의사표시는 법률행위 내용의 중요 부분에 착오가 있으면 취소할 수 있다[2020다227523, 227530].

5. 다른 제도와의 관계

(1) **착오와 해제** : 매도인이 매매계약을 적법하게 해제한 후라도 매수인으로서는 불이익을 면하기 위하여 착오를 이유로 한 취소권을 행사하여 위 매매계약 전체를 무효로 돌리게 할 수 있다[91다11308].

(2) **착오와 담보책임** : 착오로 인한 취소 제도와 매도인의 하자담보책임 제도는 취지가 서로 다르고, 요건과 효과도 구별된다. 따라서 매매계약 내용의 중요 부분에 착오가 있는 경우 매수인은 매도인의 하자담보책임이 성립하는지와 상관없이 착오를 이유로 매매계약을 취소할 수 있다[2015다78703].

Ⅴ 사기(詐欺)·강박(强迫)에 의한 의사표시(하자 있는 의사 표시)

제110조(사기, 강박에 의한 의사표시) ① 사기나 강박에 의한 의사표시는 취소할 수 있다.
② 상대방 있는 의사표시에 관하여 제3자가 사기나 강박을 행한 경우에는 상대방이 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 그 의사표시를 취소할 수 있다.
③ 전2항의 의사표시의 취소는 선의의 제3자에게 대항하지 못한다.

1. 의 의

① '사기에 의한 의사표시'란 타인의 기망행위로 말미암아 착오에 빠진 상태에서 의사표시를 한 경우를 말하고, '강박에 의한 의사표시'란 타인의 강박행위로 인하여 공포심에 빠져서 한 의사표시를 말한다. 사기 또는 강박에 의한 의사표시를 합쳐 '하자있는 의사표시'라고 한다.

② 사기 또는 강박에 의한 의사표시는 의사와 표시의 불일치는 존재하지 아니하지만 타인의 위법한 간섭에 의하여 의사결정의 자유가 방해된 상태에서 행해진 의사표시를 말하며, 민법은 이를 취소할 수 있는 것으로 규정하고 있다.

2. 하자 있는 의사표시의 성립요건

(1) 사기에 의한 의사표시

① 사기자의 2단의 고의가 있을 것

표의자를 기망하여 착오에 빠지도록 하려는 고의와 표의자로 하여금 그 착오에 기해 의사표시를 하도록 하려는 고의의 2단의 고의가 있어야 한다. 따라서 과실에 의한 기망행위는 사기가 성립하지 않으며, 또한 피기망자에게 손해를 가할 의사까지는 요구되지 않는다.

② 기망행위(欺罔行爲)가 있을 것

㉠ 기망행위란 표의자로 하여금 사실과 다른 관념을 갖도록 하거나 이를(기존의 착오를) 유지·강화하도록 하는 일체의 행위를 말한다.

㉡ 단순한 침묵이나 부작위가 기망행위에 해당하는지가 문제되는데, 거래관념에 비추어 고지의무가 있음에도 고지하지 않은 경우에는 단순한 침묵이나 부작위도 기망행위가 될 수 있다. 예컨대, 아파트 분양자는 인근에 대규모의 공동묘지가 조성되어 있는 사실 또는 쓰레기매립장이 건설예정인 사실이 있다면, 분양시 그러한 사실을 알려야 할 신의칙상 의무를 부담하고, 이를 고지하지 않을 경우 부작위에 의한 기망행위가 성립한다[2005다5812,5829,5836, 2004다48515].

③ 위법성이 있을 것

㉠ 기망행위가 사회통념상 위법해야 한다. 기망행위가 위법한가 여부는 거래상 신의성실의 원칙에 반하는 것일 때에 위법한 것으로 본다.

㉡ 위법성이 있는 경우 : 종전판매가격을 실제보다 높게 표시하여 할인판매를 가장한 정상판매를 기도한 경우와 같은 백화점변칙세일은 그 사술 의 정도가 사회적으로 용인될 수 있는 상술의 정도를 넘은 것이어서 위법성이 있다[92다52665].

㉢ 위법성이 없는 경우

ⓐ 상품의 선전, 부동산의 광고에 있어 다소의 과장이나 허위가 수반되는 것은 그것이 일반 상거래의 관행과 신의칙에 비추어 시인될 수 있는 한 기망성이 결여된다[92다52665].

ⓑ 교환계약이나 매매계약을 체결하려는 일방당사자가 자기가 소유하는 목적물의 시가를 묵비하여 상대방에게 고지하지 아니하거나 혹은 허위로 시가보다 높은 가액을 시가라고 고지하였다 하더라도 이는 상대방의 의사결정에 불법적인 간섭을 한 것이라고 볼 수 없다[2000다54406, 54413, 2012다54997].

④ 인과관계가 있을 것 : 기망행위에 의해 표의자가 착오에 빠지고, 그 착오에 의해 의사표시를 하여야 한다. 이 인과관계는 보통 일반인을 기준으로 할 필요가 없고 표의자의 주관적인 것으로 충분하다.

(2) 강박에 의한 의사표시

① 강박자에게 2단의 고의가 있을 것 : 해악을 고지하여 표의자로 하여금 공포심을 생기게 하고 이로 인하여 의사표시를 하게 하려는 2단의 고의가 있어야 한다.

② 강박행위가 있을 것

㉠ 강박행위란 '어떤 해악을 고지함으로 말미암아 공포심를 느끼게 하는 일체의 행위'를 말한다. 해악의 종류나 강박행위의 방법은 제한이 없다.

㉡ 강박이 의사결정의 자유를 제한하는 정도에 그친 경우에는 그 의사표시는 취소할 수 있으나 강박의 정도가 극심하여 표의자의 의사결정의 자유가 완전히 박탈된 상태에서 의사표시가 이루어져 단지 법률행위의 외형만이 만들어진 것에 불과한 정도라면 이는 무효이다[96다49353].

㉢ 그러나 채권자들이 채무자에게 단지 각서에 서명 날인할 것을 강력히 요구한 것만으로는 강박행위라 할 수 없다[73다1048].

③ 강박행위에 위법성이 있을 것

㉠ 어떤 해악을 고지하는 강박행위가 위법하다고 하기 위하여는, 강박행위 당시의 거래관념과 제반 사정에 비추어 해악의 고지로써 추구하는 이익이 정당하지 아니하거나 강박의 수단으로 상대방에게 고지하는 해악의 내용이 법질서에 위배된 경우 또는 어떤 해악의 고지가 거래관념상 그 해악의 고지로써 추구하는 이익의 달성을 위한 수단으로 부적당한 경우 등에 해당하여야 한다[99다64049].

㉡ 일반적으로 부정행위에 대한 고소, 고발은 정당한 권리행사가 되어 위법하다고 할 수 없으나, 부정한 이익의 취득을 목적으로 하는 경우나 목적이 정당하다 하더라도 행위나 수단 등이 부당한 때에는 위법한 강박행위가 되는 경우가 있다[92다25120].

④ **인과관계(因果關係)가 있을 것** : 강박행위로 표의자가 공포심을 일으키고 그 공포심으로 인해 의사표시를 하여야 한다. 인과관계는 표의자의 주관적인 것에 불과더라도 무방하다.

3. 사기 · 강박에 의한 의사표시의 효과

(1) 상대방이 사기 · 강박을 한 경우

표의자는 사기 · 강박에 의한 의사표시를 취소할 수 있다(제110조 제1항).

판 례

의사표시가 강박에 의한 것이어서 당연 무효라는 주장 속에 강박에 의한 의사표시이므로 취소한다는 주장이 포함된 것으로 볼 수 있는지 여부(소극)

의사표시가 강박에 의한 것이어서 당연무효라는 주장 속에 강박에 의한 의사표시이므로 취소한다는 주장이 당연히 포함되어 있다고는 볼 수 없다(대판 1996. 12. 23. 95다40038).

(2) 제3자가 사기 · 강박을 한 경우

① 상대방 있는 의사표시

상대방이 제3자의 사기 · 강박을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한해 표의자는 그 의사표시를 취소할 수 있다. 따라서 상대방이 선의 · 무과실일 경우에는 취소할 수 없다.

② 제3자의 사기 · 강박에서 제3자 해당 여부

㉠ 그 의사표시에 관한 상대방의 대리인 등 상대방과 동일시할 수 있는 자의 사기나 강박은 제3자의 사기강박에 해당되지 아니한다[98다60828]. 따라서 대리인의 사기에 의하여 상대방이 의사표시를 하였을 경우에 상대방은 본인이 그 사실을 알든, 모르든 기망에 인한 의사표시를 취소할 수 있다[4291민상101].

㉡ 단순히 상대방의 피용자의 사기나 강박은 제3자의 사기나 강박에 해당하여 상대방이 피용자의 사기 · 강박을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한해 표의자는 그 의사표시를 취소할 수 있다[96다41496].

(3) 제3자에 대한 효과

① 사기 · 강박에 의한 의사표시의 취소는 선의의 제3자에게 대항하지 못한다(법 제110조 제3항).

② 제3자는 특별한 사정이 없는 한 선의로 추정할 것이므로 표의자가 제3자에 대해 사기에 의한 의사표시의 취소를 주장하려면 제3자의 악의를 입증할 필요가 있다[70다2155].

4. 적용범위

(1) 적용되는 경우

사법상의 계약뿐만 아니라 단독행위에도 적용된다.

(2) 적용되지 않는 경우

가족법상 행위, 공법상 행위, 소송법상 행위 등에는 적용되지 않는다. 따라서 사기나 강박에 의한 소송행위는 원칙적으로 취소할 수 없다(대판 1997.10.10. 96다35484).

5. 다른 제도와의 관계

(1) 사기와 착오

① 착오가 타인의 기망행위에 기해 발생한 때에는 표의자는 사기 또는 착오를 선택적으로 주장할 수 있다. 따라서 표의자가 상대방의 기망행위로 인해 법률행위의 동기에 관하여 착오를 일으킨 경우에는 사기를 이유로 그 법률행위를 취소할 수 있다. 즉, 사기에 의해 한 의사표시는 법률행위의 중요부분에 착오가 없다고 하더라도 취소할 수 있다[68다1749].

판 례

사기에 의한 의사표시의 의의(착오에 의한 의사표시와의 구분)

사기에 의한 의사표시란 타인의 기망행위로 말미암아 착오에 빠지게 된 결과 어떠한 의사표시를 하게 되는 경우이므로 거기에는 의사와 표시의 불일치가 있을 수 없고, 단지 의사의 형성과정, 즉 의사표시의 동기에 착오가 있는 것에 불과하며, 이 점에서 고유한 의미의 착오에 의한 의사표시와 구분된다(대판 2005.5.27. 2004다43824).

② 다만, 제3자의 기망행위에 의하여 신원보증서류에 서명날인(署名捺印) 한다는 착각에 빠진 상태로 연대보증의 서면에 서명날인한 경우(표시상의 착오)에는 비록 위와 같은 착오가 제3자의 기망행위에 의하여 일어난 것이라 하더라도 민법 제110조 제2항의 규정을 적용할 것이 아니라, 착오에 의한 의사표시에 관한 법리만을 적용하여 취소권 행사의 가부를 가려야 한다[2004다43824].

(2) 담보책임과의 관계

기망에 의하여 하자있는 물건에 관한 매매가 성립한 경우에는 매수인은 하자담보책임을 묻거나 사기에 의한 취소권 행사를 선택적으로 할 수 있다.

(3) 사기와 불법행위책임

① 사기 · 강박이 불법행위의 요건을 갖춘 때에는 표의자는 의사표시의 취소와 함께 불법행위에 기한 손해배상청구권도 행사할 수 있다.

② 다만, 제3자의 사기행위로 계약을 체결한 경우, 피해자가 제3자를 상대로 손해배상청구를 하기 위하여 반드시 그 계약을 취소할 필요는 없다[97다55829]. 즉, 기망행위에 의하여 분양계약을 체결한 표의자는 기망을 이유로 분양계약을 취소하고 분양대금의 반환을 구할 수도 있고, 분양계약의 취소를 원하지 않을 경우 그로 인한 손해배상만을 청구할 수도 있다[2004다48515].

③ 또한 법률행위가 사기에 의한 것으로서 취소되는 경우에 그 법률행위가 동시에 불법행위를 구성하는 때에는 취소의 효과로 생기는 부당이득반환청구권과 불법행위로 인한 손해배상청구권은 경합하여 병존한다[92다56087].

제 3 절 의사표시의 효력발생

Ⅰ 서 설

상대방 있는 의사표시에 대하여는 상대방에게 알리는 것을 목적으로 하기 때문에 그 의사표시에 있어서는 ① 의사표시의 효력발생시기, ② 의사표시의 수령능력, ③ 상대방이 누구인지를 모르는 경우 등에 어떻게 하여야 하는가 등이 문제된다. 민법은 이들 경우에 관하여 명문규정(제111조 내지 제113조)을 두고 있다.

Ⅱ 의사표시의 효력발생시기

제111조(의사표시의 효력발생시기) ① 상대방이 있는 의사표시는 상대방에게 도달한 때에 그 효력이 생긴다.

② 의사표시자가 그 통지를 발송한 후 사망하거나 제한능력자가 되어도 의사표시의 효력에 영향을 미치지 아니한다.

1. 도달주의 원칙

(1) **의 의** : 우리 「민법」은 제111조에서 '상대방이 있는 의사표시는 상대방에게 도달한 때에 그 효력이 생긴다.'고 하여 도달주의를 원칙으로 하고 있다. 이러한 도달주의를 규정한 「민법」 제111조는 임의규정이다.

보충학습

상대방 없는 의사표시는 원칙적으로 표시행위가 완료된 때에 효력을 발생한다(표백주의).

(2) **도달의 개념**

① **도달의 의의** : 도달이라 함은 사회통념상 상대방이 통지의 내용을 알 수 있는 객관적 상태에 놓여 있는 경우를 가리키는 것으로서, 상대방이 통지를 현실적으로 수령하거나

통지의 내용을 알 것까지는 필요로 하지 않는다.

판 례

의사표시에 대한 상대방의 수령거절과 의사표시의 도달 여부

계약의 해제와 같은 상대방 있는 의사표시는 그 통지가 상대방에게 도달한 때 효력이 생기는 것이고(민법 제111조 제1항), 상대방이 정당한 사유 없이 통지의 수령을 거절한 경우에는 상대방이 그 통지의 내용을 알 수 있는 객관적 상태에 놓여 있는 때에 의사표시의 효력이 생기는 것으로 보아야 한다. 따라서 매매계약을 해제하겠다는 내용증명우편이 상대방에게 도착하였으나, 상대방이 정당한 사유 없이 그 우편물의 수취를 거절한 경우에 해제의 의사표시가 도달한 것으로 볼 수 있다(대판 2008다19973).

② 도달로 인정되는 경우

㉠ 동거하는 가족 · 고용인이 우편을 수령한 때에는 본인에게 전달되지 않은 경우에도 의사표시의 효력은 발생한다.

㉡ 상대방이 수령을 거절하더라도 그가 통지의 내용을 알 수 있는 객관적 상태에 놓인 때에 의사표시의 효력이 생기는 것으로 보아야 한다.

㉢ 등기우편이나 내용증명우편물이 발송되고 반송되지 않았다면 특단의 사정이 없는 한 그 무렵에 송달되었다고 볼 것이다[96다38322].

③ 도달로 인정되지 않는 경우

㉠ 보통우편의 방법으로 발송되었다는 사실만으로는 그 우편물이 상당기간 내에 도달하였다고 추정할 수 없고 송달의 효력을 주장하는 측에서 증거에 의하여 도달사실을 입증하여야 한다[2000다25002].

㉡ 우편물이 의사표시 상대방의 주소나 사무소가 아닌 그 동업자의 사무소에서 신원이 분명치 않은 자에게 송달되었다는 사정만으로는 도달을 인정할 수 없다[97다31281].

㉢ 우편물이 수취인 가구의 우편함에 투입되었다고 하더라도 분실 등을 이유로 그 우편물이 수취인의 수중에 들어가지 않을 가능성이 적지 않게 존재하는 현실에 비추어, 아파트 경비원이 집배원으로부터 우편물을 수령한 후 이를 우편함에 넣어 둔 사실만으로 수취인이 그 우편물을 수취하였다고 추단할 수는 없다[2005다66411].

(2) 도달주의의 효과

① **도달 후의 효과** : 의사표시는 상대방에게 도달한 때에 효력이 생기므로 도달 후에는 상대방이 그 내용을 알기 전이라도 철회할 수 없다. 그러나 표의자는 발신 후 도달 전에는 의사표시를 철회할 수 있으며 철회의 의사표시는 원래의 의사표시와 동시에 또는 그보다 먼저 도달해야 한다.

② **발신 후의 사정변경** : 의사표시를 발송한 후 도달 전에 표의자가 사망하거나 제한 능력자가 되어도 의사표시의 효력에 영향을 미치지 아니한다(제11조 제2항).

③ **불착 · 연착의 불이익 부담** : 의사표시의 불착 · 연착으로 인한 불이익은 표의자에게 귀속된다. 따라서 의사표시의 도달에 대한 입증책임은 도달을 주장하는 표의자가 부담한다.

2. 도달주의의 예외(발신주의)

제한능력자 상대방의 촉구에 대한 제한능력자 측의 확답(제15조), 무권대리인 상대방의 최고에 대한 본인의 확답(제131조), 격지자간 계약의 승낙 통지(제531조), 사원총회 소집통지(제71조), 연착한 승낙의 도달 전에 지연의 통지(제528조 제2항)는 발신주의에 따른다.

Ⅲ 의사표시의 수령능력(受領能力)

제112조(제한능력자에 대한 의사표시의 효력) 의사표시의 상대방이 의사표시를 받은 때에 제한능력자인 경우에는 의사표시자는 그 의사표시로써 대항할 수 없다. 다만, 그 상대방의 법정대리인이 의사표시가 도달한 사실을 안 후에는 그 의사표시로써 대항할 수 있다.

(1) 의 의

의사표시의 상대방이 의사표시를 유효하게 수령할 수 있는 능력을 말한다. 그러나 수령이 문제되지 않는 상대방 없는 단독행위, 제한능력자가 대리행위를 하는 경우, 발신주의가 적용되는 경우, 공시송달에 의한 의사표시 등에는 적용되지 않는다.

(2) 수령무능력자

민법은 모든 제한능력자(미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인)를 수령무능력자로 보고 있다. 다만, 미성년자, 피한정후견인에게 일정한 경우 예외적으로 행위능력이 인정되는 범위에서는 수령능력을 갖는다.

(3) 의사표시의 효력

① 표의자는 그 의사표시로써 제한능력자에게 대항하지 못하나 제한능력자 측에서 의사표시의 유효한 도달을 주장하는 것은 무방하다(제112조 본문).

② 상대방이 수령무능력자라도 법정대리인이 의사표시의 도달을 안 후에는 의사표시자는 의사표시의 도달을 주장할 수 있다(제112조 단서).

Ⅳ 의사표시의 공시송달(公示送達)

제113조(의사표시의 공시송달) 표의자가 과실없이 상대방을 알지 못하거나 상대방의 소재를 알지 못하는 경우에는 의사표시는 민사소송법 공시송달의 규정에 의하여 송달할 수 있다.

CHAPTER

04 법률행위의 대리(代理)

제 1 절 서 설

1. 대리의 의의

(1) 대리의 개념

대리란 대리인이 본인을 위한 것임을 표시하고 법률행위를 하거나 의사표시를 수령하여 법률관계를 맺게 되면, 그 법률효과가 직접 본인에게 생기게 하는 제도로서 법률행위의 행위자와 그 효과의 귀속자가 분리되는 예외적인 제도의 하나이다.

예컨대, 甲이 乙에게 건물의 매각을 위하여 대리권을 준 경우, 대리인 乙이 매수인 丙과 甲의 이름으로 매매계약을 체결하면 그에 따른 법률효과(권리와 의무)가 甲과 丙사이에 생기는 것이다.

(2) 대리가 인정되는 범위

① **법률행위** : 원칙적으로 의사표시를 요소로 하는 재산상 법률행위에만 허용되고, 법률행위 중에서도 혼인 · 인지 · 입양 · 유언 등과 같은 가족법상의 법률행위에는 성질상 대리가 허용되지 않는다.

② **사실행위, 불법행위** : 당사자의 의식의 내용을 묻지 않고 어떤 행위가 행해졌다는 결과만을 중시하는 사실행위나 불법행위 등에는 대리가 인정되지 않는다.

2. 대리의 종류

(1) 임의대리(任意代理) · 법정대리(法定代理)

대리권의 발생원인에 따라서 임의대리와 법정대리로 구분한다. '임의대리'는 본인의 수권행위에 의해 대리권이 발생한 경우이고, '법정대리'는 본인의 의사와 무관하게 법률규정에 의해 대리권이 주어지는 경우를 총칭한다.

(2) 능동대리(能動代理) · 수동대리(受動代理)

대리행위의 모습에 따른 구분으로 '**능동대리**'는 대리인이 본인을 위하여 상대방에게 의사표시를 하는 대리를 말한다. '**수동대리**'는 대리인이 상대방의 의사표시를 수령하는 경우를 말한다.

(3) 유권대리(有權代理) · 무권대리(無權代理)

대리권 유무에 따른 구분으로 '**유권대리**'는 정당한 대리권을 가지고 있는 경우의 대리를 말하고, '**무권대리**'는 정당한 대리권을 가지고 있지 않는 경우의 대리를 말한다. 무권대리에는 협의의 무권대리와 표현대리로 구분된다.

3. 대리에 있어서 3면관계

(1) 본인과 대리인과의 관계(대리권)

본인과 대리인 사이에는 대리인에게 본인을 대리하여 법률행위를 할 수 있는 권한인 대리권(代理權)이 있어야 하는데, 대리권에 관한 주된 문제로는 대리권의 발생, 범위, 제한, 소멸에 대한 내용이다.

(2) 대리인과 상대방과의 관계(대리행위)

대리인과 상대방과의 법률행위의 효과가 본인에게 귀속하기 위해서는 대리인이 그 권한 내에서 이루어진 것이어야 하며, 대리인의 의사표시가 본인을 위한 것임을 표시하여 행하여져야 한다(대리행위 代理行爲).

(3) 본인과 상대방과의 관계(대리효과)

이러한 요건들이 갖추어지면 대리행위는 직접 본인에게 대하여 효력이 생긴다(대리효과 代理效果).

제 2 절 대리의 3면관계

Ⅰ 대리권 : 본인과 대리인 관계

1. 서 설

(1) 대리권의 의의

대리권이란 타인이 본인의 이름으로 법률행위를 하거나 의사표시를 수령하여 그 법률효과를 본인에게 생기게 할 수 있는 법률상의 지위 또는 자격을 말한다.

(2) 대리권의 발생원인

① 법정대리권의 발생원인

법률의 규정(친권자 제911조, 제920조), 일상가사대리(제827조), 지정권자의 지정(미성년자의 친권자가 유언으로 지정한 미성년후견인 제931조), 법원의 선임(제한능력자를 위해 법원이 선임한 선임후견인 제932조, 부재자재산관리인 제23조, 제24조 등)에 의해 발생한다.

② 임의대리권의 발생원인 – 수권행위(授權行爲)

㉠ 수권행위의 의의

수권행위란 본인의 일방적 의사표시에 의하여 대리인에게 대리권을 수여하는 행위를 말한다. 수권행위는 상대방의 승낙을 요하지 않고 수령을 요하는 본인의 단독행위(일방적 의사표시)이다. 대리권을 수여하는 수권행위는 불요식의 행위로서 명시적인 의사

표시에 의함이 없이 묵시적인 의사표시에 의하여 할 수도 있으며, 어떤 사람이 대리인의 외양을 가지고 행위하는 것을 본인이 알면서도 이의를 하지 아니하고 방임하는 등 사실상의 용태에 의하여 대리권의 수여가 추단되는 경우도 있다[2016다203315].

㉡ **수권행위와 원인된 법률관계(기초적 내부관계)** : 위임, 고용 등 기타의 기초적 내부관계를 '대리의 원인관계'라고 하고, 수권행위는 원인된 법률관계(기초적 내부관계)와는 독립된 별개의 행위로 본다(수권행위의 독자성).

2. 대리권의 범위

(1) 법정대리권의 범위

법정대리권의 범위는 법률의 규정에 의해 정해진다.

(2) 임의대리권의 범위

① 원칙 – 수권행위의 해석

㉠ 임의대리권의 범위는 원칙적으로 본인의 수권행위에 의하여 결정된다. 본인은 대리인에게 일정한 사항에 한정하거나(특정수권) 또는 일정범위의 사항에 관하여 포괄적으로 대리권을 줄 수 있다(포괄수권). 그러므로 대리권의 범위는 궁극적으로는 수권행위의 해석에 의하여 확정된다.

㉡ 대리권의 범위에 포함되는 경우

ⓐ 임의대리권은 그 권한에 부수하여 필요한 한도에서 상대방의 의사표시를 수령하는 수동(수령)대리권을 포함하는 것이라고 한다[93다39379].

ⓑ 부동산매매계약을 체결할 대리권을 수여받은 대리인은 특별한 사정이 없는 한 그 매매계약에서 약정한 바에 따라 중도금이나 잔금을 수령할 권한도 있다[93다39379]. 따라서 대리인이 상대방으로부터 대금 전부를 지급받고 아직 본인에게 전달하지 않았더라도, 특별한 사정이 없는 한 상대방의 대금지급채무는 소멸한다.

ⓒ 부동산매매계약의 체결과 이행에 관하여 포괄적으로 대리권을 수여받은 대리인은 특별한 다른 사정이 없는 한 상대방에 대하여 약정된 매매대금지급기일을 연기하여 줄 권한도 가진다[91다43107].

㉢ 대리권의 범위에 포함되지 않는 경우

ⓐ 금전소비대차계약과 그 담보를 위한 담보권설정계약을 체결할 대리권을 수여받은 것으로 인정되는 경우라 하더라도 특별한 사정이 없는 한 이를 해제할 권한까지 당연히 가지고 있다고 볼 수는 없다[97다23372].

ⓑ 특별한 다른 사정이 없는 한 부동산을 매수할 권한을 수여받은 대리인에게 그 부동산을 처분할 대리권도 있다고 볼 수 없다(대판 1991.2.12. 90다7364).

ⓒ 대여금의 영수권한만을 위임받은 대리인이 그 대여금채무의 일부를 면제하려면 그에 관한 특별수권이 필요하다[80다3221].

ⓓ 어떠한 계약의 체결에 관한 대리권을 수여받은 대리인이 체결된 계약의 해제 등 일체의 처분권과 상대방의 의사를 수령할 권한까지 가지고 있다고 볼 수는 없다(대판 2008.6.12. 2008다11276).

ⓔ 예금계약의 체결을 위임받은 자가 가지는 대리권에 당연히 그 예금을 담보로 대출을 받거나 이를 처분할 수 있는 대리권이 포함되어 있는 것은 아니다[2000다38992].

② 수권행위로 권한을 정하지 않은 경우

> **제118조(대리권의 범위)** 권한을 정하지 아니한 대리인은 다음 각호의 행위만을 할 수 있다.
> 1. 보존행위
> 2. 대리의 목적인 물건이나 권리의 성질을 변하지 아니하는 범위에서 그 이용 또는 개량하는 행위

㉠ **보존행위** : 보존행위란 재산가치의 현상을 그대로 유지하려는 행위를 말한다. 건물의 수선, 권리소멸시효의 중단조치, 미등기부동산의 등기, 기한이 도래한 채무의 변제, 부패하기 쉬운 물건의 처분 등은 보존행위로서 제한 없이 대리가 허용된다.

㉡ 이용 · 개량행위

ⓐ 이용행위란 재산의 수익을 꾀하는 행위로서 물건의 임대, 금전의 이자부 대여 등을 말한다.

ⓑ 개량행위란 사용가치나 교환가치를 증가시키는 행위로서 무이자채권을 이자부로 변경하는 행위, 목적부동산에서 제한물권을 제거하는 행위 등이 이에 해당한다.

ⓒ 이용 · 개량행위에 관해서는 물건 · 권리의 성질을 변화시키지 않는 범위내에서만 대리가 허용되고 본인에게 이익이 되는지 여부는 묻지 않는다. 따라서 은행예금을 찾아 개인에게 대여하는 것, 은행예금을 찾아 주식을 사는 것, 임야를 대지로 형질변경 등은 허용되지 않는다.

3. 대리권의 제한

(1) 자기계약(自己契約) · 쌍방대리(雙方代理) 금지

> **제124조(자기계약, 쌍방대리)** 대리인은 본인의 허락이 없으면 본인을 위하여 자기와 법률행위를 하거나 동일한 법률행위에 관하여 당사자 쌍방을 대리하지 못한다. 그러나 채무의 이행은 할 수 있다.

① 의의

'자기계약'이란 부동산의 매도대리권을 가진 대리인이 그 부동산을 매수하는 것과 같이 대리인이 한편으로는 본인을 대리하면서 다른 한편으로는 자기 자신이 상대방이 되어 계

약을 맺는 것을 말하고, '쌍방대리'란 동일한 대리인이 하나의 법률행위를 함에 있어 당사자 쌍방의 대리인이 되어 대리행위를 하는 것을 말한다.

② 원칙적 금지

본인의 이익을 해칠 우려가 있기 때문에 대리인은 자기계약이나 쌍방대리는 하지 못한다(제124조). 이를 위반하면 무권대리가 되어 무효이나 본인이 추인하면 유효가 될 수 있다. 따라서 부동산 입찰절차에서 동일물건에 관하여 이해관계가 다른 2인 이상의 대리인이 된 경우에는 그 대리인이 한 입찰은 무효이다(대결 2004.2.13. 2003마44).

③ 예외적 허용

'본인의 허락'이 있는 경우와 '채무이행'의 경우에는 허용된다. 채무이행은 이미 성립하고 있는 이해관계의 결제에 불과하며 새로운 이해관계를 생기게 하는 것이 아니기 때문이다.

㉠ '본인의 허락'이 있는지 여부는 자기계약이나 쌍방대리행위에 관하여 유효성을 주장하는 자가 주장증명책임을 부담하고, 이때의 '허락'은 '묵시적 허락' 또는 '사후 추인'의 방식으로도 가능하다[2023다225580].

㉡ 동일한 법무사가 등기권리자(매수인)와 등기의무자(매도인) 쌍방을 대리하여 소유권이전등기를 신청하는 행위는 허용된다[69다571].

㉢ 본인이 대리인에게 채무를 진 경우 대리인은 본인의 허락이 없더라도 변제기에 도래한 그 채무를 자신에게 변제 할 수 있다(자기계약).

㉣ 그러나 채무의 이행이라도 이익 충돌의 위험이 있는 기한이 도래하지 않은 채무의 변제, 항변권이 붙은 채무의 변제나 대물변제, 경개의 경우는 허용되지 않는다.

(2) 각자대리원칙

제119조(각자대리) 대리인이 수인인 때에는 각자가 본인을 대리한다. 그러나 법률 또는 수권행위에 다른 정한 바가 있는 때에는 공동으로 대리한다.

대리인이 수인인 때에는 각자가 본인을 대리하는 것이 원칙이다(제119조). 그러나 법률규정(친권자) 또는 수권행위에 의해 대리행위를 대리인공동으로 해야 하는 경우를 공동대리라 하는데, 이는 각 대리인에 대해 대리권을 제한하고 대리인의 의사결정을 신중하게 함으로써 본인을 보호하기 위함이다.

4. 대리권의 남용(濫用)

(1) 의 의

대리인이 외형적으로는 대리권 범위 안에서 한 대리행위이지만 실질적으로는 본인의 이익에 반하여 대리인 자신 또는 제3자의 이익을 위한 배임적 행위를 한 경우를 말한다.

(2) **대리권남용의 효과**(비진의표시에 관한 규정 유추적용)

대리의사가 있고 현명이 있는 한 배임적 대리행위도 본인을 위한 대리행위로서 유효하다. 다만, 대리인의 배임행위를 상대방이 알았거나 알 수 있었을 경우에는 비진의표시에 관한 민법 제107조 제1항 단서를 유추적용하여 그 대리행위는 무효가 되어 본인은 책임을 지지 않는다[2000다20694].

5. 대리권의 소멸

(1) **임의대리 · 법정대리의 공통된 소멸사유**(제127조)

① 본인의 사망, 대리인의 사망, 대리인의 성년후견의 개시 또는 파산으로 대리권은 소멸한다.

② 주의할 점은 피성년후견인이나 파산자도 의사능력이 있으면 대리인이 될 수 있지만, 대리인으로 선임된 후에 성년후견이 개시되거나 파산자가 되면 본인에게 예상치 못한 손해를 줄 수 있으므로 대리권은 소멸한다.

③ 그러나 대리인의 한정후견의 개시는 대리권소멸사유가 아니다.

(2) **임의대리에 특유한 소멸사유**(제128조)

① 임의대리권은 그 원인된 법률관계(위임, 고용 등)의 종료에 의해 소멸한다.

② 원인된 법률관계의 종료전에도 본인이 수권행위를 철회하면 임의대리권은 소멸한다.

Ⅱ 대리행위 : 대리인과 상대방과의 관계

1. 의 의

대리행위란 대리인이 대리권의 범위 내에서 본인을 위한 것임을 표시(현명)하여 상대방에게 의사표시를 하거나 상대방으로부터 의사표시를 수령하는 것을 말한다. 대리인이 법률행위를 하더라도 본인을 위한 것임을 표시하지 않았다면 대리행위가 성립하지 않아 그 법률행위의 효력은 본인에게 귀속되지 않는다.

2. 현명주의(顯名主義)

제114조(대리행위의 효력) ① 대리인이 그 권한내에서 본인을 위한 것임을 표시한 의사표시는 직접 본인에게 대하여 효력이 생긴다.
② 전항의 규정은 대리인에게 대한 제3자의 의사표시에 준용한다.

(1) **현명의 의의**(대리의사의 표시) : 대리인이 대리행위시에 그 법률행위가 본인을 위한 것임을 표시하는 것으로써 '본인을 위한 것'은 대리인이 본인을 대리한다는 것을 뜻하는 것으로 본인에게

법률행위의 효과를 귀속시키려는 의사를 의미하는 것이지 본인의 이익을 위한 것을 뜻하지 않는다. 수동대리에서는 상대방쪽에서 본인에 대한 의사표시임을 표시하여야 한다(제114조 제2항).

(2) 현명의 방법

① 본인을 위한 것임을 알 수 있는 한 현명의 방식에는 제한이 없다. 따라서 서면으로 할 수도 있고 구두로도 할 수 있다[4278민상205].

② 현명은 주위의 사정으로부터 본인을 위한 것임이 인정되면 충분하다. 예컨대, 매매위임장을 제시하고 매매계약을 체결하는 자는 매매계약서에 대리관계의 표시 없이 대리인 자신의 이름을 기재하였다 하여도 소유자를 대리하여 매매계약을 체결한 것으로 본다[2000다20069].

③ 계약서에 대리인의 이름을 기재하지 않고, 직접 본인의 이름만을 기재하여 마치 본인 자신이 하는 것과 같은 대리행위를 하는 경우에도 주위사정에 비추어 대리의사가 있는 것으로 인정되는 한 유효한 대리행위가 된다[63다67].

(3) 현명하지 않은 경우의 효력

① 원칙

대리인이 본인을 위한 것임을 표시하지 않은 경우의 의사표시는 대리인 자신을 위한 것으로 본다(제115조 본문). 따라서 대리인이 본인을 위한 것임을 현명하지 않고 상대방과 계약을 체결하였고 상대방도 대리인이 계약당사자라고 과실 없이 믿은 경우에는 대리인이 법률관계의 당사자로 간주되므로 상대방은 대리인에 대해서만 계약의 이행을 청구 할 수 있다. 이 경우에 대리인은 현명하지 않은 것을 착오를 이유로 의사표시를 취소할 수 없다.

② 예외

대리인이 현명을 하지 않았다 하더라도 상대방이 대리인으로서 한 것임을 알았거나 알 수 있었을 때에는 유효한 대리행위가 성립하고 법률효과가 본인에게 발생한다(제115조 단서).

(4) 현명주의의 예외

상행위에는 현명주의의 원칙이 적용되지 않는다. 미성년자의 법정대리인의 법률행위는 현명하지 않더라도 미성년자를 위하여 한 행위로 추정된다[62다815].

3. 대리행위의 하자(瑕疵)

(1) 원칙 – 대리인 표준

① 의사표시의 효력이 의사의 흠결(비진의표시 · 허위표시 및 착오), 사기 · 강박 또는 어느 사정을 알았거나 과실로 알지 못한 것으로 인하여 영향을 받을 경우에 그 사실의 유무는 대리인을 표준하여 결정한다(제116조 제1항). 그러나 대리행위 하자에서 생기는 효과(취소권, 해제권 등)는 본인에게 귀속한다.

② **이중매매** : 대리인이 본인을 대리하여 매매계약을 체결함에 있어서 매도인의 배임행위에 적극가담 하였다면 설사 본인이 미리 그러한 사정을 몰랐거나 반사회성을 야기한 것이 아니라고 할지라도 그 매매계약은 사회질서에 반한다[97다45532].

③ **허위표시** : 대리인이 상대방과 통정한 허위의 의사표시는 본인에 대해서나 대리인에 대해서나 무효이다.

④ **착오** : 착오가 있었는지 여부는 대리인을 기준으로 판단하므로, 본인에게 착오가 있다고 하더라도 대리인에게 착오가 없으면 취소할 수 없다. 매수인이 대리인을 통하여 매매계약을 체결한 경우, 매수인 본인에게 계약 내용, 잔금 지급 내역 등에 관하여 착오가 있었다 하더라도 대리인이 이를 잘 알고 있었다면 매수인은 그 자신의 착오를 이유로 매매계약을 취소할 수 없다[95다41406].

⑤ **사기 · 강박**

㉠ **상대방이 대리인을 사기 · 강박한 경우**

상대방으로부터 대리인이 사기 · 강박을 당했다면 제116조 제1항에 따라 본인은 그 사실을 알든, 모르든 의사표시를 취소할 수 있다. 제116조 제1항은 대리인의 의사표시에 하자가 있는 경우에 적용된다.

㉡ **상대방이 본인을 사기 · 강박**

상대방으로부터 본인이 사기 · 강박을 당한 경우 대리인이 이를 몰랐고 사기 · 강박을 당하지도 않았다면 본인은 취소할 수 없다[66다66].

㉢ **대리인이 상대방을 사기 · 강박한 경우**

대리인은 본인과 동일시할 수 있으므로 그 상대방은 제110조 제1항에 따라 의사표시를 취소할 수 있다. 대리인의 사기 · 강박을 본인이 알든 모르든 취소할 수 있다.

(2) 예외 – 본인을 표준

① 특정한 법률행위를 위임한 경우에 대리인이 본인의 지시에 좇아 그 행위를 한 때에는 본인은 자기가 안 사정 또는 과실로 인하여 알지 못한 사정에 관하여 대리인의 부지를 주장하지 못한다(제116조 제2항). 따라서 대리인이 본인의 지시에 따라 매수를 한 경우에는 본인이 매매목적물의 하자를 알고 있었거나 과실로 알지 못했다면 대리인이 알지 못했다 하더라도 본인은 매도인에게 하자담보책임을 물을 수 없다.

② **불공정한 법률행위**

매도인의 대리인이 매매한 경우에 있어서 그 매매가 불공정한 법률행위인가를 판단함에는 매도인의 경솔, 무경험은 대리인을 기준으로 하여 판단하여야 하지만, 궁박상태에 있었는지의 여부는 매도인 본인의 입장에서 판단되어야 한다[71다2255].

4. 대리인의 능력(能力)

제117조(대리인의 행위능력) 대리인은 행위능력자임을 요하지 아니한다.

① 대리행위로 인한 법률효과는 본인에게 귀속하고 대리인은 아무런 불이익을 받지 않기 때문에, 대리인은 행위능력자임을 요하지 않는다. 따라서 제한능력자인 대리인이 대리행위를 한 때에도 그 행위는 취소할 수 없다.

② 그러나 대리인은 적어도 의사능력은 있어야 한다. 따라서 대리인이 의사능력이 없다면 그 대리행위는 무효이다.

Ⅲ 대리의 효과

대리인이 그 권한 내에서 본인을 위한 것임을 표시한 의사표시는 직접 본인에게 대하여 효력이 생긴다. 따라서 대리행위로 인한 이행청구권 · 취소권 · 해제권 · 부당이득반환 · 원상회복 등의 법률효과는 본인에게 귀속한다.

판 례

계약이 적법한 대리인에 의하여 체결되었는데 상대방 당사자가 계약상 채무불이행을 이유로 계약을 해제한 경우, 본인이 해제로 인한 원상회복의무를 부담하는지 여부(적극) 및 대리인이 수령한 계약상 급부를 현실적으로 인도받지 못하였다거나 계약상 채무불이행에 관하여 대리인에게 책임 있는 사유가 있는 경우에도 마찬가지인지 여부(원칙적 적극)

대리인이 그 권한에 기하여 계약상 급부를 수령한 경우에 그 법률효과는 계약 자체에서와 마찬가지로 직접 본인에게 귀속되고 대리인에게 돌아가지 아니한다. 따라서 계약상 채무의 불이행을 이유로 계약이 상대방 당사자에 의하여 유효하게 해제되었다면, 해제로 인한 원상회복의무는 대리인이 아니라 계약의 당사자인 본인이 부담한다. 이는 본인이 대리인으로부터 그 수령한 급부를 현실적으로 인도받지 못하였다거나 해제의 원인이 된 계약상 채무의 불이행에 관하여 대리인에게 책임 있는 사유가 있다고 하여도 다른 특별한 사정이 없는 한 마찬가지라고 할 것이다(대판 2011. 8. 18. 2011다30871).

제 3 절 복대리(復代理)

Ⅰ 의 의

① 복대리인이란 대리인이 그 권한범위 내의 행위를 하게 하기 위하여 '대리인 자신의 이름'으로 선임한 '본인의 대리인'을 말한다. 대리인이 복대리인을 선임할 수 있는 권한을 '복임권(復任權)'이라 하고 그 선임행위를 '복임행위'라고 한다.

② 복대리인은 대리인이 자신의 이름으로 선임한 자이므로 대리인의 복임행위는 대리행위가 아니라 수권행위이다.

③ 복대리인은 본인의 대리인이지 대리인의 대리인이 아니다. 따라서 복대리인은 대리행위를 할 때 본인을 위한 것임을 표시하면 되고 대리인의 이름을 표시할 필요가 없다.

④ 복대리인을 선임한 뒤에도 대리인의 대리권은 소멸되지 않고, 대리인은 여전히 대리권을 보유한다.

Ⅱ 대리인의 복임권과 책임

(1) 법정대리인의 복임권과 책임

① 법정대리인은 본인의 신임에 기초하여 대리인이 된 것도 아니고, 법정대리인의 직무범위가 광범위하여 복대리인 선임의 필요성이 크므로 언제나 복임권을 가진다. 즉, 법정대리인은 그 책임으로 복대리인을 선임할 수 있다(제122조). 그러므로 법정대리인은 복대리인의 행위에 대하여 복대리인의 선임 및 감독에 있어서 아무런 과실이 없어도 본인에 대하여 전 책임을 진다(무과실책임).

② 다만, 부득이한 사유로 복대리인을 선임한 경우에는 책임이 경감되어 선임 · 감독의 과실책임을 진다(제122조 단서).

(2) 임의대리인의 복임권과 책임

① 임의대리인은 본인의 선임에 의해 선임된 자이고 언제든지 사임할 수 있으므로 원칙적으로 복임권이 없다.

② 다만, '본인의 승낙'이 있거나 '부득이한 사유(질병으로 인하여 대리행위를 할 수 없을 때 등)'가 있는 때에는 복대리인을 선임할 수 있다. 이 경우에 임의대리인은 본인에 대하여 그 선임 · 감독의 과실 책임을 진다(제121조 제1항).

③ 다만, 대리인이 본인의 지명에 의해 복대리인을 선임한 경우에는 그 부적임 또는 불성실함을 알고 본인에의 통지나 그 해임을 태만한 때가 아니면 책임이 없다(제121조 제2항). 이 경우 대리인 자신이 직접 선임하는 경우에 비해 선임에 대한 책임은 없고, 감독의 과실책임만 지므로 책임이 경감된다.

판 례

복대리인 선임의 묵시적 승낙 여부

1. 대리의 목적인 법률행위의 성질상 대리인 자신에 의한 처리가 필요하지 않은 경우에는 본인이 복대리 금지의 의사를 명시하지 않는 한 복대리인의 선임에 관해 묵시적인 승낙이 있는 것으로 보는 것이 타당하고, 복대리인 선임을 본인이 사후에 추인하는 것도 가능하다[94다30690].
2. 그러나 부동산의 분양업무는 그 성질상 수임인의 성질에 따라 그 분양사업의 성공여부가 결정되는 사무로서, 본인의 명시적인 승낙 없이는 복대리인의 선임이 허용되지 않는다[94다30690].

Ⅲ 복대리인의 지위

제123조(복대리인의 권한) ① 복대리인은 그 권한내에서 본인을 대리한다.
② 복대리인은 본인이나 제3자에 대하여 대리인과 동일한 권리의무가 있다.

(1) 본인의 대리인

① 복대리인은 본인의 대리인이므로 그 권한 내에서 본인을 위한 것임을 표시하여야 하나(제114조), 대리인의 이름은 표시할 필요가 없다.

② 그 밖의 대리에 관한 일반원칙이 그대로 적용된다. 따라서 대리행위의 하자는 복대리인을 표준으로 결정하고, 표현대리 규정이나 무권대리 규정도 복대리에 적용될 수 있다.

(2) 항상 임의대리인

복대리인은 항상 임의대리인에 해당한다. 즉, 법정대리인이 선임한 복대리인도 임의대리인이다.

(3) 대리인에 의존

복대리인은 대리인에 의해 선임된 자이므로 대리인의 감독을 받을 뿐만 아니라 대리권의 존립과 범위에 있어 대리인의 대리권에 의존한다. 따라서 복대리인의 권한은 대리인의 권한을 초과할 수 없고, 대리인의 대리권이 소멸하면 복대리인의 복대리권도 소멸한다.

(4) 대리인과 동일한 권리 · 의무

① 복대리인은 대리인에 의해 선임된 자이지만 그 권한 내에서 본인과 상대방에 대해 대리인과 동일한 권리 · 의무를 가진다(제123조). 따라서 복대리인은 본인에 대해 선량한 관리자의 주의의무, 수취물 인도의무 등을 부담하고 보수청구권, 비용상환청구권 등의 권리를 가진다.

② 또한 복대리인은 대리인과 동일한 권리 · 의무가 있으므로 복대리인이 다시 복대리인을 선임할 수 있다. 다만, 복대리인은 항상 임의대리인이므로 본인의 승낙이 있거나 부득이한 사유가 있는 때에 복대리인을 선임할 수 있다.

(5) 복대리권의 소멸

① **일반적 소멸사유** : 본인의 사망, 복대리인의 사망 · 성년후견개시 · 파산 등

② **대리인의 대리권 소멸** : 복대리권은 대리인의 대리권에 의존하므로 대리인의 사망 · 성년후견개시 · 파산 등에 의해서도 소멸한다.

③ **복대리권 자체의 소멸** : 복대리인은 임의대리인이므로 대리인과 복대리인 사이의 기초적 내부관계의 종료 및 대리인이 복대리인에 대한 선임행위를 철회한 경우에도 복대리권은 소멸한다.

제 4 절 무권대리(無權代理)

Ⅰ 협의의 무권대리(無權代理)

1. 의 의

① 대리인이 대리권 없이 대리행위를 한 경우에 표현대리라고 볼 수 있는 특별한 사정이 존재하지 않는 경우의 무권대리를 '협의의 무권대리'라고 한다.

② 이러한 협의의 무권대리에 대하여 민법은 '계약의 무권대리'와 '단독행위의 무권대리'로 구별하여 규정하고 있다.

③ 예컨대 甲으로부터 전혀 대리권을 수여받은 바 없는 乙이 甲의 대리인이라 하면서 甲의 토지를 丙에게 매도하는 계약을 체결한 경우(계약의 무권대리)이거나 취소의 대리권 없는 乙이 甲의 이름으로 甲과 丙사이의 계약을 취소하는 경우(단독행위의 무권대리) 등을 말한다.

2. 계약의 무권대리

(1) **본인에 대한 효과**

① 유동적 무효

> **제130조(무권대리)** 대리권 없는 자가 타인의 대리인으로 한 계약은 본인이 이를 추인하지 아니하면 본인에 대하여 효력이 없다.

② 본인의 추인권(追認權)

㉠ **의의** : 무권대리행위에 대한 본인의 '추인'이란 무권대리행위로 인하여 본인에게 효력이 없는 법률행위의 효과를 자기에게 귀속시키도록 하는 본인의 일방적 의사표시를 말한다.

㉡ **추인의 법적 성질** : 추인은 '상대방 있는 단독행위'이고, 추인할 수 있는 권리인 추인권은 '형성권'이다.

㉢ **추인의 상대방** : 추인의 의사표시는 계약의 직접 상대방이나 그 무권대리행위로 인한 권리 또는 법률관계의 승계인, 무권대리인에게 할 수 있다. 그러나 추인을 상대방에 대하여 하지 아니하면 상대방이 추인 있음을 알지 못한 동안에는 본인은 상대방에게 추인의 효과를 주장하지 못한다(제132조). 따라서 본인이 무권대리인에게 추인했으나 미처 이를 알지 못한 상대방은 철회할 수 있다.

㉣ **추인의 방법**

ⓐ 추인은 특별한 방식이 요구되지 않고 명시적 · 묵시적으로 할 수 있다.

ⓑ 본인이 계약의 이행을 상대방에게 청구하거나 무권대리인이 체결한 매매대금의 전부 또는 일부를 받은 경우, 무권대리인이 차용한 금전의 반환유예를 채권자에게 요청한 경우 등은 무권대리행위를 추인하였다고 봄이 타당하다.

ⓒ 그러나 단순히 무권대리행위를 알고서 이의를 제기하지 않고 장시간 방치한 것만으로는 추인이 되지 않고, 무권대리행위가 범죄가 되는 경우에 대하여 그 사실을 알고도 장기간 형사고소를 하지 아니하였다 하더라도 그 사실만으로 묵시적인 추인이 있었다고 할 수는 없다[97다31113].

ⓓ 또한 추인은 의사표시 전부에 대해 행해져야 하고 그 일부에 대해 추인하거나 그 내용을 변경하여 추인한 경우에는 상대방의 동의를 얻지 못하는 한 무효이다[81다카549].

㉤ **추인의 효과(소급효 원칙, 遡及效 原則)**

무권대리행위의 추인은 다른 의사표시가 없는 때에는 계약시에 소급하여 효력이 생기나, 제3자의 권리를 해하지 못한다(제133조).

보충학습 무권리자 처분행위의 추인

무권대리의 추인에 관한 민법 제130조, 제133조 등을 무권리자의 추인에 유추 적용할 수 있는지 여부(적극) 및 무권리자의 처분이 계약으로 이루어진 경우, 권리자가 추인하면 계약의 효과가 계약을 체결한 때로 소급하여 권리자에 귀속되는지 여부(원칙적 적극)

권리자가 무권리자의 처분을 추인하면 무권대리에 대해 본인이 추인을 한 경우와 당사자들 사이의 이익상황이 유사하므로, 무권대리의 추인에 관한 민법 제130조, 제133조 등을 무권리자의 추인에 유추 적용할 수 있다. 따라서 무권리자의 처분이 계약으로 이루어진 경우에 권리자가 이를 추인하면 원칙적으로 계약의 효과가 계약을 체결했을 때에 소급하여 권리자에게 귀속된다고 보아야 한다(대판 2017. 6. 8. 2017다3499).

② **본인의 추인거절권(拒絕權)**

㉠ **의의** : 추인의 거절이란 본인이 추인의사 없음을 적극적으로 표시하여 무권대리행위를 확정적으로 무효화시키는 것을 말한다. 추인을 거절한 경우에는 무권대리행위는 확정적으로 무효가 되므로 본인은 이를 번복하여 추인할 수 없고, 상대방도 철회권이나 최고권을 행사할 수 없다.

㉡ **추인거절의 상대방 및 방법** : 추인과 동일하다.

㉢ **무권대리와 상속(相續)** : 무권대리인이 본인을 단독상속한 경우에 상대방이 선의 · 무과실이라면 무권대리인은 본인의 지위에서 추인을 거절할 수 없다. 즉, 甲이 대리권 없이 乙 소유 부동산을 丙에게 매도하여 소유권이전등기를 경료해준 후 甲이 乙을 상속한 경우, 원래 자신의 매매행위가 무권대리행위여서 무효였다는 이유로 소유권이전등기의 말소를 청구하는 것은 금반언의 원칙이나 신의성실의 원칙에 반하여 허용될 수 없다[94다20617].

(2) 상대방에 대한 효과

① 상대방의 최고권(催告權)

> **제131조(상대방의 최고권)** 대리권 없는 자가 타인의 대리인으로 계약을 한 경우에 상대방은 상당한 기간을 정하여 본인에게 그 추인여부의 확답을 최고할 수 있다. 본인이 그 기간내에 확답을 발하지 아니한 때에는 추인을 거절한 것으로 본다.

㉠ **의의** : 본인의 추인여부에 따라 계약 상대방의 지위가 불안정하므로 상대방이 본인에 대하여 무권대리행위를 추인할 것인지 여부를 독촉하는 것을 말한다. 상대방의 선의뿐만 아니라 상대방이 계약 당시에 무권대리행위임을 알았을 경우, 즉 악의의 경우라도 인정된다.

㉡ **최고의 상대방** : 최고의 상대방은 본인이나 본인의 법정대리인에게 할 수는 있으나, 무권대리인에게는 할 수가 없다.

㉢ **효과** : 본인이 상당한 기간 내에 확답을 발하지 아니한 때에는 추인을 거절한 것으로 본다(제131조 단서).

② 상대방의 철회권(撤回權)

> **제134조(상대방의 철회권)** 대리권 없는 자가 한 계약은 본인의 추인이 있을 때까지 상대방은 본인이나 그 대리인에 대하여 이를 철회할 수 있다. 그러나 계약당시에 상대방이 대리권 없음을 안 때에는 철회할 수 없다.

㉠ **의의** : 상대방이 무권대리행위에 따른 법률관계의 성립을 원하지 않을 경우 무권대리인과 맺은 계약을 확정적으로 무효로 하는 행위를 말한다. 선의의 상대방만이 본인이 추인하기 전에 철회 할 수 있으며, 악의의 상대방에게는 철회권이 인정되지 않는다. 상대방이 대리인에게 대리권이 없음을 알았다는 점에 대한 주장 · 입증책임은 철회의 효과를 다투는 본인에게 있다[2017다213838].

㉡ **상대방** : 철회의 의사표시는 본인이나 무권대리인에게 한다.

㉢ **효과** : 철회권을 행사하면 계약이 확정적 무효로 되어 본인은 추인할 수 없고, 상대방은 무권대리인에게 계약의 이행이나 손해배상책임을 물을 수 없다.

(3) 무권대리인의 상대방에 대한 책임

> **제135조(무권대리인의 상대방에 대한 책임)** ① 다른 자의 대리인으로서 계약을 맺은 자가 그 대리권을 증명하지 못하고 또 본인의 추인을 받지 못한 경우에는 그는 상대방의 선택에 따라 계약을 이행할 책임 또는 손해를 배상할 책임이 있다.
> ② 대리인으로서 계약을 맺은 자에게 대리권이 없다는 사실을 상대방이 알았거나 알 수 있었을 때 또는 대리인으로서 계약을 맺은 사람이 제한능력자일 때에는 무권대리인이 책임을 지지 아니한다.

① 책임발생의 요건

㉠ 본인의 추인을 얻지 못하고 표현대리가 성립하지 않아야 한다.

㉡ 무권대리인이 대리권을 증명하지 못해야 한다.

㉢ 상대방이 철회권을 행사하지 않아야 한다.

㉣ 상대방이 무권대리인에게 대리권 없음을 알지 못하고 또한 알지 못한 것에 과실이 없어야 한다(상대방의 선의·무과실). 상대방이 알았거나 알 수 있었다는 증명책임은 무권대리인에게 있다[61다202].

㉤ 무권대리인은 제한능력자가 아니어야 한다.

② **책임의 성격** : 대리권이 있다고 믿었던 상대방을 보호함으로써 거래안전을 기하기 위하여 무권대리인의 귀책사유(고의 또는 과실)를 요하지 않는 무과실 책임이다. 따라서 무권대리인이 과실없이 제3자의 기망 등 위법행위로 야기된 경우라도, 특별한 사정이 없는 한 무권대리인은 상대방에게 책임을 진다[2013다213038].

③ 책임의 내용

㉠ 무권대리인은 상대방의 선택에 좇아 계약의 이행 또는 손해배상의 책임이 있다(제135조).

㉡ 손해배상의 범위는 신뢰이익이 아니라 이행이익의 손해를 배상하여야 한다.

(4) 대리권 존부에 대한 주장 · 증명책임

① 대리권의 존재는 대리행위의 효과가 본인에게 귀속되기 위한 요건이므로 대리행위의 효과를 주장하는 자(대리권의 존재를 주장하는 자)가 대리권의 존재를 증명하여야 한다[2008다42195].

② 다만, 이미 소유권이전등기가 마쳐진 경우, 전등기명의인의 직접적인 처분행위에 의한 것이 아니라 제3자가 그 처분행위에 개입된 경우 현등기명의인이 그 제3자가 전등기명의인의 대리인이라고 주장하더라도 현소유명의인의 등기가 적법히 이루어진 것으로 추정된다 할 것이므로 위 등기가 원인무효임을 이유로 그 말소를 청구하는 전소유명의인으로서는 그 반대사실 즉, 그 제3자에게 전소유명의인을 대리할 권한이 없었다는 등의 사실에 대한 입증책임을 진다[91다26379].

3. 단독행위의 무권대리

제136조(단독행위와 무권대리) 단독행위에는 그 행위당시에 상대방이 대리인이라 칭하는 자의 대리권 없는 행위에 동의하거나 그 대리권을 다투지 아니한 때에 한하여 전6조의 규정을 준용한다. 대리권 없는 자에 대하여 그 동의를 얻어 단독행위를 한 때에도 같다.

(1) 상대방 없는 단독행위

소유권의 포기와 같은 「상대방 없는 단독행위」의 무권대리행위는 항상 확정적으로 무효이고, 본인의 추인에 의하여 유효하게 될 여지가 없고, 무권대리인의 책임도 생기지 않는다.

(2) 상대방 있는 단독행위

① 원칙

상대방 있는 단독행위의 무권대리도 능동대리 · 수동대리를 불문하고 원칙적으로 무효이다.

② 예외

예외적으로 능동대리의 경우 상대방이 대리인이라 칭하는 자의 대리권 없는 행위에 동의하거나 그 대리권을 다투지 않은 때에는 계약의 무권대리의 규정이 준용되어(제136조 전문), 본인은 추인하여 유효로 할 수 있고, 상대방은 최고나 철회를 할 수 있다. 수동대리의 경우에는 상대방이 대리권 없는 자에 대해 그 동의를 얻어 단독행위를 한 때에는 계약의 무권대리의 규정을 준용한다(제136조 후문).

Ⅱ 표현대리(表見代理)

1. 서 설

(1) 의 의

표현대리제도는 대리인에게 대리권이 없음에도 불구하고 마치 대리권이 있는 것과 같은 외관이 있고 그러한 외관의 발생에 관하여 본인이 어느 정도의 원인을 주고 있는 경우에 그 무권대리행위에 대하여 본인이 책임을 지게 함으로써 그러한 외관을 믿은 선의 · 무과실의 제3자를 보호하고 거래의 안전을 보장하며 나아가서 대리제도의 신용을 유지하려는데 그 목적이 있다[80다1475].

(2) 표현대리의 성질 및 취지

① 무권대리

표현대리는 본질적으로 무권대리의 일종이므로 본인은 추인을 할 수 있고, 상대방은 최고나 철회를 할 수 있다. 다만, 표현대리가 성립하는 경우 표현대리인의 무권대리책임을 지지 않는다.

② 유권대리 주장속에 표현대리 포함 여부

표현대리가 성립된다고 하여 무권대리의 성질이 유권대리로 전환되는 것은 아니므로, 유권대리에 관한 주장 속에 무권대리에 속하는 표현대리의 주장이 포함되어 있다고 볼 수 없다[83다카1489전합].

③ 상대방 보호

㉠ 표현대리는 외관을 신뢰한 상대방을 보호하기 위한 제도이므로 표현대리인과 거래한 직접 상대방만이 주장할 수 있고, 본인이나 전득자는 표현대리를 주장할 수 없다.

㉡ 또한 표현대리인과 거래한 상대방이 선의 · 무과실이어야 표현대리가 성립한다.

(3) 표현대리의 효과

표현대리가 성립하면 본인과 상대방 사이에 처음부터 대리권이 있는 것과 같은 효과가 발생하여 본인이 전적인 책임을 져야 하고, 상대방에게 과실이 있다고 하더라도 과실상계의 법리를 유추적용하여 본인의 책임을 경감할 수 없다[95다49554].

(4) 표현대리의 종류

민법은 ㉠ 제3자에 대하여 타인에게 대리권부여사실을 표시한 경우(제125조), ㉡ 대리인이 그 권한 외의 행위를 하였을 경우(제126조), ㉢ 대리권이 소멸한 후에 소멸한 대리권의 범위 내에서 대리행위를 행한 경우(제129조) 등 세가지의 표현대리를 규정하고 있다.

2. 대리권수여의 표시에 의한 표현대리

제125조(대리권수여의 표시에 의한 표현대리) 제3자(상대방)에 대하여 타인에게 대리권을 수여함을 표시한 자는 그 대리권의 범위내에서 행한 그 타인과 그 제3자(상대방)간의 법률행위에 대하여 책임이 있다. 그러나 제3자(상대방)가 대리권없음을 알았거나 알 수 있었을 때에는 그러하지 아니하다.

(1) 의 의

① 대리권수여의 표시에 의한 표현대리란 본인이 제3자에 대하여 타인에게 대리권을 수여하였음을 표시하였으나, 실제로는 대리권을 수여하지 않은 경우에 성립하는 표현대리를 말한다.

② 가령 甲이 乙을 대리인으로 선임한다는 취지의 광고를 내고 그것을 본 丙이 乙을 甲의 대리인으로 믿고 거래를 하였다면, 실제로 甲이 乙에게 대리권을 수여하지 않았더라도 甲에게 책임을 부담시키는 것이다.

(2) 성립요건

① 대리권수여(授與)의 표시를 하였을 것

㉠ 대리권 수여표시의 방법에는 제한이 없다.

㉡ 따라서 본인에 의한 대리권 수여의 표시는 반드시 대리권 또는 대리인이라는 말을 사용하여야 하는 것이 아니라 사회통념상 대리권을 추단할 수 있는 직함이나 명칭 등의 사용을 승낙 또는 묵인한 경우에도 대리권수여의 표시가 있은 것으로 볼 수 있다[97다53762].

㉢ 대리권 수여의 표시에 의한 표현대리는 본인과 대리행위를 한 자 사이의 기본적인 법률관계의 유무와는 관계가 없이 어떤 자가 본인을 대리하여 제3자와 법률행위를 함에 있어 본인이 그 자에게 대리권을 수여하였다는 표시를 제3자에게 한 경우에는 성립될 수가 있다고 한다[97다53762].

② 표시된 대리권범위 내의 대리행위를 하였을 것

대리인으로 표시된 자가 표시된 대리권의 범위 내에서 대리행위를 해야하고 그 범위를 넘으면 제126조의 표현대리가 성립할 수 있다.

③ 표시의 통지를 받은 상대방과 대리행위를 할 것

대리행위의 상대방은 대리권수여의 표시(통지)를 받은 자이어야 한다. 통지를 광고와 같은 불특정다수에게 한 경우에는 문제가 없으나, 통지를 특정인에게 한 경우에는 그 특정인만이 보호받는 상대방이 된다.

④ 상대방이 선의 및 무과실일 것

㉠ 표현대리에 해당하기 위하여는 상대방은 선의 · 무과실이어야 하므로 상대방에게 과실이 있다면 제125조의 표현대리를 주장할 수 없다[96다51271].

㉡ 여기서 상대방은 표현대리행위의 직접 상대방만을 말하며 그로부터 전득한 전득자는 이에 해당되지 않는다.

㉢ 상대방의 악의 또는 과실에 대한 입증책임은 본인 측에 있다.

(3) 제125조의 적용범위

제125조의 법문이 '대리권을 수여함을 표시'로 되어 있어 임의대리에만 적용되고 법정대리에는 적용되지 않는다.

3. 권한을 넘은 표현대리(월권대리, 越權代理)

제126조(권한을 넘은 표현대리) 대리인이 그 권한 외의 법률행위를 한 경우에 제3자(상대방)가 그 권한이 있다고 믿을 만한 정당한 이유가 있는 때에는 본인은 그 행위에 대하여 책임이 있다.

(1) 의 의

① 권한을 넘은 표현대리란 대리인이 가지고 있는 기본대리권의 범위를 넘어서 대리행위를 한 것을 말하며 '월권대리'라고도 한다.

② 예컨대, 甲은 乙에게 토지를 담보로 은행대출을 하고 저당권설정의 대리권을 주었는데, 乙이 그 토지를 丙에게 매각하는 대리행위를 한 경우이다.

③ 실제로는 이 표현대리 유형이 가장 빈번하게 문제되는데, 판례는 표현대리인과 거래한 상대방(제3자)를 보호하여 거래의 안전을 보호하려는 표현대리제도의 취지를 고려하여 권한을 넘은 표현대리의 성립을 폭넓게 인정하고 있다.

(2) 성립요건

① 기본대리권이 존재할 것

㉠ 본인이 대리인에게 어떠한 대리권을 수여한 사실이 있고 그 대리권은 대리행위 당시에 존재해야 한다. 따라서 전혀 아무 대리권이 없는 자에게 대하여 대리권한의 유월 또는 소멸 후의 표현대리관계는 성립할 여지가 없다[4294민상483].

㉡ 복대리인 선임권이 없는 대리인에 의해 선임된 복대리인이 대리인의 대리권 외의 행위를 한 경우도 제126조의 기본대리권이 될 수 있다[97다48982].

㉢ 기본대리권이 등기신청행위(공법상 행위)라 할지라도 표현대리인이 그 권한을 유월하여 대물변제(사법상 행위)를 한 경우에는 표현대리의 법리가 적용된다[78다282].

㉣ 부부간의 일상가사대리권도 기본대리권이 될 수 있다. 즉 일상가사대리권을 기초로 하여 문제된 행위에 관한 특별수권이 있다고 믿을 만한 정당한 이유가 있는 경우에 제126조의 표현대리가 적용된다[98다18988].

㉤ 표현대리권도 기본대리권이 될 수 있다. 제125조의 대리권의 수여의 표시를 한 때 그 표시된 범위를 넘은 행위를 한 경우 및 과거에 가졌던 대리권이 소멸되어 민법 제129조에 의하여 표현대리로 인정되는 경우에 그 표현대리의 권한을 넘는 대리행위가 있을 때에는 민법 제126조에 의한 표현대리가 성립할 수 있다[79다234].

㉥ 대리인이 사자(使者)를 통해 권한 외의 대리행위를 한 경우라도 대리행위의 주체가 되는 대리인이 별도로 있고 그에게 본인으로부터 기본대리권이 수여된 이상 권한을 넘은 표현대리가 성립할 수 있다[97다48982].

㉦ 기본대리권은 법률행위에 한정되고 사실행위는 기본대리권에 포함되지 않는다. 증권회사로부터 위임받은 고객의 유치, 투자상담 및 권유, 위탁매매 약정실적의 제고 등의 업무는 사실행위에 불과하므로 이를 기본대리권으로 하여서는 권한초과의 표현대리가 성립할 수 없다[91다32190].

② 기본대리권의 범위를 넘는 대리행위를 할 것

㉠ 대리행위가 있을 것

ⓐ 민법 제126조의 표현대리는 대리인이 본인을 위한다는 의사를 명시 혹은 묵시적으로 표시하거나 대리의사를 가지고 권한 외의 행위를 하는 경우에 성립한다[2001다49814].

ⓑ 따라서 사술을 써서 대리행위의 표시를 하지 아니하고 단지 본인의 성명을 모용하여 자기가 마치 본인인 것처럼 기망하여 본인 명의로 직접 법률행위를 한 경우[2001다49814], 타인으로부터 위임받은 등기서류를 이용하거나 위조하여 자신명의로 등기한 후 제3자에게 양도하거나 담보제공한 경우에는 표현대리가 성립하지 않는다[71다2365].

㉡ **월권행위(越權行爲)가 있을 것** : 기본대리권의 내용이 되는 행위와 표현대리행위는 반드시 동종 · 유사할 필요는 없고 전혀 별개의 것이라도 무방하다[69다548].

㉢ **대리행위가 무효가 아닐 것** : 대리행위가 강행법규 위반으로 무효인 경우 또는 비법인사단인 교회의 대표자, 종중의 대표자 등이 사원총회의 결의를 거쳐야 하는 총유에 속하는 재산의 처분에 관하여 사원총회의 결의를 거치지 아니하고 처분함으로써 무효인 경우에는 제126조 표현대리에 관한 규정이 적용되지 아니한다.

③ **제3자가 대리권한이 있다고 믿는 데 정당한 이유(正當한 理由)가 있을 것**

㉠ 제3자란 제125조 및 제129조의 경우와 마찬가지로 표현대리행위의 직접 상대방이 된 자만을 말하며, 전득자는 제3자에 해당하지 않는다.

㉡ 정당한 이유란 선의 및 무과실을 말하고, 정당한 이유의 판단시기는 자칭 대리인의 대리행위가 행해질 때에 존재하는 제반사정을 객관적으로 관찰하여 판단해야 하고, 그 이후의 사정은 고려해서는 안된다[86다카2475].

㉢ 정당한 이유의 입증책임에 대해 판례는 제126조의 표현대리행위로 인정된다는 점의 입증책임은 상대방에게 있다고 한다[68다694].

(2) **제126조의 적용범위** : 제126조의 표현대리는 임의대리 · 법정대리에 모두 적용된다.

4. 대리권소멸 후의 표현대리

제129조(대리권소멸 후의 표현대리) 대리권의 소멸은 선의의 제3자(상대방)에게 대항하지 못한다. 그러나 제3자가 과실로 인하여 그 사실을 알지 못한 때에는 그러하지 아니하다.

(1) 의 의

대리인에게 주어진 대리권이 소멸하여 이제 대리인이 아닌 자가 대리행위를 한 경우에 현재도 대리권이 있다고 믿고 그와 거래한 선의 · 무과실의 상대방을 보호하기 위하여 인정되는 표현대리이다. 예컨대 수금에 대한 대리권이 있는 영업사원이 해고된 이후에도 계속하여 이를 모르는 고객과 계약을 체결하고 수금을 하는 경우이다.

(2) 성립요건

① **존재하던 대리권의 소멸하였을 것**

㉠ 이전에 존재하였던 대리권이 대리행위 당시에 소멸한 상태여야 한다. 따라서 수권행위가 무효가 되어 처음부터 대리권이 전혀 없었던 경우라면 제129조가 적용되지 않는다.

㉡ 대리인이 대리권소멸 후 복대리인을 선임하여 복대리인으로 하여금 상대방과 사이에서 대리행위를 하도록 한 경우에도 제129조의 표현대리가 성립할 수 있다[97다55317].

② 소멸된 대리권의 범위 내에서 대리행위가 행해질 것

대리행위가 소멸되기 전의 대리권의 범위 내에서 이루어져야 하고 그 범위를 넘은 대리행위에는 제126조(권한을 넘은 표현대리)가 적용된다[2007다74713].

③ 상대방은 선의 · 무과실일 것

㉠ 상대방은 대리행위의 직접 상대방만을 말하고 그 상대방과 거래한 전득자는 포함하지 않는다.

㉡ 상대방은 대리권의 소멸에 관해 선의이고 무과실 이어야 하고 본인이 상대방의 악의 또는 과실을 입증해야 한다.

(3) 적용범위

제129조는 임의대리 · 법정대리에 모두 적용된다(미성년자의 모가 미성년자가 성년으로 된 뒤, 그의 토지를 매매한 경우[74다1199]).

CHAPTER

05 법률행위의 무효와 취소

제 1 절 법률행위의 무효(無效)

Ⅰ 서 설

1. 무효의 의의

① 법률행위가 성립요건은 갖추었으나 효력요건을 결하여 법률상 당연히 그 효력이 없는 것을 말하는데 누구의 주장을 기다리지 않고도 누구에 대해서도 처음부터 효력이 없는 것을 말한다.

② 법률행위의 무효는 이를 주장할 이익이 있는 자는 누구든지 무효를 주장할 수 있다.

2. 법률행위의 불성립과 무효의 구별

① 법률행위의 불성립은 당사자 · 목적 · 의사표시 등 법률행위의 성립요건을 갖추지 못해 형식상의 법률행위로도 존재하지 않는 것을 말하며, 법률행위의 부존재라고도 한다.

② 법률행위의 무효는 법률행위가 성립된 것을 전제로 하므로, 법률행위의 불성립(부존재)에서는 무효가 문제될 여지가 없다. 따라서 법률행위의 불성립의 경우는 법률행위의 일부무효(제137조), 무효행위의 전환(제138조), 무효인 법률행위의 추인(제139조)의 규정이 적용될 수 없다.

3. 무효의 일반적 효과

① 무효인 법률행위는 그 법률행위가 성립한 당초부터 당사자가 의욕한 대로의 효력이 발생하지 않는다. 따라서 이행하기 전이라면 이행청구나 이행강제도 할 수 없고 이행할 필요도 없다. 또한 이미 이행한 것에 대해서는 부당이득반환문제가 발생한다.

② 무효인 법률행위는 그 법률행위가 성립한 당초부터 당연히 효력이 발생하지 않는 것이므로, 무효인 법률행위에 따른 법률효과를 침해하는 것처럼 보이는 위법행위나 채무불이행이 있다고 하여도 법률효과의 침해에 따른 손해는 없는 것이므로 그 손해배상을 청구할 수는 없다[2002다72125].

Ⅱ 무효의 종류

1. 절대적 무효와 상대적 무효

① 절대적 무효

법률행위의 당사자 사이에서 뿐만 아니라 제3자에 대한 관계에서도 무효인 것으로서, 의사무능력자의 법률행위, 강행규정, 사회질서 위반의 법률행위, 불공정한 법률행위 등이 있다.

② 상대적 무효

선의의 제3자 등에게는 주장할 수 없는 무효를 말하며 이는 거래상대방의 보호 내지 거래안전유지를 위해 인정되는데 상대방이 표의자의 진의 아님을 알았거나 알 수 있었을 경우의 비진의표시와 허위표시 등이 상대적 무효이다.

2. 전부무효와 일부무효

① 전부무효

법률행위내용의 전부에 무효사유가 있는 것을 말한다.

② 일부무효

법률행위내용의 일부에만 무효사유가 있는 것을 말한다. 법률행위의 일부분이 무효인 때에 그 법률행위 전체의 효력이 문제된다.

3. 확정적 무효와 유동적(불확정적) 무효

① 확정적 무효

법률행위의 효력이 확정적으로 발생하지 않는 경우를 말하며, 무효는 확정적 무효가 원칙이다. 의사무능력자의 법률행위, 원시적 불능의 법률행위, 사회질서 위반의 법률행위, 불공정한 법률행위, 강행규정 위반의 법률행위, 불법조건이 붙은 법률행위, 물권법정주의에 위반한 경우 등을 말한다.

② 유동적 무효(불확정 무효)

법률행위의 효력이 현재는 발생하지 못하지만 추후로 허가 또는 추인 등을 받으면 유효하게 되는 법적상태를 유동적 무효라고 한다. 토지거래허가를 받지 않은 토지매매, 정지조건부 법률행위, 무권대리행위 등이 이에 해당한다.

Ⅲ 일부무효

제137조(법률행위의 일부무효) 법률행위의 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 한다. 그러나 그 무효부분이 없더라도 법률행위를 하였을 것이라고 인정될 때에는 나머지 부분은 무효가 되지 아니한다.

1. 원칙 - 전부무효

① 법률행위 일부가 무효인 경우에는 원칙적으로 그 전부를 무효로 한다(제137조).

② 예컨대, 토지거래허가구역 내의 토지와 그 지상 건물을 동시에 일괄하여 매매한 경우에 토지에 대한 허가를 받지 않은 때에는 매매계약이 전부 무효이므로 매수인은 특별한 사정이 없는 한 건물만의 소유권이전등기를 청구할 수 없다.

2. 예외 - 일부유효

① 무효부분이 없더라도 법률행위를 하였을 것이라고 인정될 때에는 나머지부분은 무효가 되지 않는다(제137조 단서).

② 일부유효가 되기 위한 요건

㉠ 법률행위의 분할 가능성(가분성)

ⓐ 무효사유에 해당하는 일부분이 다른 부분으로부터 분할될 수 있어야 한다.

ⓑ 토지거래허가구역 내의 토지와 건물을 일괄하여 매매한 경우 토지에 관한 당국의 거래허가가 없으면 건물만이라도 매매하였을 것이라고 볼 수 있는 특별한 사정이 인정되는 경우에 한하여 토지에 대한 매매거래허가가 있기 전에 건물만의 소유권이전등기를 명할 수 있다고 보아야 할 것이고, 그렇지 않은 경우에는 토지에 대한 거래허가가 있어 그 매매계약의 전부가 유효한 것으로 확정된 후에 토지와 함께 이전등기를 명하는 것이 옳을 것이다[92다16836].

㉡ 당사자의 가정적 의사

무효부분을 제외한 나머지 부분을 유효로 하려는 당사자의 의사가 있다고 인정되어야 한다. 이때 당사자의 의사는 '실재하는 의사'가 아니라 법률행위의 일부분이 무효임을 법률행위 당시에 알았다면 당사자 쌍방이 이에 대비하여 의욕하였을 '가정적(假定的) 의사'를 말한다.

Ⅳ 무효행위의 전환(轉換)

제138조(무효행위의 전환) 무효인 법률행위가 다른 법률행위의 요건을 구비하고 당사자가 그 무효를 알았더라면 다른 법률행위를 하는 것을 의욕하였으리라고 인정될 때에는 다른 법률행위로서 효력을 가진다.

1. 의 의

무효행위의 전환이란 A라는 무효인 법률행위가 다른 B라는 법률행위의 요건을 구비하고 당사자가 그 무효를 알았더라면 B라는 법률행위를 하는 것을 의욕 하였으리라고 인정될 때 그 B라는 법률행위로서의 효력을 가진다(제138조). 예컨대, 타인의 子를 자기의 子로 출생신고한 경우에 입양의 다른 요건을 충족하는 때에는 그 무효인 출생신고는 입양신고로서 효력이 발생한다. 임의규정이므로 당사자의 약정으로 그 적용을 배제할 수 있다.

2. 무효행위전환의 요건

(1) 일단 성립한 법률행위가 무효이어야 한다.

무효행위의 전환은 일단 성립한 법률행위가 무효인 경우에 문제 되므로 숨은 불합의로 법률행위가 성립하지 못한 경우에는 무효행위의 전환문제는 발생할 여지가 없다.

(2) 다른 법률행위의 요건을 구비하여야 한다.

무효인 법률행위가 다른 법률행위의 요건을 포함하고 있어야 한다. 따라서 의사무능력으로 인해 법률행위가 무효인 경우에는 무효행위의 전환이 인정되지 않는다.

(3) 당사자의 전환의사(가상적 의사)가 있어야 한다.

당사자가 그 법률행위(A)의 무효를 알았더라면 다른 법률행위(B)를 하는 것을 의욕 하였으리라고 인정되어야 한다. 이러한 전환의 의사는 현실적 의사가 아니라 가상적 의사를 말한다.

3. 적용범위 및 효과

① 매매계약이 약정된 매매대금의 과다로 말미암아 민법 제104조의 불공정한 법률행위에 해당하여 무효인 경우에도 무효행위의 전환에 관한 민법 제138조가 적용된다.

② 무효행위의 하자가 치유되어 유효한 법률행위로 되는 것이 아니라, 무효인 법률행위가 다른 법률행위로서의 효력이 발생한다.

Ⅴ 무효행위의 추인(追認)

제139조(무효행위의 추인) 무효인 법률행위는 추인하여도 그 효력이 생기지 아니한다. 그러나 당사자가 그 무효임을 알고 추인한 때에는 새로운 법률행위로 본다.

1. 의 의

① 법률행위의 당사자가 무효임을 알면서 그 법률행위를 유효로 하려는 의사에 의하여 새로운 행위로서 효력을 발생시키는 것을 말한다. 예컨대, 허위표시(가장매매)의 당사자가 후에 그 매매가 무효임을 알면서 추인을 하면 추인한 때부터 새로 매매계약을 한 것으로 본다.

② 무효행위의 추인(제139조)은 확정적으로 무효인 법률행위를 장래에 향하여 새로운 법률행위를 한 것으로 보나, 무권대리행위의 추인 은 유동적인 무효상태에 있는 법률행위가 계약시에 소급하여 유효가 된다는 점을 주의하여야 한다.

2. 추인의 요건

① 무효행위가 추인가능한 법률행위이어야 한다.

㉠ 무효행위의 추인은 의사표시의 흠결인 비진의표시나 허위표시로 인한 무효의 경우에 주로 인정된다. 따라서 강행법규 위반행위, 반사회질서 행위 · 불공정한 법률행위는 추인에 의해 유효해질 수 없다.

㉡ 토지거래허가구역이 아닌 토지를 가장매매 하였다가 추인하였는데 추인당시 그 토지가 토지거래허가구역으로 지정되어 있다면 추인시 토지거래허가를 받아야 한다.

② 법률행위가 무효임을 알고 추인하여야 한다.

무효인 법률행위를 추인에 의하여 새로운 법률행위로 보기 위하여는 당사자가 이전의 법률행위가 무효임을 알고 그 행위에 대하여 추인하여야 한다[97다15715].

③ 추인의 방식

이러한 추인은 특별한 방식을 요하지 않으므로 명시적 · 묵시적 방법으로 가능하다.

3. 추인의 효과

무효행위의 추인은 무효행위를 사후에 유효로 하는 것이 아니고, 추인한 때에 새로운 법률행위가 있는 것으로 보므로 원칙적으로 소급효가 인정되지 않는다[83므22]. 따라서 무효인 가등기를 유효한 등기로 전용키로 한 약정은 그때부터 유효하고 이로써 위 가등기가 소급하여 유효한 등기로 전환될 수 없다[91다26546].

Ⅵ 유동적 무효(流動的 無效, 불확정적 무효)

1. 의 의

법률행위가 일정한 요건을 갖추면 소급적으로 유효가 되지만 그 요건을 갖추지 않는 한 무효인 상태를 말한다. 이러한 유동적 무효로써 대표적인 예가 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」상 토지거래허가구역에서 허가받지 않은 토지의 매매이다.

2. 토지거래허가를 받기 전의 법률관계

(1) 계약의 효력 : 무효

① 의무부담이나 이행청구 불가 : 토지거래허가를 받기 전에는, 그 계약 내용대로의 효력이 있을 수 없어 당사자는 그 계약 내용에 따른 어떠한 의무도 부담하지 아니하고 어떠한 이행청구도 할 수 없다. 따라서 허가가 있을 것을 조건으로 하여 소유권이전등기청구는 할 수 없다[90다12243].

② 채무불이행으로 인한 계약해제 · 손해배상청구 불가 : 어떠한 의무도 발생하지 않으므로 그 계약 내용에 따른 상대방의 채무불이행을 이유로 계약을 해제하거나 손해배상을 청구할 수도 없다[99다40524, 2008다88795,88801].

③ 이행지체 불성립 : 거래허가 전에 매도인이 소유권이전등기 소요서류의 이행제공을 하였다 하더라도 매수인이 이행지체에 빠지는 것은 아니다[91다33612].

④ 소유권이전등기청구권을 피보전권리로 한 처분금지가처분 불허 : 유동적 무효상태에서 이행청구권이 부정되므로 소유권이전등기청구권을 피보전권리로 한 부동산처분금지가처분신청은 허용되지 않는다[2010마818].

⑤ 소유권이전등기의 효력 : 토지거래허가를 받지 않고 이루어진 소유권이전등기는 무효이다. 설령 최종매수인이 자신과 최초 매도인을 매매 당사자로 하는 토지거래허가를 받아 자신 앞으로 소유권이전등기를 경료하였다 하여도 이는 적법한 토지거래허가 없이 경료된 등기로서 무효이다[97다33218].

(2) 협력의무(協力義務)

① 협력의무 소구(訴求)가능

관할 관청의 허가 없이 체결된 매매계약이라 하더라도 당사자 사이에 그 계약이 효력있는 것으로 완성될 수 있도록 서로 협력할 의무가 있으므로 이러한 의무에 위배하여 허가신청절차에 협력하지 않는 당사자에 대하여 상대방은 협력의무의 이행을 소로써 구할 수 있다[96다49933].

② **계약해제 불인정** : 유동적 무효의 상태에 있는 거래계약의 당사자는 상대방이 그 거래계약의 효력이 완성되도록 협력할 의무를 이행하지 아니하였음을 들어 일방적으로 유동적 무효의 상태에 있는 거래계약 자체를 해제할 수 없다[98다40459 전합].

③ **손해배상 인정** : 매수인이 협력의무를 이행하지 않고 매매계약을 일방적으로 철회함으로써 매도인이 손해를 입은 경우에 매수인은 협력의무불이행과 인과관계가 있는 손해를 배상해야 하며[93다26397], 이러한 경우 상대방에게 일정한 손해액을 배상하기로 하는 약정을 유효하게 할 수도 있다[96다49933].

④ **동시이행관계 불인정** : 매도인의 협력의무와 매수인의 대금지급의무는 동시이행관계에 있는 것은 아니므로, 매도인으로서는 그러한 매매대금의 이행의 제공이 있을 때까지 협력의무의 이행을 거절할 수 있는 것이 아니다[96다23825]. 달리 표현하면, 매수인은 매매대금의 제공 없이도 매도인에게 토지거래허가신청절차에 협력할 것을 청구할 수 있다.

⑤ **협력의무이행청구권을 보전하기 위한 가처분 가능** : 매매계약의 매수인은 토지거래허가신청절차 청구권(협력의무이행청구권)을 피보전권리로 하여 매매목적물의 처분을 금하는 가처분을 구할 수 있다[98다44376].

(3) 계약금

① **부당이득반환청구 불가** : 토지거래허가가 있기전에 계약금을 교부한 당사자는 미허가를 이유로 계약의 무효를 주장하여 계약금의 반환을 부당이득으로 청구 할 수 없다[91다21435]. 다만, 불허가처분으로 확정적으로 무효로 되었을 때에는 비로소 부당이득으로 그 반환을 구할수 있다[91다33766].

② **계약금에 의한 해제 가능** : 유동적 무효상태에서도 계약금에 의한 계약해제(제565조)가 가능하므로 교부자는 계약금을 포기하고, 수령자는 배액을 상환하고 계약을 해제할 수 있다. 또한 관할관청으로부터 그 허가를 받았다 하더라도, 이는 이행의 착수에 해당하지 않으므로 이행기전이라면 계약금의 배액을 상환하여 매매계약을 해제할 수 있다[2008다62427].

3. 확정적 유효가 되는 경우

① 허가받을 것을 전제로 한 거래계약은 일단 허가를 받으면 소급하여 유효한 계약이 되므로 허가 후에 거래계약을 새로 체결할 필요는 없다[98다40459전합].

② 토지거래허가구역 내의 토지에 관해 허가없이 거래계약을 체결한 후 허가구역 지정을 해제하거나 기간 만료 후에 재지정을 하지 않은 경우 확정적 유효로 되므로 거래당사자는 그 계약의 이행을 청구할 수 있다[98다40459전합]. 따라서 토지거래허가구역 지정의 해제로 인해 토지거래계약이 일단 유효로 된 이상 그 후 그 토지가 토지거래허가구역으로 재지정되었다 하여 다시 토지거래허가를 받아야 되는 것은 아니다[2002다12635].

4. 확정적 무효가 되는 경우

① 처음부터 토지거래허가를 배제하거나 잠탈 하는 내용의 계약은 체결 당시부터 확정적으로 무효이다[92다44671]. 예컨대 ⓐ 매매계약일자를 규제구역 지정공고일 이전으로 소급 작성하고 매매대금액도 낮춘 별도의 매매계약서를 허위로 작성한 경우 ⓑ 토지거래허가를 받지 않고 매매된 토지에 관해 증여를 원인으로 소유권이전등기를 경료 한 경우, 그 매매계약은 처음 체결된 때부터 확정적으로 무효이다.

② 토지거래계약 허가구역 내 토지에 관하여 허가를 배제하거나 잠탈하는 내용으로 매매계약이 체결된 경우에는, 계약체결 후 허가구역 지정이 해제되거나 허가구역 지정기간 만료 이후 재지정을 하지 아니한 경우라 하더라도 이미 확정적으로 무효로 된 계약이 유효로 되는 것이 아니다[2017다228618].

③ 관할관청에 의한 불허가처분이 있는 경우에는 확정적으로 무효가 된다.

④ 당사자 쌍방이 허가신청협력의무 이행거절의사를 명백히 표시한 경우 또는 당사자 쌍방이 허가신청을 하지 않기로 의사표시를 명백히 한 때에는 확정적 무효이다[97다36965]. 따라서 토지거래허가 신청 전에 매도인이 매수인에게 계약해제통지를 하자 매수인이 계약금 상당액을 청구금액으로 하여 토지를 가압류한 경우, 그 매매계약은 가압류 당시 쌍방이 토지거래허가신청을 하지 않기로 하는 의사표시를 명백히 함으로써 확정적 무효로 될 수 있다[99다72460].

⑤ 정지조건부 계약에서 정지조건이 토지거래허가를 받기 전에 이미 불성취로 확정된 경우에 확정적 무효이다[97다36996].

⑥ 토지거래가 계약당사자의 의사와 표시의 불일치(비진의표시 · 허위표시 · 착오) 또는 하자있는 의사(사기 · 강박)에 의해 이루어진 경우에 이러한 사유를 주장하여 무효 또는 취소를 한 때에는 그 계약을 확정적으로 무효가 된다[97다36118].

⑦ 다만, 매매계약 체결 당시 일정한 기간 안에 토지거래허가를 받기로 약정하였다고 하더라도, 그 약정된 기간 내에 토지거래허가를 받지 못할 경우 특별한 사정이 없는 한, 위 약정기간이 경과하였다는 사정만으로 곧바로 매매계약이 확정적으로 무효가 된다고 할 수 없다[2008다50615].

⑧ 토지거래허가구역 내의 토지거래계약이 확정적으로 무효가 된 경우, 그 계약이 무효로 되는데 책임 있는 사유가 있는 자도 무효를 주장할 수 있다[94다51789].

제 2 절 법률행위의 취소(取消)

Ⅰ 서 설

1. 취소의 의의

① '취소'란 일단 유효하게 성립한 법률행위의 효력을 성립상의 하자(제한능력, 착오, 사기, 강박)를 이유로 성립당시에 소급하여 소멸(무효)시키는 일방적 의사표시(단독행위)를 말한다.

② 취소할 수 있는 법률행위는 아무나 취소할 수 있는 것이 아니고 취소권을 가진 자만이 취소할 수 있다. 또한 취소권은 취소권자의 일방적 의사표시에 의하여 법률관계의 변동을 가져오는 것이므로 일종의 형성권(形成權)이다.

③ 취소할 수 있는 사유는 민법 제140조 내지 제146조에 규정된 것으로 법정되어 있는데 이는 제한능력자의 법률행위나 착오 · 사기 · 강박에 의한 의사표시를 한 경우이다. 따라서 법률행위의 취소사유가 없는 경우에는 당사자 쌍방이 각각 취소의 의사표시를 하였다 하여도 그 법률행위가 취소되는 것이 아니다.

④ 착오, 사기 · 강박을 이유로 하는 취소의 효과는 상대적이나, 제한능력자임을 이유로 하는 취소의 효과는 절대적이다.

2. 무효와 취소의 구별

구 분	무 효	취 소
기본적 효과	특정인의 행위를 기다리지 않고 처음부터 당연히 효력이 발생하지 않는다.	성립당시의 하자를 이유로 취소권자의 취소권 행사로 소급하여 무효가 된다.
주장권자	누구든지 주장 할 수 있다.	취소권자에 한하여 주장 할 수 있다.
주장기간	언제까지나 주장 할 수 있다. 따라서 장기간 방치하더라도 무효원인이 치유되지 않는다.	3년, 10년 내에 행사해야 하고 제척기간의 경과로 취소권이 소멸한다.
추인	무효인 법률행위가 추인에 의하여 유효로 될 수 없고 그때부터 새로운 법률행위를 한 것으로 본다.	유동적 유효인 취소 할 수 있는 법률행위를 추인하면 확정적 유효로 된다.
부당이득 반환의무	부당이득반환의무 부담(단, 취소의 경우에는 제한능력자 보호규정 있음)	

Ⅱ 취소의 당사자 및 취소의 방법

1. 취소권자(제140조)

제140조(법률행위의 취소권자) 취소할 수 있는 법률행위는 제한능력자, 착오로 인하거나 사기 · 강박에 의하여 의사표시를 한 자, 그의 대리인 또는 승계인만이 취소할 수 있다.

(1) 제한능력자, 착오 · 사기 · 강박에 의하여 의사표시를 한 자

① 제한능력자는 자신이 한 행위를 단독으로 취소할 수 있으며 그 취소를 함에는 법정대리인의 동의가 필요없다.

② 착오, 사기 · 강박에 의하여 의사표시를 한 자는 그런 상태를 벗어나기 전에도 취소할 수 있다.

(2) 대리인

제한능력자나 착오 또는 사기 · 강박에 의하여 의사표시를 한 자의 대리인에는 법정대리인이나 임의대리인을 포함한다. 다만, 임의대리인은 취소를 하려면 취소권에 관한 본인의 수권이 필요하다.

(3) 승계인

포괄승계인(상속 · 회사의 합병 · 포괄유증)이든 특정승계인이든 관계없다. 다만, 취소권자의 특정승계인은 취소권만 승계는 인정되지 않고 취소할 수 있는 행위의 목적이 된 권리의 승계가 있어야 한다.

2. 취소의 상대방

제142조(취소의 상대방) 취소할 수 있는 법률행위의 상대방이 확정한 경우에는 그 취소는 그 상대방에 대한 의사표시로 하여야 한다.

① 취소의 상대방은 취소할 수 있는 법률행위의 직접 상대방 또는 포괄승계인에게만 취소권을 행사할 수 있다.

② 그러나 상대방의 특정승계인은 상대방에 해당하지 않는다. 예를 들면 甲이 乙로부터 사기를 당하여 자기소유부동산을 乙에게 양도하고 乙은 그 부동산을 丙에게 양도한 후 甲이 사기를 이유로 의사표시를 취소하려면 취소의 의사표시를 乙에게 하여야 한다.

3. 취소의 방법

(1) 취소권의 행사

① 취소권은 형성권이므로 취소권자의 일방적 의사표시에 의한다. 따라서 취소는 단독행위로서 원칙적으로 조건이나 기한을 붙일 수 없다.

② 취소는 특정한 방식이 요구되는 것이 아니고, 반드시 명시적일 필요도 없으며 묵시적으로도 가능하다.

③ 법률행위의 취소를 당연한 전제로 한 소송상의 이행청구나 이를 전제로 한 이행거절 가운데는 취소의 의사표시가 포함되어 있다고 볼 수 있다[93다13162].

(2) 법률행위의 일부취소

① 일부무효의 법리는 법률행위의 일부취소에도 유추적용된다[93다31191]. 따라서 법률행위의 일부에 취소사유가 있더라도 원칙적으로 법률행위 전체에 대하여 취소의 효력이 미친다.

② 다만, 하나의 법률행위의 일부분에만 취소사유가 있다고 하더라도 그 법률행위가 가분적이거나 그 목적물의 일부가 특정될 수 있다면 그 나머지부분이라도 유지하려는 당사자의 가정적 의사가 인정되는 경우에 그 일부만의 취소도 가능하다[2002다21509].

Ⅲ 취소의 효과

1. 소급적 무효

취소할 수 있는 법률행위를 취소하면 법률행위는 처음부터 무효인 것으로 본다(제141조). 착오, 사기 · 강박을 이유로 하는 취소의 효과는 상대적이어서 선의의 제3자에게 대항할 수 없으나 제한능력자임을 이유로 하는 취소의 효과는 절대적이어서 선의의 제3자에게도 대항할 수 있다.

2. 부당이득 반환의무

(1) 원 칙

① 취소를 하게되면 소급하여 무효가 되므로 이행 전이라면 이행할 필요가 없게 되고, 이행한 후라면 이행을 받은 자는 부당이득으로서 반환의무가 생긴다.

② 따라서 선의의 수익자는 그 받은 이익이 현존하는 한도에서 반환해야하나 악의의 수익자는 그 받은 이익에 이자를 붙여 반환하고 손해가 있으면 이를 배상해야 한다.

(2) 제한능력자의 반환범위에 관한 특칙

① 현존이익 반환의무

제한능력자는 선의 · 악의를 불문하고 취소된 법률행위로 인하여 '받은 이익이 현존하는 한도'에서 반환하면 된다.

② 이익현존의 의미

이익이 현존하는 한도란 취소되는 행위에 의하여 사실상 얻은 이익이 그대로 있거나 또는 그것이 변형되어 잔존하고 있는 것을 말한다. 따라서 이미 소비해 버린 경우에는 이익이 현존하지 않으나, 필요한 비용에 충당한 경우에는 그 한도에서 이익은 현존한 것으로 된다.

Ⅳ 취소할 수 있는 법률행위의 추인

1. 임의추인(의사표시에 의한 추인)

(1) 의 의

취소할 수 있는 법률행위를 취소하지 않고서 확정적으로 유효화 하겠다는 추인권자의 의사표시를 말한다(취소권의 포기).

(2) 추인권자 및 추인의 방법

① 추인권자

추인을 할 수 있는 자는 취소권자와 동일하다. 즉, 제한능력자, 착오로 인하거나 사기 · 강박에 의하여 의사표시를 한 자, 그의 대리인 또는 승계인이 추인할 수 있다.

② 추인의 방법

추인은 취소할 수 있는 법률행위의 상대방에 대한 의사표시로 하고, 추인은 불요식행위이며, 묵시적 추인도 가능하다.

(3) 추인의 요건

① 추인은 '취소의 원인이 소멸(종료)한 후'에 하여야 한다.

㉠ 제한능력자는 능력자가 된 후, 착오 · 사기 · 강박에 의해 의사표시를 한 자는 그런 상태에서 벗어난 후에 추인할 수 있다. 즉, 제한능력자는 능력자가 된 후, 착오 · 사기 · 강박에 의해 의사표시를 한 자는 그런 상태에서 벗어난 후에 추인할 수 있다.

㉡ 그러나 법정대리인은 취소의 원인이 소멸하기 전에도 추인할 수 있다.

② 추인은 그 행위가 취소할 수 있는 것임을 알고 하여야 한다.

(4) 추인의 효과

① **확정적 유효** : 추인 후에는 취소하지 못하므로 그 법률행위는 그때부터 확정적으로 유효가 된다. 따라서 추인하면 다시 취소하지 못한다.

② **취소한 법률행위의 추인** : 취소할 수 있는 법률행위가 일단 취소된 이상 그 후에는 취소할 수 있는 법률행위의 추인에 의해 다시 확정적으로 유효하게 할 수는 없고, 다만 무효인 법률행위의 추인의 요건과 효력으로써 추인할 수는 있다.

2. 법정추인(法定追認)

제145조(법정추인) 취소할 수 있는 법률행위에 관하여 전조의 규정에 의하여 추인할 수 있는 후에 다음 각호의 사유가 있으면 추인한 것으로 본다. 그러나 이의를 보류한 때에는 추인한 것으로 보지 아니하다.

1. 전부나 일부의 이행
2. 이행의 청구
3. 경개
4. 담보의 제공
5. 취소할 수 있는 행위로 취득한 권리의 전부나 일부의 양도
6. 강제집행

(1) 의 의

취소할 수 있는 법률행위에 관해 취소의 원인이 종료(추인할 수 있는 후)한 후에 일정한 사유가 있으면 추인의 의사나 취소권의 존재를 알고 있을 필요도 없이 법률의 규정에 의하여 당연히 추인한 것으로 보는 것을 말한다.

(2) 법정추인의 요건

① 법정추인사유의 발생

㉠ **전부 또는 일부의 이행** : 취소권자가 상대방에게 채무의 전부나 일부를 이행한 경우뿐만 아니라 취소권자가 상대방의 이행을 수령하는 경우도 포함한다.

㉡ **이행의 청구** : 취소권자(추인권자)가 상대방에게 이행을 청구한 경우에 한하여 법정추인이 되며, 취소권자가 상대방으로부터 이행의 청구를 받은 경우(취소권자의 상대방이 이행청구 경우)는 법정추인이 되지 않는다.

㉢ **경개(更改)** : 취소권자가 채권자로서 하든 채무자로서 경개(취소할 수 있는 법률행위로 인하여 발생한 채무를 소멸시키고 그 대신 다른 채무를 성립시키기로 하는 계약)를 하든 상관없다.

㉣ **담보의 제공** : 취소권자가 상대방에 대해 담보(인적 · 물적 담보를 불문)를 제공하는 경우는 물론, 상대방이 제공하는 담보를 취소권자가 받는 것도 포함한다.

㉤ **취소할 수 있는 행위로 취득한 권리의 전부나 일부의 양도** : 취소권자가 한 양도행위에 한하고, 취소권자의 상대방이 한 양도행위는 포함되지 않는다. 또한 취소함으로써 발생할 장래의 채권(장차 취소하게 되면 발생하게 될 손해배상채권 등)의 양도는 취소를 예정한 행위이므로 법정추인에 해당되지 않는다.

㉥ **강제집행** : 취소권자가 채권자로서 강제집행을 하는 것(처분금지가처분)뿐만 아니라 채무자로서 강제집행을 받는 것(가옥을 압류 당한 경우)도 포함한다.

② **취소원인의 종료**

법정추인사유가 '추인할 수 있는 후'에, 즉 취소원인이 종료한 후에 발생하여야 한다.

③ **이의를 보류하지 않을 것**

취소권자가 이의를 보류한 경우에는 법정추인사유가 존재하더라도 법정추인이 되지 않는다. 여기서 이의를 보류한다는 것은 추인으로 간주되는 법률효과를 배제한다는 의사표시를 말한다. 예컨대 변제하면서 이는 추인하는 것이 아니라는 것을 명시하는 경우이다.

④ **취소권의 인식 및 추인의 의사 불요**

법정추인은 취소권자가 취소권이 존재함을 알고 있을 필요도 없고, 추인의 의사가 있을 필요도 없다.

(3) 법정추인의 효과

법정추인에 해당하는 사유가 있으면 통상의 추인과 마찬가지로 그 법률행위는 유효한 것으로 확정되므로 취소권을 행사할 수 없게 된다.

Ⅴ 취소권의 행사기간

제146조(취소권의 소멸) 취소권은 추인할 수 있는 날로부터 3년내에 법률행위를 한 날로부터 10년내에 행사하여야 한다.

① 민법은 유동적 상태의 법률관계를 조기에 확정함으로써 상대방이나 이해관계인을 불안정한 지위에서 벗어날 수 있도록 하기 위하여 취소권의 단기소멸을 정하고 있다.

② 취소권은 추인할 수 있는 날부터 3년 내, 법률행위를 한 날부터 10년 내에 행사해야 한다(제146조). 3년, 10년 중 어느 것이든 먼저 경과하면 취소권은 소멸한다.

③ 취소권의 존속기간은 제척기간이다.

CHAPTER

06 조건과 기한

제 1 절 서 설

1. 법률행위의 부관(附款)

① 법률행위가 성립하면 곧바로 효력이 발생하는 것이 원칙이다. 그러나 당사자가 법률행위를 하면서 그 법률행위의 효력의 발생 또는 소멸에 관하여 장래의 일정한 사실에 의존시키는 경우가 있다. 이러한 것을 법률행위에 부가되는 약관이라는 의미에서 '법률행위의 부관(附款)'이라고 한다.

② 법률행위의 부관은 법률행위의 효력의 발생 또는 소멸에 관한 것이지 법률행위의 성립에 관한 것은 아니다.

2. 부관의 종류

부관에는 조건(條件)·기한(期限)·부담(負擔)이 있다. 그 중 조건과 기한에 관해서만 민법총칙에 일반적 규정이 있고, 부담에 관해서는 일반적 규정이 없다. 기간은 부관이 아니다.

제 2 절 조 건(條件)

Ⅰ 의 의

① 조건은 법률행위의 효력의 발생 또는 소멸을 장래의 불확실한 사실의 성부에 의존케 하는 법률행위의 부관을 말하며 조건이 붙은 법률행위를 '조건부 법률행위'라고 한다.

② 조건이 되는 사실은 장래의 성립 여부가 객관적으로 불확실한 사실이어야 한다. 예컨대 '시험에 합격하면 자동차를 사주겠다'와 같이 시험에의 합격 여부가 불확실한 사실이어야 조건이 된다.

③ 조건이 되려면 조건의사와 그 표시가 필요하므로, 조건의사가 있더라도 그것이 외부에 표시되지 않으면 법률행위의 동기에 불과할 뿐이고 그것만으로는 법률행위의 부관으로서의 조건이 되는 것은 아니다[2003다10797].

④ 조건은 당사자가 의사표시를 통해 임의로 부가하여 법률행위의 내용으로 삼은 것이다. 따라서 법률상 당연히 요구되는 법정조건은 조건이 아니다(법인설립에 있어서 주무관청의 허가).

Ⅱ 조건의 종류

1. 정지조건과 해제조건

(1) **정지조건**(停止條件)

① 정지조건이란 법률행위의 효력의 발생을 장래의 불확실한 사실에 의존케하는 조건을 말한다. (시험에 합격하면 자동차를 사주겠다).

② 정지조건있는 법률행위는 조건이 성취한 때로부터 그 효력이 생긴다.

③ 어떠한 법률행위가 정지조건부 법률행위에 해당한다는 사실에 대한 주장 · 입증책임은 그 법률행위로 인한 법률효과의 발생을 저지하는 사유로서 그 법률효과의 발생을 다투려는 자에게 있다[93다20832].

④ 정지조건부 법률행위에 있어서 조건성취의 사실은 이에 의해 권리를 취득하고자 하는 측이 입증해야 한다[84다카967].

(2) **해제조건**(解除條件)

① 해제조건이란 법률행위의 효력의 소멸을 장래의 불확실한 사실에 의존케 하는 조건을 말한다. (시험에 합격할 때까지 매월 100만원씩 생활비를 주겠다)

② 해제조건있는 법률행위는 조건이 성취한 때로부터 그 효력을 잃는다.

③ 건축허가를 필할 때 매매계약이 성립하고 건축허가신청이 불허되었을 때에는 이를 무효로 한다는 약정 아래 이루어진 매매계약은 해제조건부 계약이다[83다카552].

2. 가장조건(假裝條件)

(1) **의 의 :** 가장조건이란 '외관상 조건처럼 보이지만, 실질적으로는 조건으로서의 효력이 인정되지 못하는 것'을 말한다. 이러한 가장조건에는 불법조건, 기성조건, 불능조건 등이 있다.

(2) **불법조건 :** 조건이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반하는 것인 때에는 조건뿐만 아니라 그 법률행위 전부가 무효이고 조건없는 법률행위가 되는 것이 아니다(제151조 제1항). 조건부 법률행위에 있어 조건의 내용 자체가 불법적인 것이어서 무효일 경우 또는 조건을 붙이는 것이 허용되지 아니하는 법률행위에 조건을 붙인 경우 그 조건만을 분리하여 무효로 할 수는 없고 그 법률행위 전부가 무효로 된다[2005마541].

(3) **기성조건**(既成條件)

① '조건의 내용인 사실이 법률행위 성립 당시에 이미 발생되어 있는 경우'를 말한다. (이미 시험에 합격한 사람에게 '시험에 합격하면 자동차를 사주겠다'고 한 경우)

② 조건이 법률행위의 당시 이미 성취한 것 인 경우에는 그 조건이 정지조건이면 조건없는 법률행위로 하고 해제조건이면 그 법률행위는 무효로 한다(제151조 제2항).

(4) **불능조건**(不能條件)

① '객관적으로 실현불가능한 사실을 내용으로 하는 조건'을 말한다(해가 서쪽에서 뜬다면 아파트를 주겠다).

② 조건이 법률행위의 당시에 이미 성취할 수 없는 것(불능조건)인 경우에는 그 조건이 해제조건이면 조건없는 법률행위로 하고 정지조건이면 그 법률행위는 무효로 한다(제151조 제3항).

Ⅲ 조건을 붙일 수 없는 법률행위

1. 단독행위

① 취소 · 해제 · 해지 · 철회 · 상계 · 환매권 행사 등의 단독행위에는 원칙적으로 조건을 붙이지 못한다.

② 다만, 상대방의 동의가 있는 경우 또는 채무면제 · 유언 · 유증처럼 상대방에게 이익만을 주는 경우에는 가능하다.

2. 가족법상의 행위(신분행위)

혼인 · 인지 · 입양이나 상속의 승인 · 포기 등에는 조건을 붙일 수 없다.

3. 위반의 효과

조건과 친하지 않은 법률행위에 조건을 붙인 경우에는 그 법률행위는 원칙적으로 전부무효가 된다.

Ⅳ 조건부 법률행위의 효력

제148조(조건부 권리의 침해금지) 조건 있는 법률행위의 당사자는 조건의 성부가 미정한 동안에 조건의 성취로 인하여 생길 상대방의 이익을 해하지 못한다.
제149조(조건부 권리의 처분 등) 조건의 성취가 미정한 권리의무는 일반규정에 의하여 처분, 상속, 보존 또는 담보로 할 수 있다.

1. 조건의 성부 확정 전의 효력

(1) **조건부 권리의 침해금지**

조건 있는 법률행위의 당사자는 조건의 성부가 미정인 동안에 조건성취로 인해 생길 상대방의 이익을 해하지 못한다.

(2) 조건부 권리의 처분 등

조건부 권리 · 의무는 일반규정에 따라 처분 · 상속 · 보존 또는 담보로 할 수 있다(제149조). 조건부 권리는 물권과 같은 배타적 효력을 갖지 않지만 가등기를 경료한 경우에는 순위보전적 효력을 가진다.

2. 조건성취후의 효력

제147조(조건성취의 효과) ① 정지조건있는 법률행위는 조건이 성취한 때로부터 그 효력이 생긴다.
② 해제조건있는 법률행위는 조건이 성취한 때로부터 그 효력을 잃는다.
③ 당사자가 조건성취의 효력을 그 성취전에 소급하게 할 의사를 표시한 때에는 그 의사에 의한다.

(1) 원칙

조건성취의 효력은 원칙적으로 조건 성취시부터 발생하고 소급하지 않는다. 정지조건 있는 법률행위는 조건이 성취한 때로부터 그 효력이 생기고, 해제조건 있는 법률행위는 조건이 성취한 때로부터 그 효력을 잃는다.

(2) 예외

당사자가 조건성취의 효력을 성취전에 소급하게 할 의사를 표시한 때에는 그 성취 전으로 소급할 수 있다.

3. 조건의 성취, 불성취에 대한 반신의행위

(1) 조건의 성취로 의제되는 경우

① 조건의 성취로 인하여 불이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건의 성취를 방해한 때에는 상대방은 그 조건이 성취한 것으로 주장할 수 있다.

② 조건성취의 방해는 고의에 의한 것뿐만 아니라 과실에 의한 것도 포함하고, 조건이 성취된 것으로 의제되는 시점은 이러한 신의성실에 반하는 행위가 없었더라면 조건이 성취되었으리라고 추산되는 시점이다[98다42356].

(2) 조건의 불성취로 의제되는 경우

조건의 성취로 인하여 이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건을 성취시킨 때에는 상대방은 그 조건이 성취하지 아니한 것으로 주장할 수 있다(제150조 제2항).

제 3 절 기한(期限)

Ⅰ 서 설

1. 기한의 의의

기한이란 법률행위의 효력의 발생이나 소멸 또는 채무의 이행을 장래에 발생하는 것이 확실한 사실에 의존케 하는 부관을 말한다. 기한은 장래의 일정한 사실에 법률행위의 효력을 의존시킨다는 점에서 조건과 같으나 그 발생이 확실하다는 점에서 그 발생여부가 불확실한 조건과 다르다.

2. 기한의 종류

제152조(기한도래의 효과) ① 시기있는 법률행위는 기한이 도래한 때로부터 그 효력이 생긴다.
② 종기있는 법률행위는 기한이 도래한 때로부터 그 효력을 잃는다.

(1) **시기와 종기**

① **시기** : 법률행위의 효력의 발생 또는 채무의 이행을 장래에 발생할 것이 확실한 사실에 의존케 하는 기한을 말한다(내년 1월 1일부터 매달 생활비를 주겠다).

② **종기** : 법률행위의 효력의 소멸을 장래에 발생할 것이 확실한 사실에 의존케 하는 기한을 말한다. (내년 12월 31일까지 생활비를 지급하겠다)

(2) **확정기한과 불확정기한**

① **확정기한** : '내년 1월 1일'과 같이 발생시기가 확정되어 있는 기한을 말한다.

② **불확정기한** : '갑이 사망하면' 등과 같이 그 도래시기가 불확정한 기한을 불확정기한이라 한다.

③ **조건과 불확정기한의 구별**

㉠ 부관이 붙은 법률행위에 있어서 부관에 표시된 사실이 발생하지 않으면 채무를 이행하지 않아도 된다고 보는 것이 상당한 경우에는 조건으로 보아야 하고 표시된 사실이 발생한 때에는 물론이고 반대로 발생하지 않는 것이 확정된 때에도 그 채무를 이행하여야 한다고 보는 것이 상당한 경우에는 표시된 사실의 발생 여부가 확정되는 것을 불확정기한으로 정한 것으로 보아야 한다.

㉡ 당사자가 불확정한 사실이 발생한 때를 이행기한으로 정한 경우, 그 사실이 발생한 때는 물론 그 사실의 발생이 불가능하게 된 때에도 그 이행기한은 도래한 것으로 보아야 한다[2005다67353].

Ⅱ 기한을 붙일 수 없는 법률행위

1. 가족법상의 행위

법률행위의 효과가 곧 발생할 것이 요구되는 경우에는 시기를 붙이는 것이 허용되지 않는데 혼인 · 인지 등의 가족법상의 행위에는 시기를 붙이지 못한다.

2. 소급효 있는 법률행위

소급효 있는 법률행위에 시기를 붙이는 것은 무의미하므로 취소 · 상계 등에는 기한을 붙일 수 없으나 동의가 있는 경우 조건을 붙일 수 있다.

Ⅲ 기한부 법률행위의 효력

제154조(기한부 권리와 준용규정) 제148조(기한부 법률행위의 당사자는 기한의 도래가 미정한 동안에 기한의 도래로 인하여 생길 상대방의 이익을 해하지 못한다)와 제149조(기한의 도래가 미정한 권리의무는 일반규정에 의하여 처분, 상속, 보존 또는 담보로 할 수 있다)의 규정은 기한 있는 법률행위에 준용한다.

1. 기한도래 전의 효력

기한부 권리도 조건부 권리와 마찬가지로 기대권으로서 기한도래 전이라도 침해가 금지되며(제148조 · 제154조) 처분 · 상속 · 보존 · 담보의 목적으로 할 수 있다(제149조 · 제154조).

2. 기한도래 후의 효력

기한도래에는 소급효가 없으며, 당사자의 약정으로도 소급하지 못한다. 즉, 시기가 도래하면 그 때부터 효력이 발생하고, 종기가 도래하면 그 때부터 효력을 잃는다. 따라서 종기부 법률행위와 시기부 법률행위는 당사자의 특약에 의해 소급효가 인정될 수 없다.

Ⅳ 기한의 이익(利益)

제153조(기한의 이익과 그 포기) ① 기한은 채무자의 이익을 위한 것으로 추정한다.
② 기한의 이익은 이를 포기할 수 있다. 그러나 상대방의 이익을 해하지 못한다.

1. 의 의

기한의 이익이란 기한이 도래하지 않음으로 인하여 당사자가 받는 이익을 말한다.

2. 기한의 이익을 가지는 자

① 기한의 이익이 누구를 위해 존재하는지 분명하지 않은 경우에는 채무자의 이익을 위한 것으로 추정한다(제153조 제1항).

② 따라서 기한의 이익이 채권자를 위하여 존재한다는 사실은 채권자측에서 입증하여야 한다.

3. 기한의 이익의 포기

기한의 이익을 가지는 자는 그것을 포기할 수 있으나 상대방의 이익을 해하지 못한다. 따라서 채무자는 본래의 이행기까지의 이자를 지급하고서 기한 전에 채무변제를 할 수 있다.

4. 기한의 이익의 상실

제388조(기한의 이익의 상실) 채무자는 다음 각호의 경우에는 기한의 이익을 주장하지 못한다.
1. 채무자가 담보를 손상, 감소 또는 멸실하게 한 때
2. 채무자가 담보제공의 의무를 이행하지 아니한 때

『채무자 회생 및 파산에 관한 법률』 제425조(기한부채권의 변제기도래) 기한부채권은 파산선고시에 변제기에 이른 것으로 본다.

(1) 의 의

기한의 이익을 채무자에게 주는 것은 채권자가 채무자를 신용하여 기한의 유예를 주는 것이다. 따라서 채무자에게 신용상실의 사유가 발생한다면 기한의 이익을 상실케하여 채권자의 이행청구를 거절하지 못하도록 할 것이 요청된다. 이에 민법은 제388조를 두어 기한이익의 상실사유를 규정하고 있다.

(2) 기한이익의 상실특약

① 정지조건부 기한이익상실의 특약

정지조건부 기한이익상실의 특약이란 일정한 사유가 발생하면 채권자의 청구 등을 요함이 없이 당연히 기한의 이익이 상실되어 이행기가 도래하는 것으로 하는 약정을 말한다.

② 형성권적 기한이익상실의 특약

형성권적 기한이익상실의 특약이란 일정한 사유가 발생한 후 채권자의 통지나 청구 등 채권자의 의사행위를 기다려 비로소 이행기가 도래하는 것으로 하는 약정을 말한다.

③ 구별 기준

기한이익의 상실특약이 있는 때에 위의 양자 중 어느 것에 해당하느냐는 당사자의 의사해석의 문제지만 일반적으로 명백히 정지조건부 기한이익상실의 특약이라고 볼 만한 특별한 사정이 없는 이상 형성권적 기한이익상실의 특약으로 추정하는 것이 타당하다[2008다42416,42423].

PART 02

물권법

CHAPTER 01 물권법 총론(總論)

CHAPTER 02 물권의 변동(變動)

CHAPTER 03 점유권(占有權)

CHAPTER 04 소유권(所有權)

CHAPTER 05 용익물권(用益物權)

CHAPTER 06 담보물권(擔保物權)

CHAPTER

01 물권법 총론(總論)

제 1 절 물권의 의의 및 종류

Ⅰ 물권(物權)의 의의 및 객체

1. 물권의 의의

물권은 사람이 '특정한 물건을 직접 지배하여 이익을 얻는 배타적 · 독점적 권리'이다. 이에 반하여 채권은 '특정인에 대하여 일정한 행위를 청구할 수 있는 권리'를 말한다. 즉, 물권은 물건을 객체로 한다는 점에서 대물권(對物權)이고, 채권은 특정인의 행위를 객체로 한다는 점에서 대인권(對人權)이다.

2. 물권(物權)의 객체(客體)

(1) 물건(특정되고 독립된 물건)

① 물권의 객체는 원칙적으로 물건이다. 다만 예외적으로 권리도 물권의 객체가 될 수도 있는데, 지상권 · 전세권을 목적으로 하는 저당권(제371조)등의 경우가 그러하다.

② 물권의 객체는 현존하고 특정된 물건이어야 한다. 다만, 집합물에 있어서는 그 구성부분에 변경이 있더라도 특정성이 인정된다면 물권(양도담보권)의 객체가 될 수 있다.

③ 물권의 객체는 독립한 물건이어야 한다. 따라서 물건의 일부나 구성부분은 공시가 곤란하기 때문에 원칙적으로 물권의 객체가 되지 못한다. 다만 용익물권은 물건의 일부에 대해서도 인정된다.

(2) 문제되는 경우

① 건물은 토지의 정착물이면서 토지와는 독립한 물건으로 취급된다. 신축건물이 언제부터 독립된 부동산이 되는가는 사회통념에 의하여 결정될 것이나 최소한 기둥과 주벽과 지붕이 이루어진 상태를 법률상 건물로 본다[86누173].

② 수목은 독립하여 물권의 객체로 되지 못하는 것이 원칙이다. 그러나 예외적으로 '입목에 관한 법률' 에 의하여 등기된 입목과 관습법상 인정되는 명인방법을 갖춘 수목의 집단은 독립하여 물권의 객체가 된다.

③ 과수의 열매와 같은 미분리과실도 수목의 일부에 지나지 않으나, 관습법상 명인방법에 의해 공시됨으로써 독립한 물권의 객체가 된다.

④ 권원없이 타인의 토지에 재배한 농작물은 공시방법을 갖추지 않은 경우에도 토지로부터 독립된 물건으로서 경작자의 소유가 된다.

Ⅱ 물권(物權)의 종류

1. 물권법정주의(物權法定主義)

제185조(물권의 종류) 물권은 법률 또는 관습법에 의하는 외에는 임의로 창설하지 못한다.

(1) 의 의

① 물권의 종류와 내용은 민법 기타 법률로 규정한 것과 관습법에 의하여 인정된 것에 한하며 당사자가 자유로이 창설하거나 변경하지 못하는 원칙을 물권법정주의라고 한다(제185조).

② 물권의 종류와 내용을 한정하고 이를 공시함으로써 거래안전을 도모하려는 데 있다. 민법 제185조는 강행규정으로 이에 위반한 법률행위는 무효이다.

(2) 민법 제185조의 의미

① 법 률

국회가 제정하는 형식적 의미의 법률을 의미하고 명령 · 규칙은 제외된다.

② 관습법

'관습법'이란 일정한 관행이 존재하고 그것이 사회일반의 법적 확신에 의해 법적 규범력을 획득하여 정당성과 합리성을 가진 것을 말한다.

③ "임의로 창설하지 못한다"의 의미

법률 또는 관습법이 인정하지 않는 새로운 종류의 물권을 만들지 못하고, 법률 또는 관습법이 인정하는 내용과 다른 내용을 부여하지 못한다.

(3) 물권법정주의 위반의 효과

① 강행규정

제185조는 강행규정이므로 물권법정주의에 위배되는 물권행위는 원칙적으로 무효이다.

② 소유권의 사용 · 수익 권능포기 여부

물건에 대한 배타적인 사용 · 수익권은 소유권의 핵심적 권능이므로, 소유자가 제3자와의 채권관계에서 소유물에 대한 사용 · 수익의 권능을 포기하거나 사용 · 수익권의 행사에 제한을 설정하는 것을 넘어 이를 대세적, 영구적으로 포기하는 것은 법률에 의하지 않고 새로운 물권을 창설하는 것과 다를 바 없어 허용되지 않는다[2012다54133].

2. 물권의 종류

(1) 「민법」에 의하여 인정되는 물권

① 민법상 물권에는 점유권, 소유권, 지상권, 지역권, 전세권, 유치권, 질권, 저당권의 8종류가 있다.

② 이를 구별하면 크게 점유권과 점유할 권리(점유를 정당화 할 수 있는 권리=본권)로 나뉘어지며, 점유할 권리에는 다시 소유권과 제한물권으로 구분된다. 제한물권에는 다시 용익물권과 담보물권으로 구분된다. 용익물권에는 지상권, 지역권, 전세권이 있으며, 담보물권에는 유치권, 질권, 저당권이 있다.

- 물권
  - 점유권(동산 · 부동산)
  - 본권
    - 소유권(동산 · 부동산)
    - 제한물권
      - 용익물권 : 지상권 · 지역권 · 전세권(부동산)
      - 담보물권
        - 법정담보물권 : 유치권(동산 · 부동산)
        - 약정담보물권 : 질권(동산 · 권리) · 저당권(부동산)

(2) 관습법상의 물권

① 관습법상 인정되는 물권

관습법상의 물권으로서 판례에 의하여 확인되어 있는 주요한 것으로, 분묘기지권, 관습법상의 법정지상권, 동산의 양도담보 등이 있다.

② 관습법상 인정되지 않는 물권

㉠ 온천에 관한 권리(광천권 · 온천권 · 온천수이용권)는 관습법상의 물권이라고 볼 수 없다.

㉡ 성문법과 관습법 어디에도 없는 관습상의 사도통행권을 인정하는 것은 물권법정주의에 위배된다[2001다64165].

㉢ 도시공원법상 근린공원으로 지정된 공원은 일반 주민들이 다른 사람의 공동사용을 방해하지 않는 한 자유로이 이용할 수 있지만 그러한 사정만으로 인근 주민들이 누구에게나 주장할 수 있는 공원이용권이라는 배타적인 권리를 취득하였다고는 할 수 없다[94마2218].

㉣ 미등기무허가건물의 양수인이라 할지라도 그 소유권이전등기를 경료받지 않는 한 그 건물에 대한 소유권을 취득할 수 없고, 그러한 상태의 건물양수인에게 소유권에 준하는 관습상의 물권이 있다고 볼 수도 없다[2007다11347].

제 2 절 물권의 효력

1. 우선적 효력(優先的 效力)

(1) 의 의

우선적 효력이란 동일물 위에 수개의 권리가 존재하는 경우에 그 중의 하나의 권리가 다른 권리에 우선하여 효력이 인정되는 것을 말한다.

(2) 채권에 우선하는 효력

① **원칙** : 물권과 채권이 부딪치는 경우에 그 성립의 시간적 순서와는 관계없이 원칙적으로 물권이 채권에 우선한다.

② **예외** : 등기된 부동산임차권(제621조 제2항), 주택임대차보호법이나 상가건물임대차보호법상 대항요건을 갖춘 임차권, 대항요건과 확정일자를 갖춘 주택(주택임대차보호법 제3조의2)이나 상가건물임차인(상가건물임대차보호법 제5조 제2항 · 제19조)의 보증금반환채권, 가등기에 의해 순위가 보전된 청구권(채권)은 그 시점을 기준으로 하여 물권과의 우열이 정해진다.

(3) 물권 상호간의 우선적 효력

① 제한물권은 언제나 소유권에 우선한다.

② 같은 종류의 물권 상호간에는 먼저 성립한 물권이 나중에 성립한 물권에 우선한다. 종류가 다른 물권은 동일한 물건위에 동시에 성립할 수 있다. 전세권자의 전세금반환청구권과 저당권자의 피담보채권이 경합한 경우에 그 설정시기에 따라 우선변제의 순위가 결정된다.

2. 물권적 청구권(物權的 請求權)

(1) 의의 및 성질

① **의의** : 물권의 행사가 방해당하거나 방해당할 염려가 있는 경우에 물건의 반환이나 방해의 제거 · 예방을 청구할 수 있는 권리를 말한다.물권의 존재로부터 당연히 생기는 권리가 아니고 물권의 침해에 의해 비로소 생기는 권리이다.

② **법적 성질**

㉠ 물권적 청구권은 물권을 기초로 한 권리이므로 채권적 청구권에 우선한다. 또한 물권에 의존하는 권리이므로 물권이 이전 · 소멸하면 물권적 청구권도 함께 이전 · 소멸한다. 따라서 소유권을 양도함에 있어 소유권에 의해 발생되는 물권적 청구권을 소유권과 분리하여 소유권 없는 전소유자에게 유보하여 제3자에 대해 이를 행사케 하는 것은 소유권이 절대적 권리인 점에 비추어 허용될 수 없다.

㉡ 물권적 청구권이 소멸시효에 걸리느냐에 관해서는 명문의 규정이 없어 견해가 대립하는데 판례는 소유권이 소멸시효에 걸리지 않으므로 소유권에 기한 물권적 청구권도 소멸시효에 걸리지 않는다고 한다[80다2968]. 또한 일반적으로 제한물권에 기한 물권적 청구권도 물권과 독립하여 소멸시효에 걸리지 않는다고 한다.

(2) 물권적 청구권의 종류

① 방해모습에 따른 분류

물권적 청구권은 그 방해모습에 따라 물권적 반환청구권, 물권적 방해제거청구권, 물권적 방해예방청구권이 있다.

② 기초가 되는 물권에 따른 분류

㉠ 민법은 점유권에 기한 물권적 청구권(제204조, 제205조, 제206조)과 소유권에 기한 물권적 청구권(제213조, 제214조)을 규정하고, 소유권에 기한 물권적 청구권의 규정을 다른 제한물권에 준용한다.

㉡ 유치권과 질권에는 준용하는 규정이 없으나 일반적으로 질권에는 준용되지만 유치권에는 준용되지 않는다고 한다. 따라서 유치권자는 직접 유치권에 기한 물권적 청구권은 행사할 수 없고, 다만 점유권에 기한 물권적 청구권은 행사할 수 있다고 본다.

㉢ 지역권과 저당권은 점유를 본질로 하는 것이 아니므로 지역권이나 저당권에 기한 목적물반환청구권이 없다.

보충학습 임차권과 물권적 청구권

(1) 임차권 자체에 물권적 청구권을 인정할 수 없다. 다만, 임대인의 물권적 청구권을 대위행사할 수 있고, 임차인이 임대물을 점유하고 있으면 점유권에 기한 물권적 청구권을 행사할 수 있으나 이는 임차권에 기한 청구권이 아니다.

(2) 등기된 부동산임차권과 주택의 인도와 주민등록을 마친 주택임차권, 상가건물의 인도와 사업자등록을 마친 상가임차권에 대해서는 물권적청구권이 유추적용되어 임차권에 기한 방해제거 · 방해예방청구권을 행사할 수 있다.

(3) 발생요건

① 침해사실 또는 침해염려

㉠ 물권실현을 방해하거나 방해할 염려가 있어야 한다. 다만, 침해를 정당화하는 사유가 있으면 물권적 청구권을 행사할 수 없다.

㉡ 침해자의 고의 또는 과실은 요구되지 않는다. 방해의 원인이 자연적 사실(불가항력으로 인한 침해)이든 특정인의 행위(침해자의 귀책사유)이든 불문한다.

② 청구권자

침해당한 물권에 대한 현재의 정당한 권리자여야 한다. 따라서 소유권을 상실한 전 소유자는 불법점유자에 대하여 소유권에 기한 물권적 청구권을 행사할 수 없다[80다7].

③ 청구의 상대방

㉠ 물권침해의 원인을 현재(사실심의 변론종결 당시) 자기의 사회적 지배범위에 두고 있는 자가 상대방이다.

㉡ 따라서 불법점유를 이유로 하여 그 명도 또는 인도를 청구하려면 '현실적'으로 그 목적물을 점유하고 있는 자를 상대로 하여야 하고 불법점유자라 하여도 그 물건을 다른 사람에게 인도하여 현실적으로 점유를 하고 있지 않은 이상, 그 자를 상대로 한 인도 또는 명도청구는 부당하다[98다9045].

(4) 비용부담의 문제

소유자가 침해자에 대하여 방해제거 행위 또는 방해예방 행위를 하는 데 드는 비용을 청구할 수 있는 권리는 민법 제214조에 포함되어 있지 않으므로, 소유자가 민법 제214조에 기하여 방해배제 비용 또는 방해예방 비용을 청구할 수는 없다[2014다52612].

(5) 불법행위로 인한 손해배상청구권과의 관계

물권적 청구권은 귀책사유(고의 · 과실)를 불문하고 현재의 방해자를 상대로 청구하나, 손해배상청구권은 귀책사유(고의 · 과실)를 요구하고 불법행위자를 상대로 청구한다. 따라서 물권적 청구권의 상대방에 대해서 언제나 불법행위를 이유로 한 손해배상청구권을 행사할 수 있는 것이 아니지만, 침해자에게 고의 · 과실이 있는 경우에 물권적 청구권과 불법행위로 인한 손해배상청구권이 동시에 발생하여 병존할 수 있다.

CHAPTER

02 물권의 변동(變動)

제 1 절 서 설

Ⅰ 물권변동의 의의

1. 물권변동의 의의

물권변동이란 물권의 발생 · 변경 · 소멸을 말한다. 이를 물권의 주체를 중심으로 보면 물권의 득실변경(得失變更)이 된다.

2. 물권변동의 모습

① **객체(客體)에 따른 분류** : 부동산물권의 변동과 동산물권의 변동으로 구분된다.

② **원인(原因)에 따른 분류** : 법률행위로 인한 물권변동과 법률규정으로 인한 물권변동으로 구분된다.

③ 결과적으로 부동산물권변동은 법률행위에 의한 물권변동과 법률규정에 의한 물권변동으로 나누어 볼 수 있고, 동산물권도 법률행위에 의한 물권변동과 법률규정에 의한 물권변동으로 나누어 볼 수 있다.

Ⅱ 물권변동과 공시(公示)

1. 공시의 원칙

(1) **의 의**

물권에는 배타성과 관념성이 있으므로 거래안전을 위하여 물권의 귀속과 내용을 외부에서 인식할 수 있는 일정한 표상이 필요한데 이를 공시라 한다. 그러므로 물권의 변동은 일반 제3자가 쉽게 인식할 수 있는 '공시의 원칙'이 필요하다.

(2) **공시방법**

① **부동산물권** : 부동산물권의 공시방법은 등기이다(제186조 참조).

② **동산의 물권** : 동산물권의 공시방법은 점유이다. 점유를 이전하는 것을 인도(引渡)라고 한다(제188조 참조). 다만, 동산 중에서 선박, 자동차, 항공기 등은 특별법에 의해 등기 또는 등록으로 공시한다.

③ **수목의 집단 또는 미분리과실** : 수목의 집단 · 미분리과실 · 농작물 등은 관습법상 인정되는 명인방법에 의하여 공시한다.

보충학습 명인방법

명인방법이란 수목과 같은 지상물을 토지와는 별도로 거래할 수 있도록 그 소유권이 누구에게 있음을 외부에 명백히 인식시키는 관습법상의 공시방법을 말한다. 예를들어 임야의 여러 곳에 '입산금지 소유자 ○○○'라는 푯말을 송판에 써서 붙이거나 경계를 따라 적당한 거리를 두고 수피를 깍아서 거기에 소유자의 성명을 묵서한다든지(수목의 집단), 논 · 밭의 주위에 새끼를 둘러치고 소유자의 성명을 묵서한 목찰을 세우는 것(미분리의 과실) 등을 들 수 있다.

2. 공신의 원칙(公信의 原則)

(1) 의 의

공시방법에 의해 공시된 물권의 존재를 신뢰하여 거래한 경우에는 그 공시에 상응하는 물권이 존재하지 않을지라도 공시된 대로의 물권이 존재하는 것으로 다루어 져야한다는 원칙이다. 이는 거래상대방의 신뢰를 보호하고, 진정한 권리자는 피해볼 염려가 있다.

(2) 우리 민법의 태도

① 우리 민법은 동산에 대해서는 공신의 원칙을 인정하고 있다(제249조 : 선의취득). 예를 들면 甲이 동산을 점유하고 있고, 乙이 甲의 점유를 신뢰하여 그 물건을 매수한 경우에 甲이 실제로는 그 동산의 소유자가 아닌 경우에도 乙이 유효하게 소유권을 취득한다. 즉, 동산물권의 공시방법인 점유에는 공신력을 인정한다.

② 부동산물권의 공시방법인 등기에는 공신의 원칙이 인정되지 않는다. 즉, 부동산등기에는 공신력이 없다.

제 2 절 부동산물권변동

Ⅰ 등기를 하여야 부동산물권변동의 효력이 있는 경우

제186조(부동산물권변동의 효력) 부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다.

등기를 하여야 부동산의 물권변동효력이 발생하는 대표적인 경우는 다음과 같다.

① 교환계약(법률행위)에 의한 부동산물권의 취득

② 매매예약완결권 행사에 의한 부동산소유권 취득

③ 권리(지분)의 포기에 따른 물권변동

④ 현물분할의 합의에 의하여 공유토지에 대한 단독소유권을 취득하는 경우

⑤ 이행판결에 의한 소유권의 이전

⑥ 공유물분할청구소송에서 현물분할의 협의가 성립하여 조정이 된 때 공유자들의 소유권 취득
⑦ 등기된 입목에 대한 저당권의 취득
⑧ 점유취득시효에 의한 소유권의 취득(제245조 제1항 – 법률규정이지만 등기필요)

Ⅱ 등기를 요하지 않는 부동산물권변동 : 법률규정에 의한 부동산물권변동

1. 형식주의(形式主義)의 예외

제187조 (등기를 요하지 아니하는 부동산물권취득) 상속, 공용징수, 판결, 경매 기타 법률의 규정에 의한 부동산에 관한 물권의 취득은 등기를 요하지 아니한다. 그러나 등기를 하지 아니하면 이를 처분하지 못한다.

2. 적용범위

민법 제187조는 부동산에 관한 물권의 취득만을 규정하고 있으나, 물권의 변경과 소멸에도 적용된다.

(1) 상 속

상속(제1005조) · 포괄유증(제1078조)은 등기없이도 피상속인의 사망시에 물권변동이 일어난다.

(2) 공용징수

협의수용의 경우에는 협의로 정한 시기에, 재결수용의 경우에는 보상금의 지급을 정지조건으로 하여 수용 개시일에 물권변동이 일어난다.

(3) 판 결

민법 제187조에서 판결에 의하여 등기를 하지 않고 물권의 취득효력을 받는 경우는 판결 자체에 의하여 물권의 취득효력을 형성하는 형성판결을 말하고, 확인판결이나 이행판결은 이에 해당하지 않는다[62다223].

(4) 경 매

경매는 국가기관이 권력행위로서 행하는 공 · 경매를 말하며, 민사집행법상의 강제경매 · 담보권실행경매의 경우에는 매수인이 매각대금을 납부한 때, 국세징수법상의 공매의 경우에는 매수인이 매수대금을 납부한 때에 권리변동이 생긴다.

(5) 기타 법률의 규정에 의한 부동산에 관한 물권변동

① 신축건물이나 공유수면매립지의 소유권 취득
② 부동산의 멸실에 의한 물권의 소멸

③ 법정지상권의 취득(제305조 · 제366조 등)
④ 법정저당권의 취득(제649조)
⑤ 법정대위에 의한 저당권의 이전
⑥ 분묘기지권의 취득
⑦ 혼동에 의한 물권의 소멸
⑧ 피담보채권의 소멸에 의한 저당권의 소멸
⑨ 존속기간만료에 의한 용익물권의 소멸
⑩ 원인행위 실효(무효 · 취소 · 해제 등)에 의한 물권의 복귀
⑪ 소멸시효에 의한 물권의 소멸

제 3 절 부동산물권의 공시방법(등기)

Ⅰ 부동산등기의 의의 및 종류

1. 부동산등기의 의의

등기란 등기관이라는 국가기관이 법정절차에 따라 등기부라는 공적 장부에 부동산에 관한 표시와 일정한 권리관계를 기록하는 것, 또는 그 기록 자체를 말한다.

2. 등기의 종류

(1) **부동산표시에 관한 등기(표제부의 등기, 사실의 등기)**

부동산의 물리적 현황을 등기기록 표제부에 기록하는 등기로서 권리의 대상인 부동산을 구체적으로 특정하는 것을 목적으로 하는 등기이다. 토지의 소재 · 지번 · 지목 · 면적, 건물의 소재 · 대지의 지번 · 건물번호 · 건물내역(건물의 종류 및 구조, 면적)과 부속건물이 있는 경우 부속건물의 내역 등을 내용으로 한다.

(2) **권리에 관한 등기(甲구 · 乙구의 등기)**

이는 부동산의 권리에 관한 사항을 등기기록 중 甲구와 乙구의 사항란에 기록하여 공시하는 등기로서 이에는 소유권에 관한 등기와 용익권에 관한 등기, 담보권에 관한 등기가 있다.

Ⅱ 등기청구권(登記請求權)

1. 서 설

(1) 의 의

부동산등기법이 등기신청에 관해 공동신청주의를 취하기 때문에 등기권리자가 등기의무자에 대해 등기신청에 협력해 줄 것을 청구할 수 있는 실체법상 · 사법상의 권리를 말한다.

(2) 등기신청권과의 구별

등기신청권은 국가기관에 대한 공법상의 권리임에 비해, 등기청구권은 사인(私人)에 대한 사법상의 권리이다.

(3) 문제점

등기청구권이 문제되는 것은 등기청구권의 법적 성질이 채권적 청구권인가, 물권적 청구권인가에 따라 소멸시효의 대상이 되는 지가 문제된다.

2. 등기청구권이 채권적 청구권인 경우

(1) 법률행위로 인한 등기청구권

① 법률행위로 인한 등기청구권은 형식주의를 취하고 있는 현행 민법 하에서는 채권적 청구권으로서 원칙적으로 소멸시효에 걸린다[76다148전합].

② 부동산의 매수인이 목적 부동산을 인도받아 계속 점유하는 경우에는 그 소유권이전등기청구권의 소멸시효가 진행하지 않는다[98다32175전합]. 더 나아가 부동산의 매수인이 그 부동산을 인도받은 이상 이를 사용 · 수익하다가 그 부동산에 대한 보다 적극적인 권리행사의 일환으로 다른 사람에게 그 부동산을 처분하고 그 점유를 승계하여 준 경우에도 이전등기청구권의 소멸시효는 진행되지 않는다[98다32175전합].

③ 매매를 원인으로 발생하는 매수인의 소유권이전등기청구권은 채권적 청구권이지만, 그 이행과정에 신뢰가 따르므로 매매로 인한 소유권이전등기청구권은 특별한 사정이 없는 이상 그 권리의 성질상 양도가 제한되고 그 양도에 채무자의 승낙이나 동의를 요한다고 할 것이므로 통상의 채권양도와 달리 양도인의 채무자에 대한 통지만으로는 채무자에 대한 대항력이 생기지 않으며 반드시 채무자의 동의나 승낙을 받아야 대항력이 생긴다[2000다51216].

(2) 취득시효완성으로 인한 등기청구권

① 부동산의 점유취득시효에 의한 물권의 취득은 등기를 하여야 효력이 있으므로(제245조), 그에 따른 소유권이전등기청구권은 채권적 청구권이다.

② 채권적 청구권이지만 시효완성자가 점유를 계속하고 있는 동안에는 소멸시효는 진행되지 않는다. 그러나 취득시효가 완성된 점유자가 그 점유를 상실한 때로부터 소멸시효가 진행하여 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성한다.

③ 취득시효완성으로 인한 소유권이전등기청구권은 채권자와 채무자 사이에 아무런 계약관계나 신뢰관계가 없으므로 취득시효완성으로 인한 소유권이전등기청구권의 양도의 경우에는 매매로 인한 소유권이전등기청구권에 관한 양도제한의 법리가 적용되지 않고 통상의 채권양도의 방법에 의해 양도가 가능하다[2015다36167]. 즉, 소유자의 동의나 승낙이 반드시 필요하지는 않고, 소유자에 대한 통지만으로 대항력이 생긴다.

(3) 부동산임차권, 부동산환매권의 등기청구권

① 부동산임차권에 기한 등기청구권은 민법 제621조 제1항의 규정에 의해 발생하는 채권적 청구권이다.

② 부동산환매권에 관한 등기청구권은 당사자간의 계약에 의해 발생하고 환매특약에 기한 매도인의 등기청구권의 성질은 채권적 청구권이다.

3. 등기청구권이 물권적 청구권인 경우

(1) 실체관계와 등기가 일치하지 않는 경우

① 말소등기청구권

실체관계와 등기가 일치하지 않는 경우(위조등기, 계약의 무효 · 취소 · 해제 등)에 진정한 권리자는 등기명의자에게 물권의 완전한 실현을 방해당하고 있음을 이유로 방해배제청구로서 말소등기청구를 할 수 있는데 이때의 등기청구권은 물권의 효력으로서 발생하는 물권적 청구권이다.

② 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기청구권

소유권을 방해당하고 있는 진정한 소유자는 최종 소유권등기명의자에게 '말소등기청구' 대신에 '진정한 등기명의의 회복을 위한 소유권이전등기청구'를 할 수 있는데[89다카12398전합], 이 때의 등기청구권도 물권적 청구권이다. 명의신탁의 해지로 인한 신탁자의 이전등기청구권, 매매계약의 무효 · 취소 · 해제로 인한 매도인의 이전등기청구권, 부동산 양도담보에서 피담보채무가 변제된 후의 담보권설정자의 이전등기청구권 등은 진정등기명의 회복을 위한 물권적 청구권으로 인정된다.

(2) 법정지상권(제305조 · 제366조), 법정저당권(제649조) 설정등기청구권

법정지상권(제305조 · 제366조), 법정저당권(제649조)이 성립한 경우에 그 설정등기청구권은 법률의 규정에 의해 취득한 물권으로부터 발생하는 물권적 청구권이다.

Ⅲ 등기의 유효요건

1. 서 설

실행된 등기가 유효하기 위해서는 첫째, 부동산등기법이 정하는 절차상의 요건을 갖추어서 적법하게 이루어져야 하고(형식적 · 절차적 유효요건), 등기의 내용이 물권행위(실체관계)의 내용과 합치해야 한다(실질적 · 실체적 유효요건).

2. 등기의 형식적 유효요건

(1) 부동산등기법에 따른 적법절차를 준수할 것

① 등기가 유효하기 위해서는 원칙적으로 부동산등기법이 정하는 적법한 절차에 따라 이루어져야 한다.

② 다만, 등기절차상 하자가 있었지만 등기가 사실상 이루어진 경우 그 등기가 실체관계에 부합하면 유효하다는 것이 판례의 태도이다. 예컨대, 위조된 등기신청서류에 의한 등기 또는 무권리자의 등기신청으로 이루어진 등기라 하더라도 그 등기가 실체적 권리관계에 부합하면 유효하다.

③ 등기는 물권의 효력발생요건이지 효력존속요건은 아니므로, 물권에 관한 등기가 원인 없이 말소된 경우에도 그 물권의 효력에는 아무런 영향이 없다[87다카2431]. 따라서 근저당권설정등기가 불법하게 말소된 경우라도 근저당권은 소멸하지 않으므로 근저당권말소회복등기로 회복할 수 있다.

(2) 이중보존등기(중복등기)

① 의의

등기절차상의 잘못으로 하나의 부동산에 보존등기가 이중으로 행해진 경우를 말하며, 이 경우 어떤 보존등기를 유효로 할 것인가가 문제된다.

② 표제부의 이중등기

동일부동산에 관하여 보존등기가 있을 경우, 그 중 하나의 등기가 부동산의 표시에 있어서 실체와 현격한 차이가 있는 경우에는 등기의 선후에 관계없이 부동산의 실체상황과 일치하는 보존등기만이 효력을 가진다.

③ 갑구(甲區)의 이중등기

㉠ 등기명의인이 동일인인 경우 : 동일부동산에 관하여 동일인 명의로 중복보존등기가 경료된 경우 부동산등기법이 1부동산 1등기기록주의를 채택하고 있는 이상 뒤에 경료된 등기는 무효이고 이 무효인 등기에 터잡아 타인명의로 소유권이전등기가 경료되었다고 하더라도 실체관계에 부합하는 여부를 가릴 것 없이 이 등기 역시 무효이다[83다카743].

㉡ 등기명의인이 동일인이 아닌 경우 : 동일부동산에 관해 등기명의인을 달리하여 중복된 소유권보존등기가 경료된 경우에는 먼저 이루어진 소유권보존등기가 원인무효가 되지 않는 한 뒤에 한 소유권보존등기는 1부동산 1등기기록주의를 채택하고 있는 부동산등기법 아래에서는 무효이다[87다453전합].

3. 등기의 실체적 유효요건

(1) 등기와 실체관계가 부합할 것

① 등기가 유효하기 위해서는 그에 부합하는 실체적인 권리관계(물권행위)가 유효하게 존재하여야 하고 등기와 물권행위가 일치하여야 한다.

② 등기가 먼저 행하여진 경우 그에 부합하는 물권행위가 존재하지 아니하므로 일단은 효력이 없으나, 후에 그에 대응하는 물권행위가 있게 되면 유효한 등기로서 물권변동을 가져온다.

③ 따라서 신축건물의 보존등기를 건물 완성 전에 하였더라도 그 후 건물이 완성된 이상 등기를 무효라고 볼 수 없다[2013다59876].

(2) 중간생략등기(中間省略登記)

① 의 의

중간생략등기란 부동산물권이 전전 매도된 경우에 각 매매계약이 유효하게 성립함을 전제로 최초의 매도인으로부터 최종 매수인 앞으로 경료되는 이전등기를 말한다. 예컨대, 부동산물권이 甲 ⇨ 乙 ⇨ 丙으로 순차적으로 이전되어야 할 경우 중간취득자 乙의 등기를 생략하고 최초의 양도인 甲으로부터 직접 최후의 양수인 丙에게 하는 등기이다.

② 최종매수인(丙)의 최초매도인(甲)에 대한 등기청구 여부

㉠ 관계당사자 전원의 중간생략등기에 관한 합의가 있어야 최종매수인은 최초양도인에게 직접 그 소유권이전등기를 청구할 수 있다. 이러한 3자간의 합의는 순차적·묵시적으로 해도 무방하다[95다15575].

㉡ 중간생략등기의 합의가 없다면 부동산의 최종매수인은 중간자를 대위하여 그 전매도인인 등기명의자에게 매도인 앞으로의 소유권이전등기를 구할 수는 있을지언정 직접 자기 앞으로의 소유권이전등기를 구할 수는 없다[69다1351].

㉢ 만일 최종매수인이 중간자로부터 소유권이전등기청구권을 양도받았다 하더라도 최초매도인이 그 양도에 대해 동의하지 않고 있다면 최종매수인은 최초매도인에 대해 채권양도를 원인으로 하여 소유권이전등기절차이행을 청구할 수 없다[95다15575].

③ 중간생략등기 합의의 의미

㉠ 중간생략등기의 합의란 부동산이 전전매도된 경우 각 매매계약이 유효함을 전제로 그 이행의 편의상 최초의 매도인으로부터 최종의 매수인 앞으로 소유권이전등기를 경료하기로

한다는 당사자 사이의 합의에 불과할 뿐 그러한 합의가 있다고 하여 최초의 매도인과 최종의 매수인 사이에 매매계약이 체결되었다는 것을 의미하는 것은 아니다[96다3982]. 따라서 중간생략등기의 합의는 적법한 등기원인이 될 수 없다.

㉡ 중간생략등기의 합의가 있었다 하여 중간매수인의 소유권이전등기청구권이 소멸된다거나 첫 매도인의 그 매수인에 대한 소유권이전등기의무가 소멸되는 것은 아니다[91다18316].

㉢ 또한 최초매도인이 중간자에 대하여 갖고 있는 매매대금청구권의 행사가 제한되는 것도 아니므로 중간생략등기의 합의가 있은 후에도 최초매도인은 중간매수인의 매매대금 미지급을 이유로 최종매수인의 소유권이전등기청구를 거절할 수 있다. 더 나아가 중간생략등기의 합의가 있은 후에 최초 매도인과 중간매수인 간에 매매대금을 인상하는 약정이 체결된 경우, 최초매도인은 인상된 매매대금이 지급되지 않았음을 이유로 최종매수인명의로의 소유권이전등기의무의 이행을 거절할 수 있다[2003다66431].

㉣ 복수의 당사자 사이의 어느 한 계약이 무효이거나 취소·해제되면 중간생략등기의 합의도 효력을 상실하므로 최초매도인은 최종매수인명의로의 소유권이전등기의무의 이행을 거절할 수 있다[95다38875].

④ 중간생략등기의 유효성

㉠ 판례는 전원의 합의가 없더라도 이미 중간생략등기가 적법한 등기원인에 기하여 성립되어 있는 때에는 합의가 없었음을 이유로 무효를 주장할 수 없고 따라서 말소를 청구하지 못한다고 한다.

㉡ 또한 부동산등기특별조치법은 등기하지 아니하고 제3자에게 전매하는 행위를 일정목적 범위 내에서 형사처벌하도록 되어 있으나, 판례는 이 규정을 단속규정으로 보아 이로써 당사자간의 중간생략등기 합의에 관한 사법상의 효력까지 무효로 한다는 취지는 아니라고 한다.

㉢ 토지거래허가구역 안에 있는 토지에 관하여 당사자들 사이에 중간생략등기의 합의가 있었다고 하더라도 최초 매도인과 최종 매수인 사이에 매매계약이 체결되었다고 볼 수 없으므로 최종 매수인 丙은 직접 최초 매도인 甲에게 허가신청절차의 협력을 구할 수 없다.

㉣ 따라서 설사 최종 매수인이 자신과 최초 매도인을 매매당사자로 하는 토지거래허가를 받아 자신 앞으로 소유권이전등기를 경료하였더라도 그러한 최종 매수인 명의의 소유권이전등기는 적법한 토지거래허가 없이 경료된 등기로서 무효이다[96다22464].

(3) 무효등기의 유용

① 무효등기의 유용이란 처음부터 그에 부합하는 실체관계가 없어서 등기가 무효이었으나 나중에 실체관계를 갖춘 경우에는 그 등기의 말소등기를 하지 않고 그 등기를 유효한 등기로 그대로 이용(유용)할 수 있는가의 문제이다.

② 판례는 권리등기(저당권등기, 가등기 등)의 유용은 유용합의 이전에 등기부상 이해관계가 없는 경우에 한하여 유효하다고 본다.

③ 그러나 멸실된 건물의 보존등기를 신축한 건물의 보존등기로는 유용하는 표제부등기의 유용은 할 수 없다. 신축된 건물이 멸실된 건물과 그 위치, 구조 기타의 면에서 상호 같다고 하더라도 그로써 신축된 건물이 멸실된 건물과 동일한 건물이라고 할 수 없기 때문이다.

Ⅳ 등기의 추정적 효력(推定的 效力)

(1) 의 의

등기의 추정적 효력이란 부동산등기가 있으면 그에 상응하는 실체적 권리가 등기명의인에게 존재하는 것으로 추정하는 힘을 말한다. 등기는 국가기관에 의하여 관리된다는 점에서 그 진정성이 어느 정도 담보되고 있기 때문에 학설과 판례가 등기의 추정력을 인정하고 있다.

(2) 추정의 효과

① 등기된 내용은 일응 진정한 것으로 추정되는 것에 불과하므로 반대의 증거에 의하여 이 추정을 뒤집을 수 있으며, 이 경우 입증책임은 반대사실을 주장하는 자에게 있다.

② 이와 같은 등기의 추정력으로부터 등기의 내용을 신뢰하고 거래한 자는 무과실로 추정되고 선의라도 등기내용을 조사하지 아니한 경우에는 과실이 있는 것으로 추정된다.

③ 등기의 추정력은 등기와 반대사실을 '증명' 하지 않는 한 깨어지지 않으므로 등기명의자가 등기부에 기재된 것과 다른 원인으로 등기명의를 취득하였다고 주장하고 있지만 그 주장사실이 인정되지 않는다 하여도 등기의 추정력이 깨어진다고 할 수 없다[95다39526].

(3) 추정력이 미치는 범위

① **권리의 적법추정** : 등기된 권리가 등기명의인에게 귀속하는 것으로 추정되고 그 등기에 의하여 물권변동이 유효하게 성립한 것으로 추정된다. 또한 담보물권등기의 경우 그 담보물권의 존재 자체뿐만 아니라 이에 상응하는 피담보채권도 존재한다고 추정되며[68다2329], 환매기간을 제한하는 환매특약이 등기된 때에는 등기부 기재와 같은 환매특약이 진정하게 성립된 것으로 추정된다[91다13700].

② **등기절차의 적법추정** : 등기가 있는 경우에는 적법한 절차에 의하여 이루어진 등기라고 추정된다. 등기의 전제조건의 충족 등도 추정되며 부동산을 매수한 등기명의인이 상대방의 대리인과 매매계약을 체결했다고 주장하는 경우 대리권의 존재도 추정된다. 따라서 현 등기명의인의 등기가 원인무효임을 이유로 그 말소를 구하는 전 등기명의인으로서는 그 반대사실, 즉 그 제3자에게 전 등기명의인을 대리할 권한이 없었다는 등의 무효사실에 대한 증명책임을 진다[2009다10386].

③ **등기원인의 적법추정** : 등기가 경료되면 적법한 등기원인으로 마쳐진 것으로 추정된다. 따라서 부동산등기는 현재의 진실한 권리상태를 공시하면 그에 이른 과정이나 태양을 그대로 반영하지 않았어도 유효한 것이므로, 등기명의자가 전 소유자로부터 부동산을 취득함에 있어 등기부상 기재된 등기원인에 의하지 아니하고 다른 원인으로 적법하게 취득하였다고 하면서 등기원인행위의 태양이나 과정을 다소 다르게 주장하더라도 그 주장만으로 등기의 추정력이 깨어진다고 할 수 없다[92다46059].

④ **등기추정력의 인적 범위** : 부동산에 관하여 소유권이전등기가 마쳐져 있는 경우 그 등기명의자는 제3자에 대하여서 뿐만 아니라, 그 전 소유자에 대하여서도 적법한 등기원인에 의하여 소유권을 취득한 것으로 추정된다[99다65462]. 또한 등기의 추정력은 등기명의인뿐만 아니라 제3자가 추정의 효과를 원용할 수 있고, 등기명의인의 이익을 위해서는 물론 그 불이익(부동산에 대한 세금 등)을 위해서도 인정된다.

(4) 추정력이 부정되는 경우

① 등기의 추정력은 권리관계에 대한 추정이므로 권리등기가 아닌 부동산표시의 등기에는 추정력이 인정되지 않는다.

② 권리의 변동을 직접 발생케 하는 본등기에 추정력이 인정되므로 가등기에는 추정력이 인정되지 않는다. 따라서 소유권이전등기청구권보전을 위한 가등기가 있다고 하여 소유권이전등기를 청구할 어떤 법률관계가 있다고 추정되지 않는다.

③ 허무인(실재 존재하지 않는 사람)으로부터 이어받은 소유권이전등기는 특별한 사정이 없는 한 등기의 추정력을 인정할 여지가 없다[84다카2494, 2003다3157].

④ 사망한 전소유자 명의로 경료된 소유권이전등기는 추정력이 인정되지 않는다[83다카597]. 다만, 사망 전에 적법한 등기원인이 존재하는 경우에는 사망자 명의의 등기에도 추정력은 인정된다.

⑤ 담보물권등기의 경우 피담보채권도 존재한다고 추정되지만, 근저당권등기가 되어 있다는 사실만으로 그 피담보채권을 성립시키는 기본계약까지 추정하지는 않는다[2009다72070].

⑥ 등기는 물권의 효력발생요건이고 존속요건은 아니므로 등기가 원인 없이(불법) 말소된 경우에는 그 물권의 효력에는 아무런 영향이 없고, 권리소멸의 추정력이 없다. 즉, 그 회복등기가 마쳐지기 전이라도 말소된 소유권이전등기의 최종명의인은 적법한 권리자로 추정된다[95다39526].

⑦ 소유권이전등기의 원인으로 주장된 계약서가 진정하지 않은 것으로 증명된 이상 그 등기의 적법추정은 깨지는 것이고, 계속 다른 적법한 등기원인이 있을 것으로 추정될 수는 없다[98다29568]. 또한 등기절차가 적법하게 진행되지 않은 것으로 볼만한 의심스러운 사정이 있음이 입증되는 경우에는 그 추정력은 깨어진다[2002다46256].

(5) 권리변동 당사자 사이에 추정력 인정여부

① 일반적으로 등기의 추정력은 제3자에 대한 관계에서 뿐만 아니라, 권리변동의 당사자 사이에도 미친다는 것이 판례의 태도이다. 즉, 소유권이전등기가 경료되어 있는 경우에는 그 등기명의인은 제3자에 대하여 뿐만 아니라 그 전소유자에 대하여서도 적법한 등기원인에 의하여 소유권을 취득한 것으로 추정한다(대판 1992.4.24, 91다26379). 따라서 소유권이전등기가 경료된 경우 전소유자가 등기의 효력을 부인하고 소유권이전등기의 말소절차의 이행을 구하려면 전소유자가 그 무효사실을 주장하고 이를 입증하여야 한다.

② 소유권보존등기(保存登記)의 추정력

㉠ 소유권보존등기는 그 등기명의인에게 소유권이 진실하게 보존되어 있다는 사실(원시취득)에 관하여만 추정력이 있고, 권리변동사실은 추정되지 않는다.

㉡ 따라서 보존등기명의인이 원시취득자가 아니라는 점이 증명되면 그 보존등기의 추정력은 깨어진다[96다16247]. 즉, 건물의 보존등기는 그 명의자가 신축한 것이 아니라는 것이 드러난 경우, 그 보존등기명의인 외의 자가 당해 토지를 사정(査定)받은 것으로 밝혀진 경우, 보존등기명의자가 보존등기 전의 소유자로부터 소유권을 양도받았다고 주장하고 전소유자가 보존등기명의자에의 양도사실을 부인하는 경우에는 그 추정력이 깨어진다[79다1200].

(6) 특별조치법상의 등기

구 「임야소유권이전등기 등에 관한 특별조치법」, 「부동산소유권이전등기 등에 관한 특별조치법」 등에 의한 등기는 관공서의 관여하에 절차와 요건을 엄격히 하고 있으므로 이러한 등기에는 좀 더 강한 추정력을 인정한다. 따라서 등기절차상 첨부된 서면(보증서, 확인서 등)의 허위 또는 위조된 사실을 입증하여야 추정력이 깨어진다(대판 1987.10.13., 86다카2928).

제 4 절 물권의 소멸

1. 목적물의 멸실

명문규정은 없지만 물건이 멸실하면 그에 관한 물권도 당연히 소멸한다. 다만, 질권, 저당권은 목적물이 멸실되더라도 가치적 변형물(보험청구권 · 손해배상청구권 등)이 남아 있으면 의물상대위에 의해 그 변형물에 권리가 존속한다.

2. 소멸시효의 완성

점유권과 유치권, 질권, 저당권 등의 담보물권은 점유 또는 피담보채권에 의존하므로 성질상 소멸시효에 걸리지 않고 소멸시효의 대상이 되는 물권은 지상권, 지역권, 전세권뿐이다.

3. 물권의 포기

물권의 포기란 물권자가 일방적 의사표시로써 자기의 물권을 절대적으로 소멸시키는 것을 말한다. 소유권 · 점유권의 포기는 상대방 없는 단독행위이나 제한물권의 포기는 직접 이익을 얻는 자에 대하여 하는 상대방 있는 단독행위로 등기를 요한다.

4. 공용징수

공용징수로 인하여 수용자가 물권을 취득하면 이는 원시취득이므로 이로 인하여 그 목적물 위에 존재하던 권리는 모두 소멸하는 것이 원칙이다.

5. 혼동(混同)

(1) **의의** : 혼동이란 서로 대립하는 두 개의 법률적 지위 또는 자격이 동일인에게 귀속하는 것을 말한다. 민법은 혼동을 물권 · 채권의 공통된 소멸원인으로 규정하고 있으나 일정한 예외(제191조)가 인정된다. 혼동의 법적성질은 사건에 속한다.

(2) **소유권과 제한물권의 혼동**

① 원칙

> **제191조(혼동으로 인한 물권의 소멸)** ① 동일한 물건에 대한 소유권과 다른 물권(제한물권)이 동일한 사람에게 귀속한 때에는 다른 물권(제한물권)은 소멸한다.

예컨대, 甲의 토지에 지상권을 가진 乙이 그 토지의 소유권을 취득하면, 乙은 동일한 토지에 지상권과 소유권을 가지게 되는데 이 경우 지상권은 혼동으로 소멸한다.

② 예외

> **제191조(혼동으로 인한 물권의 소멸)** 그러나 그 물권(제한물권)이 제3자의 권리의 목적이 된 때에는 소멸하지 아니한다.

㉠ **제한물권이 제3자의 권리의 목적인 때** : 乙이 甲의 토지에 대해 지상권을 가지고 있고 그 지상권이 丙의 저당권의 목적인 경우에는 乙이 그 토지의 소유권을 취득하더라도 乙의 지상권은 소멸하지 않는다.

㉡ **본인의 이익을 위한 경우** : 예컨대, 甲소유토지에 乙이 1번저당권을, 丙이 2번저당권을 갖고 있는 경우에 乙이 甲소유의 토지소유권을 취득한 경우라도 乙 본인 이익을 위해 乙의 1번저당권은 소멸하지 않는다. 같은 이유로 甲의 부동산에 乙이 임차권을 가지고 있고, 그 임차권이 대항요건을 갖춘 후에 丙의 저당권이 설정된 때에는 임차인 乙이 甲소유부동산을 매수하여 그 소유권을 취득하여도 乙의 임차권은 혼동으로 소멸하지 않는다.

(3) 제한물권과 그 제한물권을 목적으로 하는 다른 제한물권의 혼동

① 원칙

> **제191조(혼동으로 인한 물권의 소멸)** ② 전항의 규정은 소유권 이외의 물권과 그를 목적으로 하는 다른 권리가 동일한 사람에게 귀속한 경우에 다른 권리는 소멸한다.

예컨대, 甲소유토지에 乙이 지상권을 취득하고, 그 지상권에 대해 저당권을 가진 丙이 지상권을 취득하면 丙의 저당권은 혼동으로 소멸한다.

② 예외

㉠ **혼동된 권리가 제3자의 권리의 목적인 때** : 예컨대 지상권을 목적으로 하는 저당권에 대한 질권자가 있는 경우에는 저당권자가 지상권을 취득하더라도 제3자인 질권자의 이익을 위해 저당권은 혼동으로 소멸하지 않는다.

㉡ **본인의 이익을 위한 경우** : 예컨대 지상권에 대한 甲의 저당권보다 후순위의 저당권자 乙이 있는 경우에는 선순위저당권자인 甲이 지상권을 취득하더라도 본인의 이익을 위해 甲의 저당권은 혼동으로 소멸하지 않는다.

(4) 혼동으로 소멸하지 않는 물권

① **점유권** : 점유권은 사실상의 지배를 내용으로 하고 본권인 소유권 · 제한물권은 법률상의 지배를 내용으로 하여 양자는 양립할 수 있으므로 점유권은 혼동으로 소멸하지 않는다(제191조 제3항). 따라서 甲소유 토지를 乙이 점유하고 있던 중 乙이 甲을 단독으로 상속한 경우 乙의 점유권은 소멸하지 않는다.

② **광업권** : 광업권은 광물의 채굴 · 취득을 목적으로 하고 토지소유권은 지표의 이용을 목적으로 하여 양자는 양립할 수 있으므로 광업권은 혼동으로 소멸하지 않는다.

(5) 효 과

원칙적으로 동산 · 부동산 구별없이 물권은 혼동으로 소멸하는데 혼동된 물권의 소멸은 절대적이어서 혼동으로 소멸한 권리는 회복되지 않는다. 그러나 혼동을 생기게 한 원인행위가 불성립 · 무효 · 취소 · 해제로 인해 효력이 없는 때에는 혼동으로 소멸한 물권은 원래의 상태로 회복된다. 따라서 근저당권자가 소유권을 취득하면 그 근저당권은 혼동에 의해 소멸하지만 그 뒤 그 소유권취득이 무효임이 밝혀지면 소멸했던 근저당권은 부활한다[71다1386].

CHAPTER

03 점유권(占有權)

제 1 절 총 설

Ⅰ 점유(占有)의 개념

1. 사실상 지배(객관적 요건)

제192조(점유권의 취득과 소멸) ① 물건을 사실상 지배하는 자는 점유권이 있다.

① 의의

물건에 대한 점유란 사회관념상 어떤 사람의 사실적 지배에 있다고 보여지는 객관적 관계를 말하는 것이다[98다20110]. 사실상의 지배가 있다고 하기 위해서는 반드시 물건을 물리적 · 현실적으로 지배할 필요는 없고, 물건과 사람과의 시간적 · 공간적 관계와 본권관계, 타인의 간섭가능성 등을 고려하여 사회관념에 따라 합목적적으로 판단하여야 한다.

② 구체적 검토

㉠ 사회통념상 건물은 그 부지를 떠나서는 존재할 수 없으므로 건물의 부지가 된 토지는 건물의 소유자가 점유하는 것이고, 이 경우 건물의 소유자가 현실적으로 건물이나 그 부지를 점거하고 있지 않다 하더라도 건물의 소유를 위하여 그 부지를 점유한다고 보아야 한다. 또한 건물의 공유자 1인이 건물을 점유하고 있더라도 그 건물부지는 건물 소유를 위해 공유자들이 공동으로 점유하고 있는 것으로 보아야 한다[2006다39157].

㉡ 한편 특별한 사정이 없는 한 건물의 소유자가 아닌 자는 실제 건물을 점유하고 있다 하더라도 그 부지를 점유하는 자로 볼 수 없다. 그러나 미등기건물을 양수하여 건물에 대한 사실상의 처분권을 보유한 양수인은 그 건물부지의 점유자이다[2006다39157].

㉢ 대지의 소유자로 등기한 자는 보통의 경우 등기할 때에 그 대지의 인도를 받아 점유를 얻은 것으로 보아야 할 것이다[98다20110]. 그러나 소유권보존등기는 이전등기와 달리 해당 토지의 양도를 전제로 하는 것이 아니어서, 보존등기를 마쳤다고 하여 일반적으로 등기명의자가 그 무렵 다른 사람으로부터 점유를 이전받는다고 볼 수는 없다[2012다201410].

2. 점유설정의사(주관적 요건)

사실상의 지배가 성립하기 위하여는 사실적 의사로서 점유설정의사가 필요하다. 점유설정의사(사실적 지배의사)는 사실행위에 의한 점유의 취득요건(점유권의 성립요건)이나 존속요건은 아니다.

Ⅱ 점유의 관념화(觀念化)

1. 의 의

사실상 지배를 함에도 점유가 인정되지 않는 경우(점유보조자의 점유, 제195조)와 사실적 지배가 없음에도 점유의 성립이 인정되는 [간접점유(제194조), 상속에 의한 점유(제193조)] 것을 점유가 관념화 되었다고 한다.

2. 점유보조자(占有補助者)

제195조(점유보조자) 가사상, 영업상 기타 유사한 관계에 의하여 타인의 지시를 받아 물건에 대한 사실상의 지배를 하는 때에는 그 타인만을 점유자로 한다.

(1) 의 의

점유보조자란 가사상, 영업상 기타 유사한 관계에 의하여 타인의 지시를 받아 물건에 대한 사실상의 지배를 하는 자를 말하며, 물건에 대하여 직접적으로 실력을 행사하면서도 점유를 인정받지 못하는 자이다.

(2) 점유보조자의 지위

① 점유보조자는 점유권을 갖지 못하므로 점유주(占有主)만이 점유자이다(제195조). 따라서 점유권이나 점유보호청구권의 주체나 상대방 자격이 없다[76다1588].

② 다만, 점유보조자는 점유주의 점유를 위하여 자력구제권(제209조)을 행사할 수 있다고 한다.

3. 간접점유(間接占有)

(1) 의 의

제194조(간접점유) 지상권, 전세권, 질권, 사용대차, 임대차, 임치 기타의 관계로 타인으로 하여금 물건을 점유하게 한 자는 간접으로 점유권이 있다.

① **간접점유란 물건을 사실상 지배하고 있지 않음에도 불구하고** 타인의 점유를 매개로 하여 점유하는 관념화된 점유를 말한다.

② 예컨대, 甲의 건물에 대하여 갑과 을이 임대차계약을 맺고 을이 현실적으로 점유·사용하는 경우라도 갑은 약정에 따른 반환청구권이 있기 때문에 甲은 그 건물을 사실상 乙을 통해서 간접적으로 지배하고 있다고 보아야 한다. 이러한 경우에 임차인인 乙을 직접점유자, 임대인인 甲을 간접점유자라 한다.

(2) **성립요건**

① 직접점유자의 타주점유

간접점유자에 대해 일정한 법률관계를 가진 직접점유자가 물건을 사실상 지배해야 하며 그 점유는 타주점유여야 한다.

② 점유매개관계의 존재

㉠ 간접점유자와 직접점유자 사이에는 지상권 · 전세권 · 질권 · 사용대차 · 임대차 · 임치 기타의 관계가 있어야 하는데 이를 점유매개관계라 한다.

㉡ 점유매개관계가 있기 위해서는 간접점유자가 직접점유자에 대하여 점유매개관계에 기한 반환청구권을 가져야 한다.

㉢ 점유매개관계는 반드시 유효할 법률관계이어야 할 필요는 없고, 중첩적으로 있을 수 있다. 예컨대, 乙이 甲로부터 임차한 건물을 甲의 동의 없이 丙에게 전대한 경우에, 丙이 직접점유자이고 甲과 乙은 모두 간접점유자이다.

(3) **간접점유자의 지위**

① 간접점유자도 점유권을 가진 점유자이다. 따라서 점유에 관한 규정은 원칙적으로 간접점유자에게 적용된다.

② 간접점유자도 점유자이므로 점유보호청구권(점유권에 기한 물권적 청구권)의 주체와 상대방이 될 수 있다(제207조). 즉, 직접점유자가 제3자에 의해 그 점유를 침탈당하거나 방해당하고 있는 경우에 간접점유자는 반환이나 방해배제를 청구할 수 있다.

제 2 절 점유의 모습(점유의 태양)

Ⅰ 자주점유와 타주점유

1. 의 의

① '자주점유'란 소유의 의사를 가지고 하는 점유를 말하고, '타주점유'란 소유의 의사 없이 하는 점유를 말한다.

② '소유의 의사'란 소유자와 동일한 지배를 하려는 의사를 가지고 하는 점유를 의미하는 것이지 법률상 그러한 지배를 할 수 있는 권원, 즉 소유권을 가지고 있거나 또는 소유권이 있다고 믿고서 하는 점유를 의미하는 것은 아니다[96다23719].

③ 예를 들면 매수인의 점유는 자주점유이나 임차인이나 전세권자의 점유는 타주점유이다.

2. 판단기준과 판단시점

(1) 판단기준

① 자주점유인지 타주점유인지 여부는 점유자의 내심의 의사에 의해 결정되는 것이 아니라 점유취득의 원인이 된 권원의 성질이나 점유와 관계가 있는 모든 사정에 의해 외형적·객관적으로 결정되어야 한다[95다28625전합].

② 예컨대, 매수인의 점유가 자주점유인 이유는 매수인의 내심의 의사에 의해 판단하는 것이 아니라 매수인이 점유를 하게 된 권원인 매매에 의하여 객관적으로 판단하기 때문이고, 전세권자의 점유가 타주점유인 것은 전세권자가 점유를 하게 된 권원이 전세권설정계약이기 때문이다.

③ 매매나 증여 등을 자주점유의 권원이라 하고, 지상권설정계약, 전세권설정계약, 임대차 등을 타주점유의 권원이라 한다.

(2) **판단시점** : 점유개시 당시를 기준으로 판단한다[95다40328]. 따라서 부동산을 매수하여 이를 점유하게 된 자는 특단의 사정이 없는 한 그 점유의 시초에 소유의 의사로 점유한 것이며, 나중에 매도자에게 처분권이 없었다는 등의 사유로 그 매매가 무효인 것이 밝혀졌다 하더라도 그와 같은 점유의 성질이 변하는 것은 아니다[95다40328].

3. 자주점유의 추정

제197조(점유의 태양) ① 점유자는 소유의 의사로 선의, 평온 및 공연하게 점유한 것으로 추정한다.

(1) **점유권원이 불분명할 경우** : 부동산의 점유권원의 성질이 분명하지 않을 때에는 민법 제197조 제1항에 의하여 점유자는 소유의 의사(자주)로 평온·공연 및 선의로 점유한 것으로 추정되는 것이다[2005다33541].

(2) 추정의 효과

① 점유자가 스스로 그 점유권원의 성질에 의한 자주점유임을 입증할 책임이 없고, 점유자의 점유가 소유의 의사 없는 타주점유임을 주장하는 상대방에게 타주점유에 대한 입증책임이 있다[98다10618].

② 점유자가 스스로 매매 또는 증여와 같은 자주점유의 권원을 주장하였으나 이것이 인정되지 않는 경우에도 원래 이와 같은 자주점유의 권원에 관한 입증책임이 점유자에게 있지 아니한 이상 자주점유의 추정이 번복된다거나 또는 점유권원의 성질상 타주점유라고는 볼 수 없다.[82다카1792,1793 전합]

③ 지방자치단체나 국가가 취득시효의 완성을 주장하는 토지의 취득절차에 관한 서류를 제출하지 못하고 있다 하더라도 자주점유의 추정은 깨어지지 않는다.

4. 자주점유인 경우

① 점유자에게 추정되는 소유의 의사는 사실상 소유할 의사가 있는 것으로 충분하므로 등기를 수반하지 아니한 점유임이 밝혀졌다고 하여 이 사실만 가지고 바로 점유권원의 성질상 소유의 의사가 결여된 타주점유라고 할 수 없다[97다37661 全合].

② 물건을 매수하여 점유하고 있으나 매매가 무효인 것을 모르는 매수인의 점유는 자주점유이다.

③ 지상건물과 함께 그 대지를 매수 · 취득하여 점유를 개시함에 있어서 매수인이 인접토지와의 경계선을 정확하게 확인해 보지 않아 착오로 인접토지의 일부를 그가 매수 · 취득한 대지에 속하는 것으로 믿고 그 부분을 현실적으로 인도받아 점유하고 있다면 인접토지 부분에 대한 점유도 소유의 의사가 있는 자주점유라고 보아야 한다[99다5866].

④ 점유자의 승계인이 자기의 점유만을 주장하는 경우, 전 점유자의 점유가 타주점유라 하더라도 현 점유자의 점유는 자주점유로 추정된다[2006다8254].

5. 타주점유인 경우

① 직접점유자(지상권자 · 전세권자 · 임차인 등)의 점유는 타주점유이다.

② 명의신탁에 기해 토지의 소유자로 등기된 자(명의수탁자)의 점유는 권원의 성질상 자주점유라고 할 수 없다[97다38503].

③ 타인의 토지 위에 분묘를 설치 또는 소유하는 자(분묘기지권자)는 점유권원의 성질상 타주점유라고 할 것이다[91다24311].

④ 점유자가 점유개시 당시에 소유권취득의 원인이 될 수 있는 법률행위 기타 법률요건이 없이 그와 같은 법률요건이 없다는 사실을 잘 알면서 타인소유의 부동산을 무단점유한 것임이 입증된 경우에도 특별한 사정이 없는 한 소유의 의사가 있는 점유라는 추정은 깨어진다[97다37661 전합].

⑤ 매매대상 토지의 면적이 공부상 면적을 상당히 초과하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 계약 당사자들이 이러한 사실을 알고 있었다고 보는 것이 상당하고, 그 초과 부분은 권원의 성질상 타주점유에 해당한다[2006다49512].

⑥ 공유토지는 공유자 1인이 그 전부를 점유하고 있다고 하여도 다른 특별한 사정이 없다면 다른 공유자의 지분비율의 범위 내에서는 타주점유라고 볼 수밖에 없다[95다53768].

⑦ 점유자가 진정한 소유자라면 통상 취하지 아니할 태도를 나타내거나 소유자라면 당연히 취했을 것으로 보이는 행동을 취하지 아니한 경우 등 외형적 · 객관적으로 보아 점유자가 타인의 소유권을 배척하고 점유할 의사를 갖고 있지 아니하였던 것이라고 볼 만한 사정이 증명된 경우에도 그 추정은 깨어지는 것이다[97다37661 전합].

6. 자주점유 · 타주점유간의 전환

(1) 타주점유에서 자주점유로의 전환

① 타주점유가 자주점유로 전환하기 위하여는 새로운 권원에 의해 다시 소유의 의사로 점유하거나 자기에게 점유시킨 자에게 소유의 의사가 있음을 표시해야 한다[94다50595]. 예컨대, 타주점유자인 임차인이 그 임차목적물을 매수하여 계속 점유하고 있다면 자주점유로 전환된다.

② 그러나 타주점유자가 그 명의로 소유권이전등기를 경료하였다 하여 그것만으로 소유의 의사를 표시하여 자주점유로 전환되었다고 볼 수 없다[92다51723].

(2) 자주점유에서 타주점유로의 전환

① 부동산을 타인에게 매도하여 그 인도의무를 지고 있는 매도인의 점유는 특별한 사정이 없는 한 타주점유로 전환된다[2003다16528].

② 경락에 의한 소유권이전등기가 있으면 종전 소유자는 경락인에게 경락부동산을 인도할 의무가 있으므로 종전소유자의 점유는 자주점유에서 타주점유로 전환된다.

③ 부동산매매에서 매수인이 그 목적물을 점유하고 있는 중에 매매계약이 해제되면 매수인의 점유는 타주점유가 된다.

보충학습

1. 토지의 점유자가 이전에 소유자를 상대로 그 토지에 관하여 소유권이전등기말소절차의 이행을 구하는 소를 제기하였다가 패소판결이 확정되었다는 사정만으로는 토지점유자의 자주점유의 추정이 번복되어 타주점유로 전환된다고 할 수 없다[98다63018]. 다만, 패소한 점유자는 그 소 제기시 부터는 토지에 대한 악의의 점유자로 간주된다.
2. 진정 소유자가 점유자명의의 소유권이전등기는 원인무효의 등기라 하여 점유자를 상대로 토지에 관한 점유자명의의 소유권이전등기의 말소등기청구소송을 제기하여 그 소송사건이 점유자의 패소로 확정되었다면, 점유자는 그 소송의 제기시부터는 토지에 대한 악의의 점유자로 간주되고, 또 패소판결확정 후부터는 타주점유로 전환되었다고 보아야 할 것이다[2000다14934,14941].

Ⅱ 선의점유와 악의점유

1. 의 의

'선의의 점유'란 점유할 권리, 즉 본권(소유권, 지상권, 전세권, 임차권)이 없음에도 불구하고 본권이 있다고 오신하면서 하는 점유를 말한다. 반면 '악의의 점유'는 점유할 권원이 없음을 알면서 하는 점유하거나 점유할 권리의 유무에 대하여 의심을 품으면서 하는 점유를 말한다.

2. 선의점유의 추정

① 점유자는 선의로 점유한 것으로 추정한다. 권원 없는 점유였음이 밝혀졌다고 하여 그 동안의 점유에 대한 선의의 추정이 깨어졌다고 볼 수 없다[99다63350].

② 그러나 선의의 점유자라도 본권에 관한 소에 패소한 때에는 그 소가 제기된 때로부터 악의의 점유자로 본다(제197조 제2항). 따라서 그 소제기일 부터는 점유를 악의로 의제하여 부당이득의 반환을 명하여야 한다[2001다6213].

Ⅲ 과실(過失) 있는 점유, 과실(過失) 없는 점유

1. 의 의

선의점유를 전제로 점유할 권리, 즉 본권이 있다고 오신하는데 과실이 있는 경우가 과실 있는 점유이고, 오신하는데 과실이 없는 점유가 과실 없는 점유이다.

2. 무과실 추정 여부

제197조에 의하면 점유의 무과실은 추정되지 않는다. 따라서 등기부취득시효에 있어서는 점유의 개시에 과실이 없었음을 필요로 하고 위와 같은 무과실에 대하여는 그 주장자에게 입증책임이 있는 것이다[92다30245].

3. 구별실익

취득시효의 기간(제245조 제1항 점유취득시효+20년, 제2항 등기부취득시효+10년+선의·무과실, 제246조 제1항 10년, 제2항 선의·무과실+5년), 선의취득(제249조 선의·무과실) 등에서 차이가 있다.

Ⅳ 하자 있는 점유, 하자 없는 점유

하자 있는 점유란 악의(惡意)·과실(過失)·강폭(强暴)·은비(隱秘)·불계속(不繼續) 등의 요건 중 하자가 하나라도 있는 점유를 말하는데 폭력 또는 은비에 의한 점유는 과실취득에 있어 악의의 점유자로 취급된다(제201조 제3항). 하자 없는 점유란 선의, 무과실, 평온, 공연, 계속 등의 요건을 모두 갖춘 점유를 말한다.

제 3 절 점유의 승계

Ⅰ 특정승계의 효과

제199조(점유의 승계의 주장과 그 효과) ① 점유자의 승계인은 자기의 점유만을 주장하거나 자기의 점유와 전점유자의 점유를 아울러 주장(점유의 병합)할 수 있다.
② 전 점유자의 점유를 아울러 주장(점유의 병합)하는 경우에는 그 하자도 계승한다.

① 점유자의 승계인은 자기의 점유만을 주장하거나(점유의 분리) 자기의 점유와 전 점유자의 점유를 동시에 주장(점유의 병합)할 수 있다(제199조 제1항).

② 여기서 전 점유자란 그 직전의 점유자에 한하는 것이 아니라 현 점유에 앞서는 모든 점유자를 포함한다. 그리고 점유자가 그 직전 점유자의 점유를 주장하거나 그 전점유자의 점유를 아울러 주장하는 것은 자유지만, 이 경우에도 그 점유시초를 전 점유자의 점유기간 중의 임의시점을 택하여 주장할 수 없다.

③ 점유자의 승계인이 전 점유자의 점유를 아울러 주장하는 경우에는 그 하자까지도 승계하게 된다(제199조 제2항). 즉, 전 점유자가 타주점유이면 승계인도 타주점유가 된다.

④ 그러나 점유의 승계가 있는 경우 전 점유자의 점유가 타주점유라 하여도 점유자의 승계인이 자기의 점유만을 주장하는 경우에는 현 점유자의 점유는 여전히 자주점유로 추정된다[99다72743]. 따라서 상대방에게 타주점유에 대한 입증책임이 있다.

Ⅱ 점유권상속의 효과

① 점유 자체가 이전하는 것이 아니라 점유에 관한 피상속인의 법적 지위가 상속인에게 승계되는 것이다. 따라서 상속인이 현실적으로 점유하거나 상속개시사실을 알 필요도 없다.

② 상속에 의해 점유권을 취득한 경우에는 상속인은 피상속인의 점유를 떠나 자기만의 점유를 주장할 수 없다. 따라서 상속인은 피상속인의 점유의 성질과 하자를 그대로 승계하므로 상속은 타주점유가 자주점유로 전환되기 위한 새로운 권원이 아니다[70다2755].

③ 다만, 상속인이 새로운 권원(매매 · 교환 · 경매 등)에 의해 자기 고유의 점유를 개시한 경우에는 자기의 점유만을 주장할 수 있다.

제 4 절 점유권의 효력

Ⅰ 점유의 추정적 효력

1. 점유태양의 추정

① 점유자는 소유의 의사로 선의 · 평온 및 공연하게 점유한 것으로 추정한다(제197조 제1항). 다만, 무과실은 추정되지 않는다.

② 선의의 점유자라도 본권에 관한 소에서 패소한 때에는 그 소가 제기될 때로부터 악의의 점유자로 본다(제197조 제2항).

2. 점유계속의 추정

제198조(점유계속의 추정) 전후 양시에 점유한 사실이 있는 때에는 그 점유는 계속한 것으로 추정한다.

점유계속추정은 동일인이 전후 양 시점에 점유한 것이 증명된 때에만 적용되는 것이 아니고 전후 양 시점의 점유자가 다른 경우에도 "점유의 승계가 입증"되는 한 점유계속은 추정된다[96다24279].

3. 점유의 권리추정력

(1) 의 의

제200조(권리의 적법의 추정) 점유자가 점유물에 대하여 행사하는 권리는 적법하게 보유한 것으로 추정한다.

점유자가 점유물에 대하여 행사하는 권리는 적법하게 보유하는 것으로 추정되는데, 예컨대 소유자로서 점유하는 자는 적법한 소유권이 있는 것으로 추정되고, 임차인으로서 점유하는 자는 적법한 임차권이 있는 것으로 추정되는 것을 말한다.

(2) 부동산에 적용여부

판례는 점유자의 권리추정의 규정은 특별한 사정이 없는 한 부동산물권에 대하여는 적용되지 아니한다고 한다[81다780]. 왜냐하면 점유는 동산의 공시방법이고, 부동산에는 등기의 추정력이 적용되기 때문이다.

Ⅱ 점유자와 회복자의 관계

1. 서 설

(1) 본권에 기하여 타인의 물건을 점유하던 자(전세권자, 임차인 등)가 그 물건을 반환하는 경우에 당사자 사이의 관계는 본권을 발생시킨 법률관계에 따라 청산되어야 한다. 그러나 당사자간에 기본적 법률관계가 부존재하거나 무효 또는 취소인 경우에 소유자(회복자)와 본권 없는 점유자 사이의 이해관계의 조절은 불법행위 또는 부당이득법리에 의하여야 할 것이지만 민법은 선의 점유자를 보호하기 위한 특칙으로 제201조 내지 제203조를 규정하고 있다.

(2) 이때 문제되는 것은 첫째 점유자가 점유 중에 취득한 과실을 취득할 수 있는지, 둘째 점유물의 멸실·훼손에 대하여 어느 정도 책임을 지는지, 셋째 점유자가 점유물에 지출한 비용은 본권자에 대하여 상환을 청구할 수 있는지 등이 있다.

2. 점유자의 과실취득 여부

(1) 선의점유자의 과실취득권(果實取得權)

제201조(점유자와 과실) ① 선의의 점유자는 점유물의 과실을 취득한다.

① 선의점유자의 의미

여기서 '선의의 점유자'라 함은 과실수취권을 포함하는 권원(소유권, 지상권, 전세권, 임차권 등)이 있다고 오신한 점유자를 말하고, 그와 같은 오신을 함에는 오신할 만한 정당한 근거(선의+무과실)가 있어야 한다[99다63350].

② 점유물의 '과실'취득

㉠ 과실은 천연과실, 법정과실 모두 포함하며, 물건의 사용이익도 이에 해당한다.

㉡ 선의의 점유자는 과실을 취득할 수 있는 범위 내에서 부당이득은 성립하지 않는다. 따라서 과실취득으로 인한 이득을 반환할 필요가 없다[95다44290].

㉢ 쌍무계약(매매계약)이 취소된 경우 선의의 매수인에게 민법 제201조가 적용되어 과실취득권이 인정되는 이상 선의의 매도인에게도 민법 제587조의 유추적용에 의하여 대금의 운용이익 내지 법정이자의 반환을 부정함이 형평에 맞다[92다45025].

③ 불법행위로 인한 손해배상책임 여부

선의의 점유자로서 그 과실(果實)을 취득할 권리가 있다 하더라도, 점유에 과실(過失)이 있다면, 불법행위로 인한 손해배상책임이 배제되는 것은 아니다[66다994].

④ 계약이 해제된 경우 적용여부

매매계약이 해제된 경우, 당사자는 선의 · 악의를 불문하고 원상회복의무를 부담하므로 선의의 매수인은 과실도 매도인에게 반환해야 한다[97다30066]. 즉, 계약해제의 경우에는 적용되지 않는다.

(2) **악의 점유자의 과실반환의무**

① 의의

㉠ 악의의 점유자는 수취한 과실을 반환하여야 하며 소비하였거나 과실(過失)로 인하여 훼손 또는 수취하지 못한 경우에는 그 과실의 대가를 보상하여야 한다(제201조 제2항).

㉡ 악의의 점유자라도 과실(過失) 없이 훼손 또는 수취하지 못한 경우에는 그 과실의 대가를 보상할 필요가 없다.

㉢ 악의의 점유자는 받은 이익에 이자를 붙여 반환하여야 하며, 그 이자의 이행지체로 인한 지연손해금도 지급하여야 한다[2001다61869].

② 악의의 점유자의 범위

㉠ 선의의 점유자라도 본권에 관한 소에 패소한 때에는 그 소가 제기된 때로부터 악의의 점유자로 본다(제197조 제2항). 따라서 소제기 이후의 과실을 반환하여야 한다.

㉡ 폭력 또는 은비에 의한 점유자도 악의의 점유자와 마찬가지로 과실을 반환하여야 한다(제201조 제3항).

3. 점유물의 멸실 · 훼손에 대한 책임

제202조(점유자의 회복자에 대한 책임) 점유물이 점유자의 책임있는 사유로 인하여 멸실 또는 훼손한 때에는 악의의 점유자는 그 손해의 전부를 배상하여야 하며 선의의 점유자는 이익이 현존하는 한도에서 배상하여야 한다. 소유의 의사가 없는 점유자는 선의인 경우에도 손해의 전부를 배상하여야 한다.

(1) **의 의** : 점유물이 점유자의 책임 있는 사유(고의 · 과실)로 인해 멸실 또는 훼손한 때에 점유자는 회복자에 대해 어떤 책임을 지는가의 문제이다. 멸실은 물리적 멸실뿐만 아니라 점유물을 선의의 제3자에게 양도하여 그 반환이 불가능하게 된 경우도 포함한다.

(2) **선의 · 자주 점유자의 책임**

점유자가 선의이며 자주점유인 경우에는 이익이 현존하는 한도 내에서 배상하여야 한다(제202조).

(3) **악의 또는 타주 점유자인 경우**

점유자가 악의점유 또는 타주점유인 경우에는 손해의 전부를 배상하여야 한다.

4. 점유자의 비용상환청구권

(1) **서 설** : 점유자가 점유물을 반환할 때 점유물에 대하여 지출한 필요비나 유익비가 있는 경우에 이를 회복자에 대하여 상환을 청구할 수 있다(제203조). 이때 점유자는 선의 · 악의 또는 자주 · 타주점유의 구별 없이 비용상환청구권을 갖는다.

(2) 필요비 상환청구권

① 점유자가 점유물을 반환할 때에는 회복자에 대하여 점유물을 보존하기 위하여 지출한 금액 기타 필요비의 상환을 청구할 수 있다(제203조 제1항).

② 그러나 점유자가 선의의 점유자로서 과실을 취득한 경우에는 통상의 필요비는 청구하지 못한다(제203조 제1항 단서). 통상의 필요비는 통상적인 보존 관리비용(기계장치의 부품교체비용, 건물의 관리비나 공과 금 등)을 말하며, 다만, 점유자가 과실을 취득한 경우라도 특별필요비(태풍으로 인한 파손부분의 수선비 등)는 상환을 청구할 수 있다.

③ 악의의 점유자는 과실을 취득하지 못하므로 통상의 필요비도 청구할 수 있다.

(3) 유익비상환청구권

① 점유자가 점유물을 개량하기 위하여 지출한 금액 기타 유익비에 관하여는 그 가액의 증가가 현존한 경우에 한하여 회복자의 선택에 좇아 그 지출금액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다(제203조 제2항).

② 지출금액 및 현존증가액에 관한 증명책임은 유익비의 상환을 구하는 점유자에게 있다.

③ 유익비상환청구권의 경우에 법원은 회복자의 청구에 의하여 상당한 상환기간을 허여할 수 있다(제203조 제3항).

(4) 비용상환청구권의 행사

① 행사시기

점유자의 필요비 또는 유익비상환청구권은 점유자가 회복자로부터 점유물의 반환을 청구받은 때에 비로소 회복자에 대해 행사할 수 있는 상태가 되고 이행기가 도래한다[2009다5162]. 따라서 회복자(소유자)가 소유권이전등기의 말소만을 구하는 본건에 있어서는 그 유익비상환청구권으로써 동시이행 또는 유치권행사의 항변을 할 수 없다[76다172].

② 상대방

점유자는 그 비용을 지출할 당시의 소유자가 누구이었는지 관계없이 점유회복 당시의 소유자 즉, 현재의 회복자에 대하여 비용상환청구권을 행사할 수 있다. 따라서 무효인 매매계약의 매수인이 점유목적물에 필요비 등을 지출한 후 매도인이 그 목적물을 제3자에게 양도한 경우, 점유자인 매수인은 양수인에게 비용상환을 청구할 수 있다.

③ 유치권행사 여부

비용상환청구권은 물건에 관하여 생긴 채권이므로 불법행위로 인한 점유가 아닌 경우 점유자는 그 상환을 받을 때까지 점유물에 대하여 유치권을 행사 할 수 있다. 그러나 유익비상환청구의 경우에 회복자가 법원으로부터 상환기간을 허여 받은 때에는 유익비에 관한 유치권을 성립시킬 수 없다.

(5) 제203조(비용상환청구권)의 적용범위

① 민법 제203조에 의한 점유자의 회복자에 대한 비용상환청구권은 점유자가 계약관계 등 적법하게 점유할 권리를 가지지 않아 소유자의 소유물반환청구에 응하여야 할 의무가 있는 경우에 성립되는 것이다[2001다64752].

② 반면, 점유자가 비용을 지출할 당시 계약관계 등 적법한 점유의 권원을 가진 경우에 그 지출비용의 상환에 관하여는 그 계약관계를 규율하는 법조항이나 법리(전세권의 제310조, 임대차의 제626조 등) 등이 적용되는 것이고 제203조는 적용되지 않는다[2001다64752].

제 5 절 점유의 보호

Ⅰ 점유보호청구권

1. 의 의

① 점유보호청구권이란 점유의 침해나 침해의 염려가 있는 경우에 본권의 유무와는 관계없이 점유 그 자체의 보호를 위하여 인정되는 일종의 물권적 청구권을 말한다.

② 자력구제가 원칙적으로 금지되는 법제에서 점유보호청구권을 통해 불법침해로부터 점유를 보호하는 것이 사회평화의 유지라는 점유권 인정취지에 부합하기 때문에 인정된다.

2. 점유회수청구권(점유물반환청구권)

(1) 의 의

① 점유자가 점유의 침탈을 당한 때에는 그 물건의 반환 및 손해의 배상을 청구할 수 있다(제204조 제1항).

② 침탈자의 고의나 과실은 점유물반환청구의 요건이 아니다. 다만, 점유의 침탈을 이유로 손해배상을 청구하기 위해서는 침탈자에게 고의나 과실이 있어야 한다.

(2) 점유의 침탈(侵奪)

① 점유의 '침탈'이란 점유자가 그의 의사에 의하지 않고서 점유를 빼앗기는 것을 말한다. 절취 · 강도를 당한 것, 위법한 강제집행에 의하여 물건의 인도를 받은 것은 점유의 침탈에 해당한다[62다919].

② 그러나 사기나 유실물을 습득한 경우 등은 점유의 침탈에 해당하지 않으므로 점유물반환청구권을 행사할 수 없다.

③ 간접점유관계가 있는 경우 점유의 침탈여부의 판단기준이 되는 자는 직접점유자이다. 따라서 직접점유자가 임의로 타인에게 점유를 양도한 경우에 점유이전이 간접점유자의 의사에 반한다 하더라도 간접점유자의 점유가 침탈된 경우에 해당하지 않는다[92다5300]. 예를 들면 甲이 乙에게 빌려준 동산을 乙이 임의로 丙에게 매도하여 양도한 경우 甲은 丙에게 점유물반환청구를 행사할 수 없다.

(3) 청구권자

① 청구권자는 점유물을 침탈당한 점유자이며, 자주점유자든 타주점유자든 또는 직접점유자이든 간접점유자이든 상관없다.

② 다만, 간접점유자는 그 물건을 직접점유자에게 반환할 것을 청구할 수 있고, 직접점유자가 그 물건의 반환을 받을 수 없거나 이를 원하지 아니하는 때에는 자기에게 반환할 것을 청구할 수 있다(제207조 제2항).

③ 상대방으로부터 점유를 위법하게 침탈당한 점유자가 상대방으로부터 점유를 탈환하였을 경우(이른바 '점유의 상호침탈'), 특별한 사정이 없는 한 상대방은 자신의 점유가 침탈당하였음을 이유로 점유자를 상대로 점유의 회수를 청구할 수 없다(2022다269675)

(4) 상대방

① 점유물반환청구의 상대방은 '침탈자' 또는 '침탈자의 포괄승계인'이다. 문제는 침탈자의 특별승계인인데 침탈자의 악의의 특별승계인에게는 점유물반환청구권을 행사할 수 있으나 선의의 특별승계인에게는 점유물반환청구권을 행사할 수 없다(제204조 제2항).

② 그리고 침탈자가 간접점유를 하고 있는 경우에는 직접점유자와 간접점유자가 모두 상대방이 되지만, 점유보조자는 상대방이 될 수 없고, 점유주를 상대로 행사하여야 한다.

(5) 제척기간(除斥期間)

① 점유물반환청구권은 침탈을 당한 날로부터 1년 내에 행사하여야 한다(제204조 제3항).

② 위의 기간은 제척기간이며, 반드시 그 기간 내에 소를 제기하여야 하는 이른바 출소기간으로 해석함이 상당하다[2001다8097,8103].

③ 그러나 민법 제204조 제3항은 본권 침해로 발생한 손해배상청구권의 행사에는 적용되지 않으므로 점유를 침탈당한 자가 본권인 유치권 소멸에 따른 손해배상청구권을 행사하는 때에는 점유를 침탈당한 날부터 1년 내에 행사할 것을 요하지 않는다[2021다213866].

④ 점유자가 제척기간 내에 점유물반환청구권을 행사하여 점유를 회수하면 점유권은 상실되지 않은 것으로 다루어진다(제192조 제2항 단서).

4. 점유보유청구권(점유물방해제거청구권)

(1) 의 의

① 점유자가 점유의 방해를 받은 때에는 그 방해의 제거 및 손해의 배상을 청구할 수 있다(제205조 제1항).

② 점유권에 의한 방해배제청구권(점유보유청구권)은 물건 자체에 대한 사실상의 지배 상태를 점유침탈 외의 방법으로 침해하는 방해행위가 있을 때 성립한다[86다카2942].

(2) 제척기간

① 원 칙

㉠ 위 청구권은 방해가 종료한 날로부터 1년 내에 행사하여야 한다(제205조 제2항).

㉡ 방해가 진행 중인 경우에는 언제든지 점유물방해제거청구권을 행사할 수 있고, 방해가 종료하면 방해제거라는 문제는 생기지 않으므로 1년의 제척기간은 손해배상의 청구에만 관련된다.

② 공사로 인한 방해

㉠ 공사로 인하여 점유의 방해를 받은 경우에는 공사착수 후 1년을 경과하거나 그 공사가 완성한 때에는 방해의 제거를 청구하지 못한다(제205조 제3항).

㉡ 공사착수 후 1년이 경과하거나 공사가 완성되어 방해제거청구를 할 수 없는 경우라도 건물의 철거는 청구할 수 없지만 방해종료일로부터 1년 내에는 손해배상청구를 할 수 있다.

5. 점유보전청구권(점유물방해예방청구권)

(1) 의 의

① 점유자가 점유의 방해를 받을 염려가 있는 때에는 그 방해의 예방 또는 손해배상의 담보를 청구할 수 있다(제206조 제1항).

② 주의할 점은 방해의 예방과 손해배상의 담보는 함께 행사하는 것이 아니라 양자 중 어느 하나를 선택적으로 행사할 수 있다는 점이다.

(2) **제척기간**

① 방해의 염려가 있는 동안에는 언제든지 방해의 예방 또는 손해배상의 담보를 청구할 수 있다.

② 다만, 공사로 인하여 점유의 방해를 받을 염려가 있는 경우에는 공사착수 후 1년을 경과하거나 또는 그 공사가 완공된 때에는 청구하지 못한다(제206조 제2항).

Ⅲ 자력구제권(自力救濟權)

1. 의 의

권리를 침해당한 자가 공권력에 의존하지 않고 스스로의 힘으로 침해된 권리를 구제하는 권리보전행위를 말한다.

2. 내 용

(1) **자력방위권(自力防衛權)**

점유자는 그 점유를 부정히 침탈 또는 방해하는 행위에 대하여 자력으로써 이를 방위할 수 있다(제209조 제1항).

(2) **자력탈환권(自力奪還權)**

점유물이 침탈되었을 경우에 부동산일 때에는 점유자는 침탈 후 직시 가해자를 배제하여 이를 탈환할 수 있고 동산일 때에는 점유자는 현장에서 또는 추적하여 가해자로부터 이를 탈환할 수 있다(제209조 제2항).

Ⅳ 점유의 소와 본권의 소의 관계

① 점유권에 기인한 소와 본권에 기인한 소는 서로 영향을 미치지 아니한다(제208조 제1항). 위 양 소권은 완전별개의 소권이라 할 것이므로 점유의 소와 본권의 소를 동시에 제기할 수도 있고 하나의 소가 패소로 확정된 후 다른 소를 제기할 수도 있다.

② 점유권에 기인한 소는 본권에 관한 이유로 재판하지 못한다(제208조 제2항). 따라서 점유자로부터 점유물반환청구의 소를 제기당한 소유자는 그 소송에서 방어방법으로 본권을 주장할 수 없다.

CHAPTER

04 소유권(所有權)

제 1 절 소유권의 범위

제211조(소유권의 내용) 소유자는 법률의 범위 내에서 그 소유물을 사용, 수익, 처분할 권리가 있다.

1. 토지소유권의 범위

① 토지의 소유권은 정당한 이익 있는 범위 내에서 토지의 상하에 미친다(제212조). 정당한 이익이 있는 범위 내에서 지표면(地表面)뿐만 아니라 지하와 지상공간을 포함한다.

② 지적법에 의하여 어떤 토지가 지적공부에 1필지의 토지로 등록되면 그 토지의 경계는 특별한 사정이 없는 한 토지소유권의 범위는 현실의 경계와 관계없이 지적공부상의 경계에 의해 확정된다. 다만 지적공부를 작성함에 있어 기술적인 착오로 말미암아 지적공부상의 경계가 진실한 경계선과 다르게 잘못 작성되었다는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 그 토지의 경계는 지적공부에 의하지 않고 실제의 경계에 의하여 확정된다.

(2) 토지의 포락(浦落)

① 의의

포락이라 함은 토지가 바닷물이나 하천법상의 하천의 물에 개먹어 무너져 바다나 하천에 떨어져 그 원상복구에 과다한 비용이 요하는 등으로 사회통념상 불가능한 상태에 이르렀을 때를 말한다[95다18659].

② 효과

한번 포락되어 토지로서의 효용을 상실하면 종전의 소유권이 영구히 소멸되고 그 후 포락된 토지가 다시 성토되어도 종전의 소유자가 다시 소유권을 취득할 수는 없다[92다24677].

2. 상린관계(相隣關係)

(1) 서 설

① 의의

인접하고 있는 부동산 상호간의 이용을 조절하기 위하여 민법의 규정에 의하여 규율되는 법률관계를 상린관계라고 한다. 상린관계로부터 발생하는 권리를 상린권이라고 하는데 독립한 물권이 아니고 소유권의 내용 자체이다.

② **적용범위** : 민법은 제216조 이하에서 부동산소유자 상호간에 관한 상린관계를 규율하고 있지만, 상린관계는 부동산 상호간의 이용의 조절이므로 소유권에 규정된 상린관계의 내용은 지상권(제290조), 전세권(제319조)에 준용되고, 통설은 토지임대차에도 유추적용한다.

③ **법적 성격** : 상린관계에 관한 규정이 강행규정인지, 임의규정인지에 관하여 견해가 대립하나 판례는 민법 제242조[62다567]와 민법 제244조는 강행규정이라고 볼 수 없고 이와 다른 내용의 당사자 특약을 무효라고 할 수 없다([80다1634])고 한다.

(2) 생활방해의 금지(Immission, 公害)

① 의 의

> **제217조(매연 등에 의한 인지에 대한 방해금지)** ① 토지소유자는 매연, 열기체, 액체, 음향, 진동 기타 이에 유사한 것으로 이웃토지의 사용을 방해하거나 이웃거주자의 생활에 고통을 주지 아니하도록 적당한 조처를 할 의무가 있다.

② 요건

매연, 열기체, 액체, 음향, 진동은 예시(例示)에 불과하므로 냄새, 가스, 먼지, 재, 유해광선, 방사선, 전류 등도 이에 해당될 수 있으나 매연 등은 적극적으로 방산되는 것이어야 한다.

③ 수인의무

> **제217조(매연 등에 의한 인지에 대한 방해금지)** ② 이웃거주자는 전항의 사태가 이웃토지의 통상의 용도에 적당한 것인 때에는 이를 인용할 의무가 있다.

④ 생활방해의 효과

제217조에 위반하여 타인에게 손해를 가한 때에는 불법행위책임(손해배상책임)을 질 수 있고, 이웃 토지소유자나 이웃거주자는 방해사유의 제거 내지 예방조치를 청구할 수 있다.

(3) 인지사용청구권(隣地使用請求權)

> **제216조(인지사용청구권)** ① 토지소유자는 경계나 그 근방에서 담 또는 건물을 축조하거나 수선하기 위하여 필요한 범위 내에서 이웃토지의 사용을 청구할 수 있다. 그러나 이웃사람의 승낙이 없으면 그 주거에 들어가지 못한다.
> ② 전항의 경우에 이웃사람이 손해를 받은 때에는 보상을 청구할 수 있다.

① 토지소유자는 당연히 인지(이웃)토지사용권을 갖는 것이 아니라 인지토지사용청구권이 있으므로, 만일 이웃 토지소유자가 승낙하지 않으면 승낙에 갈음하는 판결을 구하여야 한다.

② 그러나 이웃주거에 들어가려면 이웃사람의 승낙이 있어야 하고, 이웃사람의 승낙이 없으면 주거에 대해서는 판결로써 갈음하지 못한다.

(4) 수도(水道) 등의 시설권

제218조(수도 등 시설권) ① 토지소유자는 타인의 토지를 통과하지 아니하면 필요한 수도, 소수관(疏水管), 까스관, 전선 등을 시설할 수 없거나 과다한 비용을 요하는 경우에는 타인의 토지를 통과하여 이를 시설할 수 있다. 그러나 이로 인한 손해가 가장 적은 장소와 방법을 선택하여 이를 시설할 것이며 타토지의 소유자의 청구에 의하여 손해를 보상하여야 한다.
② 전항에 의한 시설을 한 후 사정의 변경이 있는 때에는 타토지의 소유자는 그 시설의 변경을 청구할 수 있다. 시설변경의 비용은 토지소유자가 부담한다.

이와 같은 수도 등 시설권은 법정의 요건을 갖추면 당연히 인정되는 것이고, 시설권에 근거하여 수도 등 시설공사를 시행하기 위해 따로 수도 등이 통과하는 토지 소유자의 동의나 승낙을 받아야 하는 것이 아니다. 따라서 토지 소유자의 동의나 승낙은 민법 제218조에 기초한 수도 등 시설권의 성립이나 효력 등에 어떠한 영향을 미치는 법률행위나 준법률행위라고 볼 수 없다[2015다247325].

(5) 주위토지통행권(周圍土地通行權)

① 유상통행권

㉠ **의의** : 어느 토지와 공로 사이에 그 토지의 용도에 필요한 통로가 없는 경우에 그 토지소유자는 주위의 토지를 통행 또는 통로로 하지 아니하면 공로에 출입할 수 없거나 과다한 비용을 요하는 때에는 그 주위의 토지를 통행할 수 있고 필요한 경우에는 통로를 개설할 수 있다. 그러나 이로 인한 손해가 가장 적은 장소와 방법을 선택하여야 한다(제219조 제1항).

㉡ **주체** : 민법 제219조에 정한 주위토지통행권은 인접한 토지의 상호이용의 조절에 기한 권리로서 토지의 소유자 또는 지상권자, 전세권자 등 토지사용권을 가진 자에게 인정되는 권리이다. 따라서 명의신탁자에게는 주위토지통행권이 인정되지 않는다[2007다22767].

㉢ 요건

ⓐ **기존 통로가 부적당한 경우** : 주위토지통행권은 어느 토지가 타인소유의 토지에 둘러싸여 공로에 통할 수 없는 경우뿐만 아니라[92다1025], 이미 기존의 통로가 있더라도 그것이 당해 토지의 이용에 부적합하여 실제로 통로로서의 충분한 기능을 하지 못하고 있는 경우에도 인정된다[2002다53469]. 그러나 이미 그 소유토지의 용도에 필요한 통로가 있는 경우에는 그 통로를 사용하는 것보다 더 편리하다는 이유만으로 다른 장소로 통행할 권리를 인정할 수 없다[95다1088].

ⓑ **공로 출입 불가 또는 과다비용** : 토지소유자는 주위의 토지를 통행 또는 통로로 하지 아니하면 공로에 출입할 수 없는 경우뿐만 아니라 과다한 비용을 요하는 때에도 그 주위의 토지를 통행할 수 있다.

㉣ 범 위

ⓐ 제219조의 주위토지통행권의 범위는 통행권을 가진 자에게 필요할 뿐만 아니라 이로 인한 주위토지소유자의 손해가 가장 적은 장소와 방법의 범위 내에서 인정되어야 한다[94다50656].

ⓑ 현재의 토지의 용법에 따른 이용의 범위에서 인정되는 것이지 더 나아가 장차의 이용상황까지 미리 대비하여 통행로를 정할 것은 아니다[94다50656].

ⓒ 주위토지통행권은 통행로로 인정된 이후 그 전제가 되는 포위된 토지나 주위토지 등의 현황이나 구체적 이용상황에 변동이 생긴 경우에는 구체적 상황에 맞게 통행로를 변경할 수 있다[2004다10268].

ⓓ 토지의 이용방법에 따라서는 자동차 등이 통과할 수 있는 통로의 개설도 허용되지만, 단지 토지이용의 편의를 위해 다소 필요한 상태라고 여겨지는 정도에 그치는 경우까지 자동차의 통행을 허용할 것은 아니다[2005다70144].

ⓔ 건축관련법령에 정한 도로폭에 관한 규정만으로 당연히 피포위지 소유자에게 반사적 이익으로서 건축관련법령에 정하는 도로의 폭이나 면적 등과 일치하는 주위토지통행권이 생기지는 않고, 적정한 범위를 결정하여야 한다[2005다30993].

ⓕ 주위토지통행권자는 필요한 경우에는 통행지상에 통로를 개설할 수 있으므로 모래를 깔거나 돌계단을 조성하거나 장해가 되는 나무를 제거하는 등의 방법으로 통로를 개설할 수 있으며 통행지 소유자의 이익을 해하지 않는다면 통로를 포장하는 것도 허용된다[2002다53469].

ⓖ 주위토지통행권의 본래적 기능발휘를 위하여는 그 통행에 방해가 되는 담장과 같은 축조물도 위 통행권의 행사에 의하여 철거되어야 하고, 그 담장이 비록 당초에는 적법하게 설치되었던 것이라 하더라도 그 철거의 의무에는 영향이 없으며, 철거로 인하여 손해가 발생한다 하여도 이를 이유로 담장의 철거를 거부할 수 없다[90다5238].

ⓗ 통행권을 가지고 있는 사람은 그 통행권의 범위 내에서 그 토지를 사용할 수 있을 뿐이고 그 통행지에 대한 통행지 소유자의 점유를 배제할 권능까지 있는 것은 아니므로, 그 통행지 소유자는 그 통행지를 전적으로 점유하고 있는 주위토지통행권자에 대하여 그 통행지의 인도를 구할 수 있다고 할 것이나, 주위토지통행권자가 통로를 개설하였다고 하더라도 그 통로에 대하여 통행지 소유자의 점유를 배제할 정도의 배타적인 점유를 하고 있지 않다면 통로 부분의 인도를 구하거나 그 통로에 설치된 시설물의 철거를 구할 수 없다[2002다53469].

ⓘ 일단 주위토지통행권이 발생하였다고 하더라도 나중에 그 토지(위요지)에 접하는 공로가 개설됨으로써 주위토지통행권을 인정할 필요성이 없어진 때에는 그 통행권은 소멸한다[97다47118].

㉤ 손해의 보상

ⓐ 주위토지통행권자는 통행지소유자의 손해를 보상하여야 한다(제219조 제2항). 그러나 보상의무의 이행이 통행권성립의 요건은 아니므로 통행권자가 손해를 보상하지 않더라도 통행권은 소멸하지 않고 채무불이행책임만 발생한다.

ⓑ 주위토지통행권자가 통행지 소유자에게 보상해야 할 손해액은 주위토지통행권이 인정되는 당시의 현실적 이용 상태에 따른 통행지의 임료 상당액을 기준으로 하여, 구체적인 사안에서 사회통념에 따라 감경할 수 있고, 단지 주위토지통행권이 인정되어 통행하고 있다는 사정만으로 통행지를 '도로'로 평가하여 산정한 임료 상당액이 통행지 소유자의 손해액이 된다고 볼 수 없다[2013다11669].

ⓒ 통행지 소유자는 통행권자의 허락을 얻어 사실상 통행하고 있는 자에게는 그 손해의 보상을 청구할 수 없다[91다19623].

② 무상주위토지통행권

㉠ 토지의 분할이나 일부 양도로 인하여 공로에 통하지 못하는 토지가 있는 때에는 그 토지소유자는 공로에 출입하기 위하여 다른 분할자의 토지를 통행할 수 있다. 이 경우에는 보상의 의무가 없다(제220조 제1항, 제2항).

㉡ 무상주위통행권에 관한 민법 제220조의 규정은 토지의 직접 분할자 또는 일부양도의 당사자 사이에만 적용되고 포위된 토지 또는 피통행지의 특정승계인에게는 적용되지 않고 주위토지통행권에 관한 민법 제219조의 일반원칙으로 돌아가 통행권의 유무를 가려야한다[2002다9202].

(6) 물에 관한 상린관계

① 자연적 배수(排水)

제221조(자연유수의 승수의무와 권리) ① 토지소유자는 이웃토지로부터 자연히 흘러오는 물을 막지 못한다.
② 고지소유자는 이웃저지에 자연히 흘러 내리는 이웃저지에서 필요한 물을 자기의 정당한 사용범위를 넘어서 이를 막지 못한다.
제222조(소통공사권) 흐르는 물이 저지에서 폐색(閉塞)된 때에는 고지소유자는 자비로 소통에 필요한 공사를 할 수 있다.

② 인공적 배수

제223조(저수, 배수, 인수를 위한 공작물에 대한 공사청구권) 토지소유자가 저수(貯水), 배수 또는 인수(引水) 하기 위하여 공작물을 설치한 경우에 공작물의 파손 또는 폐색으로 타인의 토지에 손해를 가하거나 가할 염려가 있는 때에는 타인은 그 공작물의 보수, 폐색의 소통 또는 예방에 필요한 청구를 할 수 있다.
제225조(처마물에 대한 시설의무) 토지소유자는 처마물이 이웃에 직접 낙하하지 아니하도록 적당한 시설을 하여야 한다.

(7) 경계에 관한 상린관계

① 경계표 · 담의 설치

제237조(경계표, 담의 설치권) ① 인접하여 토지를 소유한 자는 공동비용으로 통상의 경계표나 담을 설치할 수 있다.
② 통상의 경계표나 담의 설치비용은 쌍방이 절반하여 부담한다. 그러나 측량비용은 토지의 면적에 비례하여 부담한다.
제238조(담의 특수시설권) 인지소유자는 자기의 비용으로 담의 재료를 통상보다 양호한 것으로 할 수 있으며 그 높이를 통상 보다 높게 할 수 있고 또는 방화벽 기타 특수시설을 할 수 있다.
제239조(경계표등의 공유추정) 경계에 설치된 경계표, 담, 구거 등은 상린자의 공유로 추정한다. 그러나 경계표, 담, 구거 등이 상린자일방의 단독비용으로 설치되었거나 담이 건물의 일부인 경우에는 그 설치한 일방이 소유한다.

② 수지(樹脂) · 목근(木根)의 제거권

제240조(수지, 목근의 제거권) ① 인접지의 수목가지가 경계를 넘은 때에는 그 소유자에 대하여 가지의 제거를 청구할 수 있다.
② 가지의 제거청구에 응하지 아니한 때에는 청구자가 그 가지를 제거할 수 있다.
③ 인접지의 수목뿌리가 경계를 넘은 때에는 임의로 제거할 수 있다.

③ 토지의 심굴금지(深掘禁止)

제241조(토지의 심굴금지) 토지소유자는 인접지의 지반이 붕괴할 정도로 자기의 토지를 심굴하지 못한다. 그러나 충분한 방어공사를 한 때에는 심굴할 수 있다.

④ 경계선부근의 건축

제242조(경계선부근의 건축) ① 건물을 축조함에는 특별한 관습이 없으면 경계로부터 반미터이상의 거리를 두어야 한다.
② 인접지소유자는 전항의 규정에 위반한 자에 대하여 건물의 변경이나 철거를 청구할 수 있다. 그러나 건축에 착수한 후 1년을 경과하거나 건물이 완성된 후에는 손해배상만을 청구할 수 있다.

㉠ 제242조 제1항의 '경계로부터 반 미터'는 경계로부터 건물의 가장 돌출된 부분까지의 거리를 말한다.

㉡ 제242조는 임의규정이다. 따라서 당사자간의 합의가 있었다면 반미터 이상의 거리를 두지 않았다고 하여 그 건축을 폐기시키거나 변경시킬 수 없다[62다569].

⑤ 차면시설(遮面施設)

제243조(차면시설의무) 경계로부터 2미터 이내의 거리에서 이웃주택의 내부를 관망할 수 있는 창이나 마루를 설치하는 경우에는 적당한 차면시설을 하여야 한다.

⑥ 지하시설 등에 대한 제한

> **제244조(지하시설등에 대한 제한)** ① 우물을 파거나 용수, 하수 또는 오물등을 저치(貯置)할 지하시설을 하는 때에는 경계로부터 2미터 이상의 거리를 두어야 하며 저수지, 구거(溝渠) 또는 지하실공사에는 경계로부터 그 깊이의 반 이상의 거리를 두어야 한다.
> ② 전항의 공사를 함에는 토사가 붕괴하거나 하수 또는 오액(汚液)이 이웃에 흐르지 아니하도록 적당한 조처를 하여야 한다.

⑦ **관습에 관한 규정이 있는 상린관계** : 저수 · 인수 · 배수를 위한 공작물설치비용(제223조), 하류연안의 용수권 보호(제232조), 수류의 변경(제229조), 용수권의 승계(제233조), 소통공사의 비용(제222조), 공유하천용수권(제231조), 경계표 · 담의 설치 및 비용(제237조)과 경계선 부근의 건축(제242조)이 있고 상린관계규정이 아닌 것으로는 특수지역권(제302조)이 있다.

(8) 건물의 구분소유자간의 상린관계

> **제215조(건물의 구분소유)** ① 수인이 한 채의 건물을 구분하여 각각 그 일부분을 소유한 때에는 건물과 그 부속물 중 공용하는 부분은 그의 공유로 추정한다.
> ② 공용부분의 보존에 관한 비용 기타의 부담은 각자의 소유부분의 가액에 비례하여 분담한다.

제 2 절 소유권에 기한 물권적 청구권

1. 서 설

(1) 의 의

소유권의 실현이 어떠한 사정으로 방해되는 경우에 물건의 반환이나 방해의 제거 · 예방을 청구할 수 있는 권리를 말하는데 소유권의 실효성을 확보해주기 위해서 인정된다.

(2) 민법규정 및 유형

① 소유권에 기한 물권적 청구권을 규정하고(제213조~제214조) 이를 지상권(제290조), 지역권(제301조), 전세권(제319조), 저당권(제370조)에 준용하고 있다.

② 민법은 소유물 반환청구권(제213조) · 소유물 방해제거청구권(제214조 전단) · 소유물 방해예방청구권(제214조 후단)의 3가지를 규정하고 있다.

2. 소유물반환청구권

(1) 의 의

① 소유자는 그 소유에 속한 물건을 (법률상 정당한 원인없이)점유한 자에 대하여 반환을 청구할 수 있다(제213조).

② 소유물반환청구권은 점유물반환청구권과 달리 점유의 침탈을 당한 경우뿐만 아니라 소유자의 물건을 법률상 원인 없이 점유하고 있는 자에 대하여 행사할 수 있으며, 행사기간의 제한은 없다.

(2) 청구권자

① 소유물반환청구권을 가지는 자는 법률상의 소유자이다.

② 따라서 방해당하고 있는 소유권을 타인에게 양도한 때에는 그 양수인만 청구권을 가지며, 등기를 갖추지 못한 부동산매수인은 소유자가 아니므로 소유물반환청구권을 행사할 수 없고, 매도인의 소유물반환청구권을 대위행사할 수 있을 뿐이다.

③ 명의신탁의 경우 대외적으로 수탁자가 소유자이므로 수탁자만이 소유권자로서 그 재산에 대한 제3자의 침해에 대하여 배제를 구할 수 있으며, 신탁자는 수탁자를 대위하여 권리행사 할 수 있을 뿐 직접 제3자에 대하여 침해의 배제를 구할 수 없다[2000다36484].

④ 또한 소유권에 기한 물권적 청구권을 소유권과 분리하여 이를 소유권 없는 전 소유자에게 유보하여 행사시킬 수는 없는 것이므로 소유권을 상실한 전소유자는 제3자인 불법점유자에 대하여 소유권에 기한 물권적 청구권에 의한 방해배제를 구할 수 없다[80다7].

(3) 상대방

① 소유자의 소유물을 현재 부당하게 점유함으로써 소유자의 점유를 방해하고 있는 자로서 점유자의 고의 · 과실은 소유물반환청구의 요건이 아니다.

② 따라서 불법건물을 매수하여 이를 인도받아 점유하고 있는 매수인은 등기부상 소유명의가 없다 하더라도 그 권리의 범위내에서 그 점유 중인 건물에 대하여 법률상 · 사실상 이를 처분할 권리가 있으므로 물권적 청구권의 상대방이 된다.

③ 또한 토지매수인이 아직 소유권이전등기를 경료받지 않았다 하여도 매매계약의 이행으로 그 토지를 인도받은 때에는 매매계약의 효력으로서 이를 점유 · 사용할 권리가 생기게 된 것으로 보아야 하고, 매수인으로부터 위 토지를 다시 매수한 자는 위와 같은 토지의 점유 · 사용권을 취득한 것으로 봄이 상당하므로, 매도인은 매수인으로부터 다시 위 토지를 매수한 자에 대해 토지소유권에 기한 물권적 청구권을 행사하거나 그 점유 · 사용을 법률상 원인이 없는 이익이라고 하여 부당이득반환청구를 할 수는 없다[97다42823].

④ 상대방의 점유는 자주점유 · 타주점유 · 선의점유 · 악의점유를 불문하며 직접점유자뿐만 아니라 간접점유자도 청구의 상대방이 되나 점유보조자에 불과한 자는 이에 해당하지 않는다[2001다13983].

(4) **내 용** : 물건의 반환을 청구할 수 있다(제213조). 불법행위로 인한 손해배상청구권은 규정되어 있지 않지만, 소유권의 침해가 불법행위의 요건을 갖추게 되면 불법행위의 일반규정(제750조)에 의해 손해배상청구도 가능하다.

3. 소유물방해제거청구권

(1) 의 의

① 소유자는 소유권을 방해하는 자에 대하여 방해의 제거를 청구할 수 있다(제214조).

② 목적물에 대하여 점유침탈 이외의 방법으로 소유권을 방해하고 있어야 하고(불법으로 등기를 한 경우 등), 그 방해가 인정되기 위해서는 현재에도 지속되는 침해가 있어야 한다.

(2) 요 건

① **청구권자** : 점유상실 이외의 방법으로 현재 소유권을 방해당하고 있는 소유자로서 소유권을 타인에게 양도한 때에는 그 양수인만이 방해제거청구권을 가진다.

② 상대방

㉠ 소유자의 소유권을 '현재 방해하고 있는 자'이며, 방해자의 고의 · 과실을 요하지 않는다.

㉡ 제214조 방해배제청구로서의 말소등기청구의 상대방은 원칙적으로 현재의 등기명의인이다[93다28867].

㉢ 그러나 등기부상 진실한 소유자의 소유권에 방해가 되는 부실등기가 존재하는 경우에 그 등기명의인이 허무인 또는 실체가 없는 단체인 때에는 소유자는 그와 같은 허무인 명의로 실제 등기행위를 한 자에 대하여 소유권에 기한 방해배제로서 등기행위자를 표상하는 허무인 명의등기의 말소를 구할 수 있다[2008마615].

㉢ 불법으로 마쳐진 저당권등기가 이전된 후 저당권말소등기의 상대방은 저당권의 양수인이다. 따라서 甲소유의 건물에 乙명의의 저당권설정등기가 불법으로 경료된 후 丙에게 저당권이전등기가 경료되었다면, 甲은 丙을 상대로 저당권설정등기의 말소를 청구할 수 있다.

(3) 내 용

① 소유권에 기한 방해배제청구권에 있어서 '방해'라 함은 현재에도 지속되고 있는 침해를 의미하고, 법익 침해가 과거에 일어나서 이미 종결된 경우에 해당하는 '손해'의 개념과는 다르다.

② 따라서 소유권에 기한 방해배제청구권은 방해결과의 제거를 내용으로 하는 것이 되어서는 안 되며(이는 손해배상의 영역에 해당한다 할 것이다) 현재 계속되고 있는 방해의 원인을 제거하는 것을 내용으로 한다[2003다5917].

심화학습 토지위에 불법건물이 있는 경우

(1) 건물의 소유자가 건물을 점유하고 있는 경우

토지의 소유자는 그 건물의 소유자에 대하여 건물의 철거와 그 대지부분의 인도를 청구할 수 있을 뿐, 자기 소유의 건물을 점유하고 있는 자에 대하여 그 건물에서 퇴거할 것을 청구할 수는 없다[98다57457,57464].

(2) 건물의 소유자가 아닌 자(임차인 등)가 건물을 점유하고 있는 경우

토지소유자는 건물의 점유자가 아닌 건물 소유자에게 건물철거 및 대지의 인도를 청구할 수 있다. 다만, 토지소유자는 자신의 소유권에 기한 방해배제로서 건물점유자에 대하여 건물로부터의 퇴출을 청구할 수 있고, 이는 건물점유자가 건물소유자로부터의 임차인으로서 그 건물임차권이 이른바 대항력을 가진다고 해서 달라지지 아니한다[2010다43801].

4. 소유물방해예방청구권

제214조(소유물방해제거, 방해예방청구권) 소유자는 소유권을 방해할 염려있는 행위를 하는 자에 대하여 그 예방이나 손해배상의 담보를 청구할 수 있다.

제 3 절 소유권의 취득

Ⅰ 서 설

(1) 소유권 취득의 원인은 법률행위에 의한 경우와 법률의 규정에 의한 경우의 2가지가 있다. 법률행위에 의한 소유권취득(매매, 증여 등)은 일반적인 법률행위로 인한 물권변동의 원리가 그대로 적용되고, 여기에서는 법률규정에 의한 소유권취득에 대하여 서술한다.

(2) 법률규정에 의한 소유권취득의 원인으로 민법은 제245조 이하에서 시효취득, 선의취득, 무주물선점, 유실물습득, 매장물발견, 부합, 혼화, 가공 등을 규정하고 있다. 이들은 어느 것이나 소유권의 원시취득에 관한 것이다.

Ⅱ 취득시효

1. 서 설

(1) **의 의** : 권리를 행사하는 것과 같은 외관이 일정한 기간동안 계속되는 경우에 그 사실 상태대로 권리를 취득하게 하는 법률요건이 취득시효이고, 취득시효의 완성으로 인해 권리를 취득하는 것이 시효취득이다. 이는 사실상태의 존중과 법적 안정성의 유지, 증거보전 곤란의 구제 등을 위해 인정된다.

(2) **취득시효의 종류**

부동산물권(소유권, 지상권, 지역권, 전세권)		동산물권(소유권, 질권)	
점유취득시효	등기부취득시효	일반취득시효	단기취득시효
20년	10년	10년	5년
자주, 평온, 공연	+ 선의, 무과실	자주, 평온, 공연	+ 선의, 무과실

(3) **주 체** : 자연인, 법인, 국가나 지방자치단체도 주체가 될 수 있다. 문중 또는 종중과 같이 법인 아닌 사단 또는 재단도 취득시효완성으로 인한 소유권을 취득할 수 있다.

2. 취득시효의 목적이 되는 권리

(1) 소유권과 그 밖의 재산권

소유권, 계속되고 표현된 지역권, 점유권이 있는 지상권, 전세권, 질권과 광업권, 어업권, 무체재산권 등의 준물권이 있다.

(2) 시효취득이 인정되지 않는 재산권

점유를 수반하지 않는 물권(저당권), 법률규정에 의해 성립하는 권리(점유권, 유치권), 한번 행사하면 소멸하는 권리(취소권 · 해제권 · 철회권 등의 형성권), 신분관계를 전제로 하는 권리(부양청구권), 기타 채권, 계속적이지 않거나 표현되지 않은 지역권은 시효취득할 수 없다.

2. 취득시효의 대상

① **부동산의 일부** : 부동산의 일부는 토지의 분필등기, 건물의 구분소유권등기가 가능한 경우에 점유시효취득의 객체가 된다.

② **공유지분** : 공유지분에 대한 시효취득도 가능하다.

③ **자기소유 부동산** : 시효취득의 목적물은 타인의 부동산임을 요하지 않고 자기 소유의 부동산이라도 시효취득의 목적물이 될 수 있다[2001다17572].

④ **국유재산** : 국유재산 중에서 행정재산에 대해서는 시효취득이 인정되지 않지만 사경제적 거래의 대상이 되는 일반재산에 대해서는 시효취득이 인정된다[89헌가97]. 따라서 원래 일반재산이던 것이 행정재산으로 된 경우 일반재산일 당시에 취득시효가 완성되었다고 하더라도 행정재산으로 된 이상 이를 원인으로 하는 소유권이전등기를 청구할 수 없다[96다10782].

⑤ **집합건물의 공용부분** : 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률의 적용을 받는 집합건물의 공용부분은 취득시효의 의한 소유권취득의 대상이 될 수 없다[2011다78200,78217].

⑥ **성명불상자의 소유물** : 시효로 인한 부동산소유권의 취득은 원시취득으로서 취득시효의 요건을 갖추면 곧 등기청구권을 취득하는 것이고 또 타인의 소유권을 승계취득하는 것이 아니어서 시효취득의 대상이 반드시 타인의 소유물이어야 하거나 그 타인이 특정되어 있어야만 하는 것은 아니므로 성명불상자의 소유물에 대하여 시효취득을 인정할 수 있다[91다9312].

Ⅲ 부동산점유취득시효

1. 점유취득시효의 요건

제245조(점유로 인한 부동산소유권의 취득기간) ① 20년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 부동산을 점유하는 자는 등기함으로써 그 소유권을 취득한다.

(1) 평온 · 공연한 자주점유

① 여기서 말하는 점유에는 직접점유뿐만 아니라 간접점유도 포함된다[94다28468].

② 점유자는 소유의 의사로 평온 · 공연하게 점유한 것으로 추정된다(제197조 제1항). 따라서 입증책임은 취득시효를 부정하는 자에게 있다.

③ 부동산 명의수탁자의 점유는 타주점유이므로 신탁부동산을 점유시효취득 할 수 없다.

④ 부동산에 관하여 적법 · 유효한 등기를 마치고 소유권을 취득한 사람이 자기 소유의 부동산을 점유하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 사실상태를 권리관계로 높여 보호할 필요가 없으므로, 그러한 점유는 취득시효의 기초가 되는 점유라고 할 수 없다[2016다224596].

⑤ 점유가 불법이라고 주장하는 자로부터 이의를 받았다거나 또는 임료를 지급하든지 아니면 점유부동산을 매수할 것을 수차례 요구받았다거나 또는 소유권을 둘러싸고 분쟁이 있었다 하더라도 그러한 사실만으로 그 점유의 평온 · 공연성이 상실되지는 않는다.

(2) 20년간 점유계속

① 소유의 의사로 평온 · 공연하게 20년간 계속 점유하여야 한다(제245조 제1항). 점유의 계속은 추정되므로 점유 양 시점의 점유자가 다른 경우에도 점유의 승계가 인정되는 한 점유계속은 추정된다.

② 기산점

㉠ **원칙** : 부동산의 취득시효에 있어 기산점은 원칙적으로 시효취득의 기초가 되는 점유가 개시된 시점이 기산점이 되고 당사자가 기산점을 임의로 선택할 수 없다[98다40688].

㉡ **예외** : 취득시효를 주장하는 자는 점유기간 중에 소유자의 변동이 없는 경우(등기명의자가 동일한 경우)에는 취득시효의 기산점을 임의로 선택할 수 있고, 취득시효를 주장하는 날로부터 역산하여 20년 이상의 점유사실이 인정되면 취득시효를 인정할 수 있는 것이다[93다46360].

2. 점유취득시효완성의 효과

(1) 등기청구권의 발생

① 민법 제245조 제1항의 취득시효기간의 완성만으로는 소유권취득의 효력이 바로 생기는 것이 아니라, 다만 이를 원인으로 하여 소유권취득을 위한 등기청구권이 발생할 뿐이고, 미등기부동산의 경우라고 하여 취득시효기간의 완성만으로 등기 없이도 점유자가 소유권을 취득한다고 볼 수 없다[2006다22074].

② 건물공유자 중 일부만이 당해 건물을 점유하고 있는 경우라도 그 건물의 부지는 건물공유자 전원이 공동으로 이를 점유하는 것으로 볼 것이며, 건물공유자들이 건물부지의 공동점유로 인하여 건물부지에 대한 소유권을 시효취득하는 경우라면 그 취득시효완성으로 인한 소유권이전등기청구권은 당해 건물의 공유지분 비율과 같은 비율로 건물공유자들에게 귀속된다[2002다57935].

(2) 등기청구권의 성질

① 제245조 제1항 소정의 점유취득시효의 완성으로 발생하는 등기청구권의 성질은 채권적 청구권으로 소멸시효 대상이 되나 시효완성자가 그 토지에 대한 점유가 계속되는 한 시효로 소멸하지 않는다[93다47745전합].

② 시효 완성 후 점유를 상실하였다 하더라도 이를 "시효이익의 포기로 볼 수 있는 경우가 아닌 한" 이미 취득한 소유권이전등기청구권이 바로 소멸되지는 않지만 그 점유자는 점유를 상실한 때로부터 10년간 등기청구권을 행사하지 않으면 소멸시효가 완성한다[95다34866].

③ 취득시효완성으로 인한 소유권이전등기청구권은 채권자와 채무자 사이에 아무런 계약관계나 신뢰관계가 없으므로 취득시효완성으로 인한 소유권이전등기청구권의 양도의 경우에는 매매로 인한 소유권이전등기청구권에 관한 양도제한의 법리가 적용되지 않고 통상의 채권양도의 방법에 의해 양도가 가능하다[2015다36167]. 즉, 소유자의 동의나 승낙이 반드시 필요하지는 않고, 소유자에 대한 통지만으로 대항력이 생긴다.

(3) 등기청구의 상대방

① 취득시효 완성으로 토지의 소유권을 취득하기 위하여는 그로 인해 소유권을 상실하게 되는 시효 완성 당시의 진정한 소유자 또는 그 상속인을 상대로 소유권이전등기청구를 하는 방법에 의하여야 한다[96다53420].

② 따라서 취득시효기간 완성 전에 등기부상의 소유명의가 변경되었다 하여도 이는 취득시효 중단사유가 될 수 없고 시효취득자는 그 취득시효 완성 당시의 등기명의자에게 소유권취득을 주장할 수 있다[88다카5843].

③ 또한 취득시효기간의 완성 전에 부동산에 압류 또는 가압류 조치가 이루어졌다고 하더라도 이는 취득시효의 중단사유가 될 수 없다[2018다296878].

④ 시효 완성 당시의 소유권보존등기 또는 이전등기가 무효라면 원칙적으로 그 등기명의인은 시효취득을 원인으로 한 소유권이전등기청구의 상대방이 될 수 없다[2006다64573].

3. 점유취득시효 완성 후 등기 전의 법률관계

(1) 소유명의자와 점유자간의 법률관계

① 부동산 점유자에게 시효취득으로 인한 소유권이전등기청구권이 있다고 하더라도 이로 인하여 부동산 소유자와 시효취득자 사이에 계약상의 채권 · 채무관계가 성립하는 것은 아니므로, 그 부동산을 처분한 소유자에게 채무불이행책임을 물을 수 없다[94다4509].

② 취득시효가 완성된 이상, 소유자는 시효완성자에 대하여 토지의 인도를 구할 수 없음은 물론이고[87다카1737], 시효가 기산된 기간에 관하여 시효완성자가 얻은 사용이익을 부당이득으로 반환청구할 수 없고[92다51280], 나아가 시효완성자에 대하여 그 기간 동안의 불법점유를 이유로 하는 손해배상도 청구할 수 없다[65다2189].

③ 취득시효가 완성된 점유자는 점유권에 기하여 등기부상의 명의인을 상대로 점유방해의 배제를 청구할 수 있다 할 것이다[2004다23899, 23905].

(2) 시효완성 후 제3자에게 부동산이 처분된 경우

① 시효완성자의 제3자에 대항 여부

㉠ 취득시효기간이 만료된 토지의 점유자(시효완성자)는 원칙적으로 취득시효기간 만료 후에 새로이 토지의 소유권을 취득한 사람에 대하여는 시효취득으로 대항할 수 없다. 따라서 취득시효완성 사실을 알면서 소유자로부터 그 부동산을 매수하여 소유권이전등기를 마친 자라고 하더라도, 소유자와의 사이에서 소유자의 소유권이전등기의무를 인수하여 이행하기로 약정하였다는 등의 특별한 사정이 인정되지 않는 한, 전 소유자의 소유권이전등기의무를 승계한다고 볼 수는 없다.

㉡ 그러나 부동산을 취득한 제3자가 원소유자의 배임행위에 적극 가담하였다면 이는 사회질서위반행위로서 무효이다. 이 경우 시효완성자는 소유자를 대위하여 제3취득자 앞으로 경료된 원인무효의 등기의 말소를 구할 수 있다[93다10989].

㉢ 시효완성 전에 설정되어 있던 가등기에 기하여 시효완성 후에 소유권이전의 본등기를 마친 자도 취득시효 완성 후 소유권을 취득한 자이므로 시효완성자는 그에 대하여 시효완성을 주장할 수 없다.

㉣ 명의신탁된 부동산에 대하여 점유취득시효가 완성된 후 시효취득자가 그 소유권이전등기를 경료하기 전에 '명의신탁이 해지'되어 그 등기명의가 명의수탁자로부터 명의신탁자에게로 이전된 경우에는 명의신탁자는 시효완성 후 소유권을 취득한 제3자에 해당하여 그에 대하여 취득시효를 주장할 수 없다[2000다8861].

㉤ 취득시효 완성 후 토지소유자에 변동이 있어도 당초의 점유자가 계속 점유하고 있는 경우에는 소유권변동시를 새로운 취득시효의 기산점으로 삼아 2차의 취득시효의 완성을 주장할 수 있다[93다46360].

㉥ 미등기 토지에 대한 점유취득시효완성 당시 소유권을 가지고 있던 자가 취득시효완성 후에 자신 명의로 소유권보존등기를 마치거나, 시효완성 후에 소유자의 상속인 명의로 소유권이전등기를 마친 경우, 점유자는 그 등기명의인에게 취득시효완성을 주장할 수 있다[2006다84423].

② **원소유자의 책임** : 부동산 소유자가 취득시효가 완성된 사실을 알고 그 부동산을 제3자에게 처분하여 소유권이전등기를 넘겨줌으로써 취득시효완성을 원인으로 한 소유권이전등기의무가 이행불능에 빠지게 되어 시효취득을 주장하는 자가 손해를 입었다면 불법행위를 구성하며, 시효취득자가 입은 손해를 배상할 책임이 있다[97다56495, 99다20926].

③ **대상청구권(代償請求權)**

㉠ **인정여부** : 민법상 이행불능의 효과로서 채권자의 전보배상청구권과 계약해제권 외에 별도로 대상청구권을 규정하고 있지 않으나, 해석상 대상청구권을 부정할 이유는 없다[94다43825].

㉡ **행사요건** : 점유로 인한 부동산소유권 취득기간 만료를 원인으로 한 등기청구권이 이행불능으로 되었다고 하여 대상청구권을 행사하기 위하여는 그 이행불능 전에 등기명의자에 대해 점유로 인한 부동산소유권 취득기간이 만료되었음을 이유로 그 권리를 주장하였거나, 그 취득기간 만료를 원인으로 한 등기청구권을 행사하였어야 하고 그 이행불능 전에 그와 같은 권리의 주장이나 행사에 이르지 않았다면 대상청구권을 행사할 수 없다[94다43825].

(3) 시효 완성자가 시효 완성 후 점유를 이전해 준 경우의 법률관계

점유자가 취득시효기간의 만료로 일단 소유권이전등기청구권을 취득한 후 전 점유자의 점유를 승계한 자는 그 점유 자체와 하자만을 승계하는 것이지 그 점유로 인한 법률효과까지 승계하는 것은 아니므로 현 점유자는 전 점유자의 취득시효 완성의 효과를 주장하여 직접 자기에게 소유권이전등기를 청구할 권원은 없고, 전 점유자의 원소유자에 대한 소유권이전등기청구권을 대위 행사할 수 있을 뿐이다[93다47745전합].

(4) 시효 완성자의 시효이익포기

① 시효이익의 포기는 달리 특별한 사정이 없는 한 시효취득자가 취득시효 완성 당시의 진정한 소유자에 대하여 하여야 그 효력이 발생한다[2011다23200].

② 점유로 인한 부동산소유권의 취득기간이 경과한 뒤에 점유자가 소유자에게 그 부동산을 매수하자고 제의한 일이 있었다는 것만으로는 점유자가 위 부동산이 그 소유자의 소유임을 승인하여 타주점유로 전환되었다거나 시효의 이익을 포기하였다고는 보기 어렵다[92다26543].

4. 소유권취득의 효과(제245조 제1항)

(1) 원시취득 및 소급효

① 취득시효로 인한 권리의 취득은 원시취득이므로, 전 소유자의 권리에 존재하였던 모든 제한은 취득시효 완성과 더불어 원칙적으로 소멸하고 시효완성자는 각종 제한에 의하여 영향을 받지 아니하는 완전한 소유권을 취득한다.

② 시효취득의 효력은 점유를 개시한 때에 소급한다(제247조 제1항). 따라서 시효기간 진행 중의 시효취득자의 과실취득이나 임대 등의 처분은 유효하게 한 것으로 되어 원소유자에게 상환할 필요가 없다.

(2) 원시취득 및 소급효의 제한

① 점유취득시효가 완성되었다 하여도 특별한 사정이 없는 한 원소유자는 점유자 명의로 소유권이전등기가 마쳐지기까지는 소유자로서 그 토지에 관한 적법한 권리를 행사할 수 있다. 따라서 취득시효 완성 후 그로 인한 등기 전에 소유자가 저당권을 설정한 경우, 특별한 사정이 없는 한 시효완성자는 등기를 함으로써 저당권의 부담이 있는 소유권을 취득한다.

② 따라서 시효취득자가 취득시효완성 후 등기 전에 원소유자에 의하여 그 토지에 설정된 근저당권의 피담보채무를 변제하는 것은 그 자신의 이익을 위한 행위라 할 것이므로 위 변제액 상당에 대하여 원소유자에게 대위변제를 이유로 구상권을 행사하거나 부당이득을 이유로 그 반환청구권을 행사할 수는 없다[2005다75910].

Ⅳ 등기부취득시효

1. 등기부취득시효의 요건

제245조(점유로 인한 부동산소유권의 취득기간) ② 부동산의 소유자로 등기한 자가 10년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 선의이며 과실 없이 그 부동산을 점유한 때에는 소유권을 취득한다.

(1) 객 체 : 부동산의 일부에 관한 소유권등기는 불가능하므로 부동산의 일부는 등기부시효취득의 객체가 되지 않는다.

(2) 등 기

① 등기부취득시효의 요건으로서 소유자로 등기한자라 함은 적법 유효한 등기를 마친 자일 필요가 없고 오히려 무효인 등기도 포함된다. 다만, 소유권보존등기가 이중으로 되어 후등기가 무효인 때에는 후등기나 그에 터잡은 소유권이전등기를 근거로 해서는 등기부취득시효의 완성을 주장할 수 없다[96다12511전합].

② 등기부취득시효에 의하여 소유권을 취득하는 자는 10년간 반드시 그의 명의로 등기되어 있어야 하는 것은 아니고 앞 사람의 등기까지 아울러 그 기간 동안 부동산의 소유자로 등기되어 있으면 된다고 할 것이다[87다카2176]. 등기의 승계를 긍정하되 등기된 기간과 점유기간이 때를 같이하여 다같이 10년임을 요한다[98다20110].

(3) 평온 · 공연 · 선의 · 무과실의 자주점유

① 의의

㉠ 선의란 점유자가 그 부동산을 자기의 소유라고 믿는 것을 말하고, 무과실이란 점유자가 그 부동산을 자기의 소유라고 믿는데 있어 과실이 없음을 뜻한다.

㉡ 또한 등기부취득시효에서의 선의 · 무과실은 등기에 관한 것이 아니고 점유취득에 관한 것이다[96다48527].

② **판단시점** : 점유자의 선의 · 무과실은 점유개시시에만 있으면 족하므로 점유의 개시시에 과실이 없으면 되고 과실 없이 점유를 시작한 이후에 부동산소유권 분쟁이 있음을 알았다고 하더라도 과실이 있는 것으로 전환되지는 않는다[93다21132].

③ **입증책임** : 점유자는 소유의 의사로 선의 · 평온 · 공연하게 점유한 것으로 추정되지만 무과실은 추정되지 않으므로 시효취득을 주장하는 자가 자신의 선의에 과실이 없음을 입증해야 한다[97다2665].

2. 등기부취득시효의 효과

(1) **소유권취득** : 10년간 점유한 때에 곧바로 소유권을 취득하므로 소유권이전등기청구권의 문제는 생기지 않는다(제245조 제2항). 등기는 물권의 효력발생요건이고 효력존속요건이 아니므로 등기부취득시효가 완성된 후에 그 부동산에 관한 점유자명의의 등기가 말소되거나 적법한 원인 없이 다른 사람 앞으로 소유권이전등기가 경료되었다 하더라도, 그 점유자는 등기부취득시효의 완성에 의하여 취득한 소유권을 상실하는 것은 아니다[98다20110].

(2) **소급효** : 시효취득의 효력은 점유를 개시한 때에 소급한다(제247조 제1항).

Ⅴ 부합(附合)

1. 의 의

소유자를 달리하는 수개의 물건이 결합하여 사회관념상 한 개의 물건으로 보이고 그 분리가 사회관념상 불가능하거나 극히 곤란한 경우에 이를 분리하지 않고 하나의 물건으로 어느 특정인의 소유에 귀속시키는 것을 부합이라 한다. 예컨대 甲소유의 임야에 乙이 무단으로 수목을 식재한 경우에 乙의 수목은 甲의 임야에 부합되어 임야 소유자인 甲이 수목의 소유권을 취득한다.

2. 부동산에의 부합

제256조(부동산에의 부합) 부동산의 소유자는 그 부동산에 부합한 물건의 소유권을 취득한다. 그러나 타인의 권원에 의하여 부속된 것은 그러하지 아니하다.

(1) 요건

① 소유권의 변동이 있기 위한 부합의 정도는 훼손하지 않으면 분리할 수 없거나 분리에 과다한 비용을 요하는 경우는 물론 분리하게 되면 경제적 가치를 심히 감손케 하는 경우도 포함되며 부합의 원인은 자연적이든 인공적이든 불문한다[4294민상445].

② 부합물에 대해서 판례는 부합한 물건은 동산에만 한정되는 것은 아니고 부동산도 포함한다고 한다[4294민상445].

(2) 효과

① 부합한 물건의 가격이 피부합물인 부동산의 가격을 초과하더라도 부동산의 소유자가 그 부동산에 부합한 물건의 소유권을 취득한다.

② 적법한 권원 없이 타인의 토지에 식재한 수목은 토지에 부합된다.

③ 주유소 지하에 매설된 유류저장탱크를 토지로부터 분리하는 데에는 과다한 비용이 들고, 지하에 매설된 유류저장탱크를 분리할 경우 그 경제적 가치가 현저히 감소할 것임은 경험칙상 분명하므로 유류저장탱크는 토지에 부합된 것이라고 할 것이다[94다6345].

④ 부합으로 인해 손해를 받은 자는 부당이득에 관한 규정에 의해 보상을 청구할 수 있다(제261조).

(3) **부합의 예외**

① 타인의 권원에 의한 경우

㉠ 부합된 물건이 타인의 권원에 의하여 부속된 것인 때에는, 그 부합물은 부동산의 소유자의 소유가 되지 않고 그것을 부속시킨 자의 소유로 된다(제256조 단서).

㉡ 여기서 권원(權原)이란 지상권 · 전세권 · 임차권 등과 같이 타인의 부동산에 자기의 동산을 부속시켜서 그 부동산을 이용할 수 있는 권리를 뜻한다[88다카9067].

판 례

토지임차권에 기하여 식재된 수목을 토지경락인이 경락취득하는지 여부(소극)

토지임차권에 기하여 그 토지상에 식재된 수목은 이를 식재한 자에게 그 소유권이 있고 그 토지에 부합되지 않는다 할 것이므로 비록 그 수목이 식재된 후에 경매에 의하여 그 토지를 경락받았다고 하더라도 경락인은 그 경매에 의하여 그 수목까지 경락취득하는 것은 아니라고 할 것이다(다카21095).

㉢ 따라서 토지의 사용대차권(정당한 권원)에 기하여 그 토지상에 식재된 수목은 이를 식재한 자에게 그 소유권이 있고 그 토지에 부합되지 않는다[89다카21095].

㉣ 그러나 권원이 없는 자가 토지소유자의 승낙을 받음이 없이 그 임차인의 승낙만을 받아 그 부동산 위에 나무를 심었다면 그 나무는 토지에 부합한다[88다카9067]. 또한 부동산에 부합된 물건이 사실상 분리복구가 불가능하여 거래상 독립한 권리의 객체성을 상실하고 그 부동산과 일체를 이루는 부동산의 구성부분이 된 경우에는 타인이 권원에 의하여 이를 부합시켰더라도 그 물건의 소유권은 부동산의 소유자에게 귀속된다(대판 2008.5.8. 2007다36933).

② 건물은 토지로부터 독립된 부동산이므로 토지에 부합하지 않는다.

③ 권원 없이 타인의 토지에 경작 · 재배한 농작물일지라도 그 소유권은 경작자에게 있다[68도906].

④ 건물의 임차인이 건물소유자의 승낙을 얻어 기존건물에 증축한 경우에 증축부분이 독립된 경제적 효용을 갖지 못하고 부동산의 구성부분이 되는 경우에는 기존건물에 부합되어 증축부분은 기존 건물의 소유자에게 귀속된다[84다카2428]. 그러나 증축부분이 독립성이 인정된다면 증축부분은 기존건물에 부합되지 않고 증축한 자에게 소유권이 인정된다[99다14518].

제 4 절 공동소유(共同所有)

Ⅰ 의 의

공동소유란 하나의 물건을 2인 이상의 다수인이 공동으로 소유하는 것을 말한다. 공동소유형태는 다수인의 인적 결합관계에 따라 공유, 합유, 총유의 3가지가 있다.

Ⅱ 공유(共有)

1. 의 의

제262조(물건의 공유) ① 물건이 지분에 의하여 수인의 소유로 된 때에는 공유로 한다.

공유는 물건에 대한 1개의 소유권이 양적으로 분할되어 여러 사람에게 속하는 것이므로([91다27228]) 공유는 1물 1권주의에 반하지 않는다(양적 분할설 · 量的 分割說).

2. 공유의 성립

(1) 법률행위에 의한 성립

여러 사람이 하나의 물건을 공유하기로 합의가 이루어지는 때 공유관계가 성립한다. 부동산에 관해서는 공유의 등기와 지분의 등기를 하여야 한다.

(2) 법률의 규정에 의한 성립

① 주종을 구별할 수 없는 동산의 부합(제257조) · 혼화(제258조)는 공유로 본다. 타인의 물건 속에서의 매장물발견(제254조)은 토지 기타 물건의 소유자와 발견자가 절반한다. 무주물 공동선점(제252조), 유실물의 공동습득(제253조), 매장물의 공동발견(제254조), 공유물의 과실취득(제102조)은 해석상 공유로 인정되고, 공동상속재산(제1006조)은 개개의 물건이 공동상속인의 공유에 속한다[94다61649].

② 건물의 구분소유에 있어서 공용부분(제215조 제1항), 경계에 설치된 경계표 · 담 · 구거 등(제239조)은 공유의 성질을 가지나 공유물분할을 할 수 없다.

③ 수인의 명의수탁자의 물건소유형태는 공유([90다15341])이나 신탁법상의 수탁자가 수인 있는 경우의 신탁재산에 대한 소유형태는 합유이다.

3. 공유의 지분(持分)

(1) 지분의 의의

공유지분은 각 공유자가 공유물에 대해 가지는 권리를 표상하는 비율이다. 공유지분은 1개의 소유권의 분량적 일부분이므로 그 성질과 효력에서 소유권과 동일하지만 단지 소유의 비율일 뿐이다. 따라서 어느 공유자가 다른 공유자의 지분을 전부 매수하면 단독소유가 된다(지분의 집중).

(2) 공유지분의 비율

> **제262조(물건의 공유)** ② 공유자의 지분은 균등한 것으로 추정한다.

① 지분비율의 결정

지분비율은 공유자의 의사표시나 법률의 규정(제254조 단서, 제257조, 제258조)에 의하여 결정된다. 다만, 지분비율이 불분명한 경우에는 지분은 균등한 것으로 추정된다(제262조 제2항).

② 지분등기

공유의 등기와 각 공유자의 지분을 기재하는 지분의 등기를 해야 한다.

(3) 공유지분의 탄력성

제267조(지분포기 등의 경우의 귀속) 공유자가 그 지분을 포기하거나 상속인 없이 사망한 때에는 그 지분은 다른 공유자에게 각 지분의 비율로 귀속한다.

공유자가 사망한 경우에는 법률규정에 의한 물권변동이므로 등기를 요하지 않지만, 공유지분의 포기는 법률행위로서 제186조에 의하여 등기를 하여야 공유지분 포기에 따른 물권변동의 효력이 발생한다[65다301].

(4) 공유지분의 처분

제263조(공유지분의 처분과 공유물의 사용 · 수익) 공유자는 그 지분을 처분할 수 있고 공유물 전부를 지분의 비율로 사용 · 수익할 수 있다.

① 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 자기의 공유지분을 자유로이 양도하거나 담보로 제공할 수 있다.

② 따라서 지분양도금지의 특약은 당사자 사이에 채권적 효력을 가질 뿐이며 등기사항이 아니다. 그러므로 공유자가 지분처분금지특약에 위반하여 지분을 처분한 경우에도 그 처분행위는 유효하고 그 처분에 다른 공유자들의 동의를 받을 필요가 없다.

판 례

복수의 권리자가 소유권이전청구권 보존을 위한 가등기를 마친 경우, 일부 권리자가 단독으로 자기 지분에 관한 본등기를 청구할 수 있는지 여부(적극)

공유자가 다른 공유자의 동의 없이 공유물을 처분할 수는 없으나, 그 지분은 단독으로 처분할 수 있으므로, 복수의 권리자가 소유권이전청구권을 보존하기 위하여 가등기를 마쳐 둔 경우 특별한 사정이 없는 한 그 권리자 중 한 사람은 자신의 지분에 관하여 단독으로 그 가등기에 기한 본등기를 청구할 수 있다(대판 2002. 7. 9. 2001다43922).

4. 공유자간의 공유관계

(1) 공유물의 보존

제265조(공유물의 보존) 보존행위는 각자가 할 수 있다.

① **의의** : 보존이란 공유물의 멸실 · 훼손을 방지하고 그 현상을 유지하기 위하여 하는 사실적 · 법률적 행위를 말한다. 따라서 공유자가 다른 공유자의 지분권을 대외적으로 주장하는 것은 공유물의 보존행위에 속한다고 할 수 없다[94다35008]. 따라서 甲의 지분에 관하여 제3자 명의로 원인무효의 등기가 이루어진 경우, 공유자인 乙은 공유물의 보존행위로 그 등기의 말소를 청구할 수 없다.

② 제3자가 공유물을 불법점유하고 있는 경우

제3자가 공유물을 불법으로 점유 · 사용하고 있는 경우에 공유자 중 1인은 공유물보존행위로서 공유물전부의 반환을 청구할 수 있다.

③ 소수지분권자(1/2지분권자 포함)가 공유물을 점유하고 있는 경우

과반수 지분에 미달하는 소수지분권자가 다른 공유자와의 협의 없이 공유물을 배타적으로 점유하여 사용 · 수익하는 경우에 다른 소수지분권자는 공유물을 점유하는 자에 대하여 공유물의 보존행위로서 공유물의 인도를 청구할 수 없고, 다만 자신의 지분권에 기초하여 공유물에 대한 방해 상태를 제거하거나 공동 점유를 방해하는 행위의 금지 등을 청구할 수 있다[2018다287522].

④ 원인무효등기의 말소

㉠ 부동산의 공유자의 1인은 당해 부동산에 관하여 제3자 명의로 원인무효의 소유권이전등기가 경료되어 있는 경우, 공유물에 관한 보존행위로서 제3자에 대하여 그 등기전부의 말소를 구할 수 있다[92다52870]. 또한 공유자의 한 사람은 그 공유물의 일부 지분에 관하여서만 재판상 청구를 할 수 있고, 그로 인한 시효중단의 효력은 그 공유자와 그 청구한 소송물에 한하여 발생한다(시효중단의 효력은 재판상 청구를 한 그 공유자에 한하여 발생하고 다른 공유자에게는 미치지 아니한다)[99다15146, 79다639].

㉡ 다만, 공유자 중 1인이 공유부동산에 대하여 무단으로 자기 앞으로 소유권이전등기를 경료한 경우, 그의 지분 범위 내에서는 유효이므로 다른 공유자는 등기된 자의 지분을 제외한 나머지 지분 등기의 말소를 청구할 수 있다.

⑤ 부당이득반환청구 등

공유물을 불법점유하는 제3자나 공유물을 배타적으로 사용 · 수익하는 일부 공유자에 대해 다른 공유자는 단독으로 자기의 지분범위 안에서 부당이득반환청구 및 손해배상청구권을 행사할 수 있다[70다171].

(2) 공유물의 관리

제265조(공유물의 관리 · 보존) 공유물의 관리에 관한 사항은 공유자의 지분의 과반수로써 결정한다.

① 관리(이용 · 개량)행위

㉠ '관리' 란 처분 · 변경에 이르지 않는 정도의 이용 · 개량행위로서 공유자 사이에 공유물을 사용 · 수익할 구체적인 방법을 정하는 것은 공유물의 관리에 관한 사항이다[78다695].

㉡ 공유물의 관리에 관한 사항은 '공유자'의 과반수가 아니라 '지분'의 과반수로써 결정하고, 지분의 과반수란 지분의 2분의 1이 아니라 지분의 2분의 1을 넘어서는 것을 말한다.

② 과반수지분권자

㉠ 과반수지분의 공유자는 다른 공유자와 사이에 미리 공유물의 관리방법에 관한 협의가 없었다 하더라도 공유물의 관리에 관한 사항을 단독으로 결정할 수 있다[2002다9738].

㉡ 따라서 과반수지분의 공유자가 그 공유부동산의 특정된 한 부분을 배타적으로 사용·수익하는 것은 공유물의 관리방법으로서 적법하다. 그러므로 이 경우 다른 공유자들은 과반수지분권자에게 인도청구 또는 손해배상청구는 할 수 없고, 단지 자신의 지분에 범위 내에서 부당이득반환청구를 행사할 수 있다[2002다9738].

㉢ 또한 과반수지분의 공유자로부터 다시 그 특정부분의 사용·수익을 허락받은 제3자(예컨대 임차인)의 점유는 적법한 점유이므로 소수 지분의 공유자는 그 점유자가 사용·수익하는 건물의 철거나 퇴거 등 점유배제를 구할 수 없다[2002다9738]. 또한 그 제3(예컨대 적법한 임차인)자는 소수지분권자에 대하여 그 점유로 인하여 법률상 원인 없이 이득을 얻고 있다고 볼 수 없으므로 소수지분권자는 제3자(예컨대 적법한 임차인)에게 부당이득반환청구를 할 수 없고, 과반수지분권자에게 차임상당액을 부당이득으로 반환청구 할 수 있다[2002다9738].

㉣ 다만, 다수지분권자라 하여 나대지에 새로이 건물을 건축한다든지 하는 것은 '관리'의 범위를 넘는 것이 되어 허용될 수 없다[2000다33638].

③ 공유물의 임대 및 임대차해지

공유자가 공유물을 타인에게 임대하는 행위 및 그 임대차계약을 해지하는 행위는 공유물의 관리행위에 해당하므로 공유자의 지분의 과반수로써 결정하여야 한다.

④ 공유물에 대한 사용·수익·관리에 관한 특약

㉠ 공유물에 대한 사용·수익·관리에 관한 특약은 공유자의 특정승계인에 대하여도 당연히 승계된다고 할 것이나, 공유자 중 1인의 사용수익권을 영구히 포기하는 등 공유지분의 본질적 부분을 침해한 경우에는 특정승계인이 그러한 사실을 알고도 공유지분권을 취득하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 특정승계인에게 당연히 승계된다고 볼 수 없다[2010다 108210].

㉡ 위와 같은 특약 후에 공유자에 변경이 있고 특약을 변경할 만한 사정이 있는 경우에는 공유자의 지분의 과반수의 결정으로 기존 특약을 변경할 수 있다[2005다 1827].

(3) 공유물의 변경 및 처분

제264조(공유물의 처분, 변경) 공유자는 다른 공유자의 동의없이 공유물을 처분하거나 변경하지 못한다.

① 처분이란 법률상 및 사실상 처분(공유물의 양도·담보권설정·공유물의 훼손 등)을 포함하며, 변경이란 공유물에 대한 사실상의 물리적인 변경을 의미한다.

② 공유자 전원의 동의 없는 공유물의 처분 · 변경이 전부 무효가 되는 것이 아니라 다른 공유자의 지분범위 내에서 타인의 물건을 처분한 것과 동일한 법률효과가 발생한다(제569조). 따라서 공유자 중 1인이 다른 공유자의 동의 없이 그 공유토지의 특정부분을 매도하여 타인명의로 소유권이전등기가 마쳐졌다면 그 매도부분토지에 관한 소유권이전등기는 처분공유자의 공유지분범위 내에서는 실체관계에 부합하는 유효한 등기라고 보아야 하므로 다른 공유자는 처분공유자의 지분을 제외하고 지분말소등기를 청구할 수 있다[93다1596].

(4) 공유물의 사용 · 수익

제263조(공유지분의 처분과 공유물의 사용, 수익) 공유자는 그 지분을 처분할 수 있고 공유물 전부를 지분의 비율로 사용, 수익할 수 있다.

(5) 공유물에 관한 비용부담

① 지분의 비율로 부담

제266조(공유물의 부담) ① 공유자는 그 지분의 비율로 공유물의 관리비용 기타 의무를 부담한다.

② 지분매수청구권

제266조(공유물의 부담) ② 공유자가 1년 이상 공유물의 관리비용 기타 의무이행을 지체한 때에는 다른 공유자는 상당한 가액으로 지분을 매수할 수 있다.

지분매수청구권은 형성권으로서 지분의 매수청구권을 행사함에 있어서는 매수대상이 되는 지분 전부의 매매대금을 제공한 다음 매수청구권을 행사해야 하고 지분일부에 대한 매수청구는 허용되지 아니한다[92다25656].

5. 공유물의 분할

(1) 공유물분할의 자유와 제한

제268조(공유물의 분할청구) ① 공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년 내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다.
② 전항의 계약을 갱신한 때에는 그 기간은 갱신한 날로부터 5년을 넘지 못한다.
③ 공유물분할의 규정은 제215조(건물을 구분소유하는 경우의 공용부분), 제239조(경계에 설치된 경계표 · 담 · 구거)의 공유물에는 적용하지 아니한다.

① 분할청구의 자유

㉠ 공유는 물건을 공동으로 소유하고 있다는 것 외에는 내부적 · 단체적 구속은 없으므로 언제든지 분할을 청구 할 수 있다(제268조 제1항 본문).

㉡ 분할청구권의 행사에 의해 즉시 공유물을 분할해야 하는 법률관계가 발생하는 것이지, 바로 공유물이 분할되는 것은 아니다.

㉢ 분할청구권은 공유관계가 존재하는 한 언제나 행사할 수 있으며 소멸시효에 걸리지 않는다[80다1888].

② 분할의 제한

㉠ **당사자 약정에 의한 제한** : 공유자 사이의 계약에 의해 5년을 넘지 않는 한도에서 분할금지특약을 할 수 있으며, 이 계약은 갱신할 수 있으나 그 기간은 갱신한 날부터 5년을 넘지 못한다. 공유물이 부동산인 경우에는 분할금지약정을 등기하지 않으면 공유자의 특정승계인에게는 그 약정의 효력이 미치지 않는다.

㉡ **법률규정에 의한 제한** : 건물의 구분소유에 있어서 공용부분, 경계에 설치된 경계표 · 담 · 구거 등에 관해서는 분할청구가 인정되지 않는다.

(2) 분할의 방법

제269조(분할의 방법) ① 분할의 방법에 관하여 협의가 성립되지 아니한 때에는 공유자는 법원에 그 분할을 청구할 수 있다.

① 협의분할

㉠ 각 공유자가 다른 공유자 모두를 상대로 공유물분할을 청구하면 각 공유자는 분할에 관해 협의할 의무를 부담한다. 분할협의에는 공유자 전원이 참여해야 한다. 따라서 공유자 중 1인의 협의 없이 분할한 경우 그 공유물분할은 법률상 효력이 없다[68다647].

㉡ 구체적인 분할방법으로는 각 공유자의 지분비율에 따라 공유물을 현물 그대로 수개의 물건으로 분할하고 분할된 물건에 대하여 각 공유자의 단독소유권을 인정하는 현물분할, 타인에게 공유물을 매각하여 그 대금을 분할하는 대금분할, 공유자 중 일부가 다른 공유자의 지분을 양수하고 그 가격을 배상하고 단독소유자로 되는 가격배상이 있다.

② 재판상 분할

㉠ 분할의 방법에 관해 협의가 성립하지 않은 때에는 공유자는 다른 모든 공유자를 상대로 법원에 그 분할을 청구할 수 있다.

㉡ 공유자 사이에 이미 분할에 관한 협의가 성립된 경우에는 일부 공유자가 분할에 따른 이전등기에 협조하지 않거나 분할에 관해 다툼이 있더라도 그 분할된 부분에 대한 소유권이전등기를 청구하든가 소유권확인을 구함은 별문제이나 또다시 소로써 그 분할을 청구하거나 이미 제기한 공유물분할의 소를 유지함은 허용되지 않는다[94다30348].

㉢ 공유물분할의 소는 분할을 청구하는 공유자가 원고가 되고 나머지 공유자 전원을 피고로 하여 제기하는 형성의 소이며, 그에 따른 공유물분할판결은 형성판결로서 판결이 확정되면 등기 없이도 물권변동이 발생한다.

㉣ 재판에 의한 분할방법은 현물분할을 원칙으로 하며, 현물로 분할할 수 없거나 분할로 인하여 현저히 그 가액이 감손될 염려가 있을 때에는 법원은 물건의 경매를 명하여 그 대금을 분할할 수 있다(제269조 제2항). 대금분할은 보충적으로만 가능하므로 현물분할이 가능함에도 경매를 명함은 위법하다[95다32662].

㉤ 공유물분할의 소는 형성의 소로서 법원은 공유물분할을 청구하는 자가 구하는 방법에 구애받지 아니하고 자유로운 재량에 따라 공유관계나 그 객체인 물건의 제반상황에 따라 공유자의 지분비율에 따른 합리적인 분할을 하면 되는 것이다[2004다30583]. 여기에서 공유지분비율에 따른다 함은 지분에 따른 가액비율에 따름을 의미한다[93다27819].

판 례

공유물분할방법에 관한 판례

1. 토지를 현물분할함에 있어 일정한 요건이 갖추어진 경우에는 공유자 상호간에 금전으로 경제적 가치의 과부족을 조정하게 하여 분할을 하는 것도 현물분할의 한 방법으로 허용되고, 여러 사람이 공유하는 물건을 현물분할하는 경우에는 분할을 원하지 않는 나머지 공유자는 공유로 남겨 두는 방법도 허용된다[97다18219].
2. 특별한 사정이 있는 때에는 공유물을 공유자 중의 1인의 단독소유 또는 수인의 공유로 하되 현물을 소유하게 되는 공유자로 하여금 다른 공유자에 대하여 그 지분의 적정하고도 합리적인 가격을 배상시키는 방법에 의한 분할도 현물분할의 하나로 허용된다[2004다30583].
3. 여러 사람이 공유하는 물건을 현물분할하는 경우에는 분할청구자의 지분 한도 안에서 현물분할을 하고 분할을 원하지 않는 나머지 공유자는 공유로 남게 하는 방법도 허용되나, 그렇다고 하더라도 공유물분할을 청구한 공유자의 지분 한도 안에서는 공유물을 현물 또는 경매 · 분할함으로써 공유관계를 해소하고 단독소유권을 인정하여야지, 분할청구자들이 그들 사이의 공유관계의 유지를 원하고 있지 아니한데도 분할청구자들과 상대방 사이의 공유관계만 해소한 채 분할청구자들을 여전히 공유로 남기는 방식으로 현물분할을 하는 것은 허용될 수 없다[2014다88888].
4. 분할청구자 지분의 일부에 대하여만 공유물 분할을 명하고 일부 지분에 대하여는 이를 분할하지 아니하거나, 공유물의 지분비율만을 조정하는 등의 방법으로 공유관계를 유지하도록 하는 것은 허용될 수 없다[2010다92506].
5. 공유물분할청구소송에 있어 등기부상 지분과 실제의 지분이 다른 경우에, 지분을 양수하여 등기까지 경료한 제3자에 대하여는 특별한 사정이 없는 한 등기부상의 지분을 기준으로 할 수 밖에 없지만, 원래의 공유자들 사이에서는 실제의 지분이 기준으로 된다(대판 2001.3.9. 98다51169).

(3) 공유물분할의 효과

① 공유관계의 종료

공유물분할에 의해 공유관계는 종료하고 각 공유자간에 '현물분할'의 경우에는 지분권의 교환이 있게 되고 '가격배상'의 경우에는 지분권의 매매가 있게 된다.

② 불소급효(不遡及效)

협의상 분할의 경우에는 등기시에, 재판상 분할의 경우에는 판결확정시에 소유권을 취득하므로 공유물분할의 효과는 공유관계발생시로 소급하지 않는다.

③ 분할로 인한 담보책임

> **제270조(분할로 인한 담보책임)** 공유자는 다른 공유자가 분할로 인하여 취득한 물건에 대하여 그 지분의 비율로 매도인과 동일한 담보책임이 있다.

분할은 지분권의 교환·매매를 의미하므로 각 공유자는 다른 공유자가 분할로 취득한 물건에 대하여 그 지분의 비율로 매도인과 동일한 담보책임이 있다.

④ 지분상의 담보물권

甲·乙의 공유인 부동산 중 甲의 지분 위에 설정된 근저당권 등 담보물권은 특단의 합의가 없는 한 공유물분할이 된 뒤에도 종전의 지분비율대로 공유물 전부 위에 그대로 존속하고 근저당권설정자인 甲 앞으로 분할된 부분에 당연히 집중되는 것은 아니다[88다카24868].

판 례

부동산의 일부 공유지분에 관하여 저당권이 설정된 후 부동산이 분할된 경우, 분할된 각 부동산이 저당권의 공동담보가 되는지 여부(적극)

부동산의 일부 공유지분에 관하여 저당권이 설정된 후 부동산이 분할된 경우, 그 저당권은 분할된 각 부동산 위에 종전의 지분비율대로 존속하고, 분할된 각 부동산은 저당권의 공동담보가 된다(대판 2012.3.29. 2011다74932).

Ⅲ 합유(合有)

1. 의 의

> **제271조(물건의 합유)** ① 법률의 규정 또는 계약에 의하여 수인의 조합체로서 물건을 소유하는 때에는 합유로 한다.

민법상 조합은 2인 이상이 공동사업을 목적으로 결합한 일반적인 조합으로서 두 사람이 건축업을 동업하기로 하고 각자 일정금액을 투자하여 구입한 토지의 공동소유관계가 합유이다.

2. 합유관계의 성립

① 법률행위에 의한 성립

계는 특별한 약정이 없다면 조합계약으로 보는 것이 타당하다[62다265].

② 법률의 규정에 의한 성립

민법상 조합재산, 수탁자가 수인인 경우의 신탁재산(신탁법 제45조)은 그들의 합유에 속한다.

③ 등기

부동산을 합유하는 경우에는 등기부에 합유자의 명의를 모두 기재하고 합유라는 취지를 기재해야 한다. 합유재산을 합유자의 1인 명의로 한 소유권보존등기는 원인무효의 등기이다[69다22].

판 례

합유자의 1인 명의로 마쳐진 소유권보존등기의 효력

합유재산을 합유자의 1인 명의로 소유권보존등기한 것은 원인무효의 등기이며, 합유자는 전원의 동의 없이는 합유물에 대한 지분을 처분하지 못하는 것이므로 그 동의가 없는 이상 지분매매도 할 수 없다(대판 1970.12.29. 69다22).

3. 합유지분

① 합유지분의 의의

제271조(물건의 합유) ① 합유자의 권리는 합유물 전부에 미친다.

제273조(합유지분의 처분과 합유물의 분할금지) ① 합유자는 전원의 동의없이 합유물에 대한 지분을 처분하지 못한다.

각 합유자는 전체로서의 조합재산에 대하여 지분을 가질 뿐만 아니라, 조합재산을 구성하는 개개의 물건에 대하여도 지분을 가진다. 그런데 공유지분이 소유권의 분량적 일부분임과 달리, 합유지분은 조합관계에서 생기는 각 합유자의 권리 · 의무의 총체, 따라서 조합체의 일원으로서의 '지위'를 가리킨다.

② 합유지분의 처분 및 상속 여부

합유자는 전원의 동의없이 합유물에 대한 지분을 처분하지 못한다(제273조 제1항). 지분의 양도는 조합원으로서의 지위의 양도를 의미하기 때문이다. 또한 부동산의 합유자 중 일부가 사망한 경우 합유자 사이에 특별한 약정이 없는 한 사망한 합유자의 상속인은 합유자로서의 지위를 승계하는 것이 아니고 잔존 합유자의 합유로 귀속된다.

③ 합유지분의 포기

합유지분 포기가 적법하다면 그 포기된 합유지분은 나머지 잔존 합유지분권자들에게 균분으로 귀속하게 되지만 이는 등기하여야 효력이 있다[96다16896].

4. 합유의 법률관계

① 합유물의 보존

> **제272조(합유물의 보존)** 그러나 보존행위는 각자가 할 수 있다.

합유물에 관하여 경료된 원인무효의 소유권이전등기의 말소를 구하는 소송은 합유물에 관한 보존행위로서 합유자 각자가 할 수 있다[96다16896].

② 합유물의 처분 · 변경

> **제272조(합유물의 처분, 변경)** 합유물을 처분 또는 변경함에는 합유자 전원의 동의가 있어야 한다. 그러나 보존행위는 각자가 할 수 있다.

③ 합유물분할의 금지

> **제273조(합유지분의 처분과 합유물의 분할금지)** ② 합유자는 합유물의 분할을 청구하지 못한다.

다만, 조합이 해산된 경우에는 청산절차에 따라 합유물을 분할 할 수 있다.

5. 합유관계의 소멸

> **제274조(합유의 종료)** ① 합유는 조합체의 해산 또는 합유물의 양도로 인하여 종료한다.
> ② 전항의 경우에 합유물의 분할에 관하여는 공유물의 분할에 관한 규정을 준용한다.

Ⅳ 총유(總有)

1. 의 의

> **제275조(물건의 총유)** ① 법인이 아닌 사단의 사원이 집합체로서 물건을 소유할 때에는 총유로 한다.

2. 총유의 성립

법인 아닌 사단의 사원이 집합체로서 소유하는 형태가 총유이다. 법인 아닌 사단으로는 종중, 교회, 일정한 사찰, 자연부락, 동 · 리, 설립중의 법인, 아파트입주자대표회의, 채권자들로 구성된 청산위원회 등이 이에 해당할 수 있다. 대표자가 있는 비법인사단에 속하는 부동산은 사단명의로 등기하고, 등기신청은 사단의 대표자가 한다.

3. 총유관계

① 총유물의 보존행위

총유물의 보존에 있어서는 공유물의 보존에 관한 민법 제265조의 규정이 적용될 수 없고([94다28437]) 사원총회의 결의에 의한다.

② 총유물의 관리 · 처분

> **제276조(총유물의 관리, 처분과 사용, 수익)** ① 총유물의 관리 및 처분은 사원총회의 결의에 의한다.

총유물의 처분에 관한 정관이나 규약이 없다면 총회의 결의를 거치지 않은 총유물처분은 무효이다. 따라서 법인 아닌 사단인 종중소유의 재산은 종중원의 총유에 속하므로, 비록 종중대표자에 의한 종중재산의 처분이라고 하더라도 종중총회의 절차를 거치지 않은 채 한 행위는 무효이다[96다18656].

③ 총유물의 사용 · 수익

> **제276조(총유물의 관리, 처분과 사용, 수익)** ② 각사원은 정관 기타의 규약에 좇아 총유물을 사용, 수익할 수 있다.

4. 준공동소유

> **제278조(준공동소유)** 본절의 규정은 소유권 이외의 재산권에 준용한다. 그러나 다른 법률에 특별한 규정이 있으면 그에 의한다.

수인이 공동으로 소유권 이외의 재산권을 소유하는 것을 '준공동소유'라고 한다.

CHAPTER

05 용익물권(用益物權)

제 1 절 지상권(地上權)

Ⅰ 지상권의 의의 및 성질

1. 의 의

> **제279조(지상권의 내용)** 지상권자는 타인의 토지에 건물 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 그 토지를 사용하는 권리가 있다.

지상권이란 타인소유의 토지에서 건물 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 그 토지를 사용하는 권리를 말한다.

2. 지상권의 성질

(1) "타인토지" 에 대한 권리(他物權)

지상권은 타인의 토지에 관한 권리로서 지상권과 소유권이 동일인에게 귀속하면 지상권은 혼동으로 소멸한다. 토지는 1필의 토지의 일부라도 무방하고 지표뿐만 아니라 토지의 지상 · 지하에도 구분지상권을 설정할 수 있다.

(2) 타인의 토지를 "사용"하는 권리

① 지상권은 타인의 토지에서 건물 기타의 공작물이나 수목을 소유하는 것을 본질적 내용으로 하는 것이 아니라 타인의 토지를 사용하는 것을 본질적 내용으로 한다. 따라서 지상권설정계약 당시 건물 기타의 공작물이나 수목이 없더라도 지상권은 유효하게 성립할 수 있고, 기존의 건물 기타의 공작물이나 수목이 멸실되더라도 존속기간이 만료되지 않는 한 지상권은 소멸되지 않는다[95다49318].

② 그리고 타인의 토지를 점유할 수 있는 권리이며, 상린관계에 관한 규정이 준용된다(제290조).

(3) 건물 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위한 권리

공작물은 건물 · 교량 · 탑 · 전주 · 도로 · 연못 등의 지상공작물뿐만 아니라 지하철 · 굴 · 우물 등의 지하공작물도 포함한다. 수목(樹木)은 식림(植林)의 대상이 되는 식물을 말하며 경작(耕作)의 대상이 되는 식물(벼 · 보리 등)은 포함되지 않는다.

(4) 타인의 토지를 직접 지배하는 물권

지상권은 토지를 지배할 수 있는 물권으로서 제3자에게 대항할 수 있는 권리이며 양도성과 상속성을 가진다. 따라서 지상권자가 지상권을 양도하거나 전대를 하는 경우에 토지소유자의 동의를 필요로 하지 않는다.

(5) 지 료

지상권에 있어서 지료의 지급은 지상권의 성립요소가 아니어서 무상의 지상권설정도 가능하다. 다만, 당사자는 지료의 약정을 할 수 있고, 등기를 하면 제3자에 대하여도 효력이 있다.

Ⅱ 지상권의 존속기간

1. 설정행위로 기간을 정하는 경우

(1) 최단존속기간의 제한(제280조)

① 민법의 규정

> **제280조(존속기간을 약정한 지상권)** ① 계약으로 지상권의 존속기간을 정하는 경우에는 그 기간은 다음 연한보다 단축하지 못한다.
> 1. 석조, 석회조, 연와조 또는 이와 유사한 견고한 건물이나 수목의 소유를 목적으로 하는 때에는 30년
> 2. 견고한 건물 이외의 건물의 소유를 목적으로 하는 때에는 15년
> 3. 건물 이외의 공작물의 소유를 목적으로 하는 때에는 5년
>
> ② 전항의 기간보다 단축한 기간을 정한 때에는 전항의 기간(30년, 15년, 5년)까지 연장한다.

② **적용범위** : 최단존속기간규정은 지상권자가 그 소유의 건물 등을 건축하거나 수목을 식재하여 토지를 이용할 목적으로 지상권을 설정한 경우에만 적용되고, 지상권설정자소유의 기존건물을 사용할 목적으로 지상권을 설정하는 경우에는 적용되지 않는다[95다49318].

(2) 최장존속기간의 제한여부

민법상 지상권의 존속기간은 최단기만이 규정되어 있을 뿐 최장기에 관하여는 아무런 제한이 없으므로 지상권의 존속기간을 영구로 약정하는 것도 허용된다[99다66410].

2. 설정행위로 기간을 정하지 않은 경우

(1) 지상권의 존속기간을 정하지 않은 경우

> **제281조(존속기간을 약정하지 아니한 지상권)** ① 계약으로 지상권의 존속기간을 정하지 아니한 때에는 그 기간은 제280조의 최단존속기간(30년, 15년, 5년)으로 한다.

(2) 공작물의 종류와 구조를 정하지 않은 경우

> **제281조(존속기간을 약정하지 아니한 지상권)** ② 지상권설정 당시에 공작물의 종류와 구조를 정하지 아니한 때에는 지상권은 제280조 제2호의 건물의 소유를 목적(15년)으로 한 것으로 본다.

지상권설정 당시 공작물의 종류 및 재료를 정하지 않은 경우에는 그 존속기간이 15년이다(제281조 제2항). 다만, 여기에 수목은 제외되므로 수목의 소유를 목적으로 하는 지상권은 언제나 '30년'이다.

Ⅲ 지상권의 효력

1. 지상권자의 토지사용권

(1) 내 용

지상권자는 설정행위로 정한 목적의 범위 내에서 토지를 사용할 수 있는데 지상권설정의 목적과 범위는 등기사항이다. 그리고 지상권설정자는 지상권자의 토지사용을 방해해서는 안되는 소극적인 인용의무를 지므로 필요비는 지상권자가 부담한다.

(2) 지상권에 기한 물권적 청구권

지상권 내용의 실현이 침해된 때에 지상권자는 지상권에 기한 반환청구권, 방해제거청구권, 방해예방청구권을 행사 할 수 있는데 이는 지상권설정자에 대해서도 행사할 수 있다.

(3) 점유보호청구권

지상권은 토지를 사용하는 물권이어서 토지를 점유할 권리를 포함하므로 지상권자가 점유를 침해당한 경우에는 점유보호청구권을 행사할 수 있다(제290조).

판 례

지상권을 설정한 토지 소유자가 불법점유자에 대하여 물권적 청구권을 행사할 수 있는가 여부(적극) 및 지상권을 설정한 토지소유자가 불법점유자에 대하여 손해배상을 구할 수 있는가 여부(소극)

지상권을 설정한 토지소유권자는 불법점유자에 대하여 방해배제를 구할 수 있는 물권적 청구권을 행사할 수 있다. 그러나 지상권을 설정한 토지소유권자는 지상권이 존속하는 한 토지를 사용 · 수익할 수 없으므로 특별한 사정이 없는 한 불법점유자에게 임료 상당의 손해배상을 청구할 수 없다(대판 1974. 11.12. 74다1150).

(4) 상린관계의 준용

지상권은 토지를 사용하는 권리이므로 인접토지간의 이용을 조절하는 상린관계 규정(제216조~제244조)이 준용된다(제290조).

2. 지상권의 처분

(1) 지상권의 양도 또는 토지의 임대

① 물권인 지상권은 지상권설정자의 동의 없이 타인에게 지상권을 양도하거나 그 존속기간 내에서 그 토지를 임대할 수 있다(제282조). 제282조는 강행규정이며, 이에 위반하는 지상권자에게 불리한 약정은 효력이 없다(제289조). 따라서 지상권의 양도나 토지의 임대를 금지하는 특약은 무효이며, 지상권자는 지상권설정자의 의사에 반하여도 지상권의 존속기간 내에서 양도 · 임대할 수 있다.

② 지상권자는 지상권을 유보한 채 지상물 소유권만을 양도할 수도 있고 지상물소유권을 유보한 채 지상권만을 양도할 수도 있는 것이어서 지상권자와 그 지상물의 소유권자가 반드시 일치하여야 하는 것은 아니다[2006다6126,6133].

(2) 지상권의 담보제공

지상권자는 지상권설정자의 동의가 없더라도 자신의 지상권 위에 저당권을 설정할 수 있다. 또한 지상권 담보제공을 금지하는 특약은 무효이다.

3. 지료지급의무

(1) 무상원칙

지상권에 있어서 지료의 지급은 그 요소가 아니어서 지료에 관한 유상약정이 없는 이상 지료의 지급을 구할 수 없다[99다24874].

(2) 지료약정이 있는 경우

지료액 또는 그 지급시기 등 지료에 관한 약정은 이를 등기해야만 제3자에게 대항할 수 있으므로, 지료의 등기를 하지 않은 이상 토지소유자는 구 지상권자의 지료연체사실을 들어 지상권을 이전받은 자에게 대항하지 못하고, 지료에 관하여 등기되지 않은 경우에는 무상의 지상권으로서 지상권을 양수한 자에게 지료증액청구권도 발생할 수 없다[99다24874].

(3) 지료체납의 효과

제287조(지상권소멸청구권) 지상권자가 2년 이상의 지료를 지급하지 아니한 때에는 지상권설정자는 지상권의 소멸을 청구할 수 있다.

① 지상권자가 2년 이상의 지료를 지급하지 아니한 때에는 지상권설정자는 지상권의 소멸을 청구할 수 있다. '2년 이상 지료를 지급하지 아니한 때'란 계속해서 2년분의 지료를 체납한 때는 물론, 합해서 2년분의 지료액이 체납된 경우도 포함된다.

② 지상권자가 2년 이상의 지료를 연체하였으나, 지상권설정자가 지상권의 소멸을 청구하지 않고 있는 동안 지상권자로부터 연체된 지료의 일부를 지급받아 연체된 지료가 2년 미만으로 된 경우에는 지상권설정자는 종전에 지상권자가 2년분의 지료를 연체하였다는 사유를 들어 지상권의 소멸을 청구할 수 없다[2012다102384].

③ 지상권자의 지료지급연체가 토지소유권의 양도 전후에 걸쳐 이루어진 경우 토지양수인에 대한 연체기간이 2년이 되지 않는다면 양수인은 지상권소멸청구를 할 수 없다[99다17142].

4. 지료증감청구권

제286조(지료증감청구권) 지료가 토지에 관한 조세 기타 부담의 증감이나 지가의 변동으로 인하여 상당하지 아니하게 된 때에는 당사자는 그 증감을 청구할 수 있다.

5. 유익비상환청구권

명문규정은 없으나 지상권자가 유익비를 지출한 경우 지상권 기간 만료시에 그 가액의 증가가 현존한 때에 한하여 지출한 금액이나 그 증가액을 상환해야 한다. 다만, 필요비는 지상권자가 부담하므로 반환청구 할 수 없다.

Ⅳ 지상권의 소멸

1. 지상권의 소멸사유

(1) **물권일반의 소멸사유** : 토지의 멸실, 소멸시효의 완성, 혼동, 토지수용, 지상권자의 포기, 존속기간의 만료 기타 약정된 소멸사유의 발생 또는 지상권의 해지, 지상권에 우선하는 저당권의 실행으로 인한 경매 등으로 지상권은 소멸한다.

(2) **지상권자의 포기** : 지상권의 포기는 물권적 단독행위이므로 법률행위로 인한 물권변동이다. 따라서 포기로 인한 지상권의 소멸은 등기하여야한다. 다만 지상권에 저당권이 설정된 때에는 저당권자의 동의 없이 지상권을 소멸하게 하는 행위를 하지 못하므로(제371조 제2항), 그 경우의 지상권 포기에는 저당권자의 동의가 있어야 한다.

(3) **지상권설정자의 소멸청구**

제287조(지상권소멸청구권) 지상권자가 2년 이상의 지료를 지급하지 아니한 때에는 지상권설정자는 지상권의 소멸을 청구할 수 있다.
제288조(지상권소멸청구와 저당권자에 대한 통지) 지상권이 저당권의 목적인 때 또는 그 토지에 있는 건물, 수목이 저당권의 목적이 된 때에는 지료체납을 이유로 한 지상권소멸청구는 저당권자에게 통지한 후 상당한 기간이 경과함으로써 그 효력이 생긴다.

2. 지상권소멸의 효과

(1) 지상권자의 지상물수거의무 및 지상권설정자의 지상물매수청구권

제285조(수거의무, 매수청구권) ① 지상권이 소멸한 때에는 지상권자는 건물 기타 공작물이나 수목을 수거하여 토지를 원상에 회복하여야 한다.
② 전항의 경우에 지상권설정자가 상당한 가액을 제공하여 그 공작물이나 수목의 매수를 청구한 때에는 지상권자는 정당한 이유없이 이를 거절하지 못한다.

① 지상권자의 지상물수거의무는 의무이자 권리라고 할 수 있다.

② 지상권설정자는 지상권이 소멸하면 소멸사유를 묻지 않고 상당한 가액을 제공하여 그 공작물이나 수목의 매수를 청구할 수 있고, 지상권자는 정당한 이유 없이 이를 거절하지 못한다.

(2) 지상권자의 갱신청구권 및 지상물매수청구권

제283조(지상권자의 갱신청구권, 매수청구권) ① 지상권이 소멸한 경우에 건물 기타 공작물이나 수목이 현존한 때에는 지상권자는 계약의 갱신을 청구할 수 있다.
② 지상권설정자가 계약의 갱신을 원하지 아니하는 때에는 지상권자는 상당한 가액으로 전항의 공작물이나 수목의 매수를 청구할 수 있다.
제284조(갱신과 존속기간) 당사자가 계약을 갱신하는 경우에는 지상권의 존속기간은 갱신한 날로부터 제280조의 최단존속기간(30년, 15년, 5년)보다 단축하지 못한다. 그러나 당사자는 이보다 장기의 기간을 정할 수 있다.

① 요건 : 지상권이 존속기간의 만료로 소멸하고, 지상권의 존속기간이 만료할 당시 건물 기타 공작물이나 수목이 현존해야 한다. 그러나 2년의 지료연체로 지상권소멸청구를 당한 자는 갱신청구권 뿐만 아니라 지상물매수청구권도 행사할 수 없다.

② 절차

㉠ 지상권자는 우선 계약의 갱신을 청구하고, 지상권설정자가 계약의 갱신을 원하지 아니하는 때에 상당한 가액으로 지상물의 매수를 청구할 수 있다.

㉡ 지상권갱신청구권의 행사는 지상권의 존속기간 만료 후 지체 없이 하여야 한다. 따라서 지상권의 존속기간 만료 후 지체 없이 행사하지 아니하여 지상권갱신청구권의 소멸한 경우에는 지상물매수청구권은 발생하지 않는다[2022다1306642].

③ 효과

㉠ 갱신청구권은 형성권이 아니라 청구권이므로 지상권설정자는 지상권자의 갱신청구에 응할 수도 있고 거절할 수도 있지만, 갱신을 거절하면 지상권자는 지상물의 매수를 청구할 수 있다(형성권. 제283조 제2항).

㉡ 이때 매수청구권은 형성권으로 매수청구권을 행사하면 매매계약이 성립한 것과 같은 효력이 생기며, 그 가액은 매수청구권행사 당시의 시가 상당액이다(대판 1972.7.25. 72다653).

㉢ 지상권의 존속기간이 만료된 때에 지상물을 철거하거나 토지소유자에게 무상으로 양도하기로 하는 약정은 지상권자의 이 권리를 배제하는 내용으로서 지상권자에 불리하므로, 그 약정은 효력이 없다(제289조; 대판 1993.6.22. 93다16130).

심화학습 담보지상권

1. 의의

토지에 관하여 저당권을 취득함과 아울러 그 저당권의 담보가치를 확보하기 위하여 지상권을 취득하는 경우, 이를 담보지상권이라 한다[2003마1753].

2. 담보지상권의 효력

(1) 물권적 방해배제청구

① 제3자가 저당권의 목적인 토지 위에 건물을 신축하는 경우, 제3자가 지상권자에게 대항할 수 있는 권원을 가지고 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 지상권자는 그 방해배제청구로서 건물을 축조하는 것을 중지하도록 요구하고 신축중인 건물의 철거와 대지의 인도를 구할 수 있다[2003마1753, 2005다47205].

② 제3자의 지상권설정자에 대하여 그 토지를 사용·수익 할 수 있는 채권적 권리의 존재는 지상권자에게 대항할 수 있는 특별한 사정에 해당하지 않는다[2005다47205].

(2) 토지의 사용·수익권 여부

① 토지소유자는 저당부동산의 담보가치를 하락시킬 우려가 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 토지를 사용·수익할 수 있다고 보아야 한다[2015다69907].

② 담보지상권자는 지상권의 목적 토지를 점유, 사용함으로써 임료 상당의 이익이나 기타 소득을 얻을 수 있었다고 보기 어려우므로, 그 위에 도로개설·옹벽구축 등의 행위를 한 무단점유자에 대하여 담보가치 감소로 인한 손해배상을 구하는 외에 별도로 지상권 자체의 침해를 이유로 임료 상당 손해배상을 구할 수 없다[2006다588].

(3) 지상권의 피담보채무 확인청구 가부

담보지상권은 담보가치 유지를 위한 것이지만 담보물권은 아니므로 그 피담보채무의 범위 확인을 구하는 청구는 할 수 없다.

3. 담보지상권의 소멸

담보권자가 담보가치 하락을 막기 위해 아울러 지상권을 설정한 경우 피담보채권의 변제 등으로 담보권이 소멸하면 지상권도 함께 소멸한다고 할 것이다[2011다6342].

Ⅵ 특수한 지상권

1. 구분지상권(區分地上權)

제289조의2 (구분지상권) ① 지하 또는 지상의 공간은 상하의 범위를 정하여 건물 기타 공작물을 소유하기 위한 지상권의 목적으로 할 수 있다. 이 경우 설정행위로써 지상권의 행사를 위하여 토지의 사용을 제한할 수 있다.
② 제1항의 규정에 의한 구분지상권은 제3자가 토지를 사용·수익할 권리를 가진 때에도 그 권리자 및 그 권리를 목적으로 하는 권리를 가진 자 전원의 승낙이 있으면 이를 설정할 수 있다. 이 경우 토지를 사용·수익할 권리를 가진 제3자는 그 지상권의 행사를 방해하여서는 아니된다.

(1) 의 의

타인의 토지의 지하(지하철, 지하상가, 지하주차장) 또는 지상(육교, 고가도로)의 공간에 상하의 범위를 정하여 건물 기타 공작물을 소유하기 위한 지상권을 말한다. 객체가 토지의 상하의 어느 층에 한정되고 수목의 소유를 위하여는 성립할 수 없다는 점에서 일반 지상권과 차이가 있다.

(2) 성 립

① 당사자간의 구분지상권설정에 관한 물권적 합의와 등기에 의해서 설정된다. 또한 일반지상권과 마찬가지로 지료의 지급은 지상권 성립요건이 아니다.

② 구분지상권을 설정하려는 토지에 대하여 이미 제3자의 다른 권리(지상권 · 지역권 · 전세권이나 등기된 임차권)가 있을 때에는 그 권리자 및 그 권리를 목적으로 하는 권리를 가진 자(지상권 · 전세권을 목적으로 하는 저당권 등) 전원의 승낙을 얻어야만 구분지상권을 설정할 수 있다. 이 경우 제3자는 구분지상권의 정당한 행사를 방해해서는 아니된다.

2. 분묘기지권(墳墓基地權)

(1) 의 의

분묘기지권은 분묘를 수호하고 봉제사하는 목적을 달성하는 데 필요한 범위 내에서 타인의 토지를 사용할 수 있는 관습법상의 권리를 의미한다[95다29086].

(2) 내 용

① 봉분과 내부에 시신이 있는 경우에 분묘기지권이 인정된다. 따라서 평장(平葬), 가묘(假墓)에는 분묘기지권이 인정되지 않는다.

② 토지소유자가 분묘소유자에 대하여 분묘의 설치를 승낙한 때에는 그 분묘의 기지에 대하여 분묘소유자를 위한 지상권 유사의 물권을 설정한 것으로 보아야 한다[99다14006]. 이때 설치할 당시 토지소유자와 분묘기지권자가 지료 지급의무의 존부나 범위 등에 관하여 약정을 하였다면 그 약정의 효력은 그 토지의 승계인에 대하여도 미친다[2017다271834, 271841].

③ 자기 소유의 토지에 분묘를 설치하고 분묘이장의 특약 없이 자기 토지를 타에 양도함으로써 분묘기지권이 성립하는 경우, 분묘기지권자는 분묘기지권이 성립한 때부터 지료를 지급할 의무가 있다[2020다295892].

④ 분묘기지권을 시효로 취득한 경우, 토지소유자가 토지의 사용대가를 청구하면 분묘기지권자는 그때부터 지료지급의무를 부담한다[2017다228007].

⑤ 분묘기지권은 기존의 분묘 이외에 새로운 분묘를 설치할 권능을 포함하지 아니한다.

⑥ 분묘기지권의 존속기간은 당사자 사이의 약정이 있으면 그에 따르며, 그러한 사정이 없는 경우에는 그 분묘가 존속하고 있는 동안 존속하는 것으로 해석한다.

⑦ 분묘기지권은 이를 포기하겠다는 의사표시를 함으로 인하여 소멸되고, 점유까지 포기할 필요는 없다.

⑧ 「장사 등에 관한 법률」이 시행된 이후 설치된 분묘에 대해서는 더 이상 시효취득이 인정되지 않지만 「장사 등에 관한 법률」 시행 이전에 설치된 분묘에 관한 분묘기지권의 시효취득은 법적 규범으로 유지되고 있다.

Ⅶ 민법 제366조의 법정지상권(法定地上權)

제366조(법정지상권) 저당물의 경매로 인하여 토지와 그 지상건물이 다른 소유자에 속한 경우에는 토지소유자는 건물소유자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다. 그러나 지료는 당사자의 청구에 의하여 법원이 이를 정한다.
② 법정지상권이 성립한 경우에 대지소유자는 타인에게 그 대지를 임대하거나 이를 목적으로 한 지상권 또는 전세권을 설정하지 못한다.

1. 서 설

① 의의

제366조의 법정지상권이란 토지와 그 지상의 건물이 동일소유자에게 속하고 있는 경우에, 토지와 건물 중 어느 하나에 또는 양쪽 모두에 설정된 저당권의 실행으로 토지와 건물의 소유자가 달라진 때에 건물소유자에게 법률의 규정에 의하여 당연히 인정되는 지상권을 말한다.

② 강행규정

제366조는 가치권과 이용권의 조절을 위한 공익상의 이유로 지상권의 설정을 강제하는 강행규정이므로 이의 적용을 배제하는 특약은 효력이 없다[87다카1564].

2. 성립요건

(1) 최선순위 저당권설정 당시 건물이 존재할 것

① 제1순위 저당권의 설정 당시에 건물이 존재하고 있어야 하는데, 건물이 없는 토지에 1번저당권을 설정한 후에 건물을 신축하고 다시 그 토지에 2번저당권을 설정하여 2번저당권자의 신청으로 경매가 있게 되더라도 건물을 위한 법정지상권은 성립하지 않는다.

② 저당권설정 당시에 토지상에 건물이 존재하기만 하면 되므로 그 건물이 무허가건물이거나 미등기건물이더라도 법정지상권 성립에 아무런 장애도 될 수 없다 할 것이다[63아62].

③ 그러나 가설건축물은 특별한 사정이 없는 한 독립된 부동산으로서 건물의 요건을 갖추지 못하여 법정지상권이 성립하지 않는다[2020다224821]

④ 토지에 관하여 저당권이 설정될 당시 토지소유자에 의하여 그 지상에 건물을 건축 중이었던 경우 건물의 규모 · 종류가 외형상 예상할 수 있는 정도까지 건축이 진전되어 있었고, 그 후 경매절차에서 매수인이 매각대금을 다 낸 때까지 독립된 부동산으로서 건물의 요건을 갖추어야 법정지상권의 성립이 인정된다[2003다29043].

(2) 저당권설정 당시에 토지와 건물이 동일한 소유자에게 속할 것

① 따라서 토지에 저당권을 설정할 당시 토지의 지상에 건물이 존재하고 있었고 그 양자가 동일 소유자에게 속하였다가 그 후 저당권의 실행으로 토지가 낙찰되기 전에 건물이 제3자에게 양도된 경우, 건물을 양수한 제3자는 민법 제366조 소정의 법정지상권을 취득한다[99다52602].

② 그러나 미등기건물을 그 대지와 함께 양수한 사람이 '대지의 소유권이전등기만 넘겨받고 건물의 소유권등기를 이전받지 못한 상태'에서 대지에 관해 저당권을 설정하고 대지의 경매로 소유자가 달라지게 된 경우에는 법정지상권이 발생할 수 없다[2002다9660전합].

(3) 저당권설정 후 경매실행 전 사정변경

① 민법 제366조 소정의 법정지상권이 성립하려면 저당권설정 당시 건물이 존재한 이상 동일인의 소유에 속하는 토지와 건물 중 토지만이 저당권의 목적이 되고, 그 이후 건물을 개축, 증축하는 경우에도 법정지상권이 성립하며, 이 경우의 법정지상권의 내용인 존속기간, 범위 등은 구 건물을 기준으로 하여 그 이용에 일반적으로 필요한 범위 내로 제한된다[90다19985].

② 동일인 소유의 토지 및 그 지상건물에 '공동저당권'이 설정된 후 그 지상건물이 철거되고 새로 건물이 신축될 경우에는 특별한 사정이 없는 한 저당물의 경매로 인하여 토지와 그 신축건물이 다른 소유자에 속하게 되더라도 그 신축건물을 위한 법정지상권은 성립하지 않는다[98다43601].

(4) 담보권실행경매의 결과 토지와 건물의 소유자가 달라질 것

① 저당권의 실행으로서 경매가 있어야 하고 토지의 소유권과 건물의 소유권이 서로 다른 사람에게 귀속되어야 한다. 경매는 임의경매(담보권실행을 위한 경매)를 말하고 강제경매로 인한 경우에는 관습상의 법정지상권을 인정하면 족하다[70다1454].

② 건물공유자의 1인이 그 건물의 부지인 토지를 단독으로 소유하면서 그 토지에 관하여만 저당권을 설정하였다가 위 저당권에 의한 경매로 토지 소유자가 달라진 경우에도 위 건물공유자들은 민법 제366조 법정지상권을 취득한다[2010다67159].

Ⅷ 관습법상(慣習法上)의 법정지상권(法定地上權)

1. 의 의

동일인의 소유이던 토지와 그 지상건물이 매매 기타 원인으로 인하여 각각 소유자를 달리하게 되었으나 그 건물을 철거한다는 등의 특약이 없으면 건물소유자로 하여금 토지를 계속 사용하게 하려는 것이 당사자의 의사라고 보아 관습법상 건물소유자에게 당연히 인정되는 지상권을 말한다[2002다9660全合].

2. 성립요건

(1) 처분 당시 토지와 건물이 동일인에게 귀속

① 원래 관습법상 법정지상권이 성립하려면 토지와 그 지상건물이 애초부터 원시적으로 동일인의 소유에 속하였을 필요는 없고, 그 소유권이 유효하게 변동될 당시에 동일인이 토지와 그 지상건물을 소유하였던 것으로 족하다[2010다52140[전합]].

② 토지소유자가 매수인으로부터 토지대금을 다 받기 전에 그 토지 위에 건물을 신축할 수 있도록 토지사용을 승낙하여 매수인이 건물을 신축한 후 적법하게 해제된 경우에는 관습상의 법정지상권이 성립되지 아니한다[87다카2895].

③ 원래 동일인에게의 소유권귀속이 원인무효로 이루어졌다가 그 뒤 그 원인무효임이 밝혀져 그 등기가 말소됨으로써 그 건물과 토지의 소유자가 달라지게 된 경우에는 관습상의 법정지상권을 허용할 수 없다[98다64189].

④ 미등기건물을 그 대지와 함께 매도하였다면 비록 매수인에게 그 대지에 관하여만 소유권이전등기가 경료되고 건물에 관하여는 등기가 경료되지 아니하여 형식적으로 대지와 건물이 그 소유명의자를 달리하게 되었다 하더라도 매도인에게 관습상의 법정지상권을 인정할 이유가 없다[2002다9660[전합]].

⑤ 경매의 목적이 된 부동산에 대하여 가압류가 있고 그것이 본압류로 이행되어 경매절차가 진행된 경우에는, 매각대금완납한 때가 아니라 애초 가압류가 효력을 발생하는 때를 기준으로 토지와 그 지상건물이 동일인에 속하였는지를 판단하여야 한다[2010다52140전합].

(2) 매매 기타 원인으로 소유자가 달라질 것

① 동일한 소유자에 속하는 토지와 그 토지 위의 건물이 매매, 증여, 대물변제, 강제경매, 공유물분할 등에 의해 각기 그 소유자를 달리하게 된 경우에는 특히 그 건물을 철거한다는 조건이 없는 한 그 건물의 소유자는 그 토지 위에 그 건물을 위한 관습상의 법정지상권을 취득 한다.

② 그러나 환지처분으로 인하여 토지와 그 지상건물의 소유자가 달라진 경우, 담보권실행경매의 경우에는 관습법상 법정지상권이 성립하지 아니한다.

(3) 건물철거의 합의가 없을 것

① '토지와 건물의 소유자가 토지만을 타인에게 증여한 후 구 건물을 철거하되 그 지상에 자신의 이름으로 건물을 다시 신축하기로 합의한 경우' 그 건물철거의 합의는 건물 소유자가 토지의 계속 사용을 그만두고자 하는 내용의 합의로 볼 수 없어 관습상의 법정지상권의 발생을 배제하는 효력이 인정되지 않는다[98다58467].

② 그러나 대지와 건물의 소유자가 건물만을 양도하면서 양수인과 대지에 대한 임대차계약을 체결하였다면 특별한 사정이 없는 한 그 양수인은 대지에 관한 관습상의 법정지상권을 포기한 것이다[67다2007].

3. 관습법상 법정지상권의 내용

① **토지사용권의 범위** : 관습법상 법정지상권이 성립하면 그 내용은 지상권과 동일하다. 따라서 법정지상권의 범위는 건물의 유지 또는 사용을 위하여 일반적으로 필요한 범위 내의 대지 부분에 한정된다[96다40080].

② **지료지급의무** : 지료는 당사자의 협의가 성립하지 않으면 당사자의 청구에 의해 법원이 정한다. 그러나 관습상의 법정지상권에 관한 지료가 결정된 바 없다면 법정지상권자가 2년 이상의 지료를 지급하지 않았음을 이유로 하는 토지소유자의 지상권소멸청구는 이유가 없다[93다52297].

4. 법정지상권 성립 후 법률관계

(1) 토지가 양도된 경우

법정지상권은 물권이므로 관습상의 법정지상권자는 이를 취득할 당시의 토지소유자뿐만 아니라 토지소유권을 전득한 제3자에 대하여도 등기 없이 위 지상권을 주장할 수 있다[94다39925].

(2) 건물이 양도된 경우

① 지상권 등기 없이 건물만 양도된 경우

㉠ 건물양수인의 법정지상권 취득여부

관습상 법정지상권이 붙은 건물의 소유자가 건물을 제3자에게 처분한 경우에 법정지상권에 관한 등기를 경료하지 않은 자로서는 건물의 소유권을 취득한 사실만 가지고는 법정지상권을 취득하였다고 할 수 없고 그 법정지상권은 여전히 당초의 법정지상권자에게 유보되어 있다. 이 경우 건물양수인은 건물양도인을 순차 대위하여 토지소유자에 대하여 건물소유자였던 법정지상권자에의 법정지상권설정등기절차 이행을 청구할 수 있다[80다2873]. 또한 법정지상권이 붙은 건물의 양수인은 법정지상권자인 양도인의 갱신청구권을 대위 행사할 수 있다[94다39925].

㉡ 건물철거 및 대지인도청구 여부

법정지상권을 가진 건물소유자로부터 건물을 양수하면서 법정지상권까지 양도받기로 한 자에 대하여 대지소유자가 소유권에 기하여 건물철거를 구함은 신의성실의 원칙상 허용될 수 없다[84다카1131,1132].

㉢ 건물양수인의 부당이득반환의무

법정지상권이 있는 건물의 양수인으로서 장차 법정지상권을 취득할 지위에 있어 대지 소유자의 건물철거나 대지인도청구를 거부할 수 있다하더라도 그 대지를 점유·사용함으로 인하여 얻은 이득은 부당이득으로서 대지소유자에게 반환할 의무가 있다[96다34665].

② 건물을 경락받은 경우

건물소유를 위해 법정지상권을 취득한 자로부터 경매에 의해 건물소유권을 이전받은 경락인은 법정지상권도 당연히 이전받은 것이다(⇨ 건물의 경락취득과 함께 위 지상권도 등기없이 당연히 취득한다[84다카1578]).

제 2 절 지역권(地役權)

Ⅰ 의 의

제291조(지역권의 내용) 지역권자는 일정한 목적을 위하여 타인의 토지를 자기 토지의 편익에 이용하는 권리가 있다.

① 지역권이 성립하기 위해서는 편익을 받는 토지(요역지)와 편익을 주는 토지(승역지)가 있어야 한다. 요역지는 1필지 토지 전부이어야 하나, 승역지는 1필의 토지 일부라도 상관없다.

② 지역권의 성립 및 존속에 요역지와 승역지의 두 토지의 존재가 필요하다. 지역권은 대체로 인접하는 토지 사이에서 설정되지만, 반드시 두 토지가 인접할 필요는 없다.

판 례

요역지 존재의 증명책임

지역권은 일정한 목적을 위하여 타인의 토지를 자기의 토지의 편익에 이용하는 용익물권으로서 요역지와 승역지 사이의 권리관계에 터잡은 것이므로 피고가 이 사건 토지들에 대하여 통행지역권을 주장하려면 위 토지들의 통행으로 편익을 얻는 요역지가 있음을 주장·증명하여야 한다(대판 1993. 8. 24. 92다19804).

③ 편익의 종류에는 제한이 없다(통행, 인수, 관망 등).

Ⅱ 지역권의 법률적 성질

1. 부종성

제292조(부종성) ② 지역권은 요역지와 분리하여 양도하거나 다른 권리의 목적으로 하지 못한다.

지역권은 요역지소유권의 종된권리이므로 지역권을 요역지와 분리하여 양도하거나 다른 권리의 목적으로 하지 못한다. 따라서 지역권이 설정된 후에 요역지 위에 지상권 · 전세권 · 임차권을 취득한자는 당연히 지역권을 행사할 수 있다.

2. 수반성

제292조(부종성) ① 지역권은 요역지소유권에 부종하여 이전하며 또는 요역지에 대한 소유권 이외의 권리의 목적이 된다. 그러나 다른 약정이 있는 때에는 그 약정에 의한다.

3. 불가분성

(1) 공유관계의 불가분성

① 지역권 취득의 불가분성

제295조(취득과 불가분성) ① 공유자의 1인이 지역권을 취득한 때에는 다른 공유자도 이를 취득한다.

② 지역권 소멸의 불가분성

제293조(공유관계, 일부양도와 불가분성) ① 토지공유자의 1인은 지분에 관하여 그 토지를 위한 지역권 또는 그 토지가 부담한 지역권을 소멸하게 하지 못한다.

③ 소멸시효의 중단 · 정지와 불가분성

제296조(소멸시효의 중단, 정지와 불가분성) 요역지가 수인의 공유인 경우에 그 1인에 의한 지역권소멸시효의 중단 또는 정지는 다른 공유자를 위하여 효력이 있다.

④ 취득시효의 중단과 불가분성

제295조(취득과 불가분성) ② 점유로 인한 지역권취득기간의 중단은 지역권을 행사하는 모든 공유자에 대한 사유가 아니면 그 효력이 없다.

(2) 토지의 분할 · 일부양도의 불가분성

제293조(공유관계, 일부양도와 불가분성) ② 토지의 분할이나 토지의 일부양도의 경우에는 지역권은 요역지의 각 부분을 위하여 또는 그 승역지의 각 부분에 존속한다. 그러나 지역권이 토지의 일부분에만 관한 것인 때에는 다른 부분에 대하여는 그러하지 아니하다.

Ⅲ 지역권의 취득

1. 지역권설정계약과 등기

① 지역권설정계약

지역권도 물권이므로 지역권설정계약(물권적 합의)과 등기에 의해서 성립한다. 지역권은 두 토지의 이용을 조절하기 위한 것이므로 요역지 또는 승역지의 지상권자 · 전세권자 · 임차인도 그 물권의 범위 내에서 지역권설정계약의 당사자가 될 수 있다.

판 례

도로를 개설하여 영구히 사용케 한다는 약정을 지역권설정에 관한 합의로 본 원심을 수긍한 사례

피고가 피고 소유의 토지에 도로를 개설하여 원고로 하여금 영구히 사용케 한다고 약정하고 그 대금을 수령한 경우, 위 약정을 지역권설정에 관한 합의라고 본 원심을 수긍한 사례(대판 1980. 1. 29. 79다1704), 즉 자기 소유의 토지에 도로를 개설하여 타인에게 영구적으로 사용하도록 약정하고 대금을 수령하는 것은 지역권설정에 관한 합의이다.

② **지료** : 지료의 지급은 지역권의 요소가 아니다.

③ **존속기간** : 민법은 지역권의 존속기간에 대하여 아무런 규정이 없으나 당사자의 약정으로 존속기간을 정할 수도 있고 영구적인 지역권의 설정도 인정된다.

2. 지역권의 시효취득

제294조(지역권취득기간) 지역권은 계속되고 표현된 것에 한하여 제245조의 규정(등기)을 준용한다.

① 지역권은 계속되고 표현된 것에 한하여 시효취득이 인정된다.

② 통행지역권을 시효취득하려면 요역지의 소유자가 타인의 토지를 20년간 통행하였다는 사실만으로는 부족하고, 요역지의 소유자가 승역지상에 통로를 개설하여 승역지를 사용하고 있는 객관적 상태가 민법 제245조에 규정된 기간(20년) 계속한 사실이 있어야 한다[78다2482].

③ 통행지역권을 취득시효한 경우에도 주위토지통행권의 경우와 마찬가지로 요역지소유자는 승역지에 대한 도로 설치 및 사용에 의하여 승역지소유자가 입은 손해를 보상하여야 한다[2012다17479].

④ 토지의 불법점유자는 그 토지를 사용할 정당한 권원이 없는 자이므로 토지소유권의 상린관계로서 주위토지통행권이나 통행지역권을 시효취득할 수 없다[76다1694].

Ⅳ 지역권의 효력

1. 지역권자의 권리

지역권자는 설정행위의 내용에 따라 승역지를 자기토지의 편익에 이용할 수 있다.

2. 용수지역권

제297조(용수지역권) ① 용수승역지의 수량이 요역지 및 승역지의 수요에 부족한 때에는 그 수요 정도에 의하여 먼저 가용(家用)에 공급하고 다른 용도에 공급하여야 한다. 그러나 설정행위에 다른 약정이 있는 때에는 그 약정에 의한다.
② 승역지에 수개의 용수지역권이 설정된 때에는 후순위의 지역권자는 선순위의 지역권자의 용수를 방해하지 못한다.

3. 공작물의 공동사용

제300조(공작물의 공동사용) ① 승역지의 소유자는 지역권의 행사를 방해하지 아니하는 범위내에서 지역권자가 지역권의 행사를 위하여 승역지에 설치한 공작물을 사용할 수 있다.
② 전항의 경우에 승역지의 소유자는 수익정도의 비율로 공작물의 설치, 보존의 비용을 분담하여야 한다.

4. 승역지소유자의 의무

(1) **부작위의무** : 승역지소유자는 지역권자의 지역권행사를 인용하고 그 범위에서 자신의 토지를 이용하지 않을 부작위의무를 부담한다. 지역권자가 승역지소유자가 설치한 설비를 이용할 권리를 가지는 경우에는 승역지소유자는 이 설비를 함부로 변경해서는 안될 의무를 진다.

(2) **특별승계인의 의무부담**

제298조(승역지소유자의 의무와 승계) 계약에 의하여 승역지소유자가 자기의 비용으로 지역권의 행사를 위하여 공작물의 설치 또는 수선의 의무를 부담한 때에는 승역지소유자의 특별승계인도 그 의무를 부담한다.

(3) **위기에 의한 부담면제**

제299조(위기에 의한 부담면제) 승역지의 소유자는 지역권에 필요한 부분의 토지소유권을 지역권자에게 위기하여 제298조의 부담을 면할 수 있다.

① '위기(委棄)'란 해당 부분의 토지소유권을 무상으로 지역권자에게 이전한다는 일방적 의사표시이다. 따라서 위기에 의해 당연히 해당 토지의 소유권이 이전되는 것이 아니고, 소유권이전등기를 하여야 소유권이 이전한다.

② 위기에 의해 승역지의 소유권이 지역권자에게 이전하면 지역권은 혼동으로 소멸한다.

5. 지역권에 기한 물권적 청구권

지역권에는 승역지를 점유할 수 있는 권능이 없으므로 지역권자에게는 점유보호청구권이나 지역권에 기한 목적물반환청구권은 인정되지 않고, 방해제거청구권과 방해예방청구권만 인정되는 것이다.

제 3 절 전세권(傳貰權)

Ⅰ 서 설

1. 의 의

제303조(전세권의 내용) ① 전세권자는 전세금을 지급하고 타인의 부동산을 점유하여 그 부동산의 용도에 좇아 사용 · 수익하며, 그 부동산 전부에 대하여 후순위권리자 기타 채권자보다 전세금의 우선변제를 받을 권리가 있다.
제318조(전세권자의 경매청구권) 전세권설정자가 전세금의 반환을 지체한 때에는 전세권자는 민사집행법의 정한 바에 의하여 전세권의 목적물의 경매를 청구할 수 있다.

2. 전세권의 법적 성질

민법상의 전세권은 그 성질상 용익물권적 성격과 담보물권적 성격을 겸비한 것으로서, 전세권의 존속기간이 만료되면 전세권의 용익물권적 권능은 전세권설정등기의 말소 없이도 당연히 소멸하고 단지 전세금반환채권을 담보하는 담보물권적 권능의 범위 내에서 전세금의 반환시까지 그 전세권설정등기의 효력이 존속하고 있다[2003다35659].

Ⅱ 전세권의 성립

1. 객 체

건물과 토지는 전세권의 목적이 될 수 있지만 농경지는 전세권의 목적이 될 수 없다. 1필의 토지 또는 1동의 건물의 일부도 전세권의 목적이 될 수 있으나 지분에는 전세권을 설정할 수 없다.

2. 전세권설정계약과 등기

① 전세권은 부동산물권이므로 전세권설정자(부동산소유자)와 전세권자 사이의 설정계약과 설정등기에 의해 성립한다.

② 그리고 전세권은 다른 담보권과 마찬가지로 전세권자와 전세권설정자 및 제3자 사이에 합의가 있으면 그 전세권자의 명의를 제3자로 하는 것도 가능하므로, 임대차계약에 바

탕을 두고 이에 기한 임차보증금반환채권을 담보할 목적으로 임대인, 임차인 및 제3자 사이의 합의에 따라 제3자명의로 경료된 전세권설정등기는 유효하다[2003다12311].

③ 또한 전세권이 용익물권적인 성격과 담보물권적인 성격을 모두 갖추고 있는 점에 비추어 전세권 존속기간이 시작되기 전에 마친 전세권설정등기도 특별한 사정이 없는 한 유효한 것으로 추정된다[2017마1093].

3. 전세금의 지급

(1) 의 의

① 전세권설정시 전세권자가 전세권설정자에게 교부하였다가 전세권소멸시에 반환받는 금전을 말한다.

② 전세금의 지급은 전세권 성립의 요소이다.

③ 전세금은 등기사항이며 등기된 금액에 한해서만 제3자에게 대항할 수 있다.

(2) 전세금지급방법

전세금의 지급이 반드시 현실적으로 수수되어야 하는 것은 아니고 기존의 채권으로 전세금의 지급에 갈음할 수 있다[94다18508].

4. 전세목적물의 인도

① 목적부동산의 인도는 전세권의 성립요건이 아니다[94다18508].

② 따라서 당사자가 주로 채권담보의 목적으로 전세권을 설정하였고 그 설정과 동시에 목적물을 인도하지 않은 경우라 하더라도 장차 전세권자가 목적물을 사용·수익하는 것을 완전히 배제하는 것이 아니라면 그 전세권의 효력을 부인할 수 없다[94다18508].

Ⅲ 존속기간

1. 설정행위로 존속기간을 정하는 경우

(1) 최장존속기간의 제한

> **제312조(전세권의 존속기간)** ① 전세권의 존속기간은 10년을 넘지 못한다. 당사자의 약정기간이 10년을 넘는 때에는 이를 10년으로 단축한다.

최장기간의 제한은 건물의 전세권은 물론 토지의 전세권에도 적용된다.

(2) 최단존속기간 제한

> **제312조(전세권의 존속기간)** ② 건물에 대한 전세권의 존속기간을 1년 미만으로 정한 때에는 이를 1년으로 한다.

최단기간의 제한은 건물의 전세권에만 적용되고 토지전세권의 경우에는 최단기간의 제한이 없다.

2. 설정행위로 존속기간을 정하지 않는 경우

> **제313조(전세권의 소멸통고)** 전세권의 존속기간을 약정하지 아니한 때에는 각 당사자는 언제든지 상대방에 대하여 전세권의 소멸을 통고할 수 있고 상대방이 이 통고를 받은 날로부터 6월이 경과하면 전세권은 소멸한다.

3. 전세권의 갱신

(1) 합의에 의한 갱신(약정갱신)

> **제312조(전세권의 존속기간)** ③ 전세권의 설정은 이를 갱신할 수 있다. 그 기간은 갱신한 날로부터 10년을 넘지 못한다.

(2) 건물전세권의 법정갱신(묵시적 갱신 ; 默示的 更新)

① 건물의 전세권설정자가 전세권의 존속기간 만료 전 6월부터 1월까지 사이에 전세권자에 대하여 갱신거절의 통지 또는 조건을 변경하지 아니하면 갱신하지 아니한다는 뜻의 통지를 하지 아니한 경우에는 그 기간이 만료된 때에 전(前)전세권과 동일한 조건으로 다시 전세권을 설정한 것으로 본다(제312조 제4항).

② 전세권의 법정갱신은 건물전세권에만 인정되고 토지전세권에는 적용되지 않는다.

③ 이 경우 전세권의 존속기간은 그 정함이 없는 것으로 본다(제312조 제4항).

④ 건물전세권의 법정갱신은 법률의 규정에 의한 부동산물권의 변동이므로 등기하지 않고도 전세권설정자나 제3자에게 전세권을 주장할 수 있다[88다카21029].

Ⅳ 전세권의 효력

1. 대항력

전세권은 물권으로 대항력이 인정되므로 전세권이 성립한 후 목적물의 소유권이 이전된 경우 전세권은 전세권자와 신소유자 사이에서 계속 동일한 내용으로 존속하게 된다. 따라서

목적물의 신소유자는 전세권이 소멸하는 때에 전세권자에 대하여 전세권설정자의 지위에서 전세금반환의무를 부담하고, 구소유자는 전세권설정자의 지위를 상실하여 전세금반환의무를 면한다[99다15122, 2006다6072].

2. 전세권의 효력이 미치는 범위

① 건물전세권의 지상권, 임차권에 대한 효력

> **제304조(건물의 전세권, 지상권, 임차권에 대한 효력)** ① 타인의 토지에 있는 건물에 전세권을 설정한 때에는 전세권의 효력은 그 건물의 소유를 목적으로 한 지상권 또는 임차권에 미친다.
> ② 전항의 경우에 전세권설정자는 전세권자의 동의 없이 지상권 또는 임차권을 소멸하게 하는 행위를 하지 못한다.

㉠ 타인의 토지 위에 있는 건물에 전세권이 설정된 경우에, 전세권은 건물소유자가 가지는 건물소유를 목적으로 하는 지상권 또는 토지임차권에 미친다(제304조 제1항).

㉡ 또한 타인의 토지 위의 건물에 전세권을 설정해 준 사람은 전세권자의 이익을 보호하여야 하므로, 전세권자의 동의 없이는 지상권이나 토지임차권을 소멸시키는 처분행위를 하지 못한다(동조 제2항).

② 법정지상권

> **제305조(건물의 전세권과 법정지상권)** ① 대지와 건물이 동일한 소유자에 속한 경우에 건물에 전세권을 설정한 때에는 그 대지소유권의 특별승계인은 전세권설정자(전세권자가 아님)에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다. 그러나 지료는 당사자의 청구에 의하여 법원이 이를 정한다.

3. 전세권자의 유지 · 수선의무

> **제309조(전세권자의 유지 · 수선의무)** 전세권자(전세권설정자가 아님)는 목적물의 현상을 유지하고 그 통상의 관리에 속한 수선을 하여야 한다.

따라서 전세권자는 필요비를 지출한 경우에도 그 비용의 상환을 청구하지 못하고, 단지 유익비상환청구권만 인정된다(제310조 제1항).

4. 상린관계

전세권은 부동산을 이용하는 권리이므로 전세권자간 또는 전세권자와 인지소유자, 지상권자 간에도 상린관계에 관한 규정이 준용된다(제319조).

5. 물권적 청구권

전세권이 침해된 경우 전세권자는 전세권에 기한 물권적 청구권을 행사할 수 있다(제319조). 또한 전세권은 부동산을 점유할 권리를 포함하므로 그 점유를 침해당한 경우에는 점유보호 청구권을 행사할 수 있다.

6. 전세금증감청구권

제312조의2 (전세금 증감청구권) 전세금이 목적부동산에 관한 조세 · 공과금 기타 부담의 증감이나 경제사정의 변동으로 인하여 상당하지 아니하게 된 때에는 당사자는 장래에 대하여 그 증감을 청구할 수 있다. 그러나 증액의 경우에는 대통령령이 정하는 기준에 따른 비율을 초과하지 못한다.

Ⅴ 전세권의 처분

1. 처분의 자유와 제한

① 전세권자는 전세권을 전세권설정자의 동의 없이 타인에게 양도 또는 담보로 제공할 수 있고 그 존속기간 내에서 그 목적물을 타인에게 전전세(轉傳貰) 또는 임대하여 투하자본의 회수를 가능케 한다(제306조 본문).

② 그러나 당사자는 설정행위로 처분금지를 약정할 수 있는데 이를 등기하면 이로써 제3자에게 대항할 수 있다(제306조 단서).

2. 전세금반환채권을 전세권과 분리하여 양도할 수 있는지 여부

① 전세권이 존속하는 동안은 전세권을 존속시키기로 하면서 전세금반환채권만을 전세권과 분리하여 확정적으로 양도하는 것은 허용되지 않으며 전세권존속 중에는 장래에 그 전세권이 소멸하는 경우에 전세금반환채권이 발생하는 것을 조건으로 그 장래의 조건부채권을 양도할 수 있을 뿐이다[2001다69122].

② 그러나 전세권의 존속기간이 만료되거나 전세계약의 합의해지 등으로 담보물권적 권능만 남은 전세권을 전세금반환채권과 함께 양도하거나 전세권과는 별도로 전세금반환채권만의 양도도 가능하다[2003다35659].

3. 전세권의 담보제공

① 전세권은 저당권의 목적이 될 수 있다.

② 전세권이 기간만료로 종료된 경우 저당권 실행방법

㉠ 전세권에 대하여 저당권이 설정된 경우 전세권의 존속기간이 만료되면 전세권은 전

세권설정등기의 말소등기 없이도 당연히 소멸하므로 더 이상 전세권 자체에 대하여 저당권을 실행할 수 없게 된다[98다31301].

㉡ 따라서 이러한 경우에는 저당권의 목적물인 전세권에 갈음하여 존속하는 것으로 볼 수 있는 전세금반환채권에 대하여 물상대위권을 행사하여 압류 및 추심명령 또는 전부명령을 받는 등의 방법으로 전세권설정자에 대해 전세금의 지급을 구할 수 있다[98다31301].

5. 전전세(轉傳貰)

(1) 의 의

전세권자의 전세권을 기초로 하여 전세권의 범위 내에서 그 전세목적물에 대하여 전세권을 다시 설정하는 것을 말한다(제306조, 제308조).

(2) 성립요건

① 전전세권도 물권이므로 그 설정에는 물권적 합의와 등기가 필요하고 전전세에 있어서도 전전세금을 지급해야 하나 전전세금은 원전세금을 초과할 수 없다.

② 전전세의 당사자는 원전세권자(전전세권설정자)와 전전세권자이고 원전세권설정자의 동의는 불필요하다.

③ 존속기간은 원전세권의 존속기간 내여야 하므로 원전세권의 존속기간을 초과하는 부분은 무효이다.

(3) 효 력

① 전전세권이 설정되더라도 원전세권은 소멸하지 않고 존속하고 원전세권자는 전전세권이 존속하는 동안 원전세권을 소멸시키지 못한다.

② 그러나 원전세권설정자와 전전세권자 사이에는 직접적인 권리 · 의무가 없다.

③ 전세권자는 전전세하지 아니하였으면 면할 수 있는 불가항력으로 인한 손해에 대하여 그 책임을 부담한다(제308조).

(4) 전전세권의 소멸

① 전전세권이 소멸한 때에는 전전세권설정자(원전세권자)는 전전세권자로부터 그 목적물의 인도 및 전전세권설정등기의 말소등기에 필요한 서류의 교부를 받는 동시에 전전세금을 반환해야 한다(제317조).

② 따라서 전전세권이 소멸했는데도 전전세권설정자(원전세권자)가 전세금의 반환을 지체하는 때에는 전전세권자도 경매를 청구할 수 있다. 다만, 원전세권도 소멸하고 또한 원전세권설정자가 원전세권자(전전세권설정자)에 대해 전세금반환을 지체한 때에만 경매를 청구할 수 있는 제한이 있다(제318조).

Ⅵ 전세권의 소멸

1. 소멸사유

① 목적부동산의 멸실, 전세권설정자의 소멸청구, 전세권의 소멸통고, 존속기간의 만료, 약정된 소멸사유의 발생, 소멸시효의 완성, 혼동, 공용수용 등에 의해 소멸한다.

② 전세권설정자의 소멸청구

> **제311조(전세권의 소멸청구)** ① 전세권자가 전세권설정계약 또는 그 목적물의 성질에 의하여 정하여진 용법으로 이를 사용, 수익하지 아니한 경우에는 전세권설정자는 전세권의 소멸을 청구할 수 있다.
> ② 용법에 따른 사용 · 수익을 하지 않은 경우에 전세권설정자는 전세권자에 대하여 원상회복 또는 손해배상을 청구할 수 있다.

전세권설정자의 전세권의 소멸청구는 형성권의 행사이므로 등기 없이도 법률의 규정에 의하여 전세권 소멸의 효과가 발생한다.

③ 전세권의 소멸통고

> **제313조(전세권의 소멸통고)** 전세권의 존속기간을 약정하지 아니한 때에는 각 당사자는 언제든지 상대방에 대하여 전세권의 소멸을 통고할 수 있고 상대방이 이 통고를 받은 날로부터 6월이 경과하면 전세권은 소멸한다.

2. 목적부동산의 멸실

① 불가항력으로 인한 멸실

> **제314조(불가항력으로 인한 멸실)** ① 전세권의 목적물의 전부 또는 일부가 불가항력으로 인하여 멸실된 때에는 그 멸실된 부분의 전세권은 소멸한다.
> ② 불가항력으로 인한 일부멸실의 경우에 전세권자가 그 잔존부분으로 전세권의 목적을 달성할 수 없는 때에는 전세권설정자에 대하여 전세권 전부의 소멸을 통고하고 전세금의 반환을 청구할 수 있다.

② 전세권자의 책임있는 사유로 인한 멸실

> **제315조(전세권자의 손해배상책임)** ① 전세권의 목적물의 전부 또는 일부가 전세권자에 책임있는 사유로 인하여 멸실된 때에는 전세권자는 손해를 배상할 책임이 있다.
> ② 전항의 경우에 전세권설정자는 전세권이 소멸된 후 전세금으로써 손해의 배상에 충당하고 잉여가 있으면 반환하여야 하며 부족이 있으면 다시 청구할 수 있다.

Ⅶ 전세권소멸의 효과

1. 전세권소멸과 동시이행

제317조(전세권의 소멸과 동시이행) 전세권이 소멸한 때에는 전세권설정자는 전세권자로부터 그 목적물의 인도 및 전세권설정등기의 말소등기에 필요한 서류의 교부를 받는 동시에 전세금을 반환하여야 한다.

① 전세권이 소멸하면 전세권자의 목적부동산의 인도 및 전세권설정등기를 말소해야 할 의무와 전세권설정자의 전세금반환의무는 동시이행관계에 있다.

② 따라서 전세권자가 그 목적물을 인도하였다고 하더라도 전세권설정등기의 말소등기에 필요한 서류를 교부하거나 그 이행의 제공을 하지 않는 이상 전세권설정자는 전세금의 반환을 거부할 수 있고, 이 경우 다른 특별한 사정이 없는 한 그가 전세금에 대한 이자 상당액의 이득을 법률상 원인 없이 얻는다고 볼 수 없다[2001다62091].

2. 전세권자의 경매청구권

제318조(전세권자의 경매청구권) 전세권설정자가 전세금의 반환을 지체한 때에는 전세권자는 민사집행법의 정한 바에 의하여 전세권의 목적물의 경매를 청구할 수 있다.

3. 전세금의 우선변제권

전세권자는 목적물 전부에 대하여 후순위권리자 기타 채권자보다 전세금의 우선변제를 받을 권리가 있다(제303조 제1항 후단).

4. 전세권이 1동의 건물 일부 위에 설정된 경우

① 건물의 일부에 대하여 전세권이 설정되어 있는 경우, 건물 전부(전세권의 목적물이 아닌 나머지 부분)에 대하여 경매를 청구할 수 없다[2001마212].

② 다만, 제303조 제1항 후단에 따라 제3자가 신청한 경매에서 건물 전부에 대한 경매대금에서 우선변제받을 수는 있다.

5. 전세권자의 원상회복의무 · 부속물수거권

제316조(원상회복의무, 매수청구권) ① 전세권이 그 존속기간의 만료로 인하여 소멸한 때에는 전세권자는 그 목적물을 원상에 회복하여야 하며 그 목적물에 부속시킨 물건은 수거할 수 있다.

6. 부속물매수청구권

제316조(원상회복의무, 매수청구권) ① 그러나 전세권설정자가 그 부속물건의 매수를 청구한 때에는 전세권자는 정당한 이유없이 거절하지 못한다.
② 전항의 경우에 그 부속물건이 전세권설정자의 동의를 얻어 부속시킨 것인 때에는 전세권자는 전세권설정자에 대하여 그 부속물건의 매수를 청구할 수 있다. 그 부속물건이 전세권설정자로부터 매수한 것인 때에도 같다.

판 례

토지임차인의 지상물매수청구권에 관한 민법 제643조가 토지의 전세권에도 유추 적용되는지 여부(적극) 및 위 매수청구권의 행사요건

토지임차인의 건물 기타 공작물의 매수청구권에 관한 민법 제643조의 규정은 성질상 토지의 전세권에도 유추 적용될 수 있다고 할 것이지만, 그 매수청구권은 토지임차권 등이 건물 기타 공작물의 소유 등을 목적으로 한 것으로서 기간이 만료되어야 하고 건물 기타 지상시설이 현존하여야만 행사할 수 있는 것이다[2005다41740].

7. 유익비상환청구권

제310조(전세권자의 상환청구권) ① 전세권자가 목적물을 개량하기 위하여 지출한 금액 기타 유익비에 관하여는 그 가액의 증가가 현존한 경우에 한하여 소유자의 선택에 좇아 그 지출액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다.
② 유익비상환청구의 경우에 법원은 소유자의 청구에 의하여 상당한 상환기간을 허여할 수 있다.

CHAPTER

06 담보물권(擔保物權)

제 1 절 담보물권의 공통적 성질(통유성)

Ⅰ 부종성(附從性)

(1) 의 의

담보물권이 발생과 소멸에 있어서 피담보채권에 의존하는 성질을 말한다. 이는 담보물권의 피담보채권에 대한 종된 지위에서 비롯된다.

(2) 부종성의 내용

① 성립상의 부종성

피담보채권이 무효나 취소로 성립하지 않으면 담보물권도 성립하지 않는 성질을 말한다.

② 존속상의 부종성

피담보채권이 소멸하면 담보물권도 소멸하는 성질을 말하는데 이것은 법률의 규정에 의한 물권변동이므로 등기를 요하지 않는다.

Ⅱ 수반성(隨伴性)

① 담보물권의 수반성이란 피담보채권이 이전되면 담보물권도 따라서 이전되는 것을 말한다.

② 다만, 담보권의 수반성이란 피담보채권의 처분이 있으면 언제나 담보권도 함께 처분된다는 것이 아니라 특별한 사정이 없는 한 피담보채권의 처분에는 담보권의 처분도 당연히 포함된다고 보는 것이 합리적이라는 것일 뿐이므로 피담보채권의 처분이 있음에도 불구하고 담보권의 처분이 따르지 않는 특별한 사정이 있는 경우에는 채권양수인은 담보권이 없는 무담보의 채권을 양수한 것이 되고 채권의 처분에 따르지 않은 담보권은 소멸한다[2003다61542].

Ⅲ 불가분성(不可分性)

피담보채권 전부의 변제가 있을 때까지 목적물의 전부에 대하여 담보물권의 효력이 미치는 것을 말하는데 담보물권의 효력을 강화시킨다.

제 2 절 유치권(留置權)

Ⅰ 총 설

1. 의 의

> **제320조(유치권의 내용)** ① 타인의 물건 또는 유가증권을 점유한 자는 그 물건이나 유가증권에 관하여 생긴 채권이 변제기에 있는 경우에는 변제를 받을 때까지 그 물건 또는 유가증권을 유치할 권리가 있다.

유치권이란 타인의 물건 또는 유가증권을 점유한 자가 그 물건이나 유가증권에 관하여 생긴 채권이 변제기에 있는 경우에 변제를 받을 때까지 그 물건 또는 유가증권을 유치할 수 있는 권리를 말한다. 예컨대, 자동차를 수리한 자는 그 수리비의 지급을 받을 때까지 그 자동차를 유치(점유를 계속하고 인도를 거절)할 수 있는 권리가 있다.

2. 법적 성질

(1) 담보물권으로서의 성질

① 부종성 · 수반성

피담보채권이 없으면 유치권은 인정되지 않는다. 피담보채권과 점유가 이전되면 유치권도 이전되나 등기나 배서를 요하지 않고 유치권이전의 물권적 합의도 할 필요 없다.

② 불가분성

유치권자는 채권 전부의 변제를 받을 때까지 유치물 전부에 대하여 그 권리를 행사할 수 있다. 따라서 다세대주택의 창호 등의 공사를 완성한 하수급인이 공사대금채권 잔액을 변제받기 위하여 위 다세대주택 중 한 세대를 점유하여 유치권을 행사하는 경우, 그 유치권은 위 한 세대에 대하여 시행한 공사대금만이 아니라 다세대주택 전체에 대하여 시행한 공사대금채권의 잔액 전부를 피담보채권으로 하여 성립한다[2005다16942].

(2) 법정담보물권

① 유치권은 일정한 요건이 충족되면 법률에 의해 당연히 성립하는 법정담보물권이므로 부동산의 등기는 유치권의 성립요건이 아니다.

② 또한 유치권은 법정담보물권이므로 당사자 약정에 의하여 유치권을 성립시킬 수 없다.

(3) 인정되지 않는 성질

유치권에는 우선변제력이나 물상대위성은 인정되지 않는다. 또한 유치권은 점유를 상실하면 소멸하므로 추급력도 없다.

Ⅱ 유치권의 성립요건

1. 유치권의 목적물 - 타인의 물건

① 타인의 물건이면 족하므로 채무자뿐 아니라 제3자의 물건도 포함된다. 따라서 목적물이 채무자의 소유물임을 요하지 않는다. 또한 타인의 물건이면 부동산 일부에도 성립할 수 있다.

② 유치권이 타물권인 점에 비추어 볼 때 수급인의 재료와 노력으로 건축되었고 독립한 건물에 해당되는 기성부분은 수급인의 소유이므로 수급인은 공사대금을 지급받을 때까지 이에 대해 유치권을 가질 수 없다[91다14116].

③ 다만, 건물의 신축공사를 도급받은 수급인이 사회통념상 독립한 건물이라고 할 수 없는 정착물을 토지에 부착한 상태에서 공사가 중단된 경우에 위 정착물은 토지의 부합물에 불과하여 이러한 정착물에 대하여 유치권을 행사할 수 없다[2007마98].

2. 점 유

(1) 점유의 계속

① 점유는 유치권의 성립요건이자 존속요건이므로 점유를 상실하면 유치권도 소멸한다.

② 또한 유치권자의 점유는 직접점유이든 간접점유이든 관계가 없으나, 채무자를 직접점유자로 하는 간접점유는 유치권이 성립되지 않는다.

(2) 적법한 점유

① 점유가 적법한 점유이어야 한다. 따라서 점유개시가 불법행위로 인한 경우에는 유치권이 성립하지 않는다.

② 따라서 건물의 임차인이 임대차계약의 해지 또는 기간만료 후에 동시이행항변권에 기하지 않고서 그 건물을 점유하면서 필요비를 지출한 경우에는 그 필요비상환채권에 관한 유치권은 인정되지 않는다.

(3) 입증책임

물건의 점유자는 소유의 의사로 선의 · 평온 및 공연하게 점유한 것으로 추정되고, 점유자가 점유물에 대하여 행사하는 권리는 적법하게 보유하는 것으로 추정되므로, 점유물에 대한 유치권 주장을 배척하려면 적어도 점유가 불법행위로 인하여 개시되었거나 점유자가 비용을 지출할 당시 점유 권원이 없음을 알았거나 중대한 과실로 알지 못하였음을 상대방 당사자(유치권을 배척하려는 자)의 주장 · 증명이 있어야 한다[2009다 5162].

3. 물건에 관하여 생긴 채권(견련관계)

(1) 유치권이 성립되는 채권

① '그 물건에 관하여 생긴 채권'의 의미

'그 물건에 관하여 생긴 채권'은 공평의 원칙에 특별히 반하지 않는 한 채권이 목적물 자체로부터 발생한 경우는 물론이고 채권이 목적물의 반환청구권과 동일한 법률관계나 사실관계로부터 발생한 경우도 포함한다[2005다16942].

② 채권이 목적물 자체로부터 발생한 경우

목적물로 인해 지출된 필요비 · 유익비 등의 비용상환청구권, 수급인의 공사대금채권, 목적물로부터 받은 손해의 배상청구권과 같이 목적물이 원인이 되어 채권이 발생한 경우를 말한다.

(2) 유치권이 성립되지 않는 채권(견련관계가 인정되지 않는 경우)

① 임차인의 권리금반환청구권, 임차보증금반환청구권, 매매대금채권, 건축자재대금채권은 건물에 관하여 생긴 채권이라 할 수 없으므로 그와 같은 채권을 가지고 건물에 대한 유치권을 행사할 수 없다.

② 계약명의신탁에서 명의신탁자가 명의수탁자에게 제공한 부동산매수자금은 유치권 성립요건으로서의 목적물과 채권 사이의 견련관계를 인정할 수 없다[2008다34828].

③ 건물의 임대차에 있어서 임차인의 임대인에게 지급한 이나 임대인이 건물시설을 아니하기 때문에 임차인에게 건물을 임차목적대로 사용못한 것을 이유로 하는 손해배상청구권은 그 건물에 관하여 생긴 채권이라 할 수 없다[75다1305].

(3) 채권과 목적물의 점유와의 견련성 여부

목적물의 점유 중에 피담보채권이 발생할 것을 요하지 않는다. 따라서 물건의 점유 이전에 그 물건에 관련하여 채권이 발생한 후 그 물건의 점유를 취득한 경우에도 유치권이 성립한다[64다1977].

4. 채권의 변제기의 도래

① 피담보채권의 변제기 도래는 유치권에 있어서는 성립요건이므로 채권의 변제기가 도래하지 않는 동안에는 유치권이 성립하지 않는다.

② 따라서 유익비상환청구권에 대해 법원이 상당한 기간을 허여 해준 경우에는 유치권이 성립하지 않는다.

5. 유치권배제특약의 부존재

① 유치권은 법정담보물권이기는 하나 이를 포기하는 특약은 유효하고, 유치권을 사후에 포기한 경우 곧바로 유치권은 소멸한다고 보아야 한다[2010마1544]. 즉, 제320조는 임의규정이다.

② 유치권 배제 특약에 따른 효력은 특약의 상대방뿐 아니라 그 밖의 사람도 주장할 수 있다. 또한 유치권배제특약에도 조건을 붙일 수 있다[2016다234043].

③ 건물의 임차인이 임대차관계 종료시에는 건물을 원상으로 복구하여 임대인에게 명도하기로 약정한 것을 건물에 지출한 각종 유익비 · 필요비의 상환청구권을 미리 포기하기로 한 취지의 특약으로 보아 임차인의 유치권 주장을 배척한다[73다2010].

Ⅲ 유치권의 효력

1. 유치권자의 권리

(1) 목적물을 유치할 권리

> **제320조(유치권의 내용)** ① 타인의 물건 또는 유가증권을 점유한 자는 그 물건이나 유가증권에 관하여 생긴 채권이 변제기에 있는 경우에는 변제를 받을 때까지 그 물건 또는 유가증권을 유치할 권리가 있다.

① 대세권

유치권은 물권이므로 모든 사람에 대해 유치권을 주장할 수 있다.

② 변제청구와 유치권행사

민사집행법에서 정하는 매수인의 변제책임이란 목적물에 대한 물적 부담을 승계한다는 의미이고 인적 채무를 인수한다는 취지가 아니다. 그러므로 유치권자는 집행절차에서의 매수인에 대하여 피담보채권의 변제가 있을 때까지 유치목적물의 인도를 거절할 수 있을 뿐이고, 피담보채권의 변제를 청구할 권리는 없다(대판 1996.8.23. 95다8713).

③ 경매기입등기와의 관계

채무자소유의 건물 등 부동산에 경매개시결정의 기입등기가 되어 압류의 효력이 발생한 이후에 채무자가 위 부동산에 관한 공사대금채권자에게 그 점유를 이전함으로써 그로 하여금 유치권을 취득하게 한 경우, 점유자로서는 위 유치권을 내세워 그 부동산에 관한 경매절차의 매수인에게 대항할 수 없다. 그러나 경매로 인한 압류의 효력이 발생하기 전에 유치권을 취득한 경우에는 적용되지 아니한다[2010마1544].

④ 상환이행판결(相換履行判決)

물건의 인도를 청구하는 소송에서 피고의 유치권 항변이 인용되는 경우에는 그 물건에 관해 생긴 채권의 변제와 상환으로 그 물건의 인도를 명해야 된다[69다1592].

(2) 환가를 위한 경매권

제322조(경매, 간이변제충당) ① 유치권자는 채권의 변제를 받기 위하여 유치물을 경매할 수 있다.

이때의 경매는 우선변제를 위한 경매라기보다는 환가를 위한 경매의 성질을 띤다.

(3) 간이변제충당(簡易辨濟充當)

제322조(경매, 간이변제충당) ② 정당한 이유있는 때에는 유치권자는 감정인의 평가에 의하여 유치물로 직접 변제에 충당할 것을 법원에 청구할 수 있다. 이 경우에는 유치권자는 미리 채무자에게 통지하여야 한다.

법원이 간이변제충당 허가를 결정하면 유치권자는 그 유치물의 소유권을 취득하며, 이 경우에는 등기가 없어도 부동산물권이 변동한다(제187조).

(4) 과실수취권

제323조(과실수취권) ① 유치권자는 유치물의 과실을 수취하여 다른 채권보다 먼저 그 채권의 변제에 충당할 수 있다. 그러나 과실이 금전이 아닌 때에는 경매하여야 한다.
② 과실은 먼저 채권의 이자에 충당하고 그 잉여가 있으면 원본에 충당한다.

(5) 비용상환청구권

제325조(유치권자의 상환청구권) ① 유치권자가 유치물에 관하여 필요비를 지출한 때에는 소유자에게 그 상환을 청구할 수 있다.
② 유치권자가 유치물에 관하여 유익비를 지출한 때에는 그 가액의 증가가 현존한 경우에 한하여 소유자의 선택에 좇아 그 지출한 금액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다. 그러나 법원은 소유자의 청구에 의하여 상당한 상환기간을 허여할 수 있다.

유치권자의 비용상환청구권은 목적물에 관해 생긴 채권이므로 유치권자는 이를 피담보채권으로 해서 새로운 유치권을 행사할 수 있다[71다2414].

2. 유치권자의 의무

(1) 선관주의의무

제324조(유치권자의 선관의무) ① 유치권자는 선량한 관리자의 주의로 유치물을 점유하여야 한다.

선량한 관리자의 주의의무란 어떠한 물건이나 사무를 관리함에 있어 그 직업 또는 지위에 있는 자에게 일반적으로 요구되는 정도의 주의를 하여야 할 의무를 말하는 것으로, '자기 재산과 동일한 주의'보다 무거운 주의의무이다.

(2) 무단 사용, 대여, 담보제공 금지

제324조(유치권자의 선관의무) ② 유치권자는 채무자의 승낙 없이 유치물의 사용, 대여 또는 담보제공을 하지 못한다. 그러나 유치물의 보존에 필요한 사용은 채무자의 승낙없이 할 수 있다.

① 유치권자는 채무자의 승낙 없이 유치물의 사용, 대여 또는 담보제공을 하지 못한다. 따라서 유치권자는 채무자의 승낙이 없는 이상 그 목적물을 타에 임대할 수 있는 처분 권한이 없으므로, 소유자의 동의 없이 유치권자로부터 유치권의 목적물을 임차한 자의 점유는 '경락인에게 대항할 수 있는 권원'이 아니다[2002마3516].

② 그러나 채무자의 승낙이 있으면 유치물을 사용, 대여 또는 담보제공할 수 있으며, 유치물의 보존에 필요한 사용은 채무자의 승낙 없이 할 수 있다.

③ 공사대금채권에 기하여 유치권을 행사하는 자가 스스로 유치물인 주택에 거주하며 사용하는 것은 특별한 사정이 없는 한 유치물의 보존에 필요한 사용에 해당하므로, 그러한 경우에는 유치권의 소멸을 청구할 수 없다. 그리고 유치권자가 유치물의 보존에 필요한 사용을 한 경우에도 특별한 사정이 없는 한 차임에 상당한 이득을 소유자에게 반환할 의무가 있다[2011다107009].

(3) 의무위반의 효과

제324조(유치권자의 선관의무) ③ 유치권자가 의무에 위반한 때에는 채무자는 유치권의 소멸을 청구할 수 있다.

① 유치권자가 채무자의 승낙 없이 목적물을 사용 · 임대 · 담보제공한 경우(제324조 제2항), 그것만으로 유치권이 소멸하는 것은 아니고 채무자의 유치권소멸청구가 있어야 비로소 소멸한다(제324조 제3항).

② 하나의 채권을 피담보채권으로 하여 여러 필지의 토지에 대하여 유치권을 취득한 유치권자가 그중 일부 토지에 대하여 선량한 관리자의 주의의무를 위반하였다면 특별한 사정이 없는 한 위반행위가 있었던 필지의 토지에 대하여만 유치권소멸청구가 가능하다[2018다301350].

Ⅳ 유치권의 소멸

1. 일반적 소멸원인

(1) 물권 공통의 소멸사유

목적물의 멸실, 혼동, 공용수용, 포기, 몰수 등이 있다. 그러나 유치권이 시효로 소멸하는 일은 없다. 목적물에 대한 타인의 시효취득으로 유치권이 소멸하는 일도 없다.

(2) 유치권행사와 피담보채권의 소멸시효

제326조(피담보채권의 소멸시효) 유치권의 행사는 채권의 소멸시효의 진행에 영향을 미치지 아니한다.

2. 유치권에 특유한 소멸사유

(1) 유치권자의 의무위반과 유치권소멸청구(형성권)

제324조(유치권자의 선관의무) ③ 유치권자가 의무에 위반한 때에는 채무자는 유치권의 소멸을 청구할 수 있다.

(2) 다른 담보의 제공과 유치권소멸청구(청구권)

제327조(타담보제공과 유치권소멸) 채무자는 상당한 담보를 제공하고 유치권의 소멸을 청구할 수 있다.

① 제327조의 유치권 소멸청구는 채무자뿐만 아니라 유치물의 소유자도 할 수 있고 다른 담보의 제공에 대해 유치권자의 승낙 또는 이에 갈음하는 판결이 있어야만 유치권이 소멸된다.

② 민법 제327조에 따라 채무자나 소유자가 제공하는 담보는 유치물 가액이 피담보채권액보다 많을 경우에는 피담보채권액에 해당하는 담보를 제공하면 되고, 유치물 가액이 피담보채권액보다 적을 경우에는 유치물 가액에 해당하는 담보를 제공하면 된다[2019다216077].

3. 점유의 상실

제328조(점유상실과 유치권소멸) 유치권은 점유의 상실로 인하여 소멸한다.

점유침탈에 대해 점유회수의 소를 제기하여 승소판결을 받아 점유를 회복하면 점유를 상실하지 않았던 것으로 되어 유치권이 되살아나지만, 점유회수의 소를 제기하여 점유를 회복할 수 있다는 사정만으로는 유치권이 되살아나지 않는다.

제 3 절 저당권(抵當權)

Ⅰ 총 설

1. 의 의

저당권이란 채무자 또는 물상보증인이 채무의 담보로 제공한 부동산 기타의 목적물을 채권자가 인도받지 아니하고 그 목적물을 관념적으로만 지배하며 채무불이행시에 그 목적물로부터 우선변제를 받는 담보물권을 말한다(제360조).

2. 저당권의 법적 성질

(1) **저당권의 특질**

① **약정담보물권** : 저당권은 원칙적으로 당사자의 계약에 의해 성립하는 약정담보물권이고, 예외적으로 법률의 규정에 의해 성립하는 법정저당권이 인정된다(제649조).

② **우선변제권** : 저당권은 목적물로부터 다른 채권자나 후순위권자보다 우선변제를 받는 것을 본질로 하는 담보물권이다.

(2) **담보물권으로서의 공통적 성질**

저당권은 타인소유 부동산을 목적으로 하는 타물권(他物權)이며, 수반성 · 불가분성 · 물상대위성도 인정된다.

Ⅱ 저당권의 성립

1. 약정저당권의 성립

(1) **저당권설정계약**

① **의의** : 저당권의 설정을 목적으로 하는 당사자간의 물권적 합의를 말한다. 저당권은 채권의 존재를 필요로 하므로 저당권설정계약은 종된 계약이다. 저당권설정계약은 불요식이며, 조건이나 기한을 붙일 수 있다.

② **당사자**

㉠ **저당권자** : 원칙적으로 피담보채권의 채권자에 한한다. 따라서 근저당권설정계약상의 채무자 아닌 제3자를 채무자로 하여 된 근저당권설정등기는 채무자를 달리 한 것이므로 근저당권의 부종성에 비추어 원인 없는 무효의 등기이다[80다1468]. 그러나 채권담보를 위해 저당권을 설정하는 경우 제3자명의로 저당권등기를 하는 데 대해 채권자와 채무자 및 제3자 사이에 합의가 있었고, 나아가 제3자에게 그 채권이 실질적으로 귀속되었다고 볼 수 있는 특별한 사정이 있는 경우에는 제3자명의의 저당권등기도 유효하다[94다33583].

㉡ **저당권설정자** : 저당권설정자는 채무자 뿐만 아니라 제3자도 될 수 있다. 이 때 제3자를 물상보증인이라 한다. 또한 저당권설정행위는 처분행위에 해당하므로, 저당권설정자는 원칙적으로 그 소유자이어야 한다.

(2) 저당권설정등기

① **의의** : 저당권설정의 등기를 해야 저당권이 성립한다. 채권액과 채무자는 반드시 기재해야 한다.

② **무효등기의 유용** : 무효로 된 처음의 근저당권설정등기를 당사자가 유용하기로 합의하고 새로 거래를 계속하는 경우 유용합의 이전에 등기부상 이해관계 있는 제3자가 없는 때에는 그 근저당권설정등기는 유효하다[74다482].

③ **불법말소된 경우**

㉠ 등기는 물권의 효력발생요건이지 그 존속요건은 아니므로 물권에 관한 등기가 원인 없이 말소된 경우에는 그 물권의 효력에는 아무런 변동이 없고, 그 회복등기가 마쳐지기 전이라도 말소된 등기의 등기명의인은 적법한 권리자로 추정된다[87다카2431, 2000다59678].

㉡ 불법말소된 저당권이 회복등기되기 전에 저당목적물이 경매절차에서 경락되었다면 저당권은 당연히 소멸하여 저당권등기는 말소회복등기를 할 수 없다(대판 1998.10.2. 98다27197).

④ **피담보채권 소멸 후 저당권이전의 부기등기** : 피담보채권이 소멸하면 저당권은 그 부종성에 의하여 당연히 소멸하게 되므로, 그 말소등기가 경료되기 전에 그 저당권부채권을 가압류하고 압류 및 전부명령을 받아 저당권이전의 부기등기를 경료한 자라 할지라도, 그 근저당권을 취득할 수 없다[2002다27910].

(3) 피담보채권

① **피담보채권의 모습** : 피담보채권은 금전채권임이 보통이지만 반드시 금전채권이어야 하는 것은 아니다.

② **장래의 채권** : 조건부채권 · 기한부채권 기타 장래에 발생할 특정의 채권을 위하여 저당권을 설정할 수 있다.

3. 법정저당권의 성립

제649조(임차지상의 건물에 대한 법정저당권) 토지임대인이 변제기를 경과한 최후 2년의 차임채권에 의하여 그 지상에 있는 임차인소유의 건물을 압류한 때에는 저당권과 동일한 효력이 있다.

법률규정에 의한 물권변동이므로 저당권설정등기를 요하지 않는다. 법정저당권의 성립시기는 압류등기를 한 때이다.

Ⅲ 저당권의 효력이 미치는 범위

1. 피담보채권의 범위

제360조(피담보채권의 범위) 저당권은 원본, 이자, 위약금, 채무불이행으로 인한 손해배상 및 저당권의 실행비용을 담보한다. 그러나 지연배상에 대하여는 원본의 이행기일을 경과한 후의 1년분에 한하여 저당권을 행사할 수 있다.

① 피담보채권의 범위에 관한 제360조는 채무자를 보호하기 위한 것이 아니라 후순위권리자나 저당목적물에 관하여 이해관계 있는 제3자의 이익을 보호하기 위한 것이다.

② 따라서 저당채무자가 변제하는 경우에는 채무 전액을 변제하여야 하고, 제360조에 다른 피담보채무의 제한을 주장하지 못한다.

2. 목적물의 범위

(1) 종물 · 부합물

제358조(저당권의 효력의 범위) 저당권의 효력은 저당부동산에 부합된 물건과 종물에 미친다. 그러나 법률에 특별한 규정 또는 설정행위에 다른 약정이 있으면 그러하지 아니하다.

① 저당부동산에 부합된 물건과 종물이 저당권설정의 전후를 불문하고, 또한 등기 여부도 불문하고 저당권의 효력은 그 부합물과 종물에 미친다.

② 위 제358조는 임의규정이므로 부합물, 종물에 저당권의 효력이 미치지 않도록 약정을 할 수 있고, 이를 등기하면 제3자에게 대항할 수 있다.

③ 저당권의 목적인 건물의 증축부분이 독립적 효용이 없는 경우, 기존건물의 부합물이되어 저당권의 효력이 미친다.

④ 저당부동산에 대한 경매절차에서 부합물 · 종물이 경매목적물로 평가되지 않았다고 해도 저당권의 효력이 그에 미치므로, 경락인은 그에 대한 소유권을 취득한다[80다2757, 94다6345].

⑤ 토지소유자가 토지에 매설한 유류저장탱크는 토지의 부합물이므로 토지저당권의 효력이 미친다.

⑥ 입목법상의 입목과 명인방법을 갖춘 수목의 집단, 성숙한 농작물, 건물은 토지의 부합물이 아니므로 토지저당권의 효력이 미치지 않는다.

⑦ 저당권의 효력은 종된 권리에도 미치므로 건물에 대한 저당권은 그 건물의 소유를 목적으로 하는 지상권, 전세권, 임차권에 미친다[95다52864].

⑧ 또한 집합건물에서 특별한 사정이 없는 한 구분건물의 전유부분에 대한 저당권 또는 경매개시결정과 압류의 효력은 당연히 종물 내지 종된 권리인 대지사용권에까지 미치고, 그에 터잡아 진행된 경매절차에서 전유부분을 경락받은 자는 그 대지사용권도 함께 취득한다[2005다15048].

(2) 과 실

> **제359조(과실에 대한 효력)** 저당권의 효력은 저당부동산에 대한 압류가 있은 후에 저당권설정자가 그 부동산으로부터 수취한 과실 또는 수취할 수 있는 과실에 미친다. 그러나 저당권자가 그 부동산에 대한 소유권, 지상권 또는 전세권을 취득한 제3자에 대하여는 압류한 사실을 통지한 후가 아니면 이로써 대항하지 못한다

① 저당권은 목적물의 이용가치를 저당권설정자에게 맡기고 있으므로 목적부동산에서 생기는 과실에는 저당권의 효력이 미치지 않는다.

② 그러나 저당권의 실행으로 '저당부동산에 대한 압류가 있은 후(경매개시결정의 등기)'에 저당권설정자가 그 부동산으로부터 수취한 과실 또는 수취할 수 있는 과실에 대하여는 저당권의 효력이 미친다. 따라서 저당부동산에 대한 압류 이후의 저당권설정자의 저차임채권 등에도 저당권의 효력이 미친다[2015다230020].

3. 물상대위(物上代位)

(1) 의 의

① 물상대위란 담보물의 멸실 · 훼손 또는 공용징수로 인해 담보권설정자가 받을 금전 등의 대상물에 담보물권의 효력이 미치는 것을 말한다. 예컨대 甲이 채무자 乙에게 1억원을 빌려준 후 乙의 건물에 저당권을 설정하였는데 그 후 그 건물이 화재로 전소된 경우, 마침 그 건물에 대해 화재보험이 가입되어 있어서 보험회사로부터 乙이 보험금을 받을 수 있게 된 경우에 甲의 저당권은 건물 대신 보험금청구권에 효력이 미치는 것을 말한다.

② 우선변제적 효력이 있는 저당권에는 물상대위가 인정되나, 교환가치의 취득을 목적으로 하지 않는 유치권에는 물상대위가 인정되지 않는다.

(2) 물상대위의 객체(가치변형물)

① 담보물 멸실로 인한 손해배상청구권, 공용징수로 인한 보상금청구권, 화재보험금청구권, 전세권이 저당권의 목적인 경우 전세권소멸에 따른 전세금반환청구권 등에 물상대위가 인정된다.

② 그러나 담보물이 매각 · 임대된 경우의 매매대금 · 차임은 물상대위의 객체가 되지 않는다. 또한 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 협의취득의 경우 그 보상금은 실질적으로 매매대금의 성질을 가지므로 물상대위의 객체가 되지 않는다[80다2109].

(3) 물상대위권 행사의 방법

① 물상대위권을 행사하려면 채무자가 저당목적물의 변형물인 금전 기타 물건을 지급받기 전에 압류를 하여야 한다.

② 다만, 압류는 저당권자가 직접 하지 않더라도 저당목적물의 변형물인 금전 기타 물건에 대하여 이미 제3자가 압류하여 그 금전 또는 물건이 특정된 이상 저당권자는 물상대위권을 행사하여 일반채권자보다 우선변제를 받을 수 있다[98다12812].

판 례

1. 저당권자가 물상대위권를 행사하지 아니하여 다른 채권자가 이득을 얻었다고 하더라도 저당권자는 이를 부당이득으로서 반환청구할 수 없다[2002다33137].
2. 저당권자가 물상대위권의 행사로 금전 또는 물건의 인도청구권을 압류하기 전에 저당목적물 소유자가 그 인도청구권에 기하여 금전 등을 수령한 경우, 저당권자는 저당권을 상실하는 손해를 입게 되는 반면에, 저당목적물의 소유자는 저당권의 부담이 없었던 것과 같은 상태에서의 대가를 취득하게 되는 것이므로, 그 수령한 금액 가운데 저당권의 피담보채권액의 범위 내에서는 이득을 얻게 되므로 저당목적물 소유자는 저당권자에게 이를 부당이득으로 반환할 의무가 있다[2008다17656].

4. 우선변제적 효력

① 저당권자는 담보권실행을 위한 경매를 신청하여 다른 채권자보다 자기 채권의 우선변제를 받을 수 있다(제356조).

② 저당부동산에 대해 다른 담보권자나 일반 채권자가 경매를 신청하는 경우에는 저당권자는 배당절차에 참가하여 자기의 우선순위에 따라 변제를 받을 수 있다(민사집행법 제98조, 제145조).

5. 경매에서 저당권과 용익권과의 관계

① 저당권이 실행되면 제3자의 대항력 있는 용익권(지상권, 전세권, 대항력 있는 임차권)은 어떻게 되는가의 문제는 용익권과 저당권의 설정의 선후에 따라 결정된다.

② 저당목적물상의 모든 저당권은 경매로 인하여 소멸한다. 따라서 제3자의 대항력 있는 용익권이 저당권의 실행으로 소멸하느냐의 여부는 경매를 신청한 저당권자의 저당권이 아니라, 그 부동산 위의 최선순위저당권과의 우열로 정하여진다.

③ 최선순위저당권 설정 이전에 설정된 대항력이 있는 용익권(지역권, 지상권, 전세권, 등기된 임차권 등)은 경매에 의하여 소멸되지 않는다.

④ 다만, 전세권이 저당권보다 먼저 설정된 경우, 저당권실행시 원칙적으로 전세권은 소멸하지 아니하나 전세권자가 배당요구를 하면 전세권은 목적물의 매각으로 소멸한다.

⑤ 최선순위저당권 이후에 설정된 용익권은 저당권이 실행되면 소멸되어 매수인에게 대항하지 못한다. 즉, 1번 저당권이 설정된 후 용익권(지상권 등)이 설정되고 그 후 2번 저당권이 설정된 경우, 2번 저당권실행으로 목적물이 매각되면 용익권(지상권)은 소멸한다.

Ⅳ 제3취득자의 지위

1. 의 의

① 제3취득자란 저당권이 설정된 후 저당부동산의 소유권, 지상권 또는 전세권을 취득한 자를 말한다. 제3취득자에는 경매신청 후에 소유권, 지상권 또는 전세권을 취득한 자도 포함된다.

② 그러나 (근)저당부동산에 대하여 후순위(근)저당권을 취득한 자는 제3취득자에 해당하지 않는다[2005다17341].

③ 저당부동산의 제3취득자는 저당권이 실행되면 그 권리를 상실하게 되는 자들이므로 민법은 이러한 제3취득자의 불안한 지위를 보호하기 위한 규정을 두고 있다.

2. 제3취득자의 보호

(1) 경매인이 될 수 있는 지위

제363조(저당권자의 경매청구권, 경매인)
② 저당물의 소유권을 취득한 제3자도 경매인이 될 수 있다.

(2) 제3취득자의 변제권

제364조(제3취득자의 변제) 저당부동산에 대하여 소유권, 지상권 또는 전세권을 취득한 제3자는 저당권자에게 그 부동산으로 담보된 채권을 변제하고 저당권의 소멸을 청구할 수 있다.

제3취득자는 이해관계 있는 제3자이므로 채무자의 의사에 반해서도 변제할 수 있으며, 변제범위는 제360조에 규정된 범위 내에서만 변제하면 된다. 즉, 원본의 이행기일을 경과한 1년분만을 변제하면 족하다.

(3) 제3취득자의 비용상환청구권

제367조(제3취득자의 비용상환청구권) 저당물의 제3취득자가 그 부동산의 보존 · 개량을 위하여 필요비 또는 유익비를 지출한 때에는 제203조 제1항, 제2항의 규정에 의하여 저당물의 경매대가에서 우선상환을 받을 수 있다.

판 례

제3취득자가 제367조를 근거로 직접 저당권설정자, 저당권자 또는 경매절차의 매수인에 대하여 비용상환을 청구할 수 있는지 여부(소극) 및 이를 피담보채권으로 주장하면서 유치권을 행사할 수 있는지 여부(소극)

민법 제376조는 저당물의 제3취득자가 경매절차에서 배당받는 방법으로 필요비나 유익비에 관하여 경매절차의 매각대금에서 우선변제 받을 수 있다는 것이지 이를 근거로 제3취득자가 직접 저당권설정자, 저당권자 또는 경매절차의 매수인에 대하여 비용상환을 청구할 수 있는 권리가 인정될 수 없다. 따라서 제3취득자는 민법 제376조에 의한 비용상환청구권을 피담보채권으로 주장하면서 유치권을 행사할 수 없다(2022다265093).

Ⅴ 일괄경매청구권(一括競賣請求權)

1. 의 의

① 토지를 목적으로 저당권을 설정한 후 그 설정자가 그 토지에 건물을 축조한 때에는 저당권자는 토지와 함께 그 건물에 대하여도 경매를 청구할 수 있다(제365조).

② 본래 토지에 대한 저당권자는 토지에 대해서만 경매를 청구할 수 있을 뿐인데, 그렇다면 건물소유자는 법정지상권을 취득할 수 없어 토지의 매수인에게 대항할 수 없을 뿐만 아니라 토지만을 경락될 가능성도 높지 않아 토지의 담보가치도 하락하게 된다. 따라서 지상건물의 보호와 토지저당권실행의 편의를 위하여 일괄경매권을 인정한 것이다.

2. 요 건

(1) 토지에 저당권설정 당시 그 지상에 건물이 존재하지 않을 것

토지에 대한 저당권설정 당시에 건물이 존재하고 있다면 그 건물을 위한 법정지상권이 인정될 것이므로 일괄경매를 인정할 필요가 없기 때문이다.

(2) 경매청구 당시 저당권설정자가 건물을 소유하고 있을 것

① 원칙적으로 저당권설정자가 저당토지상에 건물을 축조하여 소유하고 있는 경우에 한하여 인정한다[93마1736]. 따라서 토지저당권설정자로부터 토지용익권(지상권, 임차권)을 취득한 자가 건물을 신축한 경우에는 일괄경매청구권이 인정되지 않는다[2003다3850].

② 또한 저당권설정자가 건물을 축조하였으나 경매개시결정 당시 건물의 소유권이 제3자에게 귀속된 경우에는 일괄경매를 청구할 수 없다[99마146].

③ 그러나 판례는 저당권설정자가 건물을 축조한 경우뿐만 아니라 저당권설정자로부터 저당토지에 대한 용익권을 설정받은 자가 그 토지에 건물을 축조한 경우라도 그 후 저당권설정자가 그 건물의 소유권을 취득한 경우에는 저당권자는 토지와 함께 그 건물에 대하여 경매를 청구할 수 있다고 한다[2003다3850].

3. 효 과

① 토지만 경매할 것인가, 토지와 건물을 일괄하여 경매할 것인가는 저당권자의 자유이다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 저당권자는 토지만에 대하여 경매를 신청하여 그 경락인이 건물의 철거를 구하는 것이 위법하다 할 수 없다[77다77].

② 일괄경매에는 민사집행법 제124조의 과잉경매규정이 적용되지 않으며, 저당물인 토지만 경매하더라도 각 채권자에게 변제하고 집행비용에 충분하더라도 일괄경매가 허용된다.

③ 그러나 그 건물의 경매대가에 대하여는 우선변제를 받을 권리가 없다(제365조 후단).

Ⅵ 저당권침해에 대한 구제방법

1. 저당권에 기한 물권적 청구권

① 저당권에 대한 침해나 침해의 우려가 있는 경우 저당권자는 방해제거청구권이나 방해예방청구권을 행사할 수 있다. 그러나 저당권자는 목적물을 점유하지 않으므로 반환청구권을 행사할 수 없다.

② 객관적인 저당권방해가 있으면 방해제거청구권이 발생하고 방해자의 고의 · 과실을 요하지 않는다. 또한 저당물의 일부가 멸실 · 훼손되고 남은 목적물로부터 피담보채권의 만족을 얻을 수 있다고 하더라도 저당물 전부에 대해 방해제거청구권을 행사할 수 있다.

2. 손해배상청구권

저당권자는 저당물의 침해로 저당권자가 채권의 만족을 얻을 수 없을 때에는 침해자에 대해 불법행위를 이유로 손해배상청구권을 행사할 수 있다[2006다42818].

3. 담보물보충청구권

제362조(저당물의 보충) 저당권설정자의 책임있는 사유로 인하여 저당물의 가액이 현저히 감소된 때에는 저당권자는 저당권설정자에 대하여 그 원상회복 또는 상당한 담보제공을 청구할 수 있다.

담보물보충청구권을 행사하면 손해배상청구권이나 즉시변제청구권을 행사할 수 없다.

4. 즉시변제청구권

제388조(기한의 이익의 상실) 채무자는 다음 각호의 경우에는 기한의 이익을 주장하지 못한다.
1. 채무자가 담보를 손상, 감소 또는 멸실하게 한 때
2. 채무자가 담보제공의 의무를 이행하지 아니한 때

Ⅶ 저당권의 처분 및 소멸

1. 저당권의 처분의 제한

제361조(저당권의 처분제한) 저당권은 그 담보한 채권과 분리하여 타인에게 양도하거나 다른 채권의 담보로 하지 못한다.

2. 저당권의 소멸

제369조(부종성) 저당권으로 담보한 채권이 시효의 완성, 기타 사유로 인하여 소멸한 때에는 저당권도 소멸한다.

목적물의 멸실, 혼동, 공용수용, 포기, 몰수 등이 있다. 그러나 저당권만 별도로 소멸시효에 걸리지는 않는다. 또한 저당권의 실행(경매 · 유저당), 다른 채권자의 경매, 별제권의 행사 등으로도 소멸한다.

Ⅷ 공동저당(共同抵當)

1. 서 설

(1) 의 의

① 채권자가 동일한 채권의 담보로서 수개의 부동산 위에 설정한 복수의 저당권을 공동저당이라고 한다(목적물마다 저당권 성립).

② 토지나 건물이 아니라도 저당권의 목적이 될 수 있는 선박 · 자동차 · 항공기 · 입목 등의 동산, 나아가 공장재단이나 광업재단 등도 동종의 목적물을 동일한 채권의 담보로 하는 한 공동저당의 목적이 될 수 있다.

(2) 공동저당의 성격

수개의 부동산에 1개의 저당권이 있는 것이 아니라 각 부동산마다 1개의 저당권이 있는 것이며 공동저당에 있어서 목적물의 수와 저당권의 수는 같다.

2. 효 력

(1) 공동저당의 실행

1개 채권의 담보로서 수개 부동산에 저당권이 설정된 공동담보가 있는 경우에는 그 중 일부가 제3자 소유라 하더라도 채권자는 그 목적물을 일괄하여 또는 그 중 어느 것을 분리하여 먼저 저당권을 실행할 수 있다[4292민재항307].

(2) 수개의 부동산이 채무자 소유인 경우

① 동시배당(同時配當)의 경우 : 부담의 안분(按分)

> **제368조(공동저당과 대가의 배당, 차순위자의 대위)** ① 동일한 채권의 담보로 수개의 부동산에 저당권을 설정한 경우에 그 부동산의 경매대가를 동시에 배당하는 때에는 각 부동산의 경매대가에 비례하여 그 채권의 분담을 정한다.

㉠ 채권의 분담을 정하는 방식은 전체 부동산의 경매대가를 분모로 하고, 해당 부동산의 경매대가를 분자로 한 비율에 채권액을 곱하는 방식으로 한다.

㉡ 동시배당에서 각 부동산의 경매대가에 비례하여 그 채권의 분담을 정하는 것은 후순위저당권자가 있든 없든 불문하고 적용된다.

② 이시배당(異時配當)의 경우(후순위저당권자의 대위)

㉠ 수개의 저당부동산 중 일부의 경매대가를 먼저 배당하는 경우에는 선순위공동저당권자는 그 대가에서 그 채권전부의 변제를 받을 수 있다.

㉡ 이 경우 경매된 부동산의 후순위저당권자는 동시에 배당하였다면 선순위저당권자가 다른 부동산의 경매대가에서 변제를 받을 수 있는 금액의 한도에서 선순위자를 대위하여 저당권을 행사할 수 있다.

(3) 채무자 소유부동산과 물상보증인 소유부동산에 공동저당권이 설정된 경우

① 채무자 소유부동산과 물상보증인 소유부동산이 동시 배당된 경우

채무자 소유부동산의 경매대가에서 공동저당권자에게 우선적으로 배당을 하고, 부족분이 있는 경우에 한하여 물상보증인 소유부동산의 경매대가에서 추가로 배당을 하여야 한다[2008다41475].

② 물상보증인 소유부동산이 먼저 매각된 경우

물상보증인 소유의 부동산에 대하여 먼저 경매가 이루어져 그 경매대금의 교부에 의하여 선순위공동저당권자가 변제를 받은 때에는 물상보증인은 채무자에 대하여 구상권을 취득함과 동시에, 변제자대위에 의하여 채무자 소유의 부동산에 대한 선순위저당권을 대위취득하고, 그 물상보증인 소유의 부동산의 후순위저당권자는 위 선순위저당권에 대하여 물상대위를 할 수 있다[2008마109].

③ 채무자 소유부동산이 먼저 매각된 경우(물상보증인우선설)

채무자 소유의 부동산에 대해 먼저 경매가 이루어져 그 경매대금의 교부에 의해 1번 공동저당권자가 변제를 받더라도, 채무자 소유의 부동산에 대한 후순위저당권자는 민법 제368조 제2항 후단에 의하여 1번 공동저당권자를 대위하여 물상보증인 소유의 부동산에 대해 저당권을 행사할 수 없다[95마500].

Ⅸ 근저당권(根抵當權)

제357조(근저당) ① 저당권은 그 담보할 채무의 최고액만을 정하고 채무의 확정을 장래에 보류하여 이를 설정할 수 있다. 이 경우에는 그 확정될 때까지의 채무의 소멸 또는 이전은 저당권에 영향을 미치지 아니한다.
② 전항의 경우에는 채무의 이자는 최고액 중에 산입한 것으로 본다.

1. 의 의

① 근저당권은 그 담보할 채무의 최고액만을 정하고, 채무의 확정을 장래에 보류하여 두는 저당권으로서, 계속적인 거래관계로부터 발생하는 다수의 불특정채권을 장래의 결산기에서 일정한 한도까지 담보할 목적으로 설정되는 저당권이다(제357조).

② 근저당권이 유효하기 위해서는 근저당권설정행위와 별도로 근저당권의 피담보채권을 성립시키는 법률행위가 있어야 한다[2003다70041].

③ 피담보채권이 확정되기 전에는 부종성이 완화되어 채무의 소멸 또는 이전은 저당권에 영향을 미치지 않는다.

2. 근저당권의 효력

(1) 피담보채권의 범위

① 채권최고액

근저당권의 효력은 채권최고액의 범위 안에서 현존하는 채권액의 전부에 미치며, 최고액을 초과한 피담보채권은 담보되지 않는다. 채권최고액이란 저당물로부터 우선변제를 받을 수 있는 최고한도액이다.

② 범 위

㉠ 원칙

원본, 위약금과 이자는 최고액 중에 산입한 것으로 간주되므로 별도의 등기도 필요없고 최고액의 범위 내이면 이자총액에 대한 제한은 없다.

㉡ 지연배상

최고액의 한도에서 인정되므로 지연배상은 1년분에 한하여 담보된다는 제360조 단서는 근저당권에는 적용되지 않는다.

㉢ 저당권의 실행비용

근저당권 실행비용은 채권최고액에 포함되지 않고 별도로 우선변제된다[2001다47986].

(2) 피담보채권의 확정

① 근저당권의 확정이란 근저당권으로 담보되는 채권의 원본이 확정되는 것을 말한다. 확정 시기에 관한 민법의 규정은 없으나 채권은 근저당권 존속기간의 만료, 기본계약이 정하는 결산기의 도래, 기본계약 또는 근저당권설정계약의 해지 · 해제, 경매신청 등으로 피담보채권은 확정된다.

② 근저당권의 존속기간을 정하거나 기본적인 거래계약에서 결산기를 정한 경우에도 근저당권에 의해 담보되는 채권이 전부 소멸되고 채무자가 거래를 계속할 의사가 없는 경우에는, 그 존속기간 또는 결산기가 경과하기 전이라 하더라도 근저당권설정자는 계약을 해지하고 근저당권설정등기의 말소를 구할 수 있다[2002다7176].

③ 존속기간의 정함이 없는 때에는 근저당권의 피담보채무의 확정방법에 대한 특별한 약정이 없는 경우라면 근저당권설정자는 언제든지 해지함으로써 피담보채무를 확정시킬 수 있다[2002다7176].

④ 경매신청의 경우, 근저당권자가 피담보채무의 불이행을 이유로 경매신청을 한 경우에는 경매신청시에 근저당권의 피담보채권액이 확정되고[97다25521], 후순위근저당권자나 제3자가 경매를 신청한 경우 선순위근저당권의 피담보채권은 경락인이 경락대금을 완납한 때에 확정된다[99다26085].

⑤ 피담보채권확정의 효과

㉠ 피담보채권이 확정되면 그 이후부터 근저당권은 부종성을 가지게 되어 보통의 저당권과 같은 취급을 받게 된다[97다25521].

㉡ 근저당권자가 피담보채무의 불이행을 이유로 경매신청을 하여 경매개시결정이 있은 후에 경매신청이 취하되었다고 하더라도 채무확정의 효과가 번복되는 것은 아니다[2001다73022].

㉢ 근저당권자의 경매신청 등의 사유로 인하여 근저당권의 피담보채권이 확정되었을 경우, 확정 이후에 새로운 거래관계에서 발생한 원본채권은 그 근저당권에 의하여 담보되지 아니하지만, 확정 전에 발생한 원본채권에 관하여 확정 후에 발생하는 이자나 지연손해금채권은 채권최고액의 범위 내에서 근저당권에 의하여 여전히 담보되는 것이다[2005다38300].

(3) 확정채무변제와 근저당권의 소멸청구

① 채권총액이 근저당권의 채권최고액을 초과하는 경우 적어도 근저당권자와 채무자 겸 근저당권설정자의 관계에 있어서는 채권전액의 변제가 있을 때까지 근저당권설정등기의 말소청구를 할 수 없다[2000다59081]. 즉, 채무자는 채무 전액을 변제해야 근저당권 말소청구를 할 수 있다[80다2712].

② 그러나 물상보증인이나 근저당부동산의 제3취득자는 채권의 최고액만을 변제하면 근저당권설정등기의 말소청구를 할 수 있다[74다998].

3. 근저당권의 변경

근저당권은 피담보채무가 확정되기 이전이라면 채무의 범위 또는 채무자를 변경할 수 있고 채무의 범위나 채무자가 변경된 경우에는 당연히 변경 후의 범위에 속하는 채권이나 채무자에 대한 채권만이 당해 근저당권에 의해 담보되고 변경 전의 범위에 속하는 채권이나 채무자에 대한 채권은 그 근저당권에 의해 담보되는 채무의 범위에서 제외된다[97다15777].

4. 근저당권의 소멸

① 근저당권은 피담보채권의 발생가능성이 확정적으로 없게 된 때에 비로소 소멸한다[67다2543].

② 근저당권이 설정된 후에 그 부동산의 소유권이 제3자에게 이전된 경우에는 현재의 소유자 가 자신의 소유권에 기하여 피담보채무의 소멸을 원인으로 그 근저당권설정등기의 말소를 청구할 수 있음은 물론 근저당권설정자인 종전의 소유자도 근저당권설정계약의 당사자로서 근저당권소멸에 따른 원상회복으로 근저당권설정등기의 말소를 구할 수 있는 계약상 권리가 있다[93다16338전합].

PART 03

계약법

CHAPTER 01 계약법 총론(總論)

CHAPTER 02 계약법 각론(各論)

CHAPTER

01 계약법 총론(總論)

제 1 절 계약 일반

Ⅰ 계약의 종류

1. 유상계약(有償契約)과 무상계약(無償契約)

(1) **유상계약(有償契約)**

① 유상계약이란 쌍방이 계약의 성립부터 그 내용실현에 이르기까지 전 과정을 통해 서로 대가적 의미를 갖는 경제적 출연을 하는 계약을 말한다.

② 매매, 교환, 임대차, 고용, 현상광고 등이 유상계약이다.

(2) **무상계약(無償契約)**

① 무상계약이란 일방만이 경제적 출연을 하거나 쌍방이 출연을 하더라도 서로 대가적 의미를 갖지 않는 계약을 말한다.

② 증여, 사용대차 등이 무상계약이다.

(3) **구별실익**

유상계약에는 매매에 관한 규정, 특히 매도인의 담보책임에 관한 규정이 준용된다는 데 있다.

2. 쌍무계약(雙務契約)과 편무계약(片務契約)

(1) **쌍무계약(雙務契約)**

① 쌍무계약이란 계약에서 발생하는 채무만을 대상으로 해서 당사자 쌍방이 서로 대가적 의미를 갖는 채무를 부담하는 계약을 말한다.

② 매매, 교환, 임대차, 유상인 소비대차, 유상인 위임 등이 쌍무계약이다.

(2) **편무계약(片務契約)**

① 편무계약이란 당사자 일방만이 채무를 부담하거나, 쌍방이 채무를 부담하더라도 그것이 대가적 의미를 갖지 않는 계약을 말한다.

② 증여, 사용대차, 현상광고, 무상인 소비대차, 무상인 위임 등이 편무계약이다.

(3) 구별실익

동시이행항변권(제536조)과 위험부담(제537~제538조)은 쌍무계약에만 적용되고, 편무계약에는 적용되지 않는다.

보충학습 유상계약과 쌍무계약의 비교

① 쌍무계약은 모두 유상계약이지만, 유상계약이 모두 쌍무계약은 아니다.
② 현상광고는 편무계약이면서 유상계약이다.

3. 낙성계약(諾成契約)과 요물계약(要物契約)

(1) 낙성계약(諾成契約)

① 낙성계약은 당사자간의 의사표시의 합치, 즉 '약정'만으로 성립하는 계약을 말한다.

② 민법상 15개의 전형계약 중 현상광고를 제외한 나머지 모두가 낙성계약이다.

(2) 요물계약(要物契約)

① 요물계약이란 당사자 간의 합의 외에 목적물의 인도, 대가의 지급, 일의 완성 등 계약에 필요한 행위의 일부 또는 전부를 완료한 때에 성립하는 계약을 말한다.

② 전형계약 중에 현상광고만이 요물계약이다. 비전형계약 중에는 계약금계약, 대물변제 등이 요물계약에 속한다.

4. 일시적 계약과 계속적 계약

(1) 일시적 계약

목적물의 인도나 대금지불이 있으면 계약의 목적을 달성하여 종료하는 계약, 즉 어떤 시점에서 급부를 이행하면 채권이 소멸하는 계약을 말하며, 이에는 매매 · 교환 · 증여 등이 있다.

(2) 계속적 계약

계속적 계약이란 일정기간 동안 계속하여 급부가 이루어져야 하는 계약을 말하며, 임대차 · 고용 등이 이에 속한다.

(3) 구별실익

일방의 채무불이행으로 계약을 해소하는 방법이 다르다. 일시적 계약은 일방의 채무불이행이 있으면 해제로 계약을 해소하여 처음부터 계약의 효력을 소멸시키지만, 계속적 계약의 경우에는 해지를 하여 계약을 효력을 장래에 소멸시킨다.

Ⅱ 계약과 약관(約款)

1. 약관의 의의

① 보통거래약관 또는 약관이란 그 명칭이나 형태 또는 범위를 불문하고 계약의 일방당사자가 다수의 상대방과 계약을 체결하기 위하여 일정한 형식에 의하여 미리 마련한 내용이 되는 것을 말한다(약관의 규제에 관한 법률 제2조 제1항).

② 약관은 집단거래를 합리적으로 신속하게 처리할 수 있는 장점이 있으나, 이를 작성한 기업자 측에서 자신들에게 일방적으로 유리하게 그 내용을 정해 놓는다는 점에서 경제적 약자인 소비자를 어떻게 보호할 것인가가 문제가 된다.

2. 약관에 의한 계약에서 주의점

① 보통보험약관이 계약당사자에 대하여 구속력을 가지는 것은 그 자체가 법규범 또는 법규범적 성질을 가진 약관이기 때문이 아니라 보험계약 당사자 사이에서 계약내용에 포함시키기로 합의하였기 때문이다[89다카24070].

② 사업자는 약관내용의 명시 및 사본교부의무, 중요내용에 대한 설명의무를 부담한다. 사업자가 약관의 명시 · 설명의무를 위반하여 계약을 체결한 경우에는 해당 약관을 계약의 내용으로 주장할 수 없다.

④ 명시 · 설명에 대한 증명책임은 그 약관내용을 계약의 내용으로 주장하는 자, 즉 사업자에게 있다(대판 2001.7.27. 99다55533 참조).

⑤ 보통거래약관의 내용은 개개 계약체결자의 의사나 구체적인 사정을 고려함이 없이 객관적 · 획일적으로 해석하여야 한다.

⑥ 약관의 조항 가운데 의미가 명확하지 않은 것이 있는 때에는, 고객에게 유리하게 약관작성자에게 불리하게 해석하여야 한다.

⑦ 약관의 일부조항이 무효인 경우에도 나머지 약관은 무효로 되지 않고 유효하게 존속한다.

제 2 절 계약의 성립

Ⅰ 계약성립요건으로서의 합의(合意)

1. 의 의

① 계약이 성립하려면 당사자간에 서로 대립하는 수개의 의사표시의 합치가 있어야 하는데 이를 '합의'라 한다.

② 매매계약에 있어서 그 목적물과 대금은 반드시 계약체결 당시에 구체적으로 특정될 필요는 없고 이를 사후에라도 구체적으로 특정할 수 있는 방법과 기준이 정해져 있으면 계약의 성립을 인정할 수 있다[96다26176].

③ 이러한 합의가 성립하기 위해서는 수 개의 의사표시의 객관적 내용이 합치되어야 하며(객관적 합치), 계약의 상대방을 누구로 하여 그러한 의사표시를 하는 것이냐, 즉 의사표시의 상대방에 대한 합치(주관적 합치)가 있어야 한다.

2. 불합의(不合意)와 착오

착오는 법률행위가 성립한 후의 문제이므로 불합의로 계약이 불성립한 경우에는 착오의 문제가 발생하지 않으므로 착오를 이유로 취소할 수도 없다.

3. 계약성립의 모습에 관한 민법의 규정

① 청약과 승낙에 의한 계약의 성립(제527조~531조, 제534조)

② 교차청약(交叉請約)에 의한 계약성립(제533조)

③ 의사실현(意思實現)에 의한 계약성립(제532조)

Ⅱ 청약과 승낙에 의한 계약의 성립

1. 청약(請約)

(1) 청약의 의의

청약은 그에 대응하는 상대방의 의사표시(승낙)와 결합하여 일정한 내용의 계약을 성립시킬 것을 목적으로 하는 구체적 · 확정적 의사표시이다.

(2) 청약의 유인(誘引)과 구별

① 청약의 유인은 상대방으로 하여금 청약을 해오도록 유인하기 위한 거래의 권유를 말하는 것으로써 확정된 의사표시가 없다는 것에 청약과 구별된다(예컨대 구인광고 · 물품판매광고 · 아파트의 분양광고, 하도급계약에서 견적서 제출 등). 청약의 유인은 원칙적으로 계약의 내용이 되지 않는다.

② 다만, 아파트 분양광고의 내용 중 아파트의 외형 · 재질 · 구조 등에 관한 것으로서 사회통념에 비추어 수분양자가 분양자에게 계약의 내용으로 이행을 청구할 수 있다고 보이는 사항에 관한 것은 특별한 사정이 없는 한 이러한 사항은 분양자와 수분양자 사이의 묵시적 합의에 의하여 분양계약의 내용으로 된다고 할 것이다.

③ 그러나 선시공 · 후분양의 방식으로 분양되는 경우에는 완공된 아파트 등 그 자체가 분양계약의 목적물로 된다고 봄이 상당하므로 분양광고 등에만 표현되어 있는 아파트 등의 외형 · 재질 등에 관한 사항은 분양계약 시에 아파트 등의 현황과는 별도로 다시 시공해 주기로 약정하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 이를 분양계약의 내용으로 하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 보기는 어렵다.

(3) 청약의 상대방

청약의 상대방은 불특정다수인이어도 무방하다(예컨대 자동판매기의 설치, 신문광고에 의한 청약).

(4) 청약의 효력발생시기

① 청약도 의사표시이므로 도달한 때에 효력이 발생한다(제111조 제1항).

② 청약의 의사표시를 발송한 후 그것이 상대방에게 도달하기 전에 청약자가 사망하거나 제한능력자가 되어도 청약의 효력에는 영향을 미치지 아니한다(제111조 제2항).

(5) 청약의 구속력(=비철회성)

제527조(계약의 청약의 구속력) 계약의 청약은 이를 철회하지 못한다.

① 의의

청약의 구속력은 청약의 효력이 발생한 후에 청약자가 이를 임의로 철회하지 못하는 것을 말한다(제527조).

② 예외

청약자가 처음부터 철회의 자유를 유보하고 청약한 경우, 승낙기간을 정하지 않은 대화자 간의 청약 등의 경우에는 철회할 수 있다. 또한 청약이 도달되기 전까지 청약자는 청약의 의사표시를 철회할 수 있다.

2. 승낙기간(청약의 존속기간, 승낙적격)

(1) 승낙기간을 정한 청약의 경우

제528조(승낙기간을 정한 계약의 청약) ① 승낙의 기간을 정한 계약의 청약은 청약자가 그 기간 내에 승낙의 통지를 받지 못한 때에는 그 효력을 잃는다.
② 승낙의 통지가 전항의 기간 후에 도달한 경우에 보통 그 기간 내에 도달할 수 있는 발송인 때에는 청약자는 지체없이 상대방에게 그 연착의 통지를 하여야 한다. 그러나 그 도달 전에 지연의 통지를 발송한 때에는 그러하지 아니하다.
③ 청약자가 전항의 통지를 하지 아니한 때에는 승낙의 통지는 연착되지 아니한 것으로 본다.

예컨대 甲이 乙에게 물건을 매도하겠다는 뜻과 승낙의 기간을 10월 30일로 하는 내용의 청약을 발송하여 乙에게 도달한 경우

① 10월 29일에 발송한 乙의 승낙통지가 10월 31일에 甲에게 도달한 경우, 그 청약은 효력을 잃고 계약은 성립하지 않는다(제528조 제1항).

② 乙이 10월 20일에 승낙통지를 발송하여 10월 31일에 도달한 경우, 이 편지의 소인을 확인하고 승낙기간 내에 도달될 수 있었던 발송임을 알았다면 지체없이 乙에게 그 연착의 통지를 하여야 하고(제528조 제2항), 이를 乙에게 알리지 않은 경우, 乙의 승낙은 승낙기간 내에 도달한 것으로 보아 계약은 성립한다(제528조 제3항).

(2) 승낙기간을 정하지 않은 청약의 경우

제529조(승낙기간을 정하지 아니한 계약의 청약) 승낙의 기간을 정하지 아니한 계약의 청약은 청약자가 상당한 기간 내에 승낙의 통지를 받지 못한 때에는 그 효력을 잃는다.

3. 승낙(承諾)

(1) 승낙의 의의

① 승낙이란 청약의 상대방이 청약에 응하여 계약을 성립시키기 위해 청약자에게 하는 청약 수령의 의사표시를 말한다.

② 승낙은 특정의 청약자에게만 하여야 하므로, 청약과는 달리 불특정다수인에 대한 승낙은 있을 수 없다.

③ 청약의 상대방에게 청약을 받아들일 것인지 여부에 관하여 회답할 의무가 있는 것은 아니므로, 청약자가 미리 정한 기간 내에 이의를 하지 않으면 승낙한 것으로 간주한다는 뜻을 청약시 표시하였다고 하더라도 이는 상대방을 구속하지 않는다[98다48903]. 따라서 상대방이 그 정한 기간 내에 승낙의 의사표시를 하지 않았다 하더라도 계약은 성립하지 않는다.

(2) 연착된 승낙

제530조(연착된 승낙의 효력) 전2조(승낙기간을 정한 계약의 청약, 승낙기간을 정하지 아니한 계약의 청약)의 경우에 연착된 승낙은 청약자가 이를 새 청약으로 볼 수 있다.

승낙기간이 경과한 후에 도달한 승낙은 계약을 성립시키지 못하지만, 청약자가 그 승낙을 새로운 청약으로 보고 이에 승낙하면 계약은 성립될 수 있다.

(3) 변경을 가한 승낙

제534조(변경을 가한 승낙) 승낙자가 청약에 대하여 조건을 붙이거나 변경을 가하여 승낙한 때에는 그 청약의 거절과 동시에 새로 청약한 것으로 본다.

청약에 조건을 붙이거나 변경을 가한 승낙으로 청약은 실효되어 계약은 성립될 수 없다. 다만, 이러한 경우에 민법은 청약의 상대방이 원래의 청약을 거절과 동시에 새로이 청약한 것으로 본다. 따라서 종전의 청약자가 이를 승낙하면 계약은 성립될 수 있다.

(4) 계약의 성립시기

제531조(격지자간의 계약성립시기) 격지자간의 계약은 승낙의 통지를 발송한 때에 성립한다.

① 격지자 간의 계약성립시기

격지자 간의 계약에 있어서는 승낙의 통지를 발송한 때에 계약이 성립한다(발신주의).

② 대화자간의 계약성립시기

대화자간에는 특별한 규정이 없으므로 제111조의 도달주의원칙에 의한다. 즉, 승낙의 의사표시가 청약자에게 도달한 때에 계약이 성립한다.

용어정리 **격지자와 대화자의 개념**

격지자와 대화자는 거리나 장소적 개념이 아니라 시간적 개념으로 상대방의 의사표시를 요지하는데 다소의 시간이 필요한 경우를 '격지자'라 하고 반면에 상대방의 의사표시를 곧 알 수 있는 위치에 있는 경우를 '대화자'라 한다. 예를 들어 서울에 있는 갑과 부산에 있는 을이 서로의 의사표시를 우편으로 발송하는 경우에는 격지자겠지만, 서로 전화로 의사표시를 발송하는 경우에는 대화자라 할 수 있다.

Ⅲ 기타 방법에 의한 계약의 성립

1. 교차청약(交叉請約)에 의한 계약성립

제533조(교차청약) 당사자간에 동일한 내용의 청약이 상호교차된 경우에는 양 청약이 상대방에게 도달한 때에 계약이 성립한다.

예를 들면 甲이 乙에게 X토지를 1억에 팔겠다는 청약을 했는데, 그 청약이 乙에게 도달하기 전에 乙도 甲에게 X토지를 1억원에 사겠다는 청약을 하는 경우이다.

2. 의사실현에 의한 계약성립

제532조(의사실현에 의한 계약성립) 청약자의 의사표시나 관습에 의하여 승낙의 통지가 필요하지 아니한 경우에는 계약은 승낙의 의사표시로 인정되는 사실이 있는 때에 성립한다.

예를 들면 서점에서 신간서적을 보내오자 책을 사기로 하고 책에 이름을 적은 경우, 유료주차장에 차를 세워둔 경우처럼 청약자의 의사표시나 관습에 의하여 승낙의 통지가 필요하지 않은 경우에는 승낙의 의사표시로 인정되는 사실이 있는 때에 계약이 성립한다. 청약자가 이러한 사실을 알았는지 여부는 문제되지 않는다.

Ⅳ 계약체결상의 과실책임

제535조(계약체결상의 과실) ① 목적이 불능한 계약을 체결할 때에 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 자는 상대방이 그 계약의 유효를 믿었음으로 인하여 받은 손해를 배상하여야 한다. 그러나 그 배상액은 계약이 유효함으로 인하여 생길 이익액을 넘지 못한다.
② 계약체결상의 과실책임은 상대방이 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 경우에는 적용하지 아니한다.

1. 의 의

계약의 성립과정에서 당사자의 일방이 책임 있는 사유로 상대방에게 손해를 발생시킨 경우에 이를 배상해야 할 책임을 말한다. 민법은 원시적 불능으로 인하여 무효인 경우에 관해서만 명문규정을 두어 이 책임을 인정하고 있다(제535조).

2. 요 건

① 계약내용의 원시적 · 객관적 전부불능

㉠ 계약내용의 전부가 원시적 · 객관적 불능이어서 그 계약 전부가 무효여야 한다.

㉡ 매매 기타의 유상계약에서 계약내용의 일부가 객관적으로 원시적 불능이더라도 계약은 유효하게 성립하고, 담보책임의 문제로 처리하므로 제535조는 적용되지 않는다. 결국 '원시적 전부불능'인 경우에만 제535조의 적용이 있게 된다.

판 례

부동산매매계약에 있어서 실제면적이 계약면적에 미달하는 경우에는 그 매매가 수량지정매매에 해당할 때에 한하여 민법 제574조, 제572조에 의한 대금감액청구권을 행사함은 별론으로 하고, 그 매매계약이 그 미달 부분만큼 일부 무효임을 들어 이와 별도로 일반 부당이득반환청구를 하거나 그 부분의 원시적 불능을 이유로 민법 제535조가 규정하는 계약체결상의 과실에 따른 책임의 이행을 구할 수 없다(대판 2002.4.9. 99다47396).

㉢ 또한 계약이 의사의 불합치로 성립하지 아니한 경우 그로 인하여 손해를 입은 당사자가 상대방이 계약이 성립되지 아니할 수 있다는 것을 알았거나 알 수 있었음을 이유로 민법 제535조를 유추적용하여 계약체결상의 과실로 인한 손해배상청구를 할 수는 없다[2015다10929].

② 배상의무자의 악의 또는 과실

배상의무자는 원시적 불능에 대해 알았거나 알 수 있었어야 한다. 따라서 배상책임을 지는 자가 선의 · 무과실이면 제535조 책임을 지지 않는다.

③ 상대방의 선의 · 무과실

상대방은 선의 · 무과실이어야 그 손해에 대한 배상을 청구할 수 있다. 따라서 계약체결시에 목적의 불능을 알았거나 알 수 있었던 상대방은 배상책임을 청구할 수 없다.

3. 효 과

① 과실 있는 당사자(채무자)는 상대방이 그 계약의 유효를 믿었음으로 인하여 받은 손해(목적물에 대한 조사비용, 대금지급을 위해 융자를 받은 경우의 이자 · 수수료, 제3자로부터의 유리한 청약을 거절한 경우의 손해액 등) 즉 '신뢰이익'을 배상해야 한다.

② 다만, 그 배상액은 계약이 유효함으로 인하여 생길 이익, 즉 이행이익을 넘지 못한다.

제 3 절 계약의 효력

Ⅰ 쌍무계약의 특질

당사자 쌍방이 서로 대가적 의미를 갖는 채무를 부담하는 쌍무계약에서는 각 채무가 서로 의존관계에 있는데, 쌍무계약에서 채무 상호간의 의존관계를 채무의 견련성(牽聯性)이라 한다.

① 성립상의 견련관계 (채무의 발생)

일방의 채무가 불성립(부존재)하거나 실효되면 타방의 채무도 불성립 또는 실효된다.

② 이행상의 견련관계 (채무의 이행)

쌍무계약에서는 상대방의 채무가 이행될 때까지 자기의 채무를 이행하지 않아도 된다. 이는 쌍무계약의 본질적 속성인 상환성(相換性)에서 연유하는데 민법은 동시이행의 항변권으로 규정하고 있다.

③ 존속상의 견련관계 (채무의 소멸)

일방의 채무가 채무자의 책임 없는 사유로 후발적 불능이 된 경우에 상대방의 채무도 소멸한다. 민법은 이를 위험부담으로 규정하고 있다.

Ⅱ 위험부담(危險負擔)

1. 의 의

① 위험부담이란 쌍무계약에서 대가적 의미를 가지는 일방의 채무가 채무자의 책임 없는 사유로 인해 후발적 불능이 되어 소멸한 경우에 그와 대가관계에 있는 타방의 채무의 운명은 어떻게 되는가의 문제이다(즉, 소멸하는가 아니면 존속하는가의 문제).

② 위험부담에 관한 규정은 임의규정이므로 당사자가 이와 다르게 약정할 수도 있다.

2. 원칙 : 채무자위험부담주의(債務者危險負擔主義)

제537조(채무자위험부담주의) 쌍무계약의 당사자 일방의 채무가 당사자 쌍방의 책임 없는 사유로 이행할 수 없게 된 때에는 채무자는 상대방의 이행을 청구하지 못한다.

① 쌍무계약의 당사자 일방의 채무가 당사자 쌍방의 책임 없는 사유로 이행할 수 없게 된 때에는 채무자는 자기의 채무를 면하지만, 동시에 상대방에 대한 채권도 상실하여 상대방의 이행을 청구하지 못한다.

② 따라서 계약관계는 해소되고 이미 이행한 급부(계약금, 중도금 등)가 있으면 채권자는 부당이득을 이유로 그 반환을 청구할 수 있다(제741조).

③ 예컨대, 甲과 乙이 甲 소유 주택에 대한 매매계약을 체결한 후, 그 이행기 전에 주택이 태풍으로 멸실된 경우, 채무자인 甲은 주택의 소유권이전의무를 면하지만, 甲은 乙에 대해 대금지급도 청구하지 못하고 받은 계약금 등을 반환하여야 한다.

④ 대상청구권

㉠ 대상청구권은 이행을 불능하게 하는 사정의 결과로 채무자가 이행의 목적물에 대신하는 이익을 취득하는 경우에 채권자가 채무자에 대하여 그 이익을 청구할 수 있는 권리이다.

㉡ 가령 토지가 공용(재결)수용된 경우, 채무자인 매도인이 보상금을 수령하기 이전에는 수용보상금청구권의 양도를, 이미 보상금을 수령한 경우에는 수용보상금 자체의 반환을 청구할 수 있다. 그러나 수용보상금청구권 자체가 채권자(매수인)에게 귀속되는 것은 아니다.

㉢ 쌍무계약의 당사자 일방이 상대방의 급부가 이행불능이 된 사정의 결과로 상대방이 취득한 대상에 대하여 급부청구권을 행사할 수 있다고 하더라도, 그 당사자 일방이 대상청구권을 행사하려면 상대방에 대하여 반대급부를 이행할 의무가 있다[95다6601].

3. 예외 : 채권자위험부담주의

제538조(채권자 귀책사유로 인한 이행불능) ① 쌍무계약의 당사자 일방의 채무가 채권자의 책임 있는 사유로 이행할 수 없게 된 때에는 채무자는 상대방의 이행을 청구할 수 있다. 채권자의 수령지체 중에 당사자 쌍방의 책임 없는 사유로 이행할 수 없게 된 때에도 같다.
② 채권자위험부담의 경우에 채무자는 자기의 채무를 면함으로써 이익을 얻은 때에는 이를 채권자에게 상환하여야 한다.

① 쌍무계약의 당사자 일방의 채무가 채권자의 책임있는 사유로 이행할 수 없게 된 때에는 채무자는 상대방의 이행을 청구할 수 있다(제538조 제1항).

② 채권자의 수령지체 중에 당사자 쌍방의 책임 없는 사유로 이행할 수 없게 된 때에도 채무자는 상대방의 이행을 청구할 수 있다(제538조 제1항). 예컨대, 甲과 乙이 甲 소유의 주택에 대한 매매계약을 체결한 후, 甲이 이행기에 소유권이전에 필요한 일체의 서류에 대한 이행의 제공을 계속하였음에도 불구하고, 乙이 정당한 이유 없이 수령을 지체하던 중 제3자의 방화로 주택이 소실된 경우, 채무자인 甲은 주택의 소유권이전의무를 면하고, 甲은 乙에 대해 매매대금의 지급을 청구할 수 있다.

③ 이때 채무자는 자기의 채무를 면함으로써 이익을 얻은 때에는(양도소득세 등) 이를 채권자에게 상환하여야 한다(제538조).

Ⅲ 동시이행의항변권(抗辯權)

제536조(동시이행의항변권) ① 쌍무계약의 당사자 일방은 상대방이 그 채무이행을 제공할 때까지 자기의 채무이행을 거절할 수 있다. 그러나 상대방의 채무가 변제기에 있지 아니하는 때에는 자기의 채무이행을 거절할 수 없다.
② 당사자 일방이 상대방에게 먼저 이행하여야 할 경우에 상대방의 이행이 곤란할 현저한 사유가 있는 때에는 자기의 채무이행을 거절할 수 있다.

1. 서 설

(1) 의 의

① 동시이행의항변권은 쌍무계약의 이행에 있어 공평의 관념과 신의칙에 입각하여 당사자 일방이 자기의 채무를 이행하거나 이행의 제공을 하지 아니한 채 상대방의 채무의 이행을 청구할 때에는 상대방은 자기의 채무이행을 거절할 수 있도록 하는 제도이다[98다53859].

② 동시이행항변권을 행사하는 것이 주로 자기 채무의 이행만을 회피하기 위한 수단이라면 권리남용에 해당한다[2001다9304].

(2) 법적 성질

① 동시이행의항변권은 상대방이 채무를 이행하거나 또는 이행의 제공을 할 때까지 자기의 채무를 거절할 수 있는 연기적 항변권(延期的 抗辯權)이다.

② 동시이행의항변권에 관한 제536조의 규정은 임의규정이다.

2. 성립요건

(1) 쌍방이 서로 대가적 의미(對價的 意味)가 있는 채무를 부담할 것

① 각 당사자가 동일한 쌍무계약(또는 법률요건)으로부터 발생한 대가적 의미의 채무를 부담하고 있어야 한다. 따라서 당사자 쌍방이 각각 별개의 약정으로 상대방에 대하여 채무를 지게 된 경우에는 동시이행을 하기로 특약한 사실이 없다면 동시이행의항변권이 생긴다고 볼 수 없다[88다카10753].

② 동시이행의 관계에 있는 쌍방의 채무가 채권양도 · 전부명령 · 채무인수 · 상속 등으로 당사자가 변경되더라도 채무의 동일성이 유지되는 한 동시이행의항변권은 존속한다.

③ 동시이행의 관계에 있는 쌍방의 채무 중 어느 한 채무가 이행불능이 됨으로 인하여 발생한 손해배상채무도 여전히 다른 채무와 동시이행의 관계에 있다[97다30066].

④ 매수인이 매도인을 상대로 매매목적 부동산 중 일부에 대해서만 소유권이전등기의무의 이행을 구하고 있는 경우에도 매도인은 매매잔대금 전부에 대하여 동시이행의 항변권을 행사할 수 있다[2005다53187].

(2) 상대방의 채무가 변제기에 있을 것

① 원칙

상대방의 채무가 아직 변제기에 있지 않고 자기의 채무만이 변제기에 있는 당사자, 즉 선이행의무자는 원칙적으로 동시이행의항변권이 없다.

② 예외 : 다음의 경우에는 선이행의무자도 항변권을 행사할 수 있다.

㉠ 불안(不安)의 항변권

당사자 일방이 상대방에게 먼저 이행해야 할 경우라도 재산상태의 악화와 같은 상대방의 이행이 곤란할 현저한 사유(예컨대 계약 성립 후 상대방의 신용불안이나 재산상태의 악화 등)가 있는 때에는 상대방 채무의 변제기가 도래하기 전에도 동시이행항변권을 행사할 수 있다(제536조 제2항).

㉡ 선이행의무자의 이행지체 중 상대방 채무의 변제기가 도래한 경우

매수인이 선이행의무 있는 중도금을 지급하지 않은 상태에서 잔대금 지급기일(이행기, 변제기)이 도래하였다면 특별한 다른 사정이 없는 한 매수인의 중도금 및 잔대금의 지급과 매도인의 소유권이전등기 소요서류의 제공은 동시이행관계에 있다 할 것이다[97다54604].

(3) 상대방이 자기의 채무의 이행 또는 이행제공을 하지 않고 이행을 청구할 것

① 상대방이 채무의 내용에 좇은 이행을 한 때에는 동시이행의항변권을 행사할 수 없다.

② 쌍무계약의 일방의 이행제공으로 수령지체에 빠진 상대방도 그 후 그 일방이 이행제공 없이 이행을 청구하는 경우에는 동시이행의 항변권을 주장할 수 있다[72다1513].

3. 동시이행항변권의 효력

(1) 동시이행항변권 존재 자체의 효과

① 이행지체 저지 : 쌍방의 채무가 동시이행관계에 있는 경우 일방의 채무의 이행기가 도래하더라도 상대방채무의 이행제공이 있을 때까지는 그 채무를 이행하지 않아도 이행지체(채무불이행)의 책임을 지지 않는다. 이와 같은 효과는 이행지체의 책임이 없다고 주장하는 자가 반드시 동시이행의항변권을 행사해야만 발생하는 것은 아니다[97다54604].

② 상계금지 : 동시이행항변권이 붙은 채권을 자동채권으로 하여 상계하지 못하나 수동채권으로 하여 상계할 수는 있다.

③ 소멸시효 중단여부 : 동시이행항변권은 소멸시효의 진행에 영향을 미치지 않는다. 즉 동시이행항변권이 붙어 있다 하여도 소멸시효는 중단되지 않고 계속 진행된다.

(2) 재판상 행사의 효과

① **소송상 원용** : 동시이행의항변권은 당사자가 원용하지 않는 한 법원이 직권으로 판단해서는 안 된다. 즉 이행거절권능은 소송상 항변을 하여야 법원이 고려한다.

② **상환이행(급부)판결** : 원고의 청구에 대해 피고가 동시이행항변권을 주장하는 경우에는 원고패소판결을 내리지 않고 상환이행(급부)판결을 한다.

보충학습 동시이행의항변권 인정 여부

1. 동시이행항변권이 인정되는 경우

① 전세권 소멸시 전세권자의 목적물 인도 및 전세권설정등기말소의무와 전세권설정자의 전세금반환의무(제317조)

② 계약해제시의 쌍방의 원상회복의무(제549조)

③ 부담부증여의 경우 부담의 이행과 증여의 이행(제561조)

④ 매도인의 담보책임으로 계약을 해제한 경우 쌍방의 원상회복의무(제583조)

⑤ 주택(상가)임대차보호법상의 목적물인도의무와 보증금반환의무(주택임대차보호법 제3조 제4항)

⑥ 가등기담보에서 청산금지급채무와 부동산의 소유권이전본등기 및 인도의무(제4조 제3항)

⑦ 계약의 무효 · 취소로 인한 쌍방의 부당이득반환의무의 이행

⑧ 계약이 해제되면 계약당사자는 상대방에 대하여 원상회복의무와 손해배상의무를 부담하는바, 이때 계약당사자가 부담하는 원상회복의무 뿐만 아니라 손해배상의무도 함께 동시이행의 관계에 있다[95다25138].

⑨ 임대차계약의 기간이 만료된 경우에 임차인이 임차목적물을 명도할 의무와 임대인의 보증금반환의무[77다1241전합]

⑩ 가압류등기(근저당권설정등기) 등이 있는 부동산의 매매계약에 있어서는 매도인의 소유권이전등기의무 및 가압류등기(근저당권등기)의 말소의무와 매수인의 대금지급의무[79다1562, 2000다8533]

⑪ 매수인이 부가가치세 또는 양도소득세를 부담하기로 약정한 경우, 특별한 사정이 없는 한 부가가치세 또는 양도소득세를 포함한 매매대금 전부와 부동산의 소유권이전등기의무[2005다58656]

⑫ 구분소유적 공유관계가 해소되는 경우, 공유지분권자 상호간의 지분이전등기의무

⑬ 변제와 영수증의 교부

2. 동시이행항변권이 부정되는 경우

① 채권의 변제와 그 채권을 위하여 설정된 담보권(유치권, 저당권, 양도담보, 가등기담보 등)의 말소의무는 채권변제가 선이행

② 변제와 채권증서(차용증)의 반환은 변제가 선이행

③ 임차권등기명령에 의해 임차권등기기 된 경우 임대인의 임대차보증금의 반환의무가 임차인의 임차권등기 말소의무보다 먼저 이행되어야 할 의무[2005다4529].

④ 매도인의 토지거래허가신청절차 협력의무와 매수인의 대금지급의무

⑤ 근저당권 실행을 위한 경매가 무효로 된 경우, 낙찰자의 채무자에 대한 소유권이전등기 말소의무와 채권자(근저당권자)의 낙찰자에 대한 배당금반환의무는 동시에 이행되어야 할 관계에 있지 아니하다[2006다24049].

⑥ 상가건물임차인의 임차목적물 반환의무와 임대인의 권리금 회수 방해로 인한 손해배상의무

Ⅳ 제3자를 위한 계약

제539조(제3자를 위한 계약) ① 계약에 의하여 당사자 일방이 제3자에게 이행할 것을 약정한 때에는 그 제3자는 채무자에게 직접 그 이행을 청구할 수 있다.

1. 의 의

① 제3자를 위한 계약이란 계약당사자가 자기들 명의로 체결한 계약에 의해 제3자로 하여금 직접 계약당사자의 일방에 대해 권리를 취득하게 하는 것을 목적으로 하는 계약을 말한다[97다28698].

② 예컨대, 甲이 자신의 건물을 乙과 매매계약을 체결하면서 乙로 하여금 제3자인 丙에게 매매대금을 지급하게 하고, 동시에 丙이 직접 乙에 대하여 그 대금청구권을 취득하도록 하는 약정을 하는 경우이다. 이 경우 채권자인 甲을 요약자(要約者), 채무자인 乙을 낙약자(諾約者), 제3자인 丙을 수익자(受益者)라 한다.

③ 제3자를 위한 계약의 예로는 타인을 위한 보험계약(상법 제639조 제1항), 채무자와 인수인의 계약으로 체결되는 병존적 채무인수 등을 들 수 있다(대판 1997.10.24. 97다28698).

2. 출연의 원인관계

(1) 기본관계(보상관계)

① 요약자와 낙약자 사이의 관계로, 낙약자가 수익자에게 급부를 함으로써 입게 되는 손실이 낙약자와 요약자 사이의 원인관계에 의하여 보상된다. 낙약자의 출연, 즉 손실이 이 관계에 의하여 보상된다는 점에서 보상관계라고도 한다.

② 보상관계는 제3자를 위한 계약의 내용을 이루므로 그 의사표시의 하자·흠결은 계약의 효력에 영향을 미친다. 따라서 위의 예에서 乙은 丙의 이행청구에 대하여 甲과의 관계에서 발생한 동시이행의 항변권을 행사할 수 있고, 가령 甲과 乙사이의 매매계약이 무효이거나 취소되면 丙의 이행청구권도 소멸한다.

(2) 대가관계

① 요약자(채권자)와 수익자(제3자)의 관계를 대가관계라 한다. 위의 예에서 甲이 乙과 매매계약을 하면서 乙로 하여금 丙에게 대금을 지급하도록 하는 약정을 하는 이유는 甲이 丙에게 부담하는 매매대금 만큼의 채무를 변제하기 위한 경우일 수도 있고, 甲이 丙에게 증여하는 것일 수도 있다.

② 대가관계는 채권자와 제3자 사이의 내부관계에 불과하므로 제3자를 위한 계약의 내용을 이루지 않으며 대가관계의 부존재나 그 의사표시의 하자·흠결은 제3자를 위한 계약의 성립이나 효력에 영향을 미치지 않는다.

③ 따라서 낙약자(채무자)는 요약자와 수익자 사이의 법률관계에 기한 항변으로 수익자에게 대항하지 못하고, 요약자도 대가관계의 부존재나 효력의 상실을 이유로 자신이 기본관계에 기하여 낙약자에게 부담하는 채무의 이행을 거부할 수 없다[2003다49771].

3. 제3자를 위한 계약의 성립요건

(1) 요약자와 낙약자 사이에 유효한 계약이 성립 할 것

① 요약자와 낙약자 사이에 계약이 유효하게 성립하고 있어야 한다.

② 요약자와 낙약자는 제3자를 위한 계약의 당사자이므로 수익자의 동의 없이 취소권이나 해제권을 행사할 수 있으며, 그로 인한 부당이득반환청구권이나 원상회복청구권도 당사자간(요약자와 낙약자)에만 행사할 수 있고 제3자인 수익자에게는 청구할 수 없다.

(2) 제3자 약관의 존재(제3자에게 직접 권리를 취득시키는 내용의 계약)

① 제3자를 위한 계약이 성립하기 위해서는 제3자로 하여금 직접 권리를 취득하게 하는 조항(제3자 약관)이 있어야 한다.

② 계약의 당사자가 제3자에 대하여 가진 채권에 관하여 그 채무를 면제하는 계약도 제3자를 위한 계약에 준하는 것으로서 유효하다[2002다37405].

③ 제3자에게 권리 뿐만아니라 부수적인 의무를 부담하게 하는 것도 가능하다.

④ 제3자는 태아나 설립 중의 법인처럼 계약 당시에 현존하거나 특정하지 않아도 무방하다.

4. 제3자에 대한 효력

(1) 제3자의 권리취득(수익의 의사표시)

제539조(제3자를 위한 계약) ② 제3자를 위한 계약에서 제3자의 권리는 그 제3자가 채무자(낙약자)에 대하여 계약의 이익을 받을 의사를 표시한 때에 생긴다.

① 제3자(수익자)의 권리는 제3자가 채무자(낙약자)에 대하여 수익의 의사를 표시한 때에 생긴다(제539조 제2항). 제3자의 수익의 의사표시는 형성권으로서 제3자를 위한 계약의 성립요건이 아니고 제3자의 권리발생요건이다.

② 수익의 의사표시는 명시적이건 묵시적이건 불문한다.

(2) 수익의 의사표시 후의 제3자의 지위

제541조(제3자의 권리의 확정) 제539조의 규정에 의하여 제3자의 권리가 생긴 후에는 당사자는 이를 변경 또는 소멸시키지 못한다.

① 제3자의 권리확정

㉠ 제3자가 수익의 의사표시를 하여 제3자의 권리가 생긴 후에는 계약당사자는 이를 변경 또는 소멸시키지 못한다(제541조). 만일 계약의 당사자가 제3자의 권리를 임의로 변경 · 소멸시키는 행위를 한 경우 이는 제3자에 대하여 효력이 없다.

㉡ 그러나 요약자와 낙약자의 합의에 의하여 제3자의 권리를 변경 · 소멸시킬 수 있음을 미리 유보하였거나 제3자의 동의가 있는 경우 계약의 당사자인 요약자와 낙약자는 제3자의 권리를 변경 · 소멸시킬 수 있다[2001다30285].

② 제3자의 급부청구권

수익의 의사표시를 한 제3자는 채무자(낙약자)에 대해 직접 자기에게 급부할 것을 청구할 수 있다[92다41559].

(3) 계약에 대한 제3자의 지위

① 계약당사자로서의 권리행사 여부

㉠ 제3자(수익자)는 계약당사자가 아니므로 계약에 관한 취소권이나 해제권을 갖지 않는다. 따라서 채무자(낙약자)의 채무불이행이 있는 경우 제3자는 계약의 당사자가 아니므로 이행지체를 이유로 계약을 해제 할 수는 없다. 다만, 제3자는 채무자에 대한 손해배상을 청구할 수는 있다[92다41559].

㉡ 계약의 당사자가 아닌 제3자(수익자)는 계약의 해제를 원인으로 한 원상회복청구권을 행사할 수 없고, 원상회복 또는 부당이득의 상대방이 되지 않는다[92다41559, 2005다7566].

② 제3자 보호규정의 제3자에 해당여부

㉠ 당사자 간의 계약이 무효 · 취소 · 해제되어 제3자가 보호받는 경우(비진의표시, 통정허위표시, 착오, 사기 · 강박, 해제 등)에도 제3자(수익자)는 보호받는 제3자에 포함되지 않는다.

㉡ 예를 들어 요약자와 낙약자 사이의 매매계약이 통정허위표시로 무효인 경우, 제3자(수익자)가 선의라 하더라도 낙약자는 제3자(수익자)에게 그 무효를 가지고 대항할 수 있다.

5. 낙약자(채무자)의 지위

(1) 낙약자의 최고권

제540조(채무자의 제3자에 대한 최고권) 전조의 경우에 채무자는 상당한 기간을 정하여 계약의 이익의 향수여부의 확답을 제3자에게 최고할 수 있다. 채무자가 그 기간내에 확답을 받지 못한 때에는 제3자가 계약의 이익을 받을 것을 거절한 것으로 본다.

(2) **낙약자의 항변권**

> **제542조(채무자의 항변권)** 채무자(낙약자)는 제3자를 위한 계약에 기한 항변으로 그 계약의 이익을 받을 제3자에게 대항할 수 있다.

① 낙약자는 수익자에게 급부를 제공할 의무를 부담하지만, 낙약자는 요약자와의 계약 자체(기본관계, 보상관계)에 기한 항변으로 수익자인 제3자에게 대항할 수 있다(제542조).

② 예컨대, 甲이 자신의 건물을 乙에게 매도하면서 乙로 하여금 丙에게 매매대금을 지급하게 하고, 동시에 제3자인 丙이 직접 乙에 대하여 그 대금청구권을 취득하도록 하는 약정을 한 경우, 잔금지급기일에 甲이 乙에게 건물의 소유권이전의무를 이행하지 않는 경우에는, 동시이행의 항변권을 행사하여 丙에 대한 잔금지급을 거절할 수 있다.

③ 그러나 낙약자는 요약자와 수익자 사이의 법률관계 에 기한 항변으로 수익자에게 대항하지 못한다.

제 4 절 계약의 해제(解除)와 해지(解止)

Ⅰ 의 의

① 계약의 해제는 유효하게 성립하고 있는 계약의 효력을 당사자의 일방적 의사표시에 의하여 소급적으로 소멸시키고 처음부터 계약이 성립하지 않았던 것과 같은 상태로 복귀시키는 것을 말한다.

② 계약을 해제할 수 있는 것은 당사자가 해제권을 가지는 경우에 한한다. 이러한 일방적 의사표시에 의해 계약을 해소시키는 권리를 '해제권'이라 하는데, 계약의 해제권은 일종의 형성권이다. 해제권에는 당사자간의 특약으로 일정한 경우에 해제권이 발생하는 것으로 미리 유보해둔 '약정해제권'과 법률의 규정에 의해 발생하는 '법정해제권'이 있다.

③ 계약의 해지란 현존하는 계속적 채권관계에 있어서 계약의 당사자가 일방적 의사표시로 계약의 효력을 장래에 향하여 소멸시키는 것을 말한다.

Ⅱ 법정해제(法定解除)

1. 법정해제권의 발생사유(법정해제사유)

(1) **민법규정** : 법정해제권의 발생사유로 민법은 채무불이행 중 이행지체와 이행불능에 관해서만 규정하고 있다(제544조~제546조).

(2) 채무자의 이행지체(履行遲滯)

제544조(이행지체와 해제) 당사자 일방이 그 채무를 이행하지 아니하는 때에는 상대방은 상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고 그 기간 내에 이행하지 아니한 때에는 계약을 해제할 수 있다. 그러나 채무자가 미리 이행하지 아니할 의사를 표시한 경우에는 최고를 요하지 아니한다.

① 상당한 기간을 정하여 이행을 최고할 것

㉠ 최고에는 '상당한 기간'을 정하여 하여야 하지만 상당하지 않은 짧은 기간의 최고나 기간을 정하지 않은 최고도 유효하고, 이 경우에는 최고 후 객관적으로 상당한 기간이 지나면 해제권이 발생한다[79다1135].

㉡ 과다최고의 경우에는 채무의 동일성이 인정되는 한 본래의 급부범위 내에서 최고의 효력이 인정되지만, 본래의 급부보다 과다한 정도가 현저하고 채권자가 청구한 금액을 제공하지 않으면 그것을 수령하지 않을 것이라는 의사가 분명한 경우에는 그 최고는 부적법하여 최고로서의 효력이 없다[94다35930, 95다19898].

② 최고기간 내에 채무자의 이행 또는 이행의 제공이 없을 것

최고기간이 지나도록 채무자가 이행이나 이행의 제공을 하지 않으면 해제권이 발생한다. 그러나 해제권이 발생한 후라도 해제권을 행사하기 전에 채무자가 채무의 내용에 좇은 이행과 지연배상을 하면 해제권은 소멸한다.

③ 최고를 요하지 않는 경우

㉠ 이행거절의 경우 : 채무자가 미리 이행하지 아니할 의사를 명백히 표시한 경우에는 최고를 요하지 아니하고 계약을 해제할 수 있다[93다11821]. 또한 이행거절을 이유로 해제를 하기 위해서 반대채무의 이행제공이 요구되지 않으며, 해제하기 위하여 채무의 이행기를 기다릴 필요도 없다. 그러나 이행거절의 의사표시가 적법하게 철회된 경우에는 상대방으로서는 자기 채무의 이행을 제공하고 상당한 기간을 정하여 이행을 최고한 후가 아니면 채무불이행을 이유로 계약을 해제할 수 없다[2000다40995].

㉡ 정기행위

제545조(정기행위와 해제) 계약의 성질 또는 당사자의 의사표시에 의하여 일정한 시일 또는 일정한 기간내에 이행하지 아니하면 계약의 목적을 달성할 수 없을 경우에 당사자 일방이 그 시기에 이행하지 아니한 때에는 상대방은 전조의 최고를 하지 아니하고 계약을 해제할 수 있다.

정기행위란 계약의 성질 또는 당사자의 의사표시에 의하여 일정한 시일 또는 일정한 기간 내에 이행하지 않으면 계약의 목적을 달성할 수 없는 계약을 말한다(결혼식 등의 잔치를 치르기 위한 음식의 주문, 연주회장으로 보낼 화환의 주문, 결혼식에 입을 것을 명시한 예복의 주문 등). 이 경우 당사자 일방이 그 시기에 이행하지 않은 때에는 상대방은 이행의 최고를 하지 않고 계약을 해제할 수 있다.

(3) 이행불능으로 인한 해제권의 발생

제546조(이행불능과 해제) 채무자의 책임있는 사유로 이행이 불능하게 된 때에는 채권자는 계약을 해제할 수 있다.

① 채무자의 귀책사유에 의한 이행불능이 있을 것

㉠ 계약이 성립한 후에 채무자의 귀책사유로 인한 후발적 불능이 있어야 한다. 따라서 매도인의 소유권이전의무가 매수인의 귀책사유로 이행불능이 된 경우에 매수인은 이행불능을 이유로 계약을 해제할 수 없다.

㉡ 채무의 일부가 이행불능인 경우에 급부가 가분적이고 나머지 부분만으로 계약의 목적을 달성할 수 있는 때에는 그 불능부분에 대해서만 해제권이 발생한다. 그러나 이행이 가능한 나머지 부분만의 이행으로 계약의 목적을 달할 수 없을 때에는 계약 전부를 해제할 수 있다[94다57817].

㉢ 매매목적물인 부동산에 대한 근저당권설정등기나 가압류등기가 말소되지 아니하였다고 하여 바로 매도인의 소유권이전등기의무가 이행불능이 되었다고 할 수 없고, **매수인이 매도인에게 상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고 그 기간 내에 이행하지 아니한 때에 한하여 계약을 해제할 수 있다**[2000다50688].

② 최고 없이 즉시 해제권 발생

이행기에 불능일 것이 확실하면 이행기를 기다리지 않고, 즉시(최고 없이) 해제권이 발생한다. 매도인의 매매계약상의 소유권이전등기의무가 이행불능이 되어 이를 이유로 매매계약을 해제함에 있어서는 상대방의 잔대금지급의무가 매도인의 소유권이전등기의무와 동시이행관계에 있다고 하더라도 그 이행의 제공을 필요로 하는 것이 아니다[2000다22850].

(4) 부수적 채무(附隨的 債務)의 불이행

부수적 채무(토지거래허가에서 협력의무)를 불이행한 데에 지나지 않은 경우에는 계약을 해제할 수 없다[2001다20394].

2. 해제권의 행사(해제의 의사표시)

(1) 해제권의 행사방법

제543조(해지, 해제권) ① 계약 또는 법률의 규정에 의하여 당사자의 일방이나 쌍방이 해지 또는 해제의 권리가 있는 때에는 그 해지 또는 해제는 상대방에 대한 의사표시로 한다.
② 전항의 의사표시는 철회하지 못한다.

① 일방적 의사표시

㉠ 해제의 의사표시는 단독행위이므로 조건이나 기한을 붙이지 못함이 원칙이다. 다만, 상당한 기간 내에 이행이 없으면 위 매매계약은 해제된 것으로 하겠다는 최고는 이행최고와 동시에 상당한 기간 내에 명도의무의 이행이 없을 것을 정지조건으로 하여 미리 해제의 의사표시를 한 것이므로 그로부터 상당기간이 경과함으로써 위 매매계약은 적법히 해제되었다[96다35590].

㉡ 한편, 해제의 의사표시는 철회할 수 없다(동조 제2항).

㉢ 또한 도달주의(제111조 제1항)의 원칙상 해제의 의사표시는 상대방에게 도달한 때에 효력이 생긴다.

② 명시적 · 묵시적 불문

해제의 의사표시를 소 제기에 의한 경우 그 소장(訴狀)이 피고에게 송달됨으로써 해제권을 행사하였다 할 것이고, 해제권은 형성권이므로 비록 그 후에 원고가 그 소송을 취하하였다 하여 위 해제권행사의 효력(소급무효)에 아무런 영향도 미치지 않는다[80다916].

(2) 해제권의 불가분성(不可分性)

① 행사상의 불가분성

> **제547조(해지 · 해제권의 불가분성)** ① 당사자의 일방 또는 쌍방이 수인인 경우에는 계약의 해지나 해제는 그 전원으로부터 또는 전원에 대하여 하여야 한다.

㉠ 따라서 계약상대방이 수인인 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 중 1인에 대하여 한 계약의 해제는 효력이 없다.

㉡ 다만, 공유자 전원이 공유물에 대한 각 그 소유지분 전부를 형식상 하나의 매매계약에 의하여 동일한 매수인에게 매도하는 경우라도 특별한 사정이 없는 한 실질상 각 공유지분별로 별개의 매매계약이 성립되었다고 할 것이고, 일부 공유자가 매수인의 매매대금지급의무불이행을 원인으로 한 그 공유지분에 대한 매매계약을 해제하는 것은 가능하다고 할 것이다[94다59745].

② 소멸상의 불가분성

> **제547조(해지 · 해제권의 불가분성)** ② 전항의 경우에 해지나 해제의 권리가 당사자 1인에 대하여 소멸한 때에는 다른 당사자에 대하여도 소멸한다.

③ 임의규정 : 해제권의 불가분성에 관한 규정(제547조)은 임의규정의 성격을 가지므로 당사자 간의 특약으로 이를 배제할 수 있다[93다46209].

3. 법정해제의 효과

(1) 계약의 소급적 실효

제548조(해제의 효과, 원상회복의무) ① 당사자 일방이 계약을 해제한 때에는 각 당사자는 그 상대방에 대하여 원상회복의 의무가 있다. 그러나 제3자의 권리를 해하지 못한다.
② 전항의 경우에 반환할 금전에는 그 받은 날로부터 이자를 가하여야 한다.

① 해제의 기본적 효과

㉠ **채권관계 소멸** : 계약이 해제되면 계약상의 구속으로 부터의 해방되어 모든 채권관계는 소급적으로 소멸한다. 따라서 일방당사자의 계약위반을 이유로 한 상대방의 계약해제 의사표시에 의하여 계약이 해제되었음에도 상대방이 계약이 존속함을 전제로 계약상 의무의 이행을 구하는 경우 계약을 위반한 당사자도 당해 계약이 상대방의 해제로 소멸되었음을 들어 그 이행을 거절할 수 있다[2001다21441].

㉡ **해제와 물권의 복귀** : 계약이 해제되면 그 계약의 이행으로 변동이 생겼던 물권은 당연히 그 계약이 없었던 원상태로 복귀한다고 한다[75다1394]. 따라서 해제에 따른 매도인의 원상회복청구권은 소유권에 기한 물권적 청구권이라 할 것이고, 따라서 이는 소멸시효의 대상이 아니다[80다2968].

② 해제의 소급효와 제3자의 보호

㉠ **제548조 제1항 단서의 성격** : 계약해제의 효력은 제3자의 권리를 해하지 못한다(제548조 제1항 단서)고 규정되어 있는데 이는 제3자의 권리 내지 거래의 안전을 보호하기 위하여 해제의 소급효에 일정한 제한을 가하고 있다.

㉡ 제3자의 범위

ⓐ 민법 제548조 제1항 단서 소정의 제3자라 함은 해제된 계약으로부터 생긴 법률적 효과를 기초로 하여 새로운 이해관계를 가졌을 뿐만 아니라 등기 · 인도 등으로 완전한 권리를 취득한 자를 말한다[2000다16169].

ⓑ 해제 전에 그 해제와 양립하지 아니하는 법률관계를 가진 제3자는 선의 · 악의를 불문하고 보호된다. 그러나 해제의 의사표시가 있은 후에 해약당사자와 양립되지 아니하는 법률관계를 가지게 된 제3자는 선의만 보호되고 악의는 보호되지 않는다.

㉢ 제3자에 해당하는 경우

ⓐ 해제된 계약의 목적물(부동산)에 대하여 소유권이전등기 또는 저당권등기나 가압류 한 가압류채권자는 민법 제548조 제1항 단서에서 말하는 제3자에 포함된다[99다40937].

ⓑ 매매계약이 해제되는 경우 매수인과 매매예약을 체결한 후 그에 기한 소유권이전청구권 보전을 위한 가등기를 마친 사람도 민법 제548조 제1항 단서에서 말하는 제3자에 포함된다[2013다14569].

ⓒ 소유권을 취득하였다가 계약해제로 인하여 소유권을 상실하게 된 임대인으로부터 그 계약이 해제되기 전에 주택을 임차받아 주택의 인도와 주민등록을 마침으로써 주택임대차보호법 소정의 대항요건을 갖춘 임차인은 등기된 임차권자와 마찬가지로 위 제3자에 해당된다[2003다12717].

㉣ 제3자에 해당하지 않는 경우

ⓐ 계약상의 채권을 양도받은 양수인이나 그 채권의 압류 · 가압류채권자는 이에 포함되지 않는다[2000다16169].

ⓑ 계약이 해제되기 전에 계약상의 채권을 양수하여 이를 피보전권리로 하여 처분금지가처분결정을 받은 자는 제3자에 해당하지 않는다.

ⓒ 매매계약에 기한 매수인의 소유권이전등기청구권을 가압류한 자는 제3자에 해당하지 않는다.

ⓓ 토지를 매도했다가 그 매매계약을 해제한 경우에 있어서 그 토지 위에 신축한 건물의 매수인은 제3자에 해당하지 않는다[90다카16761].

(2) 원상회복의무

① **의의** : 계약이 해제되면 각 당사자는 상대방에게 계약이 없었던 것과 같은 상태에 복귀하게 할 의무를 부담하는바 이를 원상회복의무라고 한다. 즉, 계약이 해제되면 각 당사자는 받은 이익의 현존 여부나 선의 · 악의를 불문하고 받은 이익의 전부를 반환하여야 한다[98다43175].

② 원상회복의 내용

㉠ 금전인 경우에는 반환할 금전에는 그 받은 날로부터 이자를 가하여야 한다. 이자의 반환은 일종의 부당이득반환의 성질을 가지는 것이지 반환의무의 이행지체로 인한 손해배상은 아니다[2000다16275].

㉡ 물건이 급부되어 있는 경우에는 원칙적으로 원물을 반환해야 한다. 과실도 반환하여야 하는데 반환당시에 과실이 남아 있지 않더라도 가액을 반환해야 하고, 매매계약이 해제된 경우 매수인이 매매목적물을 이용하였다면 그 사용으로 인한 이익(사용이익)을 매도인에게 반환해야 한다[97다30066].

(3) 계약해제와 손해배상청구

제551조(해지 · 해제와 손해배상) 계약의 해지 또는 해제는 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다.

(4) 해제의 효과와 동시이행항변권

계약이 해제되면 계약당사자는 상대방에 대하여 원상회복의무와 손해배상의무를 부담하는데, 이때 계약당사자가 부담하는 원상회복의무뿐만 아니라 손해배상의무도 함께 동시이행의 관계에 있다[95다25138].

4. 해제권의 소멸

(1) **일반적 소멸원인** : 이행지체로 해제권이 발생한 경우 해제권을 행사하기 전에 채무자가 채무에 따른 이행과 지연배상을 하게 되면 해제권은 소멸한다. 해제권은 형성권이므로 10년의 제척기간에 걸리며, 해제권의 포기에 의하여도 소멸한다.

(2) **해제권의 특수한 소멸원인**

① 상대방의 최고에 의한 소멸

> **제552조(해제권행사 여부의 최고권)** ① 해제권의 행사의 기간을 정하지 아니한 때에는 상대방은 상당한 기간을 정하여 해제권행사 여부의 확답을 해제권자에게 최고할 수 있다.
> ② 전항의 기간 내에 해제의 통지를 받지 못한 때에는 해제권은 소멸한다.

② 목적물의 훼손 또는 반환불능으로 인한 소멸

> **제553조(훼손 등으로 인한 해제권의 소멸)** 해제권자의 고의나 과실로 인하여 계약의 목적물이 현저히 훼손되거나 이를 반환할 수 없게 된 때 또는 가공이나 개조로 인하여 다른 종류의 물건으로 변경된 때에는 해제권은 소멸한다.

③ 해제권의 불가분성에 따른 소멸 : 당사자의 일방 또는 쌍방이 수인인 경우 해제권이 당사자 1인에 대해 소멸한 때에는 다른 계약당사자에 대하여도 해제권은 소멸한다(제547조 제2항).

Ⅲ 합의해제(合意解除, 해제계약)

① 의 의

㉠ 계약의 합의해제 또는 해제계약이란 해제권의 유무를 불문하고 계약당사자의 합의에 의해 기존의 계약의 효력을 소멸시켜 당초부터 계약이 체결되지 않은 것과 같은 상태로 복귀시킬 것을 내용으로 하는 새로운 계약이다. 해제가 단독행위라는 점에서 합의해제와 구별된다.

㉡ 합의해제는 명시적인 경우 뿐만 아니라 묵시적으로 이루어질 수 있는 것이므로, 매도인이 잔금기일 경과 후 해제를 주장하며 수령한 대금을 공탁하고 매수인이 이의 없이 수령한 경우, 특별한 사정이 없는 한 합의해제된 것으로 본다[79다1457]. 또한 계약 후 당사자 쌍방의 계약실현의사의 결여 또는 포기로 인하여 쌍방 모두 이행의 제공이나 최고 없이 장기간 방치한 경우에도 종전의 계약이 묵시적으로 합의해제되었다고 해석함이 상당하다[87다카2503].

㉢ 계약을 합의해제 한 후 그 합의해제를 무효화 시키고 해제된 매매계약을 부활시키는 약정도 계약자유의 원칙상 허용된다[2007도5030].

② 합의해제의 효과

㉠ 합의해제는 계약의 일종이므로 합의해제의 효력은 그 합의해제의 내용에 의하여 다루어지는 것이고, 이에는 해제에 관한 민법 제543조~제553조의 규정은 적용되지 않는다[79다1455].

㉡ 합의해제의 경우에는 해제권의 유무를 불문하며 당사자간의 약정이 없는 한 반환할 금전에 그 받은 날로부터의 이자를 가산할 의무가 없고[2000다5336], 합의해제의 경우 손해배상을 하기로 특약을 하지 않는 이상 채무불이행으로 인한 손해배상을 청구할 수 없다[86다카1147].

㉢ 합의해제로 계약은 소급적으로 소멸한다. 따라서 매매계약이 합의해제되면 매수인에게 이전되었던 소유권은 당연히 매도인에게 복귀하는 것이므로 합의해제에 따른 매도인의 원상회복청구권은 소유권에 기한 물권적 청구권이라고 할 것이고 또한 합의해제의 소급효로 제3자의 권리를 해할 수 없다[2005다6341].

Ⅳ 계약의 해지(契約의 解止)

1. 의 의

계약의 당사자가 일방적 의사표시로 현존하는 계속적 채권관계에 있어서 계약의 효력을 장래에 향하여 소멸시키는 것을 말한다. 해지는 계속적 채권계약(소비대차 · 사용대차 · 임대차 · 고용 · 위임 · 임치 · 조합 · 종신정기금 등), 즉 계약상 채무의 이행이 시간적 계속성을 가지는 경우에만 인정된다. 해지권은 해제권의 발생사유와 유사하다.

2. 해지의 효과

제550조(해지의 효과) 당사자 일방이 계약을 해지한 때에는 계약은 장래에 대하여 그 효력을 잃는다.

당사자 일방이 계약을 해지한 때에는 계약은 장래에 대하여 그 효력을 잃는다. 합의해지 또는 해지계약은 계속적 계약의 효력을 해지시점 이후부터 장래를 향하여 소멸하게 하는 것을 내용으로 하는 새로운 계약으로서, 합의해지로 인하여 반환할 금전에 그 받은 날로부터의 이자를 가하여야 할 의무가 있는 것은 아니다[2000다5336]. 계약의 해지는 손해배상의 청구에 영향을 미치지 않는다(제551조).

CHAPTER

02 계약법 각론(各論)

제 1 절 매매(賣買)

Ⅰ 서 설

1. 매매의 의의

제563조(매매의 의의) 매매는 당사자 일방이 재산권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고 상대방이 그 대금을 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다.

2. 법적 성질

매매는 낙성 · 불요식 · 쌍무 · 유상의 계약으로서 재산권(물권, 채권, 지적재산권 등)이 매매대상이 된다. 또한 타인의 권리나 물건도 매매의 목적이 될 수 있다(제569조).

Ⅱ 매매의 성립

1. 서 설

(1) **의사합치**

매매계약은 매도인이 재산권을 이전하는 것과 매수인이 그 대가로서 금원을 지급하는 것에 관하여 쌍방당사자의 합의가 이루어짐으로써 성립한다[94다34432]. 따라서 매매의 목적 이외의 사항, 즉 계약비용, 채무이행시기, 이행장소 등에 관해 반드시 합의가 있음을 요하지 않는다.

(2) **매매의 성립에 관한 특칙**

민법은 매매의 성립에 관한 매매의 일방예약(제564조), 해약금(제565조), 매매계약의 비용의 부담(제566조)에 대해 특별규정을 두고 있는데, 이것들은 성질상 모든 유상계약에도 준용된다.

2. 매매의 일방예약(豫約)

(1) **의 의**

제564조(매매의 일방예약) ① 매매의 일방예약은 상대방이 매매를 완결할 의사를 표시하는 때에 매매의 효력이 생긴다.
② 전항의 의사표시의 기간을 정하지 아니한 때에는 예약자는 상당한 기간을 정하여 매매완결 여부의 확답을 상대방에게 최고할 수 있다.
③ 예약자가 상당한 기간 내에 확답을 받지 못한 때에는 예약은 그 효력을 잃는다.

① 민법은 제564조 제1항에서 "매매의 일방예약은 상대방이 매매를 완결할 의사를 표시하는 때에 매매의 효력이 생긴다."라고 규정하여 매매의 예약은 당사자 간에 달리 특약이 없는 한 일방예약으로 추정한다(제564조).

② 매매의 예약은 당사자의 일방이 매매를 완결할 의사를 표시한 때에 매매의 효력이 생기는 것이므로 적어도 일방예약이 성립하려면 그 예약에 터잡아 맺어질 본 계약의 요소가 되는 매매목적물 · 이전방법 · 매매가액 및 지급방법 등의 내용이 확정되어 있거나 확정할 수 있어야 한다[93다4908].

(2) 예약완결권(豫約完結權)

① 의의 및 성질

예약완결권이란 상대방에 대한 일방적 의사표시만으로 본계약을 성립시키는 권리를 말한다. 이는 형성권이고 재산권이므로 양도성 · 상속성이 있다.

② 행사의 효과

예약완결권을 행사하면 본계약인 매매가 성립하고 효력이 생기므로 바로 매매계약의 이행을 청구할 수 있다.

③ 예약완결권의 존속기간

㉠ 당사자가 예약완결권의 존속기간을 정한 때에는 약정한 기간 동안 존속하지만, 존속기간을 약정하지 않은 경우에는 예약자는 상당한 기간을 정하여 매매완결 여부의 확답을 상대방에게 최고할 수 있고 예약자가 그 기간 내에 확답을 받지 못한 때에는 예약은 효력을 잃는다(제564조).

㉡ 또한 매매예약완결권은 일종의 형성권으로서 당사자 사이에 그 행사기간의 약정이 없는 때에는 그 예약이 성립한 때로부터 10년 내에 이를 행사 하여야 하고, 그 기간을 지난 때에는 상대방이 예약 목적물인 부동산을 인도받은 경우라도 예약완결권은 제척기간의 경과로 인하여 소멸한다[96다47494].

㉢ 매매예약 완결권의 제척기간이 도과하였는지 여부는 직권조사사항으로서 이에 대한 당사자의 주장이 없더라도 법원이 직권으로 조사하여 고려하여야 한다[99다18718].

3. 계약금(契約金)

(1) 의 의

계약을 체결하면서 그 계약에 부수하여 당사자 일방이 상대방에게 교부하는 금전 기타의 유가물을 말한다. 민법은 매매에 관하여 계약금에 관한 규정을 두고(제565조 제1항) 이를 다른 유상계약에 준용하고 있다(제567조).

(2) 계약금계약의 성격

① **종된 계약(從된 契約)** : 계약금의 교부에 의한 계약금계약은 매매 등의 주된 계약에 부수하여 행해지는 종된 계약이다. 따라서 주된 계약이 무효이거나 취소 · 해제되면 계약금계약도 효력을 잃는다. 다만, 반드시 주된 계약과 동시에 해야 하는 것은 아니고, 주된 계약 이후에도 가능하다.

② **요물계약(要物契約)**

㉠ 계약금계약은 금전 기타 유가물의 교부를 요건으로 하므로 요물계약이다.

㉡ 따라서 당사자가 계약금의 잔금 또는 전부를 지급하지 아니하는 한 계약금계약은 성립하지 아니하므로 특별한 사정이 없는 한 당사자가 임의로 주계약을 해제할 수는 없다 할 것이다[2007다73611].

(3) 계약금의 기능(성질)

① **증약금(證約金)** : 계약체결의 증거로서의 의미를 가지는 계약금이다. 증약금은 계약금의 최소한의 성질로서 계약금은 언제나 증약금의 성질을 갖는다.

② **해약금**

㉠ 계약금의 교부는 당사자 사이에 다른 약정이 없는 한 해제권을 보류하는 작용을 갖는다. 즉, 교부자는 계약금을 포기함으로써, 수령자는 배액을 상환함으로써 계약을 해제 할 수 있다.

㉡ 우리 민법은 당사자의 특별한 약정이 없는 경우 계약금은 해약금으로 추정한다(제565조).

㉢ 계약금의 포기나 배액상환에 의한 해제권 행사를 배제하는 당사자의 약정은 유효이다.

③ **위약금(違約金)**

㉠ **위약금 특약** : 계약금을 위약금으로 하는 당사자의 특약이 있어야 계약금은 위약금의 성질을 가진다[86누438].

㉡ **손해배상액의 예정** : 당사자 사이에 위약금의 약정이 있는 경우에 그것이 위약벌인지 손해배상액의 예정인지가 불분명하면 손해배상액의 예정으로 추정된다(제398조 제4항). 즉, 일방의 채무불이행의 경우 상대방은 손해배상을 청구할 수 있는데 계약금을 손해배상액을 미리 예정한 것으로 하여 계약금의 교부자가 채무불이행을 하면 계약금의 수령자가 이를 몰수하고, 수령자의 채무불이행이 있으면 계약금의 배액을 손해배상액으로 상환하여야 한다.

㉢ **위약금약정이 없는 경우** : 계약금을 수수하면서 위약금의 특약이 없는 이상 계약이 일방의 귀책사유로 해제되었다 하더라도 상대방은 계약불이행으로 입은 실제 손해만을 배상받을 수 있을 뿐 계약금이 위약금으로서 상대방에게 당연히 귀속되는 것은 아니다[2007다24930].

(4) 해약금에 의한 계약해제

제565조(해약금) ① 매매의 당사자 일방이 계약당시에 금전 기타 물건을 계약금, 보증금 등의 명목으로 상대방에게 교부한 때에는 당사자간에 다른 약정이 없는 한 당사자의 일방이 이행에 착수할 때까지 교부자는 이를 포기하고 수령자는 그 배액을 상환하여 매매계약을 해제할 수 있다.
② 제551조의 규정(손해배상청구권)은 전항(계약금에 의한 해제)의 경우에 이를 적용하지 아니한다.

① 해제의 시기

㉠ 당사자 '일방'이 '이행에 착수할 때까지' 계약금에 의한 해제를 할 수 있다.

㉡ 당사자 중 '일방' 만이 이행에 착수하여도 해제할 수 없으므로 당사자 쌍방 모두가 이행에 착수하지 않아야 해제할 수 있다. 따라서 매매계약의 일부 이행에 착수한 당사자는 비록 상대방이 이행에 착수하지 않았다 하더라도 해제권을 행사할 수 없다[70다105].

㉢ '이행 착수'의 의미

ⓐ 이행에 착수한다는 것은 객관적으로 외부에서 인식할 수 있는 정도로 채무의 이행행위의 일부를 하거나(중도금 지급) 또는 이행을 하기 위하여 필요한 전제행위(잔금을 준비하고 등기소 동행을 촉구하는 경우)를 하는 경우를 말하는 것으로서 단순히 이행의 준비를 하는 것만으로는 부족하다.

ⓑ 이행기의 약정이 있다 하더라도 특별한 사정이 없는 한 그 이행기 전에 이행에 착수할 수도 있다[2002다46492].

ⓒ 매도인이 매수인에 대하여 매매계약의 이행을 최고하고 매매잔대금의 지급을 구하는 소송을 제기한 것만으로는 이행에 착수하였다고 볼 수 없어 매수인은 계약금을 포기하고 계약을 해제할 수 있다[2007다72274,72281].

ⓓ 계약금만 수수한 상태에서 당사자가 토지거래허가신청을 하고 이에 따라 관할 관청으로부터 그 허가를 받았다 하더라도, 그러한 사정만으로는 아직 이행의 착수가 있다고 할 수 없어 매도인으로서는 계약금의 배액을 상환하여 매매계약을 해제할 수 있다[2008다62423].

② 해제의 방법

㉠ 당사자의 일방이 이행에 착수할 때까지 교부자는 이를 포기하고 수령자는 그 배액을 상환하여 매매계약을 해제할 수 있다.

㉡ 계약금수령자는 계약해제 의사표시 외에 계약금의 배액을 제공해야하나 상대방이 이를 수령하지 않는다 하여 이를 공탁해야 하는 것은 아니다[91다2151].

㉢ 계약금 일부만 지급된 경우 수령자가 매매계약을 해제할 수 있다고 하더라도 해약금의 기준이 되는 금원은 '실제 교부받은 계약금'이 아니라 '약정계약금'이라고 봄이 타당하므로, 매도인이 계약금의 일부로서 지급받은 금원의 배액을 상환하는 것으로는 매매계약을 해제할 수 없다[2014다231378].

③ 해제의 효과

㉠ 보통의 해제와 마찬가지로 채권관계를 소급적으로 소멸케 하지만 아직 이행이 있기 전이므로 원상회복의무는 생기지 않는다.

㉡ 채무불이행에 의한 해제가 아니라 해약금계약에 근거한 해제이므로 손해배상청구권은 발생하지 않는다(제565조 제2항).

㉢ 해약금계약이 있더라도 다른 약정사유나 채무불이행(제544조~제546조) 등의 법정사유에 의한 해제를 방해하지 않는다. 즉, 약정해제권이나 법정해제권이 발생하면 그에 따른 해제도 가능하다.

Ⅲ 매매의 효력

1. 계약비용의 부담

제566조(매매계약의 비용의 부담) 매매계약에 관한 비용은 당사자 쌍방이 균분하여 부담한다.

비용부담에 관한 당사자간의 특약이 없으면 매매계약에 관한 비용(목적물측량비용 · 계약서작성비용 · 중개수수료 등)은 당사자 쌍방이 균분하여 부담한다(제566조). 그러나 부동산등기비용은 이행에 관한 비용이며 통상 매수인이 부담한다.

2. 매도인의 재산권이전의무

제568조(매매의 효력) ① 매도인은 매수인에 대하여 매매의 목적이 된 권리를 이전하여야 하며 매수인은 매도인에게 그 대금을 지급하여야 한다.
② 전항의 쌍방의무는 특별한 약정이나 관습이 없으면 동시에 이행하여야 한다.

(1) 재산권의 이전의 내용

① 매도인은 재산권이전에 필요한 모든 행위를 할 의무가 있다. 따라서 매매의 목적인 권리가 등기 · 등록 · 인도 등의 공시방법을 갖추어야 하는 것이면 등기 · 등록에 협력하거나 인도를 하여야 한다.

② 부동산소유권 · 지상권 · 전세권처럼 부동산의 점유를 내용으로 하는 물권의 매매에 있어서는 등기 외에 목적물의 점유도 이전해야 한다.

③ 매도인이 부담하는 권리이전의무는 매수인이 권리자가 되는 것만이 아니라, 매수인이 목적물로부터 아무런 부담 없이 모든 이익을 실질적으로 향유할 수 있도록 할 의무를 진다. 따라서 부동산매도인은 목적물에 저당권과 같은 제한물권이 있는 경우에는 이를 소멸시켜서 완전한 소유권을 이전하여야 한다.

④ 특약이 없는 한 매도인은 종물이나 종된 권리도 이전해야 한다.

(2) 재산권이전과 대금지급의 동시이행

부동산의 매매계약이 체결된 경우에는 매도인의 소유권이전등기의무, 인도의무와 매수인의 잔대금지급의무는 동시이행의 관계에 있는 것이 원칙이다[2000다8533].

3. 매수인의 대금지급의무

(1) 대금지급시기

> **제585조(동일기한의 추정)** 매매의 당사자 일방에 대한 의무이행의 기한이 있는 때에는 상대방의 의무이행에 대하여도 동일한 기한이 있는 것으로 추정한다.

즉, 매매목적물의 인도할 시기만을 정한 경우에 대금의 지급도 그 시기에 할 것을 정한 것으로 추정한다.

(2) 대금지급장소

> **제586조(대금지급장소)** 매매의 목적물의 인도와 동시에 대금을 지급할 경우에는 그 인도장소에서 이를 지급하여야 한다.

4. 과실의 귀속(歸屬) 및 대금의 이자

> **제587조(과실의 귀속, 대금의 이자)** 매매계약 있은 후에도 인도하지 아니한 목적물로부터 생긴 과실은 매도인에게 속한다. 매수인은 목적물의 인도를 받은 날로부터 대금의 이자를 지급하여야 한다. 그러나 대금의 지급에 대하여 기한이 있는 때에는 그러하지 아니하다.

(1) 과실의 귀속

① 매매계약 있은 후 인도하기 전에 목적물로부터 생긴 과실은 원칙적으로 매도인에게 속한다.

② 그러나 매수인이 매매대금을 완납한 때에는 목적물이 인도되지 않았다 하더라도 매매대금완납 후부터 그 과실의 수취권은 매수인에게 귀속된다[93다28928].

(2) 대금의 이자

① 매수인이 목적물의 인도를 받은 때에는 그 날로부터 대금의 이자를 지급하여야 한다.

② 그러나 대금의 지급에 대하여 기한이 따로 정하여져 있는 때에는 비록 목적물을 인도받았다 하더라도 그 기한이 도래할 때까지 이자를 지급할 필요가 없다.

5. 매수인의 대금지급거절권

제588조(권리주장자가 있는 경우와 대금지급거절권) 매매의 목적물에 대하여 권리를 주장하는 자가 있는 경우에 매수인이 매수한 권리의 전부나 일부를 잃을 염려가 있는 때에는 매수인은 그 위험의 한도에서 대금의 전부나 일부의 지급을 거절할 수 있다. 그러나 매도인이 상당한 담보를 제공(담보물권의 설정 또는 보증계약의 체결)한 때에는 대금의 전부나 일부의 지급을 거절할 수 없다.

예컨대, 부동산매매에 있어 특별한 약정이 없는 한 매수인은 그 부동산에 설정된 근저당권 설정등기가 있어 완전한 소유권이전을 받지 못할 우려가 있으면 그 근저당권의 말소등기가 될 때까지 그, 등기상의 담보한도금액에 상당한 대금지급을 거절할 수 있다[87다카1029].

Ⅳ 매도인의 담보책임(擔保責任)

1. 서 설

(1) **의 의** : 매매의 목적인 재산권이나 목적물에 하자가 있는 경우에 매도인이 매수인에 대해 부담하는 책임을 말한다. 이러한 담보책임은 급부와 반대급부 사이에 등가성을 유지하도록 하기 위한 것으로서 거래상대방인 매수인의 보호를 목적으로 하는 보충적 규정이다.

(2) **담보책임의 성질**

① 법정무과실책임

㉠ 담보책임은 매매의 유상성을 고려하여 매수인과 거래안전을 보호하기 위해 매도인에게 특별히 인정하는 법정책임으로서 무과실책임이며 책임내용은 법률에 규정된 것에 한정된다.

㉡ 매도인의 하자담보책임이 무과실책임이라 하더라도 공평의 원칙상 하자의 발생 및 그 확대에 가공한 매수인의 잘못을 참작하여 손해배상의 범위를 정함이 상당하다[94다23920].

② 임의규정

제584조(담보책임면제의 특약) 매도인은 전15조에 의한 담보책임을 면하는 특약을 한 경우에도 매도인이 알고 고지하지 아니한 사실 및 제3자에게 권리를 설정 또는 양도한 행위에 대하여는 책임을 면하지 못한다.

㉠ 매도인의 담보책임에 관한 규정은 매수인보호를 위한 보충적 규정일 뿐 강행규정이 아니므로 당사자는 특약으로 담보책임을 배제 · 감경 또는 가중할 수 있다.

㉡ 그러나 담보책임을 면하는 특약을 한 경우에도 매도인이 알고 고지하지 아니한 사실 및 제3자에게 권리를 설정 또는 양도한 행위에 대하여는 책임을 면하지 못한다.

2. 권리의 하자에 대한 담보책임

(1) 권리의 전부가 타인에게 속한 경우(제570조)

제569조(타인의 권리의 매매) 매매의 목적이 된 권리가 타인에게 속한 경우에는 매도인은 그 권리를 취득하여 매수인에게 이전하여야 한다.
제570조(同前-매도인의 담보책임) 전조(타인의 권리의 매매)의 경우에 매도인이 그 권리를 취득하여 매수인에게 이전할 수 없는 때에는 매수인은 계약을 해제할 수 있다. 그러나 매수인이 계약당시 그 권리가 매도인에게 속하지 아니함을 안 때에는 손해배상을 청구하지 못한다.

① 의의

㉠ 예컨대, 매도인 甲이 丙의 소유에 속하는 X토지를 乙에게 매도하는 매매계약을 체결하였으나 甲이 이를 취득하여 乙에게 이전할 수 없게 된 경우 甲이 乙에게 부담하는 담보책임을 말한다.

㉡ 한편 매도인이 취득·이전할 수 없는 것에 대하여 고의 또는 과실이 있는지 여부는 문제되지 않는다[대판 1964.7.23. 64다196].

판 례

명의신탁자가 신탁부동산을 매도한 것이 타인의 권리매매에 해당하는지 여부(소극)

명의신탁한 부동산을 명의신탁자가 매도하는 경우에 명의신탁자는 그 부동산을 사실상 처분할 수 있을 뿐 아니라 법률상으로도 처분할 수 있는 권원에 의하여 매도한 것이므로 이를 민법 제569조 소정의 타인의 권리의 매매라고 할 수 없다(대판 1996.8.20. 96다18656).

부동산매수인이 소유권이전등기 없이 이를 제3자에게 전매한 경우, '타인의 권리매매'에 해당하는지 여부(소극)

부동산을 매수한 자가 그 소유권이전등기를 하지 아니한 채 이를 다시 제3자에게 매도한 경우에는 사실상 처분할 수 있을 뿐 아니라 법률상으로도 처분할 수 있는 권원에 의하여 매도한 것이므로, 그것을 민법 제569조에서 말하는 '타인의 권리매매'라고 할 수 없다(대판 1996.4.12. 95다55245).

② 담보책임의 내용

㉠ 선의의 매수인은 계약해제와 더불어 손해배상을 청구할 수 있으며, 매수인이 매도인에게 손해배상을 청구함에는 매도인은 계약이 완전히 이행된 것과 동일한 경제적 이익을 배상(이행이익배상)해야 한다.

㉡ 매수인이 계약 당시 그 권리가 매도인에게 속하지 않음을 안 때에는 계약을 해제할 수는 있으나 손해배상을 청구하지 못한다.

㉢ 제척기간

전부 타인권리의 매매에는 단기제척기간 규정이 없다.

③ 선의의 매도인의 보호(제571조)

> **제571조(同前 – 선의의 매도인의 담보책임)** ① 매도인이 계약당시에 매매의 목적이 된 권리가 자기에게 속하지 아니함을 알지 못한 경우에 그 권리를 취득하여 매수인에게 이전할 수 없는 때에는 매도인은 손해를 배상하고 계약을 해제할 수 있다.
> ② 전항의 경우에 매수인이 계약당시 그 권리가 매도인에게 속하지 아니함을 안 때에는 매도인은 매수인에 대하여 그 권리를 이전할 수 없음을 통지하고 계약을 해제할 수 있다.

민법 제571조 제1항은 선의의 매도인이 매매의 목적인 권리의 전부를 이전할 수 없는 경우에 적용될 뿐 매매의 목적인 권리의 일부를 이전할 수 없는 경우에는 적용될 수 없다[2002다33557].

(2) 권리의 일부가 타인에게 속하는 경우(제572조)

> **제572조(권리의 일부가 타인에게 속한 경우와 매도인의 담보책임)** ① 매매의 목적이 된 권리의 일부가 타인에게 속함으로 인하여 매도인이 그 권리를 취득하여 매수인에게 이전할 수 없는 때에는 매수인은 그 부분의 비율로 대금의 감액을 청구할 수 있다.
> ② 권리의 일부가 타인에게 속한 경우에 잔존한 부분만이면 매수인이 이를 매수하지 아니하였을 때에는 선의의 매수인은 계약전부를 해제할 수 있다.
> ③ 선의의 매수인은 감액청구 또는 계약해제 외에 손해배상을 청구할 수 있다.

① **의의** : 甲이 토지 1000㎡를 乙에게 매도하였는데 그 중에서 100㎡은 丙의 소유였고 丙이 그 100㎡의 매도를 거부하여 甲이 그 100㎡를 乙에게 이전할 수 없는 경우처럼 매매의 목적이 된 권리의 일부가 타인에게 속하기 때문에 매도인이 그 부분의 매수인에게 이전할 수 없는 경우 甲이 乙에게 부담하여야 할 담보책임을 말한다.

② 담보책임의 내용

㉠ 선의의 매수인은 잔존한 부분만이면 매수인이 이를 매수하지 아니하였을 경우라면 계약전부를 해제할 수 있다. 그러나 그렇지 않을 경우에는 계약을 해제하지 않고 그 부분의 비율로 대금의 감액을 청구할 수 있다.

㉡ 선의의 매수인은 감액청구 또는 계약해제 외에 손해배상을 청구할 수 있다.

㉢ 악의의 매수인은 이전하지 못한 부분의 비율로 대금의 감액만을 청구할 수 있다.

㉣ **제척기간** : 매수인이 선의인 경우에는 사실을 안 날로부터 1년 내에 행사하여야 하는데 '사실을 안 날'이라 함은 단순히 권리의 일부가 타인에게 속한 사실을 안 날이 아니라 그 때문에 매도인이 이를 취득하여 매수인에게 이전할 수 없게 되었음이 확실하게 된 사실을 안 날을 말한다[96다15596].

> **제573조(전조의 권리행사의 기간)** 권리의 일부가 타인에게 속한 경우에 계약해제 · 손해배상 · 대금감액청구권은 매수인이 선의인 경우에는 사실을 안 날로부터, 악의인 경우에는 계약한 날로부터 1년 내에 행사하여야 한다.

(3) 목적물의 수량부족, 일부멸실의 경우(제574조)

제574조(수량부족, 일부멸실의 경우와 매도인의 담보책임) 대금감액청구권, 계약해제권, 손해배상청구권은 수량을 지정한 매매의 목적물이 부족되는 경우와 매매목적물의 일부가 계약당시에 이미 멸실된 경우에 매수인이 그 부족 또는 멸실을 알지 못한 때에 준용한다.

① **의의** : 甲이 토지 100㎡를 ㎡당 100만원으로 하여 乙과 1억원에 계약을 체결하였는데 토지를 측량한 결과 10㎡가 부족한 경우(수량을 지정한 매매)나 甲이 토지 100㎡를 乙과 매매계약을 체결했으나 10㎡가 하천부지로 되어있는 경우(일부멸실)에 이 에게 부담하는 담보책임을 말한다.

② 수량을 지정한 매매

㉠ 수량을 지정한 매매의 의의

수량을 지정한 매매란 당사자가 매매의 목적인 특정물이 일정한 수량(면적)을 가지고 있다는 데 중점을 두고, 대금도 이 수량(면적)을 기준으로 정한 경우이다[95다48780].

㉡ 수량을 지정한 매매에 해당하는 경우

목적물이 일정한 면적을 가지고 있다는 데 주안을 두고 대금도 면적을 기준으로 하여 정하여지는 아파트분양계약은 수량을 지정한 매매이다[99다58136].

③ 담보책임의 내용

㉠ 선의의 매수인은 잔존한 부분만이면 매수인이 이를 매수하지 아니하였을 경우라면 계약전부를 해제할 수 있다. 그러나 그렇지 않을 경우에는 계약을 해제하지 않고 그 부분의 비율로 대금의 감액을 청구할 수 있다.

㉡ 선의의 매수인은 감액청구 또는 계약해제 외에 손해배상을 청구할 수 있다.

㉢ 악의의 매수인은 담보책임을 청구할 수 없다.

㉣ **제척기간** : 선의의 매수인은 수량부족 · 일부멸실의 사실을 안 날부터 1년 내에 행사하여야 한다.

판 례

부동산매매계약에 있어서 실제면적이 계약면적에 미달하고 그 매매가 수량지정매매에 해당하는 경우, 대금감액청구권 행사와 별도로 부당이득반환청구 또는 계약체결상의 과실책임의 이행청구가 인정되는지 여부(소극)

부동산매매계약에 있어서 실제면적이 계약면적에 미달하는 경우에는 그 매매가 수량지정매매에 해당할 때에 한하여 민법 제574조, 제572조에 의한 대금감액청구권을 행사함은 별론으로 하고, 그 매매계약이 그 미달 부분만큼 일부 무효임을 들어 이와 별도로 일반 부당이득반환청구를 하거나 그 부분의 원시적 불능을 이유로 민법 제535조가 규정하는 계약체결상의 과실에 따른 책임의 이행을 구할 수 없다(대판 2002.4.9. 99다47396).

(4) 용익적 권리에 의하여 제한되어 있는 경우(제575조)

제575조(제한물권있는 경우와 매도인의 담보책임) ① 매매의 목적물이 지상권, 지역권, 전세권, 질권 또는 유치권의 목적이 된 경우에 매수인이 이를 알지 못한 때에는 이로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우에 한하여 매수인은 계약을 해제할 수 있다. 기타의 경우에는 손해배상만을 청구할 수 있다.
② 전항의 규정은 매매의 목적이 된 부동산을 위하여 존재할 지역권이 없거나 그 부동산에 등기된 임대차계약이 있는 경우에 준용한다.
③ 계약해제와 손해배상청구는 매수인이 그 사실을 안 날로부터 1년 내에 행사하여야 한다.

① **의의** : 예컨대, 甲과 乙이 甲소유의 X토지에 대한 매매계약을 체결하였는데, X토지 위에 이 토지를 목적으로 하는 丙의 지상권이 설정되어 있어 乙이 X토지를 사용·수익할 수 없게 된 경우 甲이 乙에게 부담하는 담보책임을 말한다.

② 담보책임의 요건

㉠ 매매의 목적물이 지상권·지역권·전세권·질권 또는 유치권의 목적이 된 경우(제575조)

㉡ 목적부동산을 위하여 존재할 지역권이 없는 경우

③ 담보책임의 내용

㉠ 선의의 매수인은 용익적 권리의 존재로 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우에 한하여 계약을 해제할 수 있고, 선의의 매수인은 손해를 입은 경우 손해배상을 청구할 수 있다.

㉡ 악의의 매수인은 담보책임을 청구할 수 없다.

㉢ **제척기간** : 계약해제와 손해배상청구는 매수인이 용익권의 존재 또는 지역권의 부존재를 안 날부터 1년 내에 행사해야 한다.

(5) 저당권 · 전세권이 행사된 경우의 담보책임(제576조)

제576조(저당권, 전세권의 행사와 매도인의 담보책임) ① 매매의 목적이 된 부동산에 설정된 저당권 또는 전세권의 행사로 인하여 매수인이 그 소유권을 취득할 수 없거나 취득한 소유권을 잃은 때에는 매수인은 계약을 해제할 수 있다.
② 전항(저당권·전세권의 행사)의 경우에 매수인의 출재로 그 소유권을 보존한 때에는 매도인에 대하여 그 상환을 청구할 수 있다.
③ 전2항(저당권·전세권의 행사)의 경우에 매수인이 손해를 받은 때에는 그 배상을 청구할 수 있다.
제577조(저당권의 목적이 된 지상권, 전세권의 매매와 매도인의 담보책임) 전조의 규정은 저당권의 목적이 된 지상권 또는 전세권이 매매의 목적이 된 경우에 준용한다.

① 담보책임의 요건

㉠ 저당권에 의한 제한이 있는 것만으로는 담보책임이 발생하지 않고 매매계약 후 저당권자 또는 전세권자의 경매청구권 행사로 매수인이 그 소유권을 취득할 수 없거나 취득한 소유권을 잃은 때에 담보책임이 발생한다.

㉡ 만약 피담보채권액을 공제해서 매매대금을 정한 경우처럼 매수인이 그의 출재로 소유권을 보존하기로 한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 매도인이 담보책임을 지지 않는다[2002다11151].

② 담보책임의 내용

㉠ 저당권 또는 전세권의 행사로 인하여 매수인이 그 소유권을 취득할 수 없거나 취득한 소유권을 잃은 경우, 소유권을 취득할 수 없거나 취득한 소유권을 잃은 때에는 계약을 해제할 수 있다(제576조 제1항).

㉡ 또한 매수인이 소유권을 보존하기 위하여 자신의 출재로 피담보채권을 변제함으로써 그 부동산에 설정된 저당권을 소멸시킨 경우에는 매수인은 선·악의에 관계없이 매도인에게 그 출재의 상환을 청구할 수 있다[95다55245].

㉢ 매수인이 손해를 받은 때에는 그의 선의·악의를 불문하고 계약해제권 또는 출재비용상환청구권과 함께 그 배상을 청구할 수 있다(제576조 제3항).

㉣ 제척기간 : 제한이 없다.

③ 가등기, 가압류에도 유추적용

가등기의 목적이 된 부동산을 매수한 사람이 그 뒤 가등기에 기한 본등기가 경료됨으로써 그 부동산의 소유권을 상실하게 된 때에도 민법 제576조의 담보책임을 진다[92다21784]. 즉, 매수인은 선·악의에 관계없이 계약을 해제하고 손해배상을 청구할 수 있다.

※권리하자로 인한 담보책임 정리

담보책임의 원인		매수인	매수인의 권리(책임의 내용)			제척기간
			대금감액 청구권	계약해제권	손해배상 청구권	
권리의 하자	전부타인의 권리 (제570조)	선의	×	○	○	×
		악의	×	○	×	×
	일부 타인의 권리 (제572조)	선의	○	일정한 경우	○	안 날부터 1년
		악의	○	×	×	한 날부터 1년
	수량부족·일부멸실 (제574조)	선의	○	일정한 경우	○	안 날부터 1년
		악의	×	×	×	×
	용익권능에 의한 제한(제575조)	선의	×	목적달성 불능시	○	안 날부터 1년
		악의	×	×	×	×
	저당권·전세권의 실행(제576조)	선의	×	일정한 경우	일정한 경우	×
		악의	×	일정한 경우	일정한 경우	×

3. 물건의 하자에 대한 매도인의 담보책임(瑕疵擔保責任)

(1) 요 건

① 법률적 장애가 목적물의 하자에 해당하는지 여부

건축을 목적으로 매매된 토지에 대하여 건축허가를 받을수 없어 건축이 불가능한 경우 위와 같은 법률적 제한 내지 장애 역시 매매목적물의 하자에 해당하고, 그 하자의 존부는 매매계약성립시를 기준으로 판단하여야 한다[98다18506].

② 매수인의 선의 및 무과실

매도인의 하자담보책임을 묻기 위해서는 매수인은 물건의 하자에 대하여 선의 및 무과실이어야 한다.

(2) 특정물하자로 인한 담보책임

제580조(매도인의 하자담보책임) ① 매매의 목적물에 하자가 있는 때에는 제575조 제1항(용익권능의 제한)의 규정을 준용한다. 그러나 매수인이 하자있는 것을 알았거나 과실로 인하여 이를 알지 못한 때에는 그러하지 아니하다.
② 전항(매매의 목적물에 하자)의 규정은 경매의 경우에 적용하지 아니한다.

① **의의** : 甲과 乙이 소유의 주택에 대하여 매매계약을 체결하였는데, 그 주택에 균열이 있는 경우 甲이 乙에게 부담하는 담보책임을 말한다.

② 담보책임의 내용

㉠ 선의 · 무과실의 매수인은 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우에 한하여 계약을 해제할 수 있다(제580조 제1항).

㉡ 선의 · 무과실의 매수인은 계약해제와 상관없이 손해를 입은 경우 손해배상을 청구할 수 있다(제580조 제1항).

㉢ 선의 · 무과실의 매수인은 그 사실을 안 날부터 6월 내에 행사해야 한다(제582조). 매수인의 권리행사기간은 재판상 또는 재판 외의 권리행사기간이고 재판상 청구를 위한 출소기간은 아니다[84다카2344].

(3) 불특정물(종류물) 하자로 인한 담보책임

제581조(종류매매와 매도인의 담보책임) ① 매매의 목적물을 종류로 지정한 경우에도 그 후 특정된 목적물에 하자가 있는 때에는 전조의 규정을 준용한다.
② 전항의 경우에 매수인은 계약의 해제 또는 손해배상의 청구를 하지 아니하고 하자없는 물건을 청구할 수 있다.
제582조(전2조의 권리행사기간) 전2조에 의한 권리는 매수인이 그 사실을 안 날로부터 6월 내에 행사하여야 한다.

① **의의** : 甲과 乙이 甲 소유의 자동차에 관한 매매계약을 체결하였는데, 인도된 그 자동차의 엔진에 결함이 있는 경우 甲이 乙에게 부담하는 담보책임을 말한다.

② 담보책임의 내용

㉠ **계약해제권과 손해배상청구권** : 목적물의 하자로 매매의 목적을 달성할 수 없는 때에는 매수인은 계약을 해제함과 동시에 손해배상을 청구할 수 있다.

㉡ **완전물급부청구권** : 선의 · 무과실의 매수인은 계약해제권 또는 손해배상청구권을 행사하지 않고 하자없는 물건을 청구할 수 있다(제581조 제2항).

㉢ **권리행사기간** : 매매계약의 해제 및 손해배상청구는 매수인이 그 사실을 안 날부터 6월 내에 행사해야 한다(제582조).

핵심정리 **매도인의 하자담보책임**

1. 특정물매매의 경우
① 선의 · 무과실 : 계약해제권, 손해배상청구권
② 악의 또는 선의 · 유과실 : 담보책임 X
③ 제척기간 : 6월

2. 종류(불특정물)매매의 경우
① 선의 · 무과실 : 계약해제권 · 손해배상청구권 또는 완전물급부청구권
② 악의 또는 선의 · 유과실 : 담보책임 X
③ 제척기간 : 6월

4. 경매에 있어서의 담보책임

제578조(경매와 매도인의 담보책임) ① 경매의 경우에는 경락인은 전8조(권리의 하자)의 규정에 의하여 채무자에게 계약의 해제 또는 대금감액의 청구를 할 수 있다.
② 전항의 경우에 채무자가 자력이 없는 때에는 경락인은 대금의 배당을 받은 채권자에 대하여 그 대금 전부나 일부의 반환을 청구할 수 있다.
③ 전2항의 경우에 채무자가 물건 또는 권리의 흠결을 알고 고지하지 아니하거나 채권자가 이를 알고 경매를 청구한 때에는 경락인은 그 흠결을 안 채무자나 채권자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.

① 담보책임의 요건

㉠ 권리의 하자에만 적용

물건의 하자에 대해서는 담보책임이 인정되지 않는다(제580조 제2항).

㉡ 경매절차가 유효

제578조 제1항 · 제2항의 담보책임은 경매절차 자체가 무효인 경우에는 경매의 채무자나 채권자의 담보책임은 인정될 여지가 없다[92다15574].

② 담보책임의 내용

㉠ **대금감액청구권 · 계약해제권** : 제1차적으로 채무자(물상보증인 포함)가 경락인에 대해 담보책임을 지며, 채무자가 무자력인 경우에 2차적으로 대금의 배당을 받은 채권자가 경락인에 대해 담보책임을 진다(제578조 제1항 · 제2항).

㉡ **손해배상청구권** : 채무자가 물건 또는 권리의 흠결을 알고 고지하지 않거나 채권자가 이를 알고 경매를 청구한 때에는 경락인은 그 흠결을 안 채무자나 채권자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다(제578조 제3항).

5. 채권의 매도인의 담보책임

제579조(채권매매와 매도인의 담보책임) ① 채권의 매도인이 채무자의 자력을 담보한 때에는 매매계약 당시의 자력을 담보한 것으로 추정한다.
② 변제기에 도달하지 아니한 채권의 매도인이 채무자의 자력을 담보한 때에는 변제기의 자력을 담보한 것으로 추정한다.

Ⅴ 환매(還買)

1. 의 의

환매란 매도인이 매매계약과 동시에 매수인과의 특약으로 환매할 권리를 보류한 경우에 일정한 기간 내에 그 환매권을 행사하여 그 매매목적물을 도로 찾는 것을 말한다(제590조).

2. 환매의 요건

(1) 목적물

특별한 제한이 없으므로 동산 · 부동산, 그밖의 재산권(채권 · 무체재산권 등)이 환매의 목적물이 될 수 있다.

(2) 환매특약

제592조(환매등기) 매매의 목적물이 부동산인 경우에 매매등기와 동시에 환매권의 보류를 등기한 때에는 제3자에 대하여 그 효력이 있다.

① 환매특약은 매매계약과 동시에 해야 한다(제590조 제1항).

② 환매특약은 매매계약에 종된 계약이므로 매매계약이 무효 · 취소 · 해제되면 환매특약도 실효된다.

③ 매매의 목적물이 부동산인 경우에 매매등기와 동시에 환매권의 보류를 부기등기한 때에는 제3자에 대하여 그 효력이 있다.

④ 환매특약등기가 경료되었다 하여 매수인이 그 부동산을 처분할 수 없는 것은 아니다. 따라서 환매특약등기가 된 부동산을 매수인이 제3자에게 다시 매도하였다면, 그 부동산 매수인은 제3자에 대하여 환매특약의 등기사실을 들어 소유권이전등기절차 이행을 거절할 수 없다.

(3) 환매대금(제590조)

환매대금은 매매대금과 매수인이 부담한 매매비요이지만, 당사자 특약으로 달리 정할 수 있다(제590조 제1항).

(4) 환매기간

제591조(환매기간) ① 환매기간은 부동산은 5년, 동산은 3년을 넘지 못한다. 약정기간이 이를 넘는 때에는 부동산은 5년, 동산은 3년으로 단축한다.
② 환매기간을 정한 때에는 다시 이를 연장하지 못한다.
③ 환매기간을 정하지 아니한 때에는 그 기간은 부동산은 5년, 동산은 3년으로 한다.

3. 환매의 실행(實行)

(1) 환매권의 행사방법

제594조(환매의 실행) ① 매도인은 기간 내에 대금과 매매비용을 매수인에게 제공하지 아니하면 환매할 권리를 잃는다.

① 환매권자는 환매기간 내에 매매대금과 매매비용을 환매의무자에게 제공하고 환매의 의사표시를 해야 한다.

② 환매권은 양도성이 있으므로 양도된 때에는 양수인이 행사하고, 환매권이 등기된 경우에는 환매의 의사표시는 목적물의 전득자에게 한다.

(2) 환매권의 대위행사

제593조(환매권의 대위행사와 매수인의 권리) 매도인의 채권자가 매도인을 대위하여 환매하고자 하는 때에는 매수인은 법원이 선정한 감정인의 평가액에서 매도인이 반환할 금액을 공제한 잔액으로 매도인의 채무를 변제하고 잉여액이 있으면 이를 매도인에게 지급하여 환매권을 소멸시킬 수 있다.

(3) 매수인이 사용 · 수익

매수인이 목적부동산 위에 제한물권을 설정한 것은 유효하나 매도인이 환매권을 행사하면 매수인은 그러한 제한이 없는 소유권을 이전해야 한다.

4. 환매의 효과

(1) 기본적 효과

① 환매권을 행사하면 환매가 성립하고 이를 원인으로 매도인명의로 소유권이전등기를 하여야 다시 소유권을 취득한다.

② 따라서 매도인이 환매기간 내에 환매의 의사표시만 하고 그 환매에 의한 권리취득의 등기를 하지 않았다면 그 부동산을 가압류 집행한 자에 대하여 권리취득을 주장할 수 없다[90다카16914].

③ 부동산의 매매계약에 있어 당사자 사이의 환매특약에 따라 소유권이전등기와 함께 민법 제592조에 따른 환매등기가 마쳐진 경우 매도인이 환매기간 내에 적법하게 환매권을 행사하면 환매등기 후에 마쳐진 제3자의 근저당권 등 제한물권은 소멸한다[2000다27411].

(2) 상계간주

제590조(환매의 의의) ③ 환매의 경우에 목적물의 과실과 대금의 이자는 특별한 약정이 없으면 이를 상계한 것으로 본다.

(3) 비용상환청구

제594조(환매의 실행) ② 매수인이나 전득자가 목적물에 대하여 비용을 지출한 때에는 매도인은 제203조의 규정에 의하여 이를 상환하여야 한다. 그러나 유익비에 대하여는 법원은 매도인의 청구에 의하여 상당한 상환기간을 허여할 수 있다.

제 2 절 교환(交換)

1. 의 의

제596조(교환의 의의) 교환은 당사자 쌍방이 금전 이외의 재산권을 상호 이전 할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다.

① 낙성 · 쌍무 · 유상 · 불요식의 계약인 점에서 매매와 같으나 반대급부의 목적물이 금전 외의 재산권이라는 점에서 다르다.

② 교환의 대상은 금전 외의 재산권이어야 한다. 금전은 교환이 아니다. 다만 당사자 일방이 재산권이전과 금전의 보충지급을 약정하는 것은 가능하다.

2. 효 력

① 매매규정 준용

제567조(유상계약에의 준용) 본절(매매)의 규정은 매매 이외의 유상계약에 준용한다.

② 보충금

제597조(금전의 보충지급의 경우) 당사자 일방이 전조의 재산권이전과 금전의 보충지급을 약정한 때에는 그 금전에 대하여는 매매대금에 관한 규정을 준용한다.

③ 담보책임

교환계약이 이행된 후에도 이전받은 재산권에 하자가 있을 때에는 당사자는 계약을 해제할 수 있다[66다76].

④ 쌍무계약의 효력

또한 쌍무계약이므로 동시이행항변권 및 위험부담에 관한 규정이 적용된다.

⑤ 교환계약에서 당사자가 자기 소유 목적물의 시가를 묵비하여 상대방에게 고지하지 않은 경우, 특별한 사정이 없는 한 상대방의 의사결정에 불법적인 간섭을 한 것이 아니다. 즉, 사기가 아니다.

판 례

교환계약에서 당사자의 일방이 교환목적물인 각 재산권의 차액에 해당하는 금원인 보충금의 지급에 갈음하여 상대방으로부터 이전받을 목적물에 관한 근저당권의 피담보채무를 인수하기로 약정한 경우, 특별한 사정이 없는 한 채무를 인수한 일방은 위 보충금을 제외한 나머지 재산권을 상대방에게 이전하여 줌으로써 교환계약상의 의무를 다한 것이 된다. 그리고 위 피담보채무를 인수한 교환계약의 당사자 일방이 인수채무인 근저당권의 피담보채무의 변제를 게을리함으로써 교환목적물에 관하여 설정된 근저당권의 실행으로 임의경매절차가 개시되었거나 개시될 염려가 있어 상대방이 이를 막기 위하여 부득이 피담보채무를 변제한 경우 등의 특별한 사정이 있는 경우에는, 상대방은 이와 같은 특별한 사정이 있다는 사유를 들어 교환계약을 해제할 수도 있다(대판 1998.7.24. 98다13877).

제 3 절 임대차(賃貸借)

Ⅰ 서 설

1. 의 의

제618조(임대차의 의의) 임대차는 당사자 일방(임대인)이 상대방에게 목적물을 사용 · 수익하게 할 것을 약정하고 상대방(임차인)이 이에 대하여 차임을 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다.

① 임대차는 당사자 일방이 상대방에게 목적물을 사용 · 수익하게 할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 차임을 지급할 것을 약정함으로써 성립하는 낙성 · 유상 · 쌍무의 채권계약이다.

② 차임은 반드시 금전일 필요 없다.

③ 임대인이 소유권이나 처분권을 가지고 있을 필요 없다. 따라서 무권한자도 의무부담행위는 할 수 있다(제569조).

2. 부동산임차권의 물권화(物權化) 문제

(1) 의 의

경제적 약자인 임차인을 보호하기 위하여 부동산임차권은 실제 효력에 있어서는 어느 정도 물권에 접근하는 규정들을 두고 있는데, 이를 '부동산임차권의 물권화'라 한다.

(2) 대항력(對抗力)

① 의의

채권인 '임차권'은 대항력이 없으나 민법은 부동산임차권 등기를 하거나 토지임대차의 경우 지상건물을 등기한 때에는 제3자에게 효력이 있는 것으로 규정하고 있다.

② 대항력이 있는 경우

㉠ 등기 된 부동산 임대차

당사자간에 반대약정이 없으면 임차인은 임대인에 대하여 임대차의 등기절차에 협력할 것을 청구할 수 있고 부동산임대차를 등기한 때에는 그 때부터 제3자에 대하여서도 효력이 생긴다(제621조).

㉡ 건물 등기 있는 토지임대차

건물의 소유를 목적으로 한 토지임대차는 이를 등기하지 아니한 경우에도 임차인이 그 지상건물을 등기한 때에는 제3자에 대하여 임대차의 효력이 생긴다(제622조 제1항).

(3) 제3자의 침해에 대한 방해배제청구권

① 대항력 있는 임차권

등기된 임차권(대항력 있는 주택임차권 및 상가건물임차권 포함)의 침해에 대하여는 임차권에 의하여 방해배제를 청구할 수 있다.

② 대항력을 갖추지 않는 경우

임차인이 점유하고 있는 경우에는 점유권에 기한 점유보호청구권이 인정되고, 점유조차 하고 있지 않은 경우에는 임대인의 권리를 대위행사 할 수 있다.

3. 임대차의 성립

(1) 임대차의 목적물

민법은 임대차의 목적물을 물건에 한하고 있으나 특허권 · 영업권 등의 권리도 임대차의 목적물이 될 수 있다는 것이 다수설이다. 한편 임대차는 물건의 일부에 대해서도 성립한다.

(2) 의사합치

① 임대차는 낙성 · 불요식계약 이므로 임대인과 임차인간의 합의만으로 성립한다. 또한 임대인이 목적물에 대한 소유권이나 처분권을 가지고 있을 것을 요하지 않는다.

② 타인소유의 부동산을 임대한 것이 임대차계약을 해지할 사유는 될 수 없고 목적물이 반드시 임대인의 소유일 것을 특히 계약의 내용으로 삼은 경우라야 착오를 이유로 임차인이 임대차계약을 취소할 수 있다[74다2069].

(3) 차임의 지급

차임의 지급은 임대차의 요소이나 차임은 금전에 한하지 않는다. 보증금은 요소가 아니나 임대차계약에서 보증금을 지급하였다는 입증책임은 보증금의 반환을 구하는 임차인이 부담한다[2004다19647].

Ⅱ 임대차의 존속기간

1. 계약으로 기간을 정하는 경우

민법상의 임대차의 경우 최장기간이나 최단기의 제한을 받지 않고 당사자가 자유롭게 존속기간을 약정할 수 있은므로 임차기간을 영구적으로 정한 임대차도 특별한 사정이 없는 한 허용된다.

2. 계약으로 기간을 정하지 않는 경우

제635조(기간의 약정없는 임대차의 해지통고) ① 임대차기간의 약정이 없는 때에는 당사자는 언제든지 계약해지의 통고를 할 수 있다.
② 상대방이 전항의 통고를 받은 날로부터 다음 각호의 기간이 경과하면 해지의 효력이 생긴다.
1. 토지, 건물 기타 공작물에 대하여는 임대인이 해지를 통고한 경우에는 6월, 임차인이 해지 통고한 경우에는 1월
2. 동산에 대하여는 5일

제636조(기간의 약정있는 임대차의 해지통고) 임대차기간의 약정이 있는 경우에도 당사자일방 또는 쌍방이 그 기간 내에 해지할 권리를 보류한 때에는 전조의 규정을 준용한다.

3. 임대차의 갱신

(1) 계약에 의한 갱신

갱신횟수의 제한은 없다.

(2) 묵시의 갱신(법정갱신)

제639조(묵시의 갱신) ① 임대차기간이 만료한 후 임차인이 임차물의 사용 · 수익을 계속하는 경우에 임대인이 상당한 기간 내에 이의를 하지 아니한 때에는 전임대차와 동일한 조건으로 다시 임대차한 것으로 본다. 그러나 당사자는 제635조(기간의 약정없는 임대차의 해지통고)의 규정에 의하여 해지의 통고를 할 수 있다.
② 전항(묵시적 갱신)의 경우에 전임대차에 대하여 제3자가 제공한 담보는 기간의 만료로 인하여 소멸한다.

Ⅲ 임대차의 효력

1. 임대인의 권리 · 의무

(1) 임대인의 권리

① 차임지급청구권

임대인의 권리 중 가장 중요한 권리이다. 임차인의 차임연체액이 2기의 차임액에 달하는 때에는 임대인은 계약을 해지할 수 있다(제640조).

② 차임증감청구권

제628조(차임증감청구권) 임대물에 대한 공과부담의 증감 기타 경제사정의 변동으로 인하여 약정한 차임이 상당하지 아니하게 된 때에는 당사자는 장래에 대한 차임의 증감을 청구할 수 있다.

㉠ 효력발생시기

민법 제628조에 의하여 장래에 대한 차임의 증액을 청구하였을 때에 그 청구가 상당하다고 인정되면 그 효력은 재판시를 표준으로 할 것이 아니고 그 청구시에 곧 발생한다.

㉡ 편면적 강행규정

임대차계약 체결시에 임대인이 일방적으로 차임을 인상할 수 있고 상대방(임차인)은 이의를 할 수 없다고 약정하였다면 이는 강행규정인 임차인에게 불리한 것이므로 민법 제652조에 의하여 효력이 없다[92다31163]. 뿐만 아니라 차임감액금지특약도 임차인에게 불리하므로 효력이 없다.

(2) 임대인의 의무

제623조(임대인의 의무) 임대인은 목적물을 임차인에게 인도하고 계약존속 중 그 사용 · 수익에 필요한 상태를 유지하게 할 의무를 부담한다.

① 목적물을 사용 · 수익하게 할 의무

통상의 임대차관계에 있어서 임대인의 임차인에 대한 의무는 특별한 사정이 없는 한 단순히 임차인에게 임대목적물을 제공하여 임차인으로 하여금 이를 사용 · 수익하게 함에 그치는 것이고, 더 나아가 임차인의 안전을 배려하여 주거나 도난을 방지하는 등의 보호의무까지 부담한다고 볼 수 없다[99다10004].

② 수선의무

㉠ 임대차기간 중 임대목적물의 사용 · 수익함에 필요한 상태를 유지하여야 할 적극적 의무의 내용으로 임대인은 임차목적물에 대한 수선의무를 진다(제623조). 반면 임차인은 임대인의 수선을 용인하여야 하지만(제624조), 그로 말미암아 임차의 목적을 달성할 수 없다면 임대차를 해지할 수 있다(제625조).

㉡ 임대인에게 귀책사유가 있는 임대차목적물의 훼손의 경우에는 물론 그에게 귀책사유가 없는 훼손의 경우에도 수선의무를 부담한다[2009다96984].

㉢ 임대차계약에 있어서 임대목적물에 파손 또는 장해가 생긴 경우 그것이 임차인이 별 비용을 들이지 않고도 손쉽게 고칠 수 있을 정도의 사소한 것이어서 임차인의 사용 · 수익을 방해할 정도의 것이 아니라면 임대인은 수선의무를 부담하지 않지만, 그것을 수선하지 않으면 임차인이 계약에 의하여 정해진 목적에 따라 사용 · 수익할 수 없는 상태로 될 정도의 것이라면 임대인은 그 수선의무를 부담한다[94다34692].

㉣ 그러나 임대인은 특약이 없는 한 임차인의 특별한 용도를 위한 사용 · 수익에 적합한 구조를 유지하게 할 의무까지는 없다(대판 1996.11.26. 96다28172).

㉤ 임대인이 수선의무를 이행하지 않는 경우에, 임차인은 손해배상을 청구할 수 있고, 임대차계약을 해지할 수 있으며, 목적물의 사용·수익이 부분적으로 지장이 있는 한도 내에서 차임의 지급을 거절할 수 있다.

③ 임대인의 담보책임(제567조)

임대차는 유상계약이므로 임대인은 매도인과 같은 담보책임을 진다.

2. 임차인의 권리

① 사용·수익권(제610조, 제654조)

> **제610조(차주의 사용 · 수익권)** ① 임차인은 계약 또는 그 목적물의 성질에 의하여 정하여진 용법으로 이를 사용 ·수익하여야 한다.

② 일부멸실과 차임감액청구권

> **제627조(일부멸실 등과 감액청구, 해지권)** ① 임차물의 일부가 임차인의 과실없이 멸실 기타 사유로 인하여 사용 · 수익할 수 없는 때에는 임차인은 그 부분의 비율에 의한 차임의 감액을 청구할 수 있다.
> ② 전항의 경우에 그 잔존부분으로 임차의 목적을 달성할 수 없는 때에는 임차인은 계약을 해지할 수 있다.

③ 경제사정의 변동과 차임감액청구권

> **제628조(차임증감청구권)** 임대물에 대한 공과부담의 증감 기타 경제사정의 변동으로 인하여 약정한 차임이 상당하지 아니하게 된 때에는 당사자는 장래에 대한 차임의 증감을 청구할 수 있다.

④ 비용상환청구권(제626조)

> **제626조(임차인의 상환청구권)** ① 임차인이 임차물의 보존에 관한 필요비를 지출한 때에는 임대인에 대하여 그 상환을 청구할 수 있다.
> ② 임차인이 유익비를 지출한 경우에는 임대인은 임대차종료시에 그 가액의 증가가 현존한 때에 한하여 임차인의 지출한 금액이나 그 증가액을 상환하여야 한다. 이 경우에 법원은 임대인의 청구에 의하여 상당한 상환기간을 허여할 수 있다.
>
> **제617조(손해배상, 비용상환청구의 기간)** 계약 또는 목적물의 성질에 위반한 사용 · 수익으로 인하여 생긴 손해배상의 청구와 임차인이 지출한 비용의 상환청구는 임대인이 물건의 반환을 받은 날로부터 6월 내에 하여야 한다.

㉠ 필요비상환청구권 : 임차인이 임차물의 보존에 관한 필요비를 지출한 때에는 임대차의 종료를 기다리지 않고 '즉시' 상환을 청구할 수 있다. 임대인의 필요비상환의무는 특별한 사정이 없는 한 임차인의 차임지급의무와 서로 대응하는 관계에 있으므로, 임차인은 지출한 필요비 금액의 한도에서 차임의 지급을 거절할 수 있다[2016다227694].

㉡ 유익비상환청구권

임차인이 지출한 유익비는 임대차 '종료시'에 그 가액의 증가가 현존한 때에 한하여 임차인이 지출한 금액이나 그 증가액을 상환해야 한다. 임차인이 임차건물에 간이음식점을 경영하기 위하여 부착시킨 시설물에 불과한 간판설치비는 유익비라 할 수 없다. 유익비상환의 경우에 법원은 임대인의 청구에 의하여 상당한 상환기간을 허여할 수 있다.

㉢ 행사기간(제654조, 제617조)

임대인이 목적물을 반환받은 날로부터 6개월 내에 필요비와 유익비의 상환을 청구해야 한다.

㉣ 유치권

적법한 임차인은 비용상환청구권에 관하여 유치권을 가진다. 다만, 유익비의 경우 법원이 상당한 기간을 허여한 경우에는 유치권은 행사할 수 없다.

㉤ 임의규정

ⓐ 비용상환청구권은 임의규정이므로 당사자간의 특약에 의해 임대인의 비용상환의 무를 감면할 수도 있다.

ⓑ 임대차계약에서 "임차인은 임대인의 승인하에 개축 또는 변조할 수 있으나 부동산의 반환기일 전에 임차인의 부담으로 원상복구하기로 한다."라고 약정한 경우 이는 임차인이 임차목적물에 지출한 각종 유익비의 상환청구권을 미리 포기하기로 한 취지의 특약이다[95다12927].

ⓒ 건물임차인이 자신의 비용을 들여 증축한 부분을 임대인소유로 귀속시키기로 하는 약정은 유익비의 상환청구권을 포기하기로 한 약정으로 유효이다[94다44705].

⑤ 건물임차인의 부속물매수청구권(제646조)

제646조(임차인의 부속물매수청구권) ① 건물 기타 공작물의 임차인이 그 사용의 편익을 위하여 임대인의 동의를 얻어 이에 부속한 물건이 있는 때에는 임대차의 종료시에 임대인에 대하여 그 부속물의 매수를 청구할 수 있다.
② 임대인으로부터 매수한 부속물에 대하여도 전항과 같다.

㉠ **의의** : 건물 기타 공작물의 임차인이 그 사용의 편익을 위하여 임대인의 동의를 얻어 임차물에 부속한 물건 또는 임대인으로부터 매수한 부속물이 있는 경우 임차인이 임대차 종료시에 임대인에 대해 그 부속물의 매수를 청구할 수 있는 권리를 말한다.

㉡ **법적 성질** : 형성권이므로 임차인의 일방적 의사표시로 효력이 발생하고, 10년의 제척기간 내에 행사하면 된다.

㉢ 요건

ⓐ **임차인 소유의 독립한 물건일 것** : 부속물은 건물에 부속된 물건으로서 임차인의 소유에 속하고 건물의 구성부분이 아니면서 건물의 사용에 객관적인 편익를 가져오게 하는 물건을 말한다. 따라서 부속된 물건이 오로지 임차인의 특수한 목적에 사용하기 위한 것이라면 매수대상이 되는 부속물에 해당하지 않는다[93다25738].

ⓑ **임대인의 동의 또는 매수** : 부속물은 임대인의 동의를 얻어서 부속시킨 것이거나 또는 임대인으로부터 매수한 것이어야 한다.

ⓒ **임차인의 채무불이행이 없을 것** : 건물임차인의 채무불이행을 이유로 임대인이 임대차계약을 해지한 경우는 부속물매수청구권을 부인한다[88다카7245].

ⓓ 일시사용을 위한 임대차에는 인정되지 않는다.

㉣ 행사의 효과

ⓐ **매매계약의 성립** : 부속물매수청구권이 행사되면 임대인의 승낙없이도 임대인과 임차인 사이에 부속물매매계약이 성립하여 그 날부터 임차인은 부속물인도의무를 부담하고 임대인은 대금지급의무를 부담한다.

ⓑ **유치권 부정** : 부속물매수청구권은 건물 기타 공작물 자체에 대하여 생긴 권리라 볼 수 없으므로 부속물매수대금청구권에 기한 건물 · 공작물 유치권의 성립은 부정된다.

㉤ **편면적 강행규정** : 편면적 강행규정으로 이에 위반하는 약정으로 임차인에게 불리한 것은 무효이다. 다만, 임차보증금과 임료를 시가보다 저렴하게 해 주고 그 대신 임차인은 임대차가 종료될 때 그가 설치한 부속물에 대한 시설료나 필요비 · 이익비 · 권리금 등을 일체 청구하지 않기로 약정하였다면 임차인은 매수청구권을 포기하였다 할 것이고 위와 같은 약정이 임차인에게 일방적으로 불리한 것이라고 볼 수도 없다[92다24998].

⑥ 토지임차인의 지상물매수청구권 (제643조 ⇨ 제283조 제2항)

제643조(임차인의 갱신청구권, 매수청구권) 건물 기타 공작물의 소유 또는 식목, 채염, 목축을 목적으로 한 토지임대차의 기간이 만료한 경우에 건물, 수목 기타 지상시설이 현존한 때에는 제283조의 규정을 준용한다.

제644조(전차인의 임대청구권, 매수청구권) ① 건물 기타 공작물의 소유 또는 식목, 채염, 목축을 목적으로 한 토지임차인이 적법하게 그 토지를 전대한 경우에 임대차 및 전대차의 기간이 동시에 만료되고 건물, 수목 기타 지상시설이 현존한 때에는 전차인은 임대인에 대하여 전전대차와 동일한 조건으로 임대할 것을 청구할 수 있다.

② 전항의 경우에 임대인이 임대할 것을 원하지 아니하는 때에는 제283조 제2항의 규정을 준용한다.

제645조(지상권목적토지의 임차인의 임대청구권, 매수청구권) 전조의 규정은 지상권자가 그 토지를 임대한 경우에 준용한다.

㉠ 의의

ⓐ 토지임대차의 기간이 만료한 경우에 건물·수목 기타 지상시설이 현존한 경우에 임차인은 임대인에 대하여 계약의 갱신을 청구할 수 있으며 임대인이 계약의 갱신을 원하지 않는 경우 임차인은 상당한 가액으로 공작물이나 수목의 매수를 청구할 수 있다.

ⓑ 다만, 존속기간의 정함이 없는 임대차의 경우 임대인이 해지통고를 한 때에는 임대인이 갱신을 거절한 것으로 보아 임차인은 갱신청구할 필요 없이 즉시 매수청구를 할 수 있다[94다51178].

㉡ 매수청구권의 대상

ⓐ **경제적 가치 여부** : 지상건물이 객관적으로 경제적 가치가 있는지 여부나 임대인에게 소용이 있는지 여부는 행사요건이 아니다[2001다42080].

ⓑ **임대인의 동의 여부** : 반드시 임대차계약 당시의 기존건물이거나 임대인의 동의를 얻어 신축한 것에 한정되지 않는다[93다34589].

ⓒ **미등기무허가건물** : 행정관청의 허가를 받은 적법한 건물이 아니더라도 임차인의 건물매수청구권의 대상이 될 수 있다[97다37753].

ⓓ **근저당권이 설정된 건물** : 매수청구의 대상이 되는 건물에 근저당권이 설정되어 있는 경우에도 인정된다.

ⓔ **행사범위** : 임차인 소유건물이 임대인이 임대한 토지 외에 임차인 또는 제3자 소유의 토지 위에 걸쳐서 건립되어 있는 경우에는 임차지상에 서 있는 건물부분 중 구분소유의 객체가 될 수 있는 부분에 한해 임차인에게 매수청구가 허용된다[93다42634전합].

㉢ 청구권자

ⓐ 지상물매수청구권은 지상물의 소유자인 임차인에 한하여 행사할 수 있다[93다6386]. 따라서 임차인이 지상물의 소유권을 타인에게 이전한 경우, 임차인은 지상물매수청구권을 행사할 수 없다.

ⓑ 다만, 종전 임차인으로부터 미등기 무허가건물을 매수하여 점유하고 있는 임차인은 비록 소유자로서의 등기명의가 없어 소유권을 취득하지 못하였다 하더라도 임대인에 대하여 지상물매수청구권을 행사할 수 있다(2013다48364,48371).

ⓒ 그러나 임차인의 채무불이행으로 임대차가 종료된 경우에는 임차인은 지상물매수청구권을 행사할 수 없다.

㉣ 상대방

ⓐ 원칙적으로 임차권소멸 당시 토지소유자인 임대인이다. 따라서 토지소유자가 아닌 제3자가 토지를 임대한 경우에 임대인은 특별한 사정이 없는 한 지상물매수청구권의

상대방이 될 수 없다[2020다254228]. 또한 임대인이 임차권 소멸 당시에 이미 토지소유권을 상실한 경우에는 그에게 지상물매수청구권을 행사할 수 없다[93다59717].

ⓑ 다만, 토지임차인이 건물에 관해 토지임차인 명의의 소유권등기가 되어 있는 경우 등 대항력을 갖춘 경우에는 임차권소멸 후에 그 토지를 양수한 자에 대해서도 매수청구권을 행사할 수 있다[96다14517].

㉤ 행사방법 및 시기

토지임차인의 지상물매수청구권은 그 행사에 특정의 방식을 요하지 않으므로 재판상 · 재판외에서도 행사할 수 있고 그 행사의 시기에 제한이 없다[2001다42080]. 임대인이 제기한 토지인도 및 건물철거청구소송에서 임차인이 패소하였다 하더라도, 그 판결에 의하여 건물철거가 집행되지 아니한 이상 임차인은 건물매수청구권을 청구할 수 있다[95다42195].

㉥ 행사효과

ⓐ 지상물에 대한 매매성립

형성권이므로 그 행사로 임대인 · 임차인 사이에 지상물에 관한 매매가 성립하는 것이지 임대인의 승낙이 있어야 하는 것은 아니다[98다2389]

ⓑ 매매대금

매매가액은 매수청구권 행사 당시의 시가 상당액이며, 건물에 근저당권이 설정되어 있는 경우에도 근저당권의 채권최고액이나 피담보채무액을 공제한 금액을 매수가격으로 정할 것은 아니다[2007다4356].

ⓒ 동시이행관계

토지임차인의 매수청구권행사로 지상건물에 대해 시가에 의한 매매유사의 법률관계가 성립된 경우에 토지임차인의 건물명도 및 그 소유권이전등기의무와 토지임대인의 건물대금지급의무는 서로 대가관계에 있는 채무이므로 동시이행을 주장할 수 있다[91다3260]. 다만, 이 경우 임차인은 지상건물 등의 점유 · 사용을 통하여 그 부지를 계속하여 점유 · 사용하는 한, 그로 인한 부당이득으로서 부지의 임료 상당액을 반환해야 할 의무가 있다.

㉦ 편면적 강행규정

지상물매수청구권에 관한 규정은 강행규정이므로 임차인에게 불리한 약정은 그 효력이 없다[94다34265전합]. 따라서 임대차 종료시에 건물을 철거하기로 한 특약, 임차인이 임대차가 종료하기 전에 임대인과 간에 건물 기타 지상시설 일체를 포기하기로 약정을 하였다고 하더라도 위와 같은 약정은 임차인에게 불리한 것으로서 민법 제652조에 의하여 효력이 없다[2001다42080].

(2) 임차인의 의무

① 차임지급의무

제633조(차임지급의 시기) 차임은 동산, 건물이나 대지에 대하여는 매월 말에, 기타 토지에 대하여는 매년 말에 지급하여야 한다. 그러나 수확기 있는 것에 대하여는 그 수확 후 지체없이 지급하여야 한다.

② 공동임차인의 연대의무(제654조, 제616조)

제616조(공동차주의 연대의무) 수인이 공동하여 물건을 차용한 때에는 연대하여 그 의무를 부담한다.

③ 임차물보관의무 · 통지의무 · 보존행위

제624조(임대인의 보존행위, 인용의무) 임대인이 임대물의 보존에 필요한 행위를 하는 때에는 임차인은 이를 거절하지 못한다.
제625조(임차인의 의사에 반하는 보존행위와 해지권) 임대인이 임차인의 의사에 반하여 보존행위를 하는 경우에 임차인이 이로 인하여 임차의 목적을 달성할 수 없는 때에는 계약을 해지할 수 있다.
제634조(임차인의 통지의무) 임차물이 수리를 요하거나 임차물에 대하여 권리를 주장하는 자가 있는 때에는 임차인은 지체없이 임대인에게 이를 통지하여야 한다. 그러나 임대인이 이미 이를 안 때에는 통지할 필요가 없다.

④ 임차물반환의무

㉠ 임대차관계가 종료되면 임차인은 임차목적물을 임대인에게 반환해야 할 계약상의 의무가 있다[94다54641].

㉡ 임차인의 임대차목적물 반환의무가 이행불능이 된 경우 임차인이 그 이행불능으로 인한 손해배상책임을 면하려면 그 이행불능이 임차인의 귀책사유로 말미암은 것이 아님을 입증할 책임이 있고, 임차건물이 화재로 소훼된 경우에 있어서 그 화재의 발생원인이 불명인 때에도 임차인이 그 책임을 면하려면 그 임차건물의 보존에 관하여 선량한 관리자의 주의의무를 다하였음을 입증하여야 하는 것이다[2009다96984].

⑤ 원상회복의무

제615조(임차인의 원상회복의무와 철거권) 임차인이 임차물을 반환하는 때에는 이를 원상에 회복하여야 한다. 이에 부속시킨 물건은 철거할 수 있다.

판 례

임대인의 귀책사유로 임대차계약이 해지된 경우에도 임차인이 원상회복의무를 부담하는지 여부(적극)

임대차계약이 중도에 해지되어 종료하면 임차인은 목적물을 원상으로 회복하여 반환하여야 하는 것이고, 임대인의 귀책사유로 임대차계약이 해지되었다고 하더라도 임차인은 그로 인한 손해배상을 청구할 수 있음은 별론으로 하고 원상회복의무를 부담하지 않는다고 할 수는 없다(대판 2002.12.6. 2002다42278).

Ⅳ 임차권의 양도와 전대(賃借權의 讓渡와 轉貸)

1. 서 설

(1) 의 의

① '임차권의 양도'란 임차권의 동일성을 유지하면서 제3자에게 이전하는 것을 말한다. 임차권의 양도가 있으면 양수인은 임차인의 지위를 승계하며, 기존의 임차인은 임대차관계에서 탈퇴하게 된다.

② '전대'란 임차인이 제3자로 하여금 임차물의 전부 또는 일부를 사용·수익하게 하는 계약을 말한다. 전대의 경우 임차인은 임대차관계에서 탈퇴하지 않고 계속하여 임차인의 지위를 유지하면서 전대인의 지위를 가진다.

(2) 무단양도 · 무단전대의 금지

① 원칙

임차인은 임대인의 동의없이 그 권리를 양도하거나 임차물을 전대하지 못하고, 임차인이 이에 위반한 때에는 임대인은 계약을 해지할 수 있다(제629조).

② 예외

건물임차인이 그 건물의 소부분을 타인에게 사용하게 하는 경우에는 이와 같은 제한이 없다(제632조).

2. 임대인의 동의 없는 임차권의 양도 · 전대

(1) 임대인과 임차인(전대인) 사이의 관계

① 임대인은 해지권을 취득하나, 임대인이 임대차계약을 해지하지 않는 한 임대차 관계는 소멸하지 않는다.

② 그러나 임차인이 임대인으로부터 별도의 승낙을 얻은 바 없이 제3자에게 임차물을 사용·수익하도록 한 경우에 있어서도 임차인의 당해 행위가 임대인에 대한 배신적 행위라고 인정할 수 없는 특별한 사정(예컨대 임차권의 양수인이 임차인과 부부로서 임차건물에 동거하면서 함께 가구점을 경영하고 있는 등의 사정)이 있는 경우에는 민법 제629조에 의한 해지권은 발생하지 않는다[92다45308].

판 례

임차인이 임대인의 승낙 없이 제3자에게 임차물을 사용·수익하도록 한 행위가 임대인에 대한 배신적 행위라고 인정할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우, 임대인에게 임대차계약해지권이 있는지 여부(소극)

임차인이 임대인으로부터 별도의 승낙을 얻은 바 없이 제3자에게 임차물을 사용·수익하도록 한 경우에 있어서도 임차권의 양수인이 임차인과 부부로서 임차건물에 동거하면서 함께 가구점을 경영하고 있는 등의 사정은 임차인의 당해 행위가 임대인에 대한 배신적 행위라고 인정할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우에 해당하여 임대인의 해지권은 발생하지 않는다(대판 1993.4.27. 92다45308).

③ 건물의 소부분을 타인에게 사용하게 한 경우에는 임대인의 동의 없는 전대도 유효하고 임대인은 해지권을 갖지 않는다(제632조).

(2) 임차인(양도인, 전대인)과 양수인(전차인) 사이의 관계

임대인의 동의를 받지 않고 임차권을 양도한 계약도 이로써 임대인에게 대항할 수 없을 뿐 임차인과 양수인 사이에는 유효한 것이고, 이 경우 임차인은 양수인을 위하여 임대인의 동의를 받아 줄 의무가 있다[85다카1812].

판 례

임대인의 동의없는 임차권 양수인이 임대인의 권한을 대위행사할 수 있는지 여부(소극)

임대인의 동의없는 임차권의 양도는 당사자 사이에서는 유효하다 하더라도 다른 특약이 없는 한 임대인에게는 대항할 수 없는 것이고 임대인에 대항할 수 없는 임차권의 양수인으로서는 임대인의 권한을 대위행사 할 수 없다(대판 1985.2.8. 84다카188).

(3) 임대인과 양수인(전차인) 사이의 관계

① **임차권 주장 불가** : 양수인은 임대인에게 임차권의 주장을 할 수 없다.

② **양수인의 불법점유**

양수인은 임대인에 대한 관계에서 불법점유자가 되므로 임대인은 소유권에 기한 물권적 청구권을 행사할 수 있다.

③ **손해배상청구 여부**

임대인이 임대차계약을 해지하지 않는 한 임대인은 임차인에 대하여 여전히 차임청구권을 가지므로, 임대차계약이 존속하는 한도 내에서는 제3자에게 불법점유를 이유로 한 차임상당의 손해배상청구나 부당이득반환청구를 할 수 없다[2007다77446].

3. 임대인의 동의 있는 임차권의 전대

(1) 임대인과 임차인(전대인)사이의 관계

전대차로 인하여 아무런 영향을 받지 않는다.

(2) 전대인(임차인)과 전차인 사이의 관계

임차인과 전차인의 관계는 전대차계약의 내용에 따라 정해진다. 따라서 전차인은 임차인에 대하여 전차인으로서의 권리 · 의무를 갖는다.

(3) 임대인과 전차인 사이의 관계

① 임대차관계 불성립

임대인과 전차인 사이에 직접 임대차관계가 성립하지는 않는다.

② 전차인의 임대인에 대한 의무

전차인은 임대인에 대하여 직접 의무를 부담하지만, 권리는 갖지 않는다(제630조).

③ 차임지급의무

전차인은 직접 임대인에 대해 의무를 부담하므로 전차인이 임대인에게 직접 차임을 지급하면 그 한도에서 전대인에 대한 차임채무를 면하나 전대인에 대한 차임의 지급으로써 임대인에게 대항하지 못한다(제630조 후단). 여기서 임대인에게 대항할 수 없는 차임의 범위는 전차인이 전대차계약상의 차임지급시기를 기준으로 하여 그 전에 임차인에 대한 차임의 지급으로써 임대인에게 대항하지 못한다[2006다45459].

(4) 전차인의 보호를 위한 특별규정

① 원칙적으로 임차인의 임차권이 소멸하면 전차인의 전차권도 소멸하지만, 임대인과 임차인의 합의로 임대차계약을 종료한 때에는 전차인의 권리는 소멸하지 않는다(제631조).

② 임대차계약이 해지의 통고로 인하여 종료된 경우에 그 임대물이 적법하게 전대되었을 때에는 임대인은 전차인에 대하여 그 사유를 통지하지 않으면 해지로써 전차인에게 대항하지 못한다(제638조 제1항).

③ 그러나 민법 제640조에 터 잡아 임차인의 차임연체액이 2기의 차임액에 달함에 따라 임대인이 임대차계약을 해지하는 경우에는 전차인에 대하여 그 사유를 통지하지 않더라도 해지로써 전차인에게 대항할 수 있다[2012다55860].

④ 임차인이 임대인의 동의를 얻어 임차물을 전대한 경우, 전차인은 전대인과의 합의로 차임이 감액되었음을 임대인에게 주장할 수 있다[2018다200518].

⑤ 임대차와 전대차가 동시에 종료하고 전차인이 임대인에게 목적물을 직접 반환하면 전차인의 임차인(전대인)에 대한 반환의무를 면하게 된다.

⑥ 부속물매수청구권

건물 기타 공작물의 임차인이 적법하게 전대한 경우에 전차인이 임대인의 동의를 얻어 이에 부속한 물건이나 임대인으로부터 매수하였거나 임대인의 동의를 얻어 임차인으로부터 매수한 부속물에 대하여 임대인에게 매수할 것을 청구할 수 있다(제647조).

⑦ 임대청구권 · 지상물매수청구권

토지임차인이 적법하게 그 토지를 전대한 경우에 임대차 및 전대차의 기간이 동시에 만료되고 지상시설이 현존한 때에는 전차인은 임대인에 대하여 전전대차와 동일한 조건으로 임대할 것을 청구할 수 있다(제644조 제1항). 이 때 임대인이 임대할 것을 원하지 않으면 임차인은 상당한 가액으로 공작물이나 수목의 매수를 청구할 수 있다(제644조 제2항).

Ⅵ 보증금

1. 보증금의 의의

① 보증금은 특히 건물의 임대차에서 임차인이 부담하는 차임 기타 채무, 가령 목적물의 멸실 · 훼손 등으로 신한 손해배상채무를 담보하기 위하여 임차인 또는 제3자가 임대인에게 교부하는 금전이다. 민법은 보증금에 대해 전혀 규정하고 있지 않아, 관습이나 판례에 의해 해결할 수밖에 없다.

② 임대차계약에서 보증금을 지급하였다는 입증책임은 보증금의 반환을 구하는 임차인이 부담한다[대판 2005.1.13. 2004다19647].

2. 보증금의 효력

(1) 담보적 효력

① 임대차계약에 있어 임대차보증금은 임대차계약 종료 후 목적물을 임대인에게 명도할 때까지 발생하는, 임대차에 따른 임차인의 모든 채무를 담보하는 것으로서, 그 피담보채무 상당액은 임대차관계의 종료 후 목적물이 반환될 때에, 특별한 사정이 없는 한, 별도의 의사표시 없이 보증금에서 당연히 공제되는 것이므로, 임대인은 임대차보증금에서 그 피담보채무를 공제한 나머지만을 임차인에게 반환할 의무가 있다[2005다8323, 8330].

② 임대차가 계속되는 동안 '임대인'은 임차인의 연체차임 등을 임대차보증금으로 충당할 것인지 여부를 자유롭게 선택할 수 있다. 반면 임차인은 보증금의 존재를 이유로 차임의 지급을 거절하거나 그 연체에 따른 책임을 면할 수 없다(대판 1994.9.9. 94다4417).

(2) **공제의 대상**

① 임대차계약 종료 후 목적물을 임대인에게 명도할 때까지 발생하는 임대차에 따른 임차인의 모든 채무가 공제의 대상이 된다.

② 임대보증금이 수수된 임대차계약에서 차임채권에 관하여 압류 및 추심명령이 있었다 하더라도, 잔존하는 차임채권 상당액도 임대보증금에서 당연히 공제된다[2004다56554, 56561].

③ 임대인의 지위를 승계한 임차건물의 양수인이 임대인의 지위를 승계하기 전까지 발생한 연체차임이나 관리비 등이 채권양도의 요건을 갖추지 않았더라도 임대차보증금에서 당연히 공제된다[2016다277880, 2016다218874].

④ 임대인이 임차인을 상대로 차임연체로 인한 임대차계약의 해지를 원인으로 임대차목적물인 부동산의 인도 및 연체차임의 지급을 구하는 소송비용도 반환할 임대차보증금에서 당연히 공제할 수 있다[2012다49490].

(3) **유치권의 성립 여부(부정)** : 임차인의 임대인에게 지급한 임차보증금반환청구권은 유치권의 피담보채권이 될 수 없다(대판 1976.5.11. 75다1305).

(4) **동시이행관계와 부당이득** : 임대차종료 후 임차인의 임차목적물명도의무와 임대인의 연체차임 기타 손해배상금을 공제하고 남은 임대차보증금반환채무와는 동시이행의 관계에 있다(대판 1989.2.28. 87다카2114).

Ⅵ 임대차의 종료

1. 임대차의 종료원인

(1) **존속기간의 만료**

당사자의 약정 또는 법률의 규정에 의한 존속기간이 만료되면 임대차는 종료한다.

(2) **해지의 통고**

① 기간 약정이 없는 임대차는 당사자가 언제든지 계약해지의 통고를 할 수 있다.

② 임대차 기간의 약정이 있더라도 임차인이 파산선고를 받은 경우에는 임대인 또는 파산관재인은 계약 해지의 통고를 할 수 있다.

(3) **해지 ⇨ 즉시 해지의 효력발생**

① 임대인의 해지

㉠ **동의 없는 임차권의 양도 · 전대** : 임차인이 임대인의 동의 없이 임차권을 양도하거나 임차물을 전대한 때에는 임대인은 계약을 해지할 수 있다.

㉡ 2기의 차임연체의 경우 : 건물 기타 공작물의 임대차에서 임차인의 차임연체액이 2기의 차임액에 달하는 때에는 임대인은 계약을 해지할 수 있다(제640조).

② 임차인의 해지

㉠ 임차인의 의사에 반하는 보존행위

임대인이 임차인의 의사에 반하여 보존행위를 하는 경우에 임차인이 이로 인하여 임차의 목적을 달성할 수 없는 때에는 계약을 해지할 수 있다.

㉡ 일부멸실 등

임차물의 일부가 임차인의 과실 없이 멸실 기타 사유로 인하여 사용·수익할 수 없고, 그 잔존부분으로 임차의 목적을 달성할 수 없는 때에는 임차인은 계약을 해지할 수 있다.

2. 편면적 강행규정

제652조(강행규정) 제627조(일부멸실 등과 감액청구, 해지권), 제628조(차임증감청구권), 제631조(전차인의 권리의 확정), 제635조(기간의 약정없는 임대차의 해지통고), 제638조(해지통고의 전차인에 대한 통지), 제640조(차임연체와 해지), 제641조(차임연체와 해지), 제643조(임차인의 갱신청구권, 매수청구권,전차인의 임대청구권, 매수청구권,지상권목적토지의 임차인의 임대청구권, 매수청구권,임차인의 부속물매수청구권) 내지 제647조(전차인의 부속물매수청구권)의 규정에 위반하는 약정으로 임차인이나 전차인에게 불리한 것은 그 효력이 없다.

3. 일시임대차의 특례

제653조(일시사용을 위한 임대차의 특례) 제628조(차임증감청구권), 제638조(해지통고의 전차인에 대한 통지), 제640조(차임연체와 해지), 제646조(임차인의 부속물매수청구권, 전차인의 부속물매수청구권) 내지 제648조(임차지의 부속물, 과실 등에 대한 법정질권), 제650조(임차건물등의 부속물에 대한 법정질권) 및 제625조의 규정(강행규정)은 일시사용하기 위한 임대차 또는 전대차인 것이 명백한 경우에는 적용하지 아니한다.

제654조(준용규정) 제610조 제1항(제610조 제1항 차주는 계약 또는 그 목적물의 성질에 의하여 정하여진 용법으로 이를 사용 · 수익하여야 한다), 제615조 내지 제617조(차주의 원상회복의무와 철거권, 공동차주의 연대의무, 손해배상, 비용상환청구의 기간)의 규정은 임대차에 이를 준용한다.

제616조(공동차주의 연대의무) 수인이 공동하여 물건을 차용한 때에는 연대하여 그 의무를 부담한다.

일시임대차인 경우에는 임대차에 관한 민법규정이 모두 임의규정이다.

PART 04

민사특별법

CHAPTER 01 주택임대차보호법

CHAPTER 02 상가건물임대차보호법

CHAPTER 03 가등기담보 등에 관한 법률

CHAPTER 04 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률

CHAPTER 05 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률

CHAPTER

01 주택임대차보호법

제 1 절 서 설

1. 목적(目的)

제1조(목적) 이 법은 주거용 건물의 임대차에 관하여 「민법」에 대한 특례를 규정함으로써 국민 주거생활의 안정을 보장함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

제2조(적용 범위) 이 법은 주거용 건물(이하 "주택"이라 한다)의 전부 또는 일부의 임대차에 관하여 적용한다. 그 임차주택(賃借住宅)의 일부가 주거 외의 목적으로 사용되는 경우에도 또한 같다.

(1) 주거용 건물의 임대차

① 판단기준

주거용 건물에 해당하는지 여부는 임대차목적물의 공부상의 표시만을 기준으로 할 것이 아니라 그 실지 용도에 따라서 정한다[95다51953].

② 판단시점

주거용 건물에 해당하는지 여부는 임대차계약체결 당시를 기준으로 판단한다. 따라서 사무실로 사용되던 건물에 근저당권이 설정된 후 그 건물이 주거용 건물로 용도변경되어 이를 임차한 소액 임차인도 특별한 사정이 없는 한 보증금 중 일정액을 근저당권자보다 우선하여 변제받을 권리가 있다[대판 2009.8.20].

③ 미등기 또는 무허가 건물

어느 건물이 국민의 주거생활의 용도로 사용되는 주택에 해당하는 이상 주택임대차보호법의 적용대상이 된다[2004다26133全合].

④ 대지 포함 여부

'주거용 건물'의 임대차라 함은 같은 법의 적용대상을 대지를 제외한 건물에만 한정하는 취지는 아니다[96다7595]. 즉, 대지의 환가대금에서도 보증금을 우선변제 받을 수 있다.

(2) 적법한 임대차

주택의 소유자는 아니지만 주택에 관하여 적법하게 임대차계약을 체결할 수 있는 권한을 가진 임대인과 임대차계약이 체결된 경우도 포함된다[2007다38908].

(3) 임차인이 법인(法人)인 경우에 적용 여부

① **원칙** : 원칙적으로 임차인이 법인인 경우에는 적용되지 아니한다. 따라서 법인의 직원이 주민등록을 마쳤다 하여 이를 법인의 주민등록으로 볼 수 없으므로, 주식회사가 아파트를 인도받고 임대차계약서상의 확정일자를 구비하였다 하더라도 우선변제권을 주장할 수는 없다[96다7236].

② **예 외**

㉠ 다만, 주택도시기금을 재원으로 하여 저소득층 무주택자에게 주거생활 안정을 목적으로 전세임대주택을 지원하는 법인(한국토지주택공사, 주택사업을 목적으로 설립된 지방공사)이 주택을 임차한 후 지방자치단체의 장 또는 그 법인이 선정한 입주자가 그 주택을 인도받고 주민등록을 마쳤을 때에는 그 다음 날부터 제3자에 대하여 효력이 생긴다(제3조 제2항).

㉡ 또한 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업에 해당하는 법인이 소속 직원의 주거용으로 주택을 임차한 후 그 법인이 선정한 직원이 해당 주택을 인도받고 주민등록을 마쳤을 때에는 제1항을 준용한다.

(4) 미등기전세에의 준용(準用)

제12조(미등기전세에의 준용) 주택의 등기를 하지 아니한 전세계약에 관하여는 이 법을 준용한다. 이 경우 "전세금"은 "임대차의 보증금"으로 본다.

(5) 일시사용(一時使用)을 위한 임대차

제11조(일시사용을 위한 임대차) 이 법은 일시사용하기 위한 임대차임이 명백한 경우에는 적용하지 아니한다.

제 2 절 대항력(對抗力)

1. 대항력의 요건

제3조(대항력 등) ① 임대차는 그 등기가 없는 경우에도 임차인이 주택의 인도와 주민등록을 마친 때에는 그 다음 날부터(익일 오전 0시) 제3자에 대하여 효력이 생긴다. 이 경우 전입신고를 한 때에 주민등록이 된 것으로 본다.

(1) 주택의 인도

① 여기에서 '주택의 인도'는 임차목적물인 주택에 대한 점유의 이전을 말한다.

② 임차인이 현실인도 받아 '직접점유'하는 경우뿐만 아니라 '간접점유'하는 경우에도 인정된다.

(2) 주민등록

① **입법취지** : 주민등록은 거래의 안전을 위하여 임차권의 존재를 제3자가 명백히 인식할 수 있게 하는 공시방법으로 마련된 것이다[2002다15467].

② **가족의 주민등록** : 주민등록은 임차인 본인 뿐 아니라 가족의 주민등록을 포함한다. 따라서 주택 임차인이 그 가족과 함께 그 주택에 대한 점유를 계속하고 있으면서 그 가족의 주민등록을 그대로 둔 채 임차인만 주민등록을 일시 다른 곳으로 옮긴 경우라면, 제3자에 대한 대항력을 상실하지 아니한다[95다30338].

③ **전대차의 경우** : 임차인이 타인 의 점유를 매개로 하여 주택을 간접점유하는 경우(적법한 전대차)에는 당해 주택에 실제로 거주하는 직접점유자자(전차인)가 자신의 주민등록을 마친 경우에 한하여 그 임차인의 임대차가 제3자에 대하여 적법하게 대항력을 취득할 수 있다[2000다55645].

④ **주민등록과 등기부상 표시의 일치** : 주민등록과 등기부상 주택의 표시가 일치하여야 한다.

⑤ **다가구주택** : 다가구주택은 단독주택이므로 전입신고시 지번만 올바르게 기재하였다면 동호·수를 기재하지 않거나 잘못 기재하여도 공시방법으로 유효하다. 그리고 처음에 다가구용 단독주택인 건물의 일부를 임차한 임차인이 이를 인도받고 임차 건물의 지번을 정확히 기재하여 전입신고를 하여 적법한 대항력을 취득하였다면, 나중에 다가구용 단독주택이 다세대 주택으로 변경되었다는 사정만으로 임차인이 이미 취득한 대항력을 상실하게 되는 것은 아니다[2006다70516].

⑥ **다세대주택** : 다세대주택, 연립주택, 아파트 등은 동호수까지 정확하게 기재하여야 공시방법으로써 유효하다.

⑦ **주민등록신고의 효력발생시기** : 주민등록의 신고는 행정청에 도달하기만 하면 신고로서의 효력이 발생하는 것이 아니라 행정청이 수리한 경우에 비로소 신고의 효력이 발생한다.

⑧ **외국인 또는 재외국민** : 외국인의 경우에는 구 출입국관리법에 따라서 한 외국인등록이나 체류지변경신고, 재외국민의 경우에는 구 재외동포법에 따라서 마친 국내거소신고에 대해서 주택임대차보호법 제3조 제1항에서 주택임대차의 대항력 취득요건으로 규정하고 있는 주민등록과 동일한 법적 효과가 인정된다[2014다218030, 2015다254507].

2. 대항력의 발생시기 및 존속요건

(1) 대항력의 발생시기

① **다음날 오전 0시** : 임차인이 주택의 인도와 주민등록을 마친 때에는 그 다음 날 오전 0시부터 제3자에 대하여 효력이 생긴다[99다9981].

② **매도인의 대항력 취득시기** : 전입신고를 마친 주택소유자가 그 주택을 타인에게 매도함과 동시에 이를 임차하여 잔금수령일부터 임차인으로서 거주하는 경우에는 매수인에게 소유권이전등기를 경료해 준 날 이후에야 비로소 그 주민등록이 임대차 공시방법으로서 효력이 있다[98다32939]. 즉, 소유권이전등기 경료일의 다음 날부터 임차인으로 대항력을 가진다[99다59306].

③ **전대인(임차인)이 소유자가 된 경우 전차인의 대항력취득시기** : 전차인이 임차인으로부터 A주택을 전차하여 입주한 뒤 주민등록 전입신고를 마쳤는데, 그 후 임차인이 A주택의 소유권을 취득한 경우, 전차인은 A주택에 관하여 임차인명의의 소유권이전등기가 경료되는 즉시 위 임차권의 대항력을 취득한다. [2000다58026].

(2) 대항력의 존속요건

① **배당요구의 종기인 경락기일까지 존속** : 주택의 인도 및 주민등록이라는 대항요건은 대항력 취득시 뿐만 아니라 대항력을 유지하기 위해서도 계속 존속하고 있어야 한다. 대항력과 우선변제권을 인정받기 위한 주택의 인도와 주민등록이라는 요건은 경매절차의 배당요구의 종기인 경락기일까지 계속 존속하고 있어야 한다[2000다61466].

② **주민등록 직권말소** : 주택임차인의 의사에 의하지 않고 주민등록법 및 동법시행령에 따라 시장·군수 또는 구청장에 의하여 직권조치로 주민등록이 말소된 경우에도 원칙적으로 그 대항력은 상실된다[2002다20957].

③ **직권말소 후 이의절차에 따라 재등록** : 직권말소 후 동법 소정의 이의절차에 따라 그 말소된 주민등록이 회복되거나 동법시행령 제29조에 의하여 재등록이 이루어짐으로써 주택임차인에게 주민등록을 유지할 의사가 있었다는 것이 명백히 드러난 경우에는 소급하여 그 대항력이 유지된다[2002다20957].

3. 대항력의 내용

(1) 주택양수인에 대한 효력

제3조(대항력 등) ④ 임차주택의 양수인(그 밖에 임대할 권리를 승계한 자를 포함한다)은 임대인의 지위를 승계한 것으로 본다.

① 임대인의 지위승계

㉠ 주택의 임차인이 제3자에 대한 대항력을 갖춘 후 임차주택의 소유권이 양도되어 그 양수인이 임대인의 지위를 승계하는 경우에는, 임차보증금 반환채무도 주택의 소유권과 결합하여 일체로서 이전하는 것이므로 그 임차주택의 양수인이 임대차보증금반환채무를 면책적으로 인수하고, 양도인은 임대차관계에서 탈퇴하여 임차인에 대한 임대차보증금반환채무를 면하게 된다[2011다49523전합].

㉡ 따라서 주택의 임차인이 제3자에 대한 대항력을 구비한 후 임차 주택의 양수인이 임차인에게 임대차보증금을 반환하였다 하더라도, 이는 자신의 채무를 변제한 것에 불과할 뿐이므로 임차주택의 양수인은 양도인에 대하여 부당이득반환을 청구할 수 없다[93다17324].

㉢ 다만, 임차인이 임대인의 지위승계를 원하지 않는 경우에는 임차인이 임차주택의 양도사실을 안 때로부터 상당한 기간 내에 이의를 제기함으로써 승계되는 임대차관계의 구속으로부터 벗어날 수 있다고 보아야 하므로, 임대차기간의 만료 전에 임대인과 합의에 의하여 임대차계약을 해지하고 임대인으로부터 임대차보증금을 반환받을 수 있으며, 이러한 경우 임차주택의 양수인은 임대인의 지위를 승계하지 아니한다[2016다265689].

㉣ 한편 임차인의 임대차보증금반환채권이 가압류된 상태에서 임대주택이 양도되면 양수인이 채권가압류의 제3채무자의 지위도 승계하고, 가압류권자 또한 임대주택의 양도인이 아니라 양수인에 대하여만 위 가압류의 효력을 주장할 수 있다고 보아야 한다[2011다49523전합].

㉤ 대항력을 갖춘 임차인이 당해 주택을 양수한 때에도 임대인의 보증금반환채무는 소멸하고 양수인인 임차인이 임대인의 자신에 대한 보증금반환채무를 인수하게 되어, 결국 임차인의 보증금반환채권은 혼동으로 인하여 소멸하게 된다[96다38216].

㉥ 주택의 공동임차인 중 1인이라도 대항력 요건을 갖추게 되면 그 대항력은 임대차 전체에 미치므로, 임차 건물이 양도되는 경우 특별한 사정이 없는 한 공동임차인에 대한 보증금반환채무 전부가 임대인 지위를 승계한 양수인에게 이전되고 양도인의 채무는 소멸한다[2021다238650].

㉦ 임차인이 대항력을 갖춘 후에 그 임차주택이 양도되어 양수인이 임차보증금반환채무를 부담하게 된 후에 임차인이 주민등록을 다른 곳으로 옮겼다 하여 이미 발생한 양수인의 임차보증금반환채무가 소멸하는 것은 아니다[93다36615].

㉧ 임대인 지위가 양수인에게 승계된 경우 이미 발생한 연체차임채권은 따로 채권양도의 요건을 갖추지 않는 한 승계되지 않는다. 따라서 양수인이 연체차임채권을 양수받지 않은 이상 승계 이후의 연체차임액이 2기 이상의 차임액에 달하여야만 비로소 임대차계약을 해지할 수 있다[2008다3022].

② **양수인에 해당하는 경우** : 임대인의 지위를 승계한 것으로 보게 되는 임차주택의 양수인이 될 수 있는 경우는 주택을 임대할 권리나 이를 수반하는 권리를 종국적, 확정적으로 이전받게 되는 경우라야 하므로 매매, 증여, 경매, 상속, 공용징수 등에 의하여 임차주택의 소유권을 취득한 자 등은 위에서 말하는 임차주택의 양수인에 해당된다[93다4083].

③ **양수인에 해당하지 않는 경우** : 임차주택의 양도담보권자, 임차주택의 대지만 경락받은 자는 임대인의 지위를 승계받는 임차주택의 양수인이라고 할 수는 없다[98다3276].

(2) 경매에 있어서의 대항력

> **제3조의5(경매에 의한 임차권의 소멸)** 임차권은 임차주택에 대하여 「민사집행법」에 따른 경매가 행하여진 경우에는 그 임차주택의 경락에 따라 소멸한다. 다만, 보증금이 모두 변제되지 아니한, 대항력이 있는 임차권은 소멸하지 아니한다.

① 임차인이 대항요건을 갖추었다 하여도 경매에 있어서는 선순위 담보물권이나 가압류 등이 있는 경우에는 대항력이 인정되지 않는다.

② **임차권이 최선순위인 경우** : 대항력 있는 임차권이 최선순위인 경우에는 보증금이 모두 변제되지 않는 한, 임차권은 소멸하지 아니하고 경매절차의 매수인(경락인)에게 대항할 수 있다.

③ **임차권보다 선순위 저당권이 있는 경우** : 임차권보다 선순위로 저당권이 있는 경우에는 후순위저당권의 실행으로 목적부동산이 경락되어 그 선순위저당권이 함께 소멸한 경우라면 대항력을 갖춘 임차권은 함께 소멸하고, 경락인에 대해 그 임차권의 효력을 주장할 수 없다[86다카1936].

④ **대항력을 갖춘 선순위 임대차의 보증금증액** : 대항력을 갖춘 임차인(1순위)이 저당권설정등기(2순위) 이후에 임대인과 합의로 보증금을 증액(3순위)한 경우, 임차인은 저당권설정등기 이후에 증액한 임차보증금으로써는 건물을 경락받은 소유자에게 대항할 수 없다[90다카11377].

제 3 절 보증금의 회수

1. 우선변제권

(1) 의 의

법 제3조 제1항 · 제2항 또는 제3항의 대항요건과 임대차계약증서상의 확정일자(確定日字)를 갖춘 임차인은 「민사집행법」에 따른 경매 또는 「국세징수법」에 따른 공매를 할 때에 임차주택(대지를 포함한다)의 환가대금에서 후순위권리자나 그 밖의 채권자보다 우선하여 보증금을 변제받을 권리가 있다(제3조의2 제2항).

(2) **발생요건**(대항요건 + 확정일자)

① 확정일자의 규정취지

확정일자의 요건을 규정한 것은 임대인과 임차인 사이의 담합으로 임차보증금의 액수를 사후에 변경하는 것을 방지하고자 하는 취지일 뿐 대항요건으로 규정된 주민등록과 같이 당해 임대차의 존재사실을 제3자에게 공시하고자 하는 것은 아니다. 따라서 임대차계약서에 임대차 목적물을 표시하면서 아파트의 명칭과 그 전유부분의 동 · 호수를 누락하였다는 사유만으로 확정일자의 요건을 갖추지 못하였다고 볼 수는 없다[99다7992].

② 확정일자부여기관

제3조의6(확정일자부여 및 임대차정보제공 등) ① 제3조의2 제2항의 확정일자는 주택소재지의 읍 · 면사무소, 동 주민센터 또는 시(특별시 · 광역시 · 특별자치시는 제외하고, 특별자치도는 포함한다) · 군 · 구(자치구를 말한다)의 출장소, 지방법원 및 그 지원과 등기소 또는 「공증인법」에 따른 공증인(이하 이 조에서 "확정일자부여기관"이라 한다)이 부여한다.

② 확정일자부여기관은 해당 주택의 소재지, 확정일자부여일, 차임 및 보증금 등을 기재한 확정일자부를 작성하여야 한다. 이 경우 전산처리정보조직을 이용할 수 있다.

③ 임대차정보제공의 요청 및 임대인의 정보제시의무

제3조의6(확정일자부여 및 임대차정보제공 등) ③ 주택의 임대차에 이해관계가 있는 자는 확정일자부여기관에 해당 주택의 확정일자부여일, 차임 및 보증금 등 정보의 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 확정일자부여기관은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.

④ 임대차계약을 체결하려는 자는 임대인의 동의를 받아 확정일자부여기관에 제3항에 따른 정보제공을 요청할 수 있다.

⑤ 제1항 · 제3항 또는 제4항에 따라 확정일자를 부여받거나 정보를 제공받으려는 자는 수수료를 내야 한다.

제3조의7(임대인의 정보 제시 의무) 임대차계약을 체결할 때 임대인은 다음 각 호의 사항을 임차인에게 제시하여야 한다.

1. 제3조의6제3항에 따른 해당 주택의 확정일자 부여일, 차임 및 보증금 등 정보. 다만, 임대인이 임대차계약을 체결하기 전에 제3조의6제4항에 따라 동의함으로써 이를 갈음할 수 있다.
2. 「국세징수법」 제108조에 따른 납세증명서 및 「지방세징수법」 제5조제2항에 따른 납세증명서. 다만, 임대인이 임대차계약을 체결하기 전에 「국세징수법」 제109조제1항에 따른 미납국세와 체납액의 열람 및 「지방세징수법」 제6조제1항에 따른 미납지방세의 열람에 각각 동의함으로써 이를 갈음할 수 있다.

④ **우선변제권 발생시기** : 우선변제권은 대항력을 전제로 하여 발생하므로 주택임차인이 주택인도와 주민등록을 마친 당일(예컨대 2월 15일) 또는 그 이전에 임대차계약증서상에 확정일자를 갖춘 경우, 우선변제권은 대항력과 마찬가지로 주택의 인도와 주민등록을 마친 다음 날(2월 16일 오전 0시)을 기준으로 발생한다. 그러나 대항요건을 갖춘(예컨대 2월 14일) 후 확정일자를 받은 경우(2월 15일)에는 확정일자 받은 날(2월 15일)부터 우선변제권이 발생한다.

⑤ 임차보증금 지급여부

주택임대차보호법은 임차인에게 우선변제권이 인정되기 위하여 대항요건과 임대차계약증서상의 확정일자를 갖추는 것 외에 계약 당시 임차보증금이 전액 지급되어 있을 것을 요구하지는 않는다[2017다212194].

⑥ 배당요구채권

주택임대차보호법에 의하여 우선변제권이 있는 임차인은 배당요구를 할 수 있다. 배당요구를 하지 않으면 배당금으로부터 우선변제를 받지 못한다.

(3) 우선변제적 효력의 내용

① 임차인이 보증금에 대한 배당요구를 하여 보증금 전액을 배당받을 수 있는 경우에는, 임차인이 그 배당금을 지급받을 수 있는 때, 즉 임차인에 대한 배당표가 확정될 때까지는 임차권이 소멸하지 않는다고 해석함이 상당하다 할 것이다[2003다23885].

② 임대차 성립당시 임대인의 소유였던 대지가 타인에게 양도되어 임차주택과 대지의 소유자가 서로 달라진 경우에도 임차인은 대지의 경매대금에 대하여 우선변제권을 행사할 수 있다. 또한 대항요건 및 확정일자를 갖춘 임차인과 소액임차인은 임차주택과 그 대지가 함께 경매될 경우뿐만 아니라 임차주택과 별도로 그 대지만이 경매될 경우에도 그 대지의 환가대금에 대하여 우선변제권을 행사할 수 있다[2004다26133全合].

③ 주택임대차보호법상 우선변제권을 가진 임차인으로부터 임차권과 분리하여 임차보증금반환채권만을 양수한 채권양수인이 주택임대차보호법상의 우선변제권을 행사할 수 있는 임차인에 해당한다고 볼 수 없다[2010다10276].

④ 그러나 금융기관 등이 우선변제권을 취득한 임차인의 보증금반환채권을 계약으로 양수한 경우에는 양수한 금액의 범위에서 우선변제권을 승계한다(법 제3조의2 제7항).

(4) 보증금의 회수와 주택의 인도

제3조의2(보증금의 회수) ③ 임차인은 임차주택을 양수인에게 인도하지 아니하면 제2항에 따른 보증금을 받을 수 없다.

(5) 임차인의 경매신청시 특칙

제3조의2(보증금의 회수) ① 임차인(제3조 제2항 및 제3항의 법인을 포함한다. 이하 같다)이 임차주택에 대하여 보증금반환청구소송의 확정판결이나 그 밖에 이에 준하는 집행권원(⇨ 화해조서 등)에 따라서 경매를 신청하는 경우에는 집행개시요건에 관한 「민사집행법」 제41조에도 불구하고 반대의무의 이행이나 이행의 제공을 집행개시의 요건으로 하지 아니한다.

2. 우선변제권을 갖춘 임차인이 전세권등기를 한 경우

① 주택임차인으로서 우선변제를 받을 수 있는 권리와 전세권자로서 우선변제를 받을 수 있는 권리는 별개의 것이므로, 최선순위 전세권자로서 배당요구를 하여 전세권이 매각으로 소멸되었다 하더라도 변제받지 못한 나머지 보증금에 기하여 대항력을 행사할 수 있고, 그 범위 내에서 임차주택의 매수인 은 임대인의 지위를 승계한 것으로 보아야 한다[2010마900].

② 주택임대차보호법상 임차인으로서의 지위와 전세권자로서의 지위를 함께 가지고 있는 자가 그 중 임차인으로서의 지위에 기하여 경매법원에 배당요구를 하였다면 배당요구를 하지 아니한 전세권에 관하여는 배당요구가 있는 것으로 볼 수 없다[2009다40790].

3. 보증금의 일정액의 보호(소액임차인의 최우선변제권)

(1) 의의 및 요건

제8조(보증금 중 일정액의 보호) ① 임차인은 보증금 중 일정액을 다른 담보물권자보다 우선하여 변제받을 권리가 있다. 이 경우 임차인은 주택에 대한 경매신청의 등기 전에 제3조 제1항의 요건(주택의 인도+전입신고)을 갖추어야 한다.

① **의의** : 보증금 중 일정액에 대해서는 순위에 관계 없이 선순위담보권자보다도 우선하여 경매절차에서 배당을 받을 수 있는데, 이를 최우선변제권이라 한다.

② **요건** : 이 경우 임차인은 주택에 대한 경매신청의 등기 전에 대항요건(주택의 인도와 주민등록)을 갖추어야 한다. 다만, 확정일자까지는 필요 없다.

③ **배당요구채권(配當要求債權)** : 소액임차인의 소액보증금반환채권은 배당요구가 필요한 배당요구채권에 해당한다.

(2) 일정액의 범위와 기준

제8조(보증금 중 일정액의 보호) ③ 제1항에 따라 우선변제를 받을 임차인 및 보증금 중 일정액의 범위와 기준은 제8조의2에 따른 주택임대차위원회의 심의를 거쳐 대통령령으로 정한다.

① 우선변제를 받을 임차인의 범위와 보증금 중 일정액의 범위(시행령 제10조, 제11조)

㉠ **서울특별시** : 보증금 1억 6천 5백만원 이하에 5천 5백만원

㉡ **「수도권정비계획법」에 따른 과밀억제권역**(서울특별시는 제외한다), **세종특별자치시, 용인시, 화성시, 김포시** : 보증금 1억 4천 5백만원 이하에 4,800만원

㉢ **광역시**(「수도권정비계획법」에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역은 제외한다), **안산시, 광주시, 파주시, 이천시 및 평택시** : 보증금 8천 5백만원 이하에 2천 800만원

㉣ **그 밖의 지역** : 보증금 7천 5백만원 이하에 2천 5백만원

② 최우선변제액의 한도

> **제8조(보증금 중 일정액의 보호)** ③ 다만, 보증금 중 일정액의 범위와 기준은 주택가액(대지의 가액을 포함한다)의 2분의 1을 넘지 못한다.

③ 관련판례

㉠ 처음 임대차계약을 체결할 당시에는 소액임차인에 해당하지 않았지만 그 후 새로운 임대차계약에 의하여 정당하게 보증금을 감액하여 소액임차인에 해당하게 되었다면, 소액임차인으로 보호받을 수 있다[2007다23203].

㉡ 대지에 관한 저당권 설정 후 지상에 건물이 신축된 경우, 건물의 소액임차인은 저당권 실행에 따른 대지의 환가대금에 대하여 우선변제를 받을 수 없다고 보아야 한다[99다25532].

제 4 절 임차권등기명령(賃借權登記命令)

1. 의 의

> **제3조의3(임차권등기명령)** ① 임대차가 끝난 후 보증금이 반환되지 아니한 경우 임차인은 임차주택의 소재지를 관할하는 지방법원 · 지방법원지원 또는 시 · 군 법원에 임차권등기명령을 신청할 수 있다.

임차인이 임대차가 종료된 후 보증금을 반환받지 못한 상태에서 다른 곳으로 이사를 하거나 주민등록을 전출하면 임차인이 종전에 가지고 있던 대항력과 우선변제권이 상실되어 보증금을 반환받는 것이 곤란하게 되는 문제점을 해소하기 위하여 임차권등기명령제도를 두게 되었다.

2. 임차권등기의 효력

(1) 대항력과 우선변제권의 취득과 유지

① 임차인은 임차권등기명령의 집행에 따른 임차권등기를 마치면 대항력과 우선변제권을 취득한다(제3조의3 제5항 전단).

② 다만, 임차인이 임차권등기 이전에 이미 대항력이나 우선변제권을 취득한 경우에는 그 대항력이나 우선변제권은 그대로 유지되며, 임차권등기 이후에는 대항요건을 상실하더라도(전출하더라도) 이미 취득한 대항력이나 우선변제권을 상실하지 아니한다(제3조의3 제5항 후단).

(2) 임차권 등기비용

> **제3조의3(임차권등기명령)** ⑧ 임차인은 제1항에 따른 임차권등기명령의 신청과 그에 따른 임차권등기와 관련하여 든 비용을 임대인에게 청구할 수 있다.

(3) 임차권등기 이후 소액임차인의 최우선변제권 배제

제3조의3(임차권등기명령) ⑥ 임차권등기명령의 집행에 따른 임차권등기가 끝난 주택(임대차의 목적이 주택의 일부분인 경우에는 해당 부분으로 한정한다)을 그 이후에 임차한 임차인은 제8조에 따른 우선변제를 받을 권리(최우선변제권)가 없다.

(4) 기 타

① 당연배당채권

임차권등기명령에 의하여 임차권등기를 한 임차인은 별도로 배당요구를 하지 않아도 당연히 배당받을 채권자에 속한다[2005다33039].

② 보증금반환의무와 임차권등기말소의무

주택임대차보호법 제3조의3 규정에 의한 임차권등기가 된 경우, 임대인의 임대차보증금 반환의무가 임차인의 임차권등기 말소의무보다 먼저 이행되어야 할 의무이다(즉, 보증금 반환의무와 임차권등기 말소의무가 동시이행관계 아니다)[2005다4529].

3. 민법에 따른 주택임차권등기의 효력

민법 제621조에 따라 임대인의 협력에 의하여 공동으로 실행한 주택임대차등기의 효력에 관하여는 임차권등기명령에 의한 임차권등기의 효력(대항력 및 우선변제권, 소액임차인 우선변제권 배제)을 준용한다(제3조의4 제1항).

제 5 절 임대차기간 및 계약의 갱신 · 차임 · 기타

1. 임대차기간

제4조(임대차기간 등) ① 기간을 정하지 아니하거나 2년 미만으로 정한 임대차는 그 기간을 2년으로 본다. 다만, 임차인은 2년 미만으로 정한 기간이 유효함을 주장할 수 있다(임대인은 주장 불가).
② 임대차기간이 끝난 경우에도 임차인이 보증금을 반환받을 때까지는 임대차관계가 존속되는 것으로 본다.

2. 계약의 갱신

(1) 약정갱신

계약자유의 원칙에 의해 임대인과 임차인은 당연히 약정으로 임대차계약을 갱신할 수 있다.

(2) 묵시적 갱신(법정갱신)

① **묵시적 갱신이 인정되는 경우** : 임대인이 임대차기간이 끝나기 6개월 전부터 2개월 전까지의 기간에 임차인에게 갱신거절의 통지를 하지 아니하거나 계약조건을 변경하지 아니하면 갱신하지 아니한다는 뜻의 통지를 하지 아니한 경우에는 그 기간이 끝난 때에 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 임대차한 것으로 본다. 또한 임차인이 임대차기간이 끝나기 2개월 전까지 통지하지 아니한 경우에도 같다(법 제6조 제1항).

② **묵시적 갱신의 내용** : 전 임대차와 동일한 조건으로 갱신된 것으로 보지만, 임대차의 존속기간은 2년으로 본다(법 제6조 제2항).

③ **묵시적 갱신의 경우 계약의 해지** : 임차인은 언제든지 임대인에게 계약해지를 통지할 수 있으며, 이 경우 임대인이 그 통지를 받은 날부터 3개월이 지나면 해지의 효력이 발생한다(법 제6조의2).

④ **묵시적 갱신이 인정되지 않는 경우** : 임차인이 2기(期)의 차임액(借賃額)에 달하도록 연체하거나 그 밖에 임차인으로서의 의무를 현저히 위반한 임차인에 대하여는 제1항을 적용하지 아니한다(법 제6조 제3항).

(2) 임차인의 계약갱신 요구(제6조의3)

① **의의** : 임대인은 임차인이 임대차기간이 끝나기 6개월 전부터 2개월 전까지의 기간 이내에 계약갱신을 요구할 경우 정당한 사유 없이 거절하지 못한다.

② **임대인의 거절사유** : 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 거절할 수 있다.

㉠ 임차인이 2기의 차임액에 해당하는 금액에 이르도록 차임을 연체한 사실이 있는 경우

㉡ 임차인이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 임차한 경우

㉢ 서로 합의하여 임대인이 임차인에게 상당한 보상을 제공한 경우

㉣ 임차인이 임대인의 동의 없이 목적 주택의 전부 또는 일부를 전대(轉貸)한 경우

㉤ 임차인이 임차한 주택의 전부 또는 일부를 고의나 중대한 과실로 파손한 경우

㉥ 임차한 주택의 전부 또는 일부가 멸실되어 임대차의 목적을 달성하지 못할 경우

㉦ 임대인이 목적 주택의 전부 또는 대부분을 철거하거나 재건축하기 위하여 목적 주택의 점유를 회복할 필요가 있는 경우

㉧ 임대인(임대인의 직계존속 · 직계비속을 포함한다)이 목적 주택에 실제 거주하려는 경우(당해 주택에 실제 거주한다는 사실은 임대인이 증명책임)

㉨ 그 밖에 임차인이 임차인으로서의 의무를 현저히 위반하거나 임대차를 계속하기 어려운 중대한 사유가 있는 경우

③ **임대인의 실제거주위반으로 인한 손해배상책임**

㉠ 임대인이 해당 주택에 실제 거주의 사유(위 ⑧)로 갱신을 거절하였음에도 불구하고 갱

신요구가 거절되지 아니하였더라면 갱신되었을 기간이 만료되기 전에 정당한 사유 없이 제3자에게 목적 주택을 임대한 경우 임대인은 갱신거절로 인하여 임차인이 입은 손해를 배상하여야 한다.

㉡ 손해배상액의 산정

ⓐ 거절 당시 당사자 간에 손해배상액의 예정에 관한 합의가 이루어 진 경우에는 그 합의된 금액에 의한다.

ⓑ 손해배상액의 예정에 관한 합의가 이루어지지 않는 경우에는 다음 각 호의 금액 중 큰 금액으로 한다.

- 갱신거절 당시 월차임(차임 외에 보증금이 있는 경우에는 그 보증금을 제7조의2 각 호 중 낮은 비율에 따라 월 단위의 차임으로 전환한 금액을 포함한다. 이하 "환산월차임"이라 한다)의 3개월분에 해당하는 금액
- 임대인이 제3자에게 임대하여 얻은 환산월차임과 갱신거절 당시 환산월차임 간 차액의 2년분에 해당하는 금액
- 갱신거절로 인하여 임차인이 입은 손해액

④ 임차인의 갱신요구 후에 임대인의 지위를 승계한 양수인의 갱신요구 거절여부

㉠ 임대인의 거절사유가 임차인의 갱신요구권 행사 후에 발생한 때에도 임대인은 임대차 기간 만료 6개월 전부터 2개월 전까지의 기간 내라면 갱신거절권을 행사할 수 있다.

㉡ 또한 거절할 수 있는 '임대인'을 임차인이 갱신을 요구할 당시의 임대인만으로 제한하여 해석하기 어렵고, 임대인의 지위를 승계한 양수인도 이에 포함된다 할 것이다.

㉢ 따라서 임대인의 지위를 승계한 임차주택의 양수인도 그 주택에 실제 거주하려는 경우 위 갱신거절 기간 내에 실제거주사유를 들어 임차인의 계약갱신 요구를 거절할 수 있다 [2021다266631].

⑤ 계약갱신 요구행사의 효과 및 제한

㉠ 갱신되는 임대차는 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 계약된 것으로 본다. 다만, 차임과 보증금은 20분의 1의 범위에서 증감할 수 있다.

㉡ 이 경우 갱신되는 임대차의 존속기간은 2년으로 본다. 다만, 임차인은 언제든지 임대인에게 계약해지를 통지할 수 있고, 임대인이 그 통지를 받은 날부터 3개월이 지나면 해지의 효력이 발생한다.

㉢ 임차인이 임대차계약의 갱신을 요구하면 임대인에게 갱신거절 사유가 존재하지 않는 한 임대인에게 갱신요구가 도달한 때 갱신의 효력이 발생한다. 갱신요구에 따라 임대차계약에 갱신의 효력이 발생한 경우 임차인은 언제든지 계약의 해지통지를 할 수 있고, 해지통지 후 3개월이 지나면 그 효력이 발생하며, 이는 계약해지의 통지가 갱신된 임대차계약 기간이 개시되기 전에 임대인에게 도달하였더라도 마찬가지이다 [2023다258672].

㉣ 임차인은 계약갱신요구권을 1회에 한하여 행사할 수 있다.

⑥ 적용범위

㉠ 이 법 시행 당시 존속 중인 임대차에 대하여도 적용한다.

㉡ 이 법 시행 전에 임대인이 갱신을 거절하고 제3자와 임대차계약을 체결한 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

3. 차임 등

(1) **차임연체와 해지** : 주택임대차보호법상 규정이 없기 때문에 민법의 규정이 적용되어 임차인의 차임연체액이 2기의 차임액에 달하는 때에는 임대인은 계약을 해지할 수 있다(민법 제640조). 2기의 연체는 연속적임을 요하지 않는다.

(2) **차임 등의 증감청구권**

> **제7조(차임 등의 증감청구권)** ① 당사자는 약정한 차임이나 보증금이 임차주택에 관한 조세, 공과금, 그 밖의 부담의 증감이나 경제사정의 변동으로 인하여 적절하지 아니하게 된 때에는 장래에 대하여 그 증감을 청구할 수 있다. 이 경우 증액청구는 임대차계약 또는 약정한 차임이나 보증금의 증액이 있은 후 1년 이내에는 하지 못한다.
> ② 제1항에 따른 증액청구는 약정한 차임이나 보증금의 20분의 1(5%)의 금액을 초과하지 못한다. 다만, 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 도 및 특별자치도는 관할 구역 내의 지역별 임대차 시장 여건 등을 고려하여 본문의 범위에서 증액청구의 상한을 조례로 달리 정할 수 있다.

주택임대차보호법 제7조의 규정은 임대차계약의 존속 중 당사자 일방이 약정한 차임 등의 증감을 청구한 때에 한해 적용되고, 임대차계약이 종료된 후 재계약을 하는 경우 또는 임대차계약 종료 전이라도 당사자의 합의로 차임 등이 증액된 경우에는 적용되지 않는다[2002다23482].

4. 기 타

(1) **주택임차권의 승계**

① 임차인의 상속인이 없는 경우 : 그 주택에서 가정공동생활을 하던 사실상의 혼인 관계에 있는 자가 임차인의 권리와 의무를 승계한다.

② 임차인의 상속인이 있는 경우 :

㉠ 상속인이 가정공동생활을 하는 경우 : 상속인이 단독으로 임차인의 권리와 의무를 승계한다.

㉡ 상속인이 가정공동생활을 하지 않는 경우 : 그 주택에서 가정공동생활을 하던 사실상의 혼인관계에 있는 자와 2촌 이내의 친족이 공동으로 임차인의 권리와 의무를 승계한다.

③ 임차인이 사망한 후 1개월 이내에 승계대상자가 임대인에게 반대의사를 표시한 경우에는 승계되지 아니한다.

(2) **편면적 강행규정**

> **제10조(강행규정)** 이 법에 위반된 약정(約定)으로서 임차인에게 불리한 것은 그 효력이 없다.

CHAPTER

02 상가건물임대차보호법

제 1 절 서 설

1. 목 적

제1조(목적) 이 법은 상가건물임대차에 관하여 「민법」에 대한 특례를 규정하여 국민경제생활의 안정을 보장함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

(1) 대상 상가건물

① 상가건물임대차보호법이 적용되는 상가건물의 임대차는 사업자등록의 대상이 되는 건물로서 임대차목적물인 건물을 영리를 목적으로 하는 영업용으로 사용하는 임대차를 가리킨다고 볼 것이다. 따라서 상가건물의 임차인이라도 종교 · 자선단체 및 친목모임 사무실 등은 적용대상이 되지 않는다.

② 그리고 상가건물임대차보호법이 적용되는 상가건물에 해당하는지는 공부상 표시가 아닌 건물의 현황 · 용도 등에 비추어 영업용으로 사용하느냐에 따라 실질적으로 판단하여야 하고, 단순히 상품의 보관 · 제조 · 가공 등 사실행위만이 이루어지는 공장 · 창고 등은 영업용으로 사용하는 경우라고 할 수 없으나 그곳에서 그러한 사실행위와 더불어 영리를 목적으로 하는 활동이 함께 이루어진다면 상가건물임대차보호법 적용대상인 상가건물에 해당한다[2009다40967].

③ 사업자등록의 대상은 자연인(외국인 포함)은 물론 법인도 포함하고 있으므로 상가건물임대차보호법은 임차인이 법인인 경우에도 적용된다 할 것이다.

(2) 적용되는 보증금의 범위

제2조(적용범위) ① 「상가건물임대차보호법」(이하 "법"이라 한다) 제2조 제1항 단서에서 "대통령령으로 정하는 보증금액"이란 다음 각 호의 구분에 의한 금액을 말한다.

1. 서울특별시 : 9억원
2. 「수도권정비계획법」에 따른 과밀억제권역(서울특별시는 제외한다) 및 부산광역시 : 6억 9천만원
3. 광역시(「수도권정비계획법」에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역, 부산광역시는 제외한다), 세종특별자치시, 파주시, 화성시, 안산시, 용인시, 김포시 및 광주시: 5억 4천만원
4. 그 밖의 지역 : 3억 7천만원

② 법 제2조 제2항의 규정에 의하여 보증금 외에 차임이 있는 경우의 차임액은 월 단위의 차임액으로 한다.
③ 법 제2조 제2항에서 "대통령령으로 정하는 비율"이라 함은 1분의 100을 말한다.

① 상가건물임대차보호법은 대통령령이 정하는 환산보증금액[보증금+차임환산액(차임×100)]을 초과하는 임대차에 대하여는 적용하지 않는다(법 제2조 제1항 단서, 시행령 제2조 제1항, 제2항, 제3항).

② 예를 들어 보증금이 2억원이고 월세가 550만원인 경우 환산보증금은 2억원+(550만원×100)=7억 5천만원이 된다. 따라서 서울특별시라면 상가건물임대차보호법의 적용을 받을 수 있지만, 과밀억제권역이라면 적용되지 않는다.

(3) 적용보증금을 초과하는 경우에도 적용되는 경우

제2조(적용범위) ③ 제1항 단서에도 불구하고 제3조, 제10조 제1항, 제2항, 제3항 본문, 제10조의2부터 제10조의8까지의 규정 및 제19조는 제1항 단서에 따른 보증금액을 초과하는 임대차에 대하여도 적용한다.

① 대항력(법 제3조), 계약갱신요구 등(법 제10조 제1항, 제2항, 제3항), 계약갱신시 차임 및 보증금의 증감청구(법 제10조의2), 권리금(법 제10조의3 내지 제10조의7), 3기 차임연체와 해지(법 제10조의8), 표준계약서작성 등(법 제19조)은 보증금액을 초과하는 임대차에 대하여도 적용한다.

② 다만, 대통령령으로 정한 보증금액을 초과하는 임대차에서 기간을 정하지 않은 경우에는 상가건물 임대차보호법상 최단기간규정(1년)이 적용되지 않고 민법의 적용을 받으므로 임대차기간이 정해져 있음을 전제로 기간 만료 6개월 전부터 1개월 전까지 사이에 행사하도록 규정된 임차인의 계약갱신요구권은 발생할 여지가 없다.

3. 미등기전세에의 준용

제17조(미등기전세에의 준용) 목적건물을 등기하지 아니한 전세계약에 관하여 이 법을 준용한다. 이 경우 "전세금"은 "임대차의 보증금"으로 본다.

4. 일시사용을 위한 임대차

제16조(일시사용을 위한 임대차) 이 법은 일시사용을 위한 임대차임이 명백한 경우에는 적용하지 아니한다.

제 2 절 대항력(對抗力)

1. 대항요건

제3조(대항력 등) ① 임대차는 그 등기가 없는 경우에도 임차인이 건물의 인도와 「부가가치세법」 제8조, 「소득세법」 제168조 또는 「법인세법」 제111조에 따른 사업자등록을 신청 하면 그 다음 날부터 제3자에 대하여 효력이 생긴다.

① 사업자등록은 대항력의 취득요건일 뿐만 아니라 존속요건이기도 하므로 배당요구의 종기까지 존속하고 있어야 한다[2005다64002].

② 상가건물을 임차하고 사업자등록을 마친 사업자가 임차건물을 적법하게 전대차한 경우에는 임차인이 상가건물임대차보호법상의 대항력 및 우선변제권을 유지하기 위해서는 건물을 직접 점유하면서 사업을 운영하는 전차인이 그 명의로 사업자등록을 하여야 한다[2005다64002].

③ 사업자가 폐업신고를 하였다가 다시 같은 상호 및 등록번호로 사업자등록을 하였다고 하더라도 상가건물임대차보호법상의 대항력 및 우선변제권이 그대로 존속한다고 할 수 없다[2006다56299].

④ 건물의 일부분을 임차한 경우 그 사업자등록이 제3자에 대한 관계에서 유효한 임대차의 공시방법이 되기 위해서는 특별한 사유가 없는 한 사업자등록신청시 그 임차부분을 표시한 도면을 첨부하여야 한다[2008다44238].

2. 대항력의 내용

(1) 상가건물 양수인에 대한 효력

제3조(대항력 등) ② 임차건물의 양수인(그 밖에 임대할 권리를 승계한 자를 포함한다)은 임대인의 지위를 승계한 것으로 본다.

① '임차건물의 양수인'이란 대항요건을 갖춘 후에 매매, 증여, 상속 등으로 임차건물의 소유권을 취득한 자를 말한다. 이러한 양수인은 종전 임대인의 지위를 그대로 승계하고 동시에 양도인은 기존의 임대차관계에서 벗어나므로 임대차종료 후 양수인이 보증금반환의무를 부담하고 종전 임대인은 보증금반환의무를 면한다.

② 그러나 새로운 소유자와 임차인이 동일한 목적물에 관하여 종전 임대차계약의 효력을 소멸시키려는 의사로 그와는 별개의 임대차계약을 새로이 체결한 경우, 다른 특별한 사정이 없는 한 이제 종전의 임대차계약을 기초로 발생하였던 대항력 또는 우선변제권 등도 종전 임대차계약과 함께 소멸하여 이를 새로운 소유자 등에게 주장할 수 없다고 할 것이다[2013다211919].

(2) 대항력의 존속

제8조(경매에 의한 임차권의 소멸) 임차권은 임차건물에 대하여 「민사집행법」에 따른 경매가 실시된 경우에는 그 임차건물이 매각되면 소멸한다. 다만, 보증금이 전액 변제되지 아니한 대항력이 있는 임차권은 소멸하지 아니한다.
제9조(임대차기간 등) ② 임대차가 종료한 경우에도 임차인이 보증금을 돌려받을 때까지는 임대차관계는 존속하는 것으로 본다.

제 3 절 보증금의 회수

1. 우선변제권

(1) 요건 (대항요건 + 확정일자)

> **제5조(보증금의 회수)** ② 제3조 제1항의 대항요건을 갖추고 관할 세무서장으로부터 임대차계약서상의 확정일자를 받은 임차인은 「민사집행법」에 따른 경매 또는 「국세징수법」에 따른 공매시 임차건물(임대인 소유의 대지를 포함한다)의 환가대금에서 후순위권리자나 그 밖의 채권자보다 우선하여 보증금을 변제받을 권리가 있다.

(2) 확정일자부여 및 임대차정보의 제공 등

① 확정일자부여권자 : 제5조 제2항의 확정일자는 상가건물의 소재지 관할 세무서장이 부여한다. 관할 세무서장은 임대차계약이 변경되거나 갱신된 경우 임차인의 신청에 따라 새로운 확정일자를 부여한다.

② 임대차정보의 제공

㉠ 상가건물의 임대차에 '이해관계가 있는 자'는 관할 세무서장에게 해당 상가건물의 확정일자 부여일, 차임 및 보증금 등 정보의 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 관할 세무서장은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.

㉡ 임대차계약을 체결하려는 자도 임대인의 동의를 받아 관할 세무서장에게 위 정보제공을 요청할 수 있다.

(3) 보증금의 회수와 건물의 인도

> **제5조(보증금의 회수)** ③ 임차인은 임차건물을 양수인에게 인도하지 아니하면 제2항에 따른 보증금을 받을 수 없다(동시이행관계).

(4) 경매신청의 특칙

> **제5조(보증금의 회수)** ① 임차인이 임차건물에 대하여 보증금반환청구소송의 확정판결, 그 밖에 이에 준하는 집행권원(화해조서)에 의하여 경매를 신청하는 경우에는 「민사집행법」 제41조에도 불구하고 반대의무의 이행이나 이행의 제공을 집행개시의 요건으로 하지 아니한다(목적물을 인도하지 아니하고 경매청구할 수 있다).

2. 보증금 중 일정액의 우선변제권(최우선변제권)

(1) 의 의

> **제14조(보증금 중 일정액의 보호)** ① 임차인은 보증금 중 일정액을 다른 담보물권자보다 우선하여 변제받을 권리가 있다. 이 경우 임차인은 건물에 대한 경매신청의 등기 전에 제3조 제1항의 요건(건물의 인도와 사업자등록)을 갖추어야 한다(확정일자는 불필요).

② 제1항의 경우에 제5조 제4항부터 제6항까지의 규정(우선변제의 순위와 보증금에 대하여 이의가 있는 이해관계인은 경매법원이나 체납처분청에 이의를 신청)을 준용한다.

(2) 일정액의 범위와 기준

① 우선변제를 받을 임차인의 범위와 보증금 중 일정액의 범위(시행령 제6조, 제7조)

㉠ **서울특별시** : 보증금 6천 5백만원 이하에 2천 200만원

㉡ **「수도권정비계획법」에 따른 과밀억제권역**(서울특별시는 제외한다) : 보증금 5천 500만원 이하에 1천 900만원

㉢ **광역시**(「수도권정비계획법」에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역은 제외한다), **안산시, 용인시, 김포시 및 광주시** : 보증금 3천 8백만원 이하에 1천 300만원

㉣ **그 밖의 지역** : 보증금 3천만원 이하에 1천만원

② 최우선변제액의 한도

제14조(보증금 중 일정액의 보호) ③ 제1항에 따라 우선변제를 받을 임차인 및 보증금 중 일정액의 범위와 기준은 임대건물가액(임대인 소유의 대지가액을 포함한다)의 2분의 1 범위에서 해당 지역의 경제 여건, 보증금 및 차임 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.

제 4 절 임차권등기명령(賃借權登記命令)

1. 의 의

제6조(임차권등기명령) ① 임대차가 종료된 후 보증금이 반환되지 아니한 경우 임차인은 임차건물의 소재지를 관할하는 지방법원, 지방법원지원 또는 시·군법원에 임차권등기명령을 신청할 수 있다.
④ 임차권등기명령신청을 기각하는 결정에 대하여 임차인은 항고할 수 있다.
⑨ 금융기관등은 임차인을 대위하여 제1항의 임차권등기명령을 신청할 수 있다. 이 경우 제3항·제4항 및 제8항의 "임차인"은 "금융기관 등"으로 본다.

2. 효 력

제6조(임차권등기명령) ⑤ 임차권등기명령의 집행에 따른 임차권등기를 마치면 임차인은 제3조 제1항에 따른 대항력과 제5조 제2항에 따른 우선변제권을 취득한다. 다만, 임차인이 임차권등기 이전에 이미 대항력 또는 우선변제권을 취득한 경우에는 그 대항력 또는 우선변제권이 그대로 유지되며, 임차권등기 이후에는 제3조 제1항의 대항요건을 상실하더라도 이미 취득한 대항력 또는 우선변제권을 상실하지 아니한다.
⑥ 임차권등기명령의 집행에 따른 임차권등기를 마친 건물(임대차의 목적이 건물의 일부분인 경우에는 그 부분으로 한정한다)을 그 이후에 임차한 임차인은 제14조에 따른 우선변제(최우선변제권)를 받을 권리가 없다.

제 5 절 존속기간의 보장

1. 최단기간의 제한

제9조(임대차기간 등) ① 기간을 정하지 아니하거나 기간을 1년 미만으로 정한 임대차는 그 기간을 1년으로 본다. 다만, 임차인은 1년 미만으로 정한 기간이 유효함을 주장할 수 있다(주택은 2년).
② 임대차가 종료한 경우에도 임차인이 보증금을 돌려받을 때까지는 임대차관계는 존속하는 것으로 본다.

2. 임차인의 계약갱신요구권

(1) 의 의

① 임대인은 임차인이 임대차기간이 만료되기 6개월 전부터 1개월 전까지 사이에 행하는 계약갱신요구에 대하여 정당한 사유 없이 이를 거절하지 못한다(제10조 제1항).

② 임대인의 갱신 거절 통지의 선후와 관계없이 임차인은 계약갱신요구권을 행사할 수 있다. 즉, 임대차기간이 만료되기 6개월 전부터 1개월 전까지 사이에 임대인의 갱신 거절의 통지가 있다하더라도 임차인은 갱신요구권을 행사할 수 있다.

(2) 임대인의 갱신거절(제10조 제1항)

① 임대인의 갱신거절 사유(제10조 제1항)

㉠ 임차인이 3기의 차임액에 해당하는 금액에 이르도록 차임을 연체한 사실이 있는 경우

㉡ 임차인이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 임차한 경우

㉢ 임차인이 임대인의 동의 없이 목적건물의 전부 또는 일부를 전대(轉貸)한 경우

㉣ 임차인이 임차한 건물의 전부 또는 일부를 고의나 중대한 과실로 파손한 경우

㉤ 임차한 건물의 전부 또는 일부가 멸실되어 임대차의 목적을 달성하지 못할 경우

㉥ 임대인이 목적 건물의 전부 또는 대부분을 철거하거나 재건축하기 위해 목적 건물의 점유회복이 필요한 경우

㉦ 쌍방 합의하에 임대인이 임차인에게 상당한 보상을 제공한 경우

㉧ 그 밖에 임차인이 임차인으로서의 의무를 현저히 위반하거나 임대차를 존속하기 어려운 중대한 사유가 있는 경우

② 상가건물임대차보호법이 적용되는 상가건물의 공유자인 임대인이 같은 법 제10조 제4항에 의하여 임차인에게 갱신거절의 통지를 하는 행위는 실질적으로 임대차계약의 해지와 같이 공유물의 임대차를 종료시키는 것이므로 공유물의 관리행위에 해당하여 공유자의 지분의 과반수로써 결정하여야 한다[2010다37905].

(3) 행사범위 및 효과

① 갱신요구권 행사의 범위

㉠ 임차인의 계약갱신요구권은 최초의 임대차기간을 포함한 전체 임대차기간이 10년을 초과하지 아니하는 범위에서만 행사할 수 있다(법 제10조 제2항).

㉡ '최초의 임대차기간' 이라 함은 위 법 시행 이후에 체결된 임대차계약에 있어서나 위 법 시행 이전에 체결되었다가 위 법 시행 이후에 갱신된 임대차계약에 있어서 모두 당해 상가건물에 관하여 최초로 체결된 임대차계약의 기간을 의미한다고 할 것이다[2005다74320].

② 갱신요구권 행사의 효과(법 제10조 제3항, 제10조의2)

㉠ 갱신되는 임대차는 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 계약된 것으로 본다.

㉡ 다만, 차임과 보증금은 100분의 5 범위 안에서 증감할 수 있다.

(4) 전대차관계에 적용

① 계약갱신요구에 관한 제10조는 전대인(轉貸人)과 전차인(轉借人)의 전대차관계에 적용한다(제13조 제1항).

② 임대인의 동의를 받고 전대차계약을 체결한 전차인은 임차인의 계약갱신요구권 행사기간 이내에 임차인을 대위(代位)하여 임대인에게 계약갱신요구권을 행사할 수 있다(제13조 제2항).

3. 묵시적 갱신(법정갱신)

① 임대인이 기간 만료 전 6월 전부터 1월까지 사이에 임차인에 대하여 통지를 하지 아니한 경우에는 그 기간이 만료된 때에 전임대차와 동일한 조건으로 다시 임대차한 것으로 본다(제10조 제4항). 임차인에 대해서는 별도의 갱신거절 통지의 기간의 규정이 없으므로 임차인이 임대차기간 만료 1개월 전부터 만료일 사이에 갱신거절의 통지를 한 경우, 해당 임대차계약은 묵시적 갱신이 인정되지 않고 임대차기간의 만료일에 종료한다고 보아야 한다[2023다307024].

② 이 경우 임대차의 존속기간은 1년으로 본다. 다만, 임차인은 언제든지 계약해지의 통고를 할 수 있고, 임대인이 그 통고를 받은 날부터 3개월이 경과하면 그 효력이 발생한다(제10조 제4항 단서, 제5항).

③ 임차인의 갱신요구권과 묵시적 갱신(법정갱신)은 그 취지와 내용을 달리하는 것이므로 임차인의 계약갱신요구권에 관하여 전체 임대차기간을 10년으로 제한하는 규정은 법정갱신에 대하여는 적용되지 아니한다[2009다64307]. 즉, 법정갱신의 경우에는 10년을 초과하여도 갱신이 가능하다.

제 6 절 권리금(權利金)

1. 서 설

① **권리금의 의의** : 권리금이란 임대차목적물인 상가건물에서 영업을 하는 자 또는 영업을 하려는 자가 영업시설 · 비품, 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 상가건물의 위치에 따른 영업상의 이점 등 유형 · 무형의 재산적 가치의 양도 또는 이용대가로서 임대인, 임차인에게 보증금과 차임 이외에 지급하는 금전 등의 대가를 말한다.

② **권리금계약** : 권리금계약이란 신규임차인이 되려는 자가 임차인에게 권리금을 지급하기로 하는 계약을 말한다.

2. 권리금 회수기회 보호

(1) 권리금 회수방해 행위금지 및 예외

① 임대인은 임대차기간이 끝나기 6개월 전부터 임대차 종료시까지 다음 ㉠ ~ ㉣의 어느 하나에 해당하는 행위를 함으로써 권리금계약에 따라 임차인이 주선한 신규임차인이 되려는 자로부터 권리금을 지급받는 것을 방해하여서는 아니 된다. 다만, 제10조 제1항 각 호의 어느 하나 에 해당하는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

㉠ 임차인이 주선한 신규임차인이 되려는 자에게 권리금을 요구하거나 임차인이 주선한 신규임차인이 되려는 자로부터 권리금을 수수하는 행위

㉡ 임차인이 주선한 신규임차인이 되려는 자로 하여금 임차인에게 권리금을 지급하지 못하게 하는 행위

㉢ 임차인이 주선한 신규임차인이 되려는 자에게 상가건물에 관한 조세, 공과금, 주변 상가건물의 차임 및 보증금, 그 밖의 부담에 따른 금액에 비추어 현저히 고액의 차임과 보증금을 요구하는 행위

㉣ 그 밖에 정당한 사유 없이 임대인이 임차인이 주선한 신규임차인이 되려는 자와 임대차계약의 체결을 거절하는 행위

② 계약갱신요구 거절사유(제10조 제1항 각호의 사유)가 있는 경우에는 임대인은 권리금 보호 의무를 부담하지 않는다.

③ 또한 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 임차인이 주선한 신규임차인이 되려는 자와 임대차계약의 체결을 거절할 정당한 사유가 있는 것으로 본다.

㉠ 임차인이 주선한 신규임차인이 되려는 자가 보증금 또는 차임을 지급할 자력이 없는 경우

㉡ 임차인이 주선한 신규임차인이 되려는 자가 임차인으로서의 의무를 위반할 우려가 있거나 그 밖에 임대차를 유지하기 어려운 상당한 사유가 있는 경우

㉢ 임대차목적물인 상가건물을 1년 6개월 이상 영리목적으로 사용하지 아니한 경우

㉣ 임대인이 선택한 신규임차인이 임차인과 권리금계약을 체결하고 그 권리금을 지급한 경우

판 례

종전 소유자인 임대인이 임대차 종료 후 상가건물을 영리목적으로 사용하지 아니한 기간이 1년 6개월에 미치지 못하는 사이에 상가건물의 소유권이 변동된 경우, 위 조항에 따른 정당한 사유를 인정하기 위한 요건

종전 소유자인 임대인이 임대차 종료 후 상가건물을 영리목적으로 사용하지 아니한 기간이 1년 6개월에 미치지 못하는 사이에 상가건물의 소유권이 변동되었더라도, 임대인이 상가건물을 영리목적으로 사용하지 않는 상태가 새로운 소유자의 소유기간에도 계속하여 그대로 유지될 것을 전제로 처분하고, 실제 새로운 소유자가 그 기간 중에 상가건물을 영리목적으로 사용하지 않으며, 임대인과 새로운 소유자의 비영리 사용기간을 합쳐서 1년 6개월 이상이 되는 경우라면, 임대인에게 임차인의 권리금을 가로챌 의도가 있었다고 보기 어려우므로, 그러한 임대인에 대하여는 위 조항에 의한 정당한 사유를 인정할 수 있다[2021다272346].

④ 최초의 임대차기간을 포함한 전체 임대차기간이 10년을 초과하여 임차인이 계약갱신요구권을 행사할 수 없는 경우에도 임대인은 같은 법 제10조의4 제1항에 따른 권리금 회수기회 보호의무를 부담한다고 보아야 한다[2019. 5. 16 선고 2017다225312, 225329].

(2) 임대인의 손해배상책임

① 임대인이 권리금 회수방해행위를 하여 임차인에게 손해를 발생하게 한 때에는 그 손해를 배상할 책임이 있다. 이 경우 그 손해배상액은 신규임차인이 임차인에게 지급하기로 한 권리금과 임대차 종료 당시의 권리금 중 낮은 금액을 넘지 못한다.

② 임차인의 임대인에게 손해배상을 청구할 권리는 임대차가 종료한 날부터 3년 이내에 행사하지 아니하면 시효의 완성으로 소멸한다.

③ 임대인의 권리금 회수기회 방해로 인한 손해배상채무는 임대차가 종료한 날에 이행기가 도래하여 그다음 날부터 지체책임이 발생하는 것으로 보아야 한다[2022다260586].

④ 상가건물임대차보호법 제10조의4에서 정한 권리금 회수 방해로 인한 손해배상책임이 성립하기 위하여 반드시 임차인과 신규임차인이 되려는 자 사이에 권리금 계약이 미리 체결되어 있어야 하는 것은 아니다[2019. 7. 10. 선고 2018다239608].

⑤ 임차인의 임차목적물 반환의무와 임대인의 권리금 회수 방해로 인한 손해배상의무는 별개의 원인에 기하여 발생한 것일 뿐 아니라 공평의 관점에서 보더라도 그 사이에 이행상 견련관계를 인정하기 어렵다. 즉, 동시이행관계가 아니다[2019. 7. 10. 선고 2018다242727].

(3) 임차인의 신규임차인에 대한 정보제공

임차인은 임대인에게 임차인이 주선한 신규임차인이 되려는 자의 보증금 및 차임을 지급할 자력 또는 그 밖에 임차인으로서의 의무를 이행할 의사 및 능력에 관하여 자신이 알고 있는 정보를 제공하여야 한다(제10조의 4 제5항).

3. 권리금 적용제외

권리금에 관한 규정인 제10조의4는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상가건물임대차의 경우에는 적용하지 아니한다.

① 임대차목적물인 상가건물이 「유통산업발전법」 제2조에 따른 대규모 점포 또는 준대규모 점포의 일부인 경우(다만, 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」 제2조 제1호에 따른 전통시장은 제외한다)

② 임대차목적물인 상가건물이 「국유재산법」에 따른 국유재산 또는 「공유재산 및 물품관리법」에 따른 공유재산인 경우

제 7 절 기 타

1. 차임연체와 해지

제10조의8(차임연체와 해지) 임차인의 차임연체액이 3기의 차임액에 달하는 때에는 임대인은 계약을 해지할 수 있다.

2. 차임연체에 관한 특례

제10조의9(계약갱신요구 등에 관한 임시특례) 임차인이 이 법 시행일(2020. 9. 29)부터 6개월까지의 기간 동안 연체한 차임액은 제10조제1항제1호, 제10조의4제1항 단서 및 제10조의8의 적용에 있어서는 차임연체액으로 보지 아니한다. 이 경우 연체한 차임액에 대한 임대인의 그 밖의 권리는 영향을 받지 아니한다.

3. 차임 등의 증감청구권

제11조(차임 등의 증감청구권) ① 차임 또는 보증금이 임차건물에 관한 조세, 공과금, 그 밖의 부담의 증감이나 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 제1급감염병 등에 의한 경제사정의 변동으로 인하여 상당하지 아니하게 된 경우에는 당사자는 장래의 차임 또는 보증금에 대하여 증감을 청구할 수 있다. 그러나 증액의 경우에는 대통령령으로 정하는 기준에 따른 비율(청구당시의 차임 또는 보증금의 100분의 5)을 초과하지 못한다.

② 제1항에 따른 증액 청구는 임대차계약 또는 약정한 차임 등의 증액이 있은 후 1년 이내에는 하지 못한다.

③ 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 제1급감염병에 의한 경제사정의 변동으로 차임 등이 감액된 후 임대인이 제1항에 따라 증액을 청구하는 경우에는 증액된 차임 등이 감액 전 차임 등의 금액에 달할 때까지는 같은 항 단서(청구당시의 차임 또는 보증금의 100분의 5)를 적용하지 아니한다.

법 제11조 제1항에 따른 증액비율을 초과하여 지급하기로 하는 차임에 관한 약정은 증액비율을 초과하는 범위 내에서 무효이고, 임차인은 초과지급된 차임에 대하여 부당이득으로 반환을 구할 수 있다[2013다35115].

CHAPTER

03 가등기담보 등에 관한 법률

제 1 절 가등기담보의 의의 및 성질

1. 가등기담보의 의의

① 채권담보를 위해 저당권을 설정하지 않고 부동산에 대하여 채권자 앞으로 소유권이전의 가등기를 하거나(가등기담보) 아니면 아예 소유권이전등기를 하는(양도담보) 변칙적 담보형식이다.

② 가등기가 담보가등기인지, 청구권보전을 위한 가등기인지의 여부는 등기부상 표시나 등기 시에 주고받은 서류의 종류에 의하여 형식적으로 결정되는 것이 아니고 거래의 실질과 당사자의 의사해석에 따라 결정된다.

2. 가등기담보권의 성질

(1) 담보물권성

① 가등기담보권은 일종의 담보물권으로서 가등기담보법은 가등기담보권자에게 경매청구권(제12조), 우선변제권(제13조), 별제권(제17조 제1항)을 인정하고 있다. 즉, 가등기담보권은 일종의 특수한 저당권으로서의 성질을 가진다.

② 따라서 가등기담보권도 담보물권의 특성인 부종성, 수반성, 불가분성, 물상대위성이 그대로 인정된다.

(2) 용익관계

① 가등기담보권이 실행될 때까지는 목적물의 소유권이 담보권설정자에게 있으므로, 담보권설정자는 목적물을 자유롭게 사용·수익할 수 있고 담보목적물에 대한 과실을 수취할 수도 있다.

② 따라서 양도담보의 경우 목적부동산을 임대할 권한은 양도담보설정자에게 있고, 양도담보권자는 담보설정자로부터 목적부동산을 임차한 임차인에 대하여 목적물의 인도나 임료 상당의 부당이득반환청구를 할 수 없다.

③ 그러나 양도담보권자는 담보권의 실행을 위하여 담보채무자가 아닌 제3자에 대하여도 담보물의 인도를 구할 수 있고, 인도를 거부하는 경우에는 담보권 실행이 방해된 것을 이유로 하는 손해배상을 구할 수는 있으나, 그러한 경우에도 양도담보권자에게는 목적 부동산에 대한 사용·수익권이 없으므로 임료 상당의 손해배상을 구할 수는 없다[90다9780].

④ 담보목적물에 대한 과실수취권 등을 포함한 사용·수익권은 청산절차의 종료와 함께 채권자에게 귀속된다[2000다20465].

제 2 절 가등기담보법의 적용범위

1. 소비대차에 의한 채권

① 가등기담보법은 소비대차에 의하여 발생한 채권(차용금, 대여금)을 담보하기 위하여 실행된 가등기 또는 재산권이전등기에 관하여 적용된다.

② 따라서 소비대차 이외의 사유로 발생한 채권인 경우에는 적용되지 않는다. 즉, 매매대금, 공사대금채권, 물품대금의 반환채무를 담보하는 담보가등기의 경우 등에는 이 법이 적용되지 않는다.

2. 등기 · 등록이 가능한 물건이나 권리

① 가등기담보법이 적용되는 목적물은 등기 또는 등록할 수 있는 재산이어야 한다. 따라서 등기 · 등록할 수 없는 동산양도담보에는 적용되지 않는다.

② 또한 등기 또는 등록할 수 있는 재산권에 적용되므로 소유권 뿐만 아니라 소유권 외의 권리의 취득을 목적으로 하는 담보계약에 관하여 적용된다.

③ 다만, 그 자체가 담보권의 성질을 가지는 전세권, 질권, 저당권의 취득을 위한 담보계약에는 적용되지 않는다.

3. 예약 당시의 목적물의 가액이 피담보채권액을 초과하는 경우

① 차용물(借用物)의 반환에 관하여 차주 가 차용물을 갈음하여 다른 재산권을 이전할 것을 예약할 때 그 재산의 예약 당시 가액이 차용액과 이에 붙인 이자를 합산한 액수를 초과하는 경우에 적용된다(제1조). 따라서 가등기담보 부동산에 대한 예약 당시의 시가가 그 피담보채무액에 미치지 못하는 경우에는 같은 법 제3조, 제4조가 정하는 청산금평가액의 통지 및 청산금지급 등의 절차를 이행할 여지가 없다[93다27611].

② 재산권이전의 예약 당시 재산에 대하여 선순위근저당권이 설정되어 있는 경우에는 재산의 가액에서 피담보채무액을 공제한 나머지 가액이 차용액 및 이에 붙인 이자의 합산액을 초과하는 경우에만 적용된다[2005다61140].

4. 모든 비전형담보에 적용

가등기담보법은 비전형담보로서 가등기담보에만 적용되는 것이 아니라 양도담보, 매도담보, 환매, 재매매의 예약 등 명칭 여하를 불문하고 그 실질이 채권담보를 목적으로 한 경우에는 모두 적용된다.

제 3 절 가등기담보권의 실행

Ⅰ 가등기담보권의 실행방법

① 채무자가 변제기에 채무의 변제를 하지 않는 경우에는 가등기담보권자는 권리취득에 의한 실행(귀속청산=취득정산)과 경매에 의한 실행 중 한 가지 방법을 임의로 선택하여 가등기담보권을 실행할 수 있다.

② 가등기담보법은 귀속청산과 경매신청에 의한 우선변제만을 인정하고 가등기담보권자의 주도에 의한 처분 및 그 대금으로의 변제 및 청산을 의미하는 처분청산은 인정하지 않는다[2002다42001].

Ⅱ 귀속청산에 의한 실행(권리취득에 의한 실행)

1. 담보권실행 통지(청산통지)

(1) 통지할 내용

① 청산금의 평가액

청산금의 평가액은 통지 당시의 목적부동산의 평가액에서 가등기담보권자의 채권액을 뺀 금액인데, 이 경우 담보목적부동산에 선순위담보권 등의 권리가 있을 때에는 그 채권액을 계산할 때에 선순위담보 등에 의하여 담보된 채권액을 포함한다.

② 명시사항

청산금통지에는 통지 당시의 담보목적부동산의 평가액과 「민법」 제360조에 규정된 채권액(원본, 이자, 위약금, 채무불이행으로 인한 손해배상 등)을 밝혀야 한다. 이 경우 부동산이 둘 이상인 경우에는 각 부동산의 소유권이전에 의하여 소멸시키려는 채권과 그 비용을 밝혀야 한다(제3조 제2항).

③ 객관적 가치에 미달의 경우

여기에서 담보목적부동산의 평가액은 담보권자가 주관적으로 평가한 청산금의 산출근거를 알려주려는 것일 뿐이므로, 통지한 평가액이 통지 시점의 객관적 가액에 미달하더라도 담보권 실행 통지의 효력이나 청산기간의 진행에는 아무런 영향이 없다[2014다61630, 96다6974].

④ 청산금이 없는 경우

실행통지 당시의 부동산의 평가액이 피담보채권액에 미달하여 청산금이 없다고 인정되는 경우에는 그 뜻을 통지하여야 한다.

⑤ 통지의 구속력

채권자는 그가 통지한 청산금의 금액에 관하여 다툴 수 없다(제9조).

⑥ 채무자 등이 청산금에 대해 이의가 있는 경우

채무자 등은 채권자가 통지한 청산금액을 다투고 정당하게 평가된 청산금을 지급받을 때까지 목적부동산의 소유권이전등기 및 인도채무의 이행을 거절하거나 채권자에게 정당하게 평가된 청산금을 청구할 수도 있다. 한편, 채무자는 채권자가 통지한 청산금액에 동의함으로써 청산금을 확정시킬 수 있으며, 그 경우 동의는 명시적 뿐만 아니라 묵시적으로도 가능하다고 할 것이다[2005다36618].

(2) 통지절차

① 통지의 상대방

실행통지의 상대방은 '채무자 등', 즉 채무자, 담보가등기목적부동산의 물상보증인, 담보가등기 후 소유권을 취득한 제3자이다(제3조 제1항, 제2조 제2호). 통지는 이들 모두에게 하여야 하며 채무자 등의 전부 또는 일부에 대하여 통지를 하지 않으면 청산기간이 진행할 수 없다[94다36162].

② 통지시기

채권자가 담보계약에 따른 담보권을 실행하여 그 담보목적부동산의 소유권을 취득하기 위하여는 그 채권의 변제기 후에 언제라도 상관없다(제3조 제1항).

③ 통지방법

귀속정산의 통지방법에는 아무런 제한이 없다[2000다15661].

2. 청산기간의 경과

제3조(담보권실행의 통지와 청산기간) ① 채권자가 담보계약에 따른 담보권을 실행하여 그 담보목적부동산의 소유권을 취득하기 위하여는 그 채권의 변제기 후에 제4조의 청산금의 평가액을 채무자등에게 통지하고, 그 통지가 채무자 등에게 도달한 날부터 2개월(이하 "청산기간"이라 한다)이 지나야 한다.

3. 청산(淸算)

(1) 청산금의 지급

① 청산금

채권자는 청산기간 경과 후에 실행통지 당시의 담보목적부동산의 가액에서 그 채권액을 뺀 금액(이하 "청산금" 이라 한다)을 채무자 등에게 지급하여야 한다. 이 경우 담보목적부동산에 선순위담보권(先順位擔保權) 등의 권리가 있을 때에는 그 채권액을 계산할 때에 선순위담보 등에 의하여 담보된 채권액을 포함한다(제4조 제1항).

② 청산금의 공탁

청산금채권이 압류되거나 가압류된 경우에 채권자는 청산기간이 지난 후 이에 해당하는 청산금을 채무이행지(債務履行地)를 관할하는 지방법원이나 지원(支院)에 공탁(供託)하여 그 범위에서 채무를 면(免)할 수 있다(제8조 제1항).

(2) 채권자의 소유권의 취득

① 청산금이 있는 경우(제4조 제2항)

㉠ 채권자가 담보가등기를 마친 경우에는 청산기간이 지난 후 채무자 등에게 청산금을 지급하면서 그 가등기에 따른 본등기를 청구하여 본등기를 마치면 소유권을 취득한다.

㉡ 담보목적부동산에 관하여 이미 소유권이전등기를 마친 경우에는(부동산 양도담보) 청산기간이 지난 후 청산금을 채무자 등에게 지급한 때에 담보목적부동산의 소유권을 취득한다.

② 청산금이 없는 경우

청산금을 지급할 여지가 없는 때에는 2월의 청산기간이 경과함으로써 청산절차는 종료되고, 채권자는 더 이상의 반대급부의 제공 없이 채무자에 대하여 소유권이전등기청구권 및 목적물인도청구권을 가진다[2000다20465].

③ 동시이행관계

이때에 채권자의 청산금의 지급채무와 채무자의 부동산의 소유권이전등기 및 인도채무(引渡債務)는 동시이행관계에 있다(제4조 제3항).

(3) 법정지상권

제10조(법정지상권) 토지와 그 위의 건물이 동일한 소유자에게 속하는 경우 그 토지나 건물에 대하여 제4조 제2항에 따른 소유권을 취득하거나 담보가등기에 따른 본등기가 행하여진 경우에는 그 건물의 소유를 목적으로 그 토지 위에 지상권이 설정된 것으로 본다. 이 경우 그 존속기간과 지료는 당사자의 청구에 의하여 법원이 정한다.

(4) 채무자 등의 말소등기청구권

① 채무자 등은 청산금채권을 변제받을 때까지 그 채무액 을 채권자에게 지급하고 그 채권담보의 목적으로 마친 가등기나 소유권이전등기의 말소를 청구할 수 있다(제11조 전단, 66다6974).

② 다만, 그 채무의 변제기가 지난 때부터 10년이 지나거나 선의의 제3자가 소유권을 취득한 경우에는 소유권이전등기의 말소를 청구할 수 없다(제11조 후단).

4. 편면적 강행규정

제4조(청산금의 지급과 소유권의 취득) ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 어긋나는 특약(特約)으로서 채무자 등에게 불리한 것은 그 효력이 없다(편면적 강행규정). 다만, 청산기간이 지난 후에 행하여진 특약으로서 제3자의 권리를 침해하지 아니하는 것은 그 효력이 있다.

① 청산절차를 거치지 않고 이루어진 본등기는 가등기담보법의 강행규정에 위반되어 무효이다[2002다9127].

② 다만, 청산절차를 거치지 않은 무효인 본등기도 그 후에 청산절차를 마치면 그 소유권이전등기는 유효한 등기로 된다[2009다90160,90177].

③ 청산금의 지급을 면제하는 것과 같은 무청산의 특약은 청산기간이 경과한 후에 제3자의 권리를 침해하지 아니하는 경우에만 유효하다(제4조 제4항 후단).

4. 후순위권리자의 권리보호

(1) 실행통지사실 등의 통지

① 통지시기 및 내용

채권자는 제3조 제1항에 따른 통지(권리실행통지)가 채무자 등에게 도달하면 지체 없이 후순위권리자에게 그 통지의 사실과 내용 및 도달일을 통지하여야 한다(제6조 제1항).

② 통지하지 않은 경우

가등기담보권자인 채권자가 채무자에게 청산통지를 하였다는 사실 등을 후순위권리자에게 통지하지 아니하고, 채무자에게 청산금을 지급한 경우에는 이로써 후순위권리자에게 대항할 수 없을 뿐이지, 후순위권리자가 존재한다는 사유만으로 채무자에게 담보권의 실행을 거부할 권원을 부여하는 것은 아니다[2002다42001].

(2) 경매청구권

후순위권리자는 청산기간에 한정하여 그 피담보채권의 변제기 도래 전이라도 담보목적부동산의 경매를 청구할 수 있다(제12조 제2항).

(3) 청산금에 대한 권리행사

후순위권리자는 그 순위에 따라 채무자 등이 지급받을 청산금에 대하여 제3조 제1항에 따라 통지된 평가액의 범위에서 청산금이 지급될 때까지 그 권리를 행사할 수 있고, 채권자는 후순위권리자의 요구가 있는 경우에는 청산금을 지급하여야 한다(제5조 제1항).

(4) 청산금에 대한 처분제한

① 채무자가 청산기간이 지나기 전에 한 청산금에 관한 권리의 양도나 그 밖의 처분은 이로써 후순위권리자에게 대항하지 못한다(제7조 제1항).

② 채권자가 청산기간이 지나기 전에 청산금을 지급한 경우 또는 제6조 제1항에 따른 통지를 하지 아니하고 청산금을 지급한 경우에도 후순위권리자에게 대항하지 못한다(제7조 제2항).

Ⅲ 경매에 의한 실행(公的 實行)

1. 선택적 행사

제12조(경매의 청구) ① 담보가등기권리자는 그 선택에 따라 제3조에 따른 담보권을 실행(귀속청산)하거나 담보목적부동산의 경매를 청구할 수 있다. 이 경우 경매에 관하여는 담보가등기권리를 저당권으로 본다.

2. 우선변제권

제13조(우선변제청구권) 담보가등기를 마친 부동산에 대하여 강제경매 등이 개시된 경우에 담보가등기권리자는 다른 채권자보다 자기채권을 우선변제 받을 권리가 있다. 이 경우 그 순위에 관하여는 그 담보가등기권리를 저당권으로 보고, 그 담보가등기를 마친 때에 그 저당권의 설정등기(設定登記)가 행하여진 것으로 본다.

3. 본등기 청구제한

제14조(강제경매 등의 경우의 담보가등기) 담보가등기를 마친 부동산에 대하여 강제경매 등의 개시결정이 있는 경우에 그 경매의 신청이 청산금을 지급하기 전에 행하여진 경우(청산금이 없는 경우에는 청산기간이 지나기 전)에는 담보가등기권리자는 그 가등기에 따른 본등기를 청구할 수 없다.

4. 소제주의(掃除主義)

제15조(담보가등기권리의 소멸) 담보가등기를 마친 부동산에 대하여 강제경매 등이 행하여진 경우에는 담보가등기권리는 그 부동산의 매각에 의하여 소멸한다.

경락인이 경락허가결정을 받아 그 경락대금을 모두 지급함으로써 소유권을 취득하였다면 담보가등기권리는 소멸되었다고 보아야 할 것이고 그 후에 경료된 위 가등기에 기한 본등기는 원인을 결여한 무효의 등기가 된다[93다52853].

CHAPTER

04 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률

Ⅰ 입법목적

제1조(목적) 이 법은 부동산에 관한 소유권과 그 밖의 물권을 실체적 권리관계와 일치하도록 실권리자명의(名義)로 등기하게 함으로써 부동산등기제도를 악용한 투기 · 탈세 · 탈법행위 등 반사회적 행위를 방지하고 부동산거래의 정상화와 부동산가격의 안정을 도모하여 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

부동산에 관한 소유권과 그 밖의 물권을 실체적 권리관계와 일치하도록 실권리자명의 로 등기하게 함으로써 부동산등기제도를 악용한 투기 · 탈세 · 탈법행위 등 반사회적 행위를 방지하고 부동산거래의 정상화와 부동산가격의 안정을 도모하여 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 부동산실명법이 제정되었다.

Ⅱ 적용대상

1. 명의신탁의 경우

(1) 원칙적 무효

제4조(명의신탁약정의 효력) ① 명의신탁약정은 무효로 한다.
② 명의신탁약정에 따른 등기로 이루어진 부동산에 관한 물권변동은 무효로 한다.
③ 제1항 및 제2항의 무효는 제3자에게 대항하지 못한다.

① 부동산실명법이 규정하는 명의신탁약정 자체로 사회질서에 위반하는 경우에 해당한다고 할 수 없으므로 무효인 명의신탁약정에 기하여 타인 명의의 등기가 마쳐졌다는 이유만으로 그것이 당연히 불법원인급여에 해당한다고 볼 수 없다[2003다41722].

② 명의신탁약정과 그에 따른 등기의 무효는 제3자에게 대항하지 못한다. 여기서 '제3자'는 명의신탁약정의 당사자 및 포괄승계인 이외의 자로서 명의수탁자가 물권자임을 기초로 그와 사이에 직접 새로운 이해관계를 맺은 사람으로서 소유권 등 물권을 취득한 자뿐만 아니라 압류 또는 가압류채권자도 포함하고 그의 선의 · 악의를 묻지 않는다.

(2) 종중, 종교단체 및 배우자에 대한 특례(유효인 경우)

제8조(종중, 배우자 및 종교단체에 대한 특례) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 조세 포탈, 강제집행의 면탈(免脫) 또는 법령상 제한의 회피를 목적으로 하지 아니하는 경우에는 제4조부터 제7조까지 및 제12조 제1항부터 제3항까지를 적용하지 아니한다(명의신탁은 유효).

1. 종중(宗中)이 보유한 부동산에 관한 물권을 종중(종중과 그 대표자를 같이 표시하여 등기한 경우를 포함한다) 외의 자의 명의로 등기한 경우
2. 배우자명의로 부동산에 관한 물권을 등기한 경우
3. 종교단체의 명의로 그 산하 조직이 보유한 부동산에 관한 물권을 등기한 경우

① 법률상 배우자

배우자사이의 명의신탁으로 유효인 경우에서 배우자는 법률상의 배우자를 의미하고, 사실상의 배우자는 포함하지 아니한다.

② 사실혼배우자가 혼인한 경우

본래 명의신탁등기가 부동산실권리자명의등기에관한법률의 규정에 따라 무효로 된 경우에도 그 후 명의신탁자가 수탁자와 혼인을 함으로써 법률상의 배우자가 되고 위 법률 제8조 제2호의 특례의 예외사유(조세 포탈, 강제집행의 면탈 또는 법령상 제한의 회피를 목적으로 하지 아니하는 경우)에 해당되지 않으면 그 때부터는 위 특례가 적용되어 그 명의신탁등기가 유효로 된다[2001마1235].

③ 배우자 일방의 사망

부동산실명법 제8조 제2호에 따라 부부간 명의신탁이 일단 유효한 것으로 인정되었다면 그 후 배우자 일방의 사망으로 부부관계가 해소되었다 하더라도 그 명의신탁약정은 사망한 배우자의 다른 상속인과의 관계에서도 여전히 유효하게 존속한다[2011다99498].

④ 유효인 명의신탁의 법률관계

㉠ 대내적으로는 신탁자가 소유자이다. 따라서 신탁자는 언제든지 신탁계약을 해지하고 수탁자에 대하여 소유권이전등기를 청구할 수 있다. 이러한 소유권이전등기청구권은 물권적 청구권으로서 소멸시효에 걸리지 않는다.

㉡ 명의신탁에 의하여 부동산의 소유자로 등기된 자의 점유는 그 점유권원의 성질상 타주점유이다.

㉢ 명의신탁한 부동산을 명의신탁자가 매도하는 경우에 이를 담보책임에서의 타인의 권리의 매매 라고 할 수 없다[96다18656].

㉣ 대외적으로는 수탁자가 소유자이다. 따라서 제3자가 신탁재산을 침해하는 경우 물권적 청구권자는 수탁자이므로 신탁자는 소유권에 기하여 직접 반환청구나 방해배제청구를 할 수 없고, 수탁자를 대위하여 행사할 수 있을 뿐이다[77다1079].

㉤ 명의수탁자는 신탁 부동산을 유효하게 제3자에게 처분할 수 있고, 제3자는 선의 · 악의를 불문하고 소유권을 취득한다. 다만, 제3자가 수탁자의 배임행위에 적극 가담한 경우에는 사회질서 위반으로 무효이다.

2. 명의신탁이 아닌 경우(부동산실명법이 적용되지 않는 경우)

① 부동산의 양도담보와 가등기담보

채무의 변제를 담보하기 위하여 채권자가 부동산에 관한 물권을 이전(부동산양도담보)받거나 가등기하는 경우(가등기담보)는 명의신탁약정에 해당하지 않는다(제2조 1호 가목).

② 신탁재산

「신탁법」 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁재산인 사실을 등기한 경우도 명의신탁이 아니다(제2조 1호 다목).

③ 상호명의신탁

㉠ 의의

부동산의 위치와 면적을 특정하여 2인 이상이 구분소유하기로 하는 약정을 하고 그 구분소유자의 공유로 등기하는 경우에는 구분소유적 공유관계가 성립하여 명의신탁에 해당되지 않는다(제2조 1호 나목).

㉡ 내부관계

구분소유적 공유관계에 있어서는 당사자 내부에 있어서는 각자가 특정부분은 각자의 단독소유로 된다[93다49871]. 상호명의신탁의 지분권자는 특정부분에 한해 소유권을 취득하고 이를 배타적으로 사용 · 수익할 수 있으며, 다른 구분소유자의 방해행위에 대하여는 소유권에 터잡아 그 배제를 구할 수 있다[93다42986].

㉢ 대외관계(공유자와 제3자와의 관계)

1필지 전체에 관해 공유자로서의 권리만을 주장할 수 있으므로, 제3자의 방해행위가 있는 경우에는 각 지분권자는 자기의 구분소유부분 뿐만 아니라 전체 토지에 대해 공유물의 보존행위로서의 방해배제청구를 할 수 있다[93다42986].

㉣ 특정부분의 처분

공유자 각자는 자신의 특정 구분부분을 단독으로 처분하고 이에 해당하는 공유지분등기를 자유로이 이전할 수 있다.

㉤ 상호명의신탁(구분소유적 공유)의 해소

공유지분권을 주장하지 않고 목적물의 특정부분을 소유한다고 주장하는 자는 특정부분에 대한 명의신탁해지를 원인으로 한 지분이전등기절차의 이행만을 구하면 되고, 공유물분할청구를 할 수는 없다[2006다84171].

Ⅲ 무효인 명의신탁의 법률관계

1. 2자간 등기명의신탁(이전형 명의신탁)

① 의의

명의신탁자가 자기 소유 명의로 등기된 부동산물권을 명의수탁자의 명의로 이전해 주는 것을 말한다.

② 명의신탁자와 명의수탁자 사이의 법률관계

㉠ 신탁자는 수탁자를 상대로 소유권에 기한 등기말소를 구하거나 진정명의회복을 원인으로 하는 소유권이전등기를 구할 수 있다.

㉡ 명의신탁약정이 무효이므로 명의신탁자는 명의수탁자에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 한 소유권이전등기를 청구할 수 없다[2005다5140].

③ 명의수탁자가 수탁받은 물권을 처분한 경우의 법률관계

㉠ 제3자와의 관계

명의신탁약정과 물권변동의 무효는 제3자에게 대항하지 못하므로 제3자는 선의, 악의를 불문하고 유효하게 권리를 취득한다(제4조 제3항).

㉡ 명의신탁자와 명의수탁자간의 법률관계

명의신탁자는 명의신탁부동산의 처분을 이유로 명의수탁자에게 손해배상 등을 청구할 수 있다[2008다1132].

㉢ 양자간 등기명의신탁에서 명의수탁자가 신탁부동산을 처분하여 제3취득자가 유효하게 소유권을 취득하고 이로써 명의신탁자가 신탁부동산에 대한 소유권을 상실한 후에 명의수탁자가 우연히 신탁부동산의 소유권을 다시 취득하였다고 하더라도 명의신탁자의 소유권에 기한 물권적 청구권인 말소등기청구권이나 진정명의회복을 원인으로 한 이전등기청구권도 더 이상 인정되지 않는다[2010다89814].

④ 벌칙

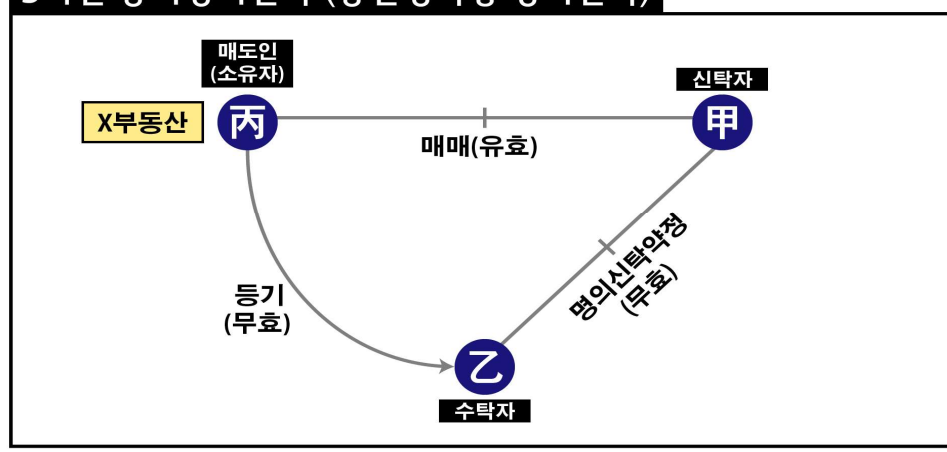
명의신탁자는 과징금처분과 형벌을 받게 되고(제5조 제1항, 제7조 제1항), 명의수탁자는 형벌을 받게 된다(제7조 제2항).

2. 3자간 등기명의신탁(중간생략등기형 명의신탁)

① 의의

명의신탁자 甲이 제3자 丙과 매매 등 물권이전을 위한 계약을 체결한 후에 명의신탁약정을 맺은 명의수탁자 乙명의로 직접 이전등기를 하는 경우이다.

3자간 등기명의신탁 (중간생략형 명의신탁)



② 신탁자 · 수탁자 · 매도인 사이의 법률관계

㉠ 명의신탁약정 무효

명의신탁자와 명의수탁자간의 명의신탁약정은 무효이고 매도인(양도인)으로부터 명의수탁자 앞으로의 등기에 의한 물권변동도 무효이다(제4조). 따라서 부동산의 소유자는 원래의 매도인(양도인)이다.

㉡ 매도인(丙)과 명의신탁자(甲)간의 법률관계

매도인(丙)과 명의신탁자(甲) 사이의 매매계약은 여전히 유효하므로 명의신탁자(甲)는 매도인(丙)에 대하여 매매계약에 기한 소유권이전등기를 청구할 수 있고[99다21738], 매도인(丙)은 신탁자(甲)에 대하여 소유권이전등기의무가 있다. 만일 목적 부동산을 명의신탁자(甲)가 인도받아 점유하고 있다면, 명의신탁자(甲)의 매도인(丙)에 대한 소유권이전등기청구권은 소멸시효가 진행하지 않는다[2013다26647].

㉢ 매도인(丙)과 명의수탁자간(乙)의 법률관계

물권변동이 무효이므로 소유권 등 물권은 원래의 소유자 (丙)에게 있다. 매도인(丙)은 소유권에 기한 방해배제청구로 수탁자(乙)에게 등기말소를 청구할 수 있고, 진정한 등기명의의 회복을 위한 소유권이전등기를 청구할 수도 있다.

㉣ 명의신탁자(甲)와 명의수탁자(乙)간의 법률관계

ⓐ 명의신탁자(甲)와 명의수탁자(乙)간의 명의신탁약정은 무효이고, 신탁된 부동산물권에 관해 명의수탁자(乙)는 대내적으로뿐만 아니라 대외적으로도 무권리자이다.

ⓑ 명의신탁자(甲)는 명의수탁자(乙)를 상대로 부당이득반환을 원인으로 한 소유권이전등기를 구할 수 없다[2008다55290]. 또한 명의신탁자(甲)는 소유자가 아니므로 명의수탁자(乙)에 대하여 등기의 말소를 구할 수도 없다.

ⓒ 다만, 명의신탁자(甲)는 매도인(丙)를 대위하여 명의수탁자(乙)에게 무효인 수탁자 명의등기의 말소를 구할 수 있다[2001다61654].

ⓓ 명의수탁자(乙)가 명의신탁자(甲) 앞으로 소유권이전등기를 경료해 주었다면 그 등기는 실체관계에 부합하여 유효하다[2004다6764].

③ 명의수탁자가 제3자(丁)에게 처분한 경우

㉠ 명의수탁자(乙)가 신탁부동산을 임의로 제3자(丁)에게 매각처분한 경우에 특별한 사정이 없는 한 그 매수인(丁)은 선의 · 악의를 불문하고 유효하게 소유권을 취득한다[2001다61654].

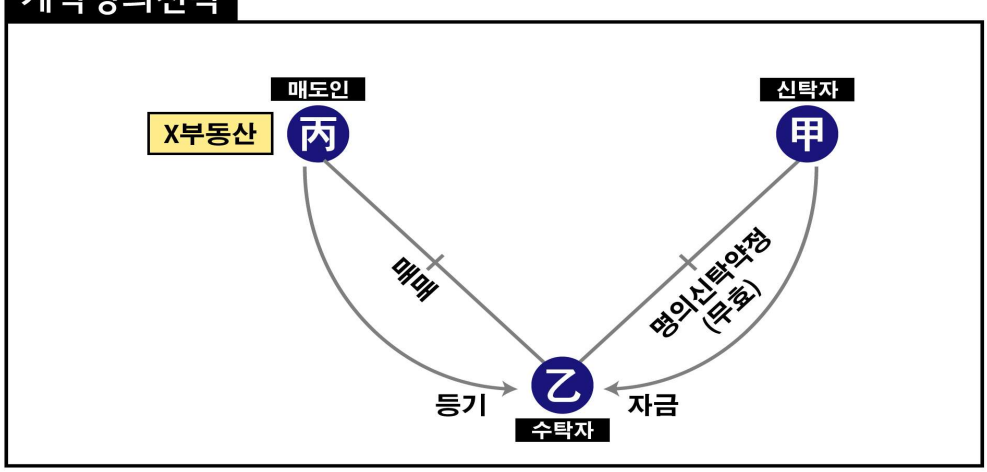
㉡ 명의수탁자(乙)가 신탁부동산을 제3자(丁)에게 처분한 경우, 특별한 사정이 없는 한 제3취득자(丁)는 유효하게 소유권을 취득하므로 그 결과 명의수탁자(乙)는 신탁부동산의 처분대금이나 보상금을 취득하는 이익을 얻게 되므로, 명의수탁자(乙)는 명의신탁자(甲)에게 그 이익을 부당이득으로 반환할 의무가 있다[2009다49193, 49209].

㉢ 그러나 매도인(丙)으로서는 명의수탁자가 부동산을 처분하였다 하더라도, 명의신탁자에 대하여 신의칙 내지 민법 제536조 제1항 본문(동시이행의 항변권) 규정에 의하여 매매대금 반환채무의 이행을 거절할 수 있으므로, 결국 매도인(丙)으로서는 명의수탁자의 처분행위로 인하여 손해를 입은 바가 없어 수탁자(乙)에 대한 매도인(丙)의 손해배상청구도 허용되지 아니한다[2001다61654].

3. 계약명의신탁(위임형 명의신탁)

① **의의** : 명의신탁자 甲과 명의수탁자 乙이 명의신탁자 甲이 명의수탁자 乙에게 매수자금을 제공하고 등기를 乙명의로 하기로 하는 명의신탁약정을 체결하고, 명의수탁자 乙이 매수인이 되어 매도인 丙과 매매계약을 체결한 후 명의수탁자 乙명의로 소유권이전등기를 하는 경우를 말한다.

계약명의신탁



② 매도인(丙)이 선의인 경우의 법률관계

㉠ 매도인(丙)과 명의신탁자(甲)간의 법률관계

아무런 법률관계가 존재하지 않는다.

㉡ 매도인(丙)과 명의수탁자(乙)간의 법률관계

수탁자와 명의신탁약정이 있다는 사실을 알지 못하는 소유자와 사이에 체결된 매매계약은 유효이므로 수탁자(乙)는 전소유자인 매도인뿐만 아니라 신탁자에 대한 관계에서도 유효하게 당해 부동산의 소유권을 취득한 것으로 보아야 한다[98도4347].

㉢ 명의신탁자(甲)와 명의수탁자(乙)간의 법률관계

ⓐ 명의신탁약정은 무효이고, 명의신탁자(甲)는 목적물의 물권자가 아니므로 물권적 청구권을 행사할 수 없고, 명의신탁자(甲)는 명의수탁자(乙)에 대하여 불법행위를 원인으로 한 손해배상청구 등도 할 수 없다[2001도2722].

ⓑ 다만, 명의신탁자(甲)는 명의수탁자(乙)에 대하여 부당이득반환을 청구할 수 있을 뿐이다. 부당이득반환 대상으로 부동산실명법 실행 이전의 계약명의신탁의 경우에는 '당해 부동산'을 부당이득으로 반환할 의무가 있으나 부동산실명법 실행 이후 계약명의신탁의 경우에는 명의수탁자(乙)에게 제공한 매수자금이다[2008다34828].

ⓒ 만일 명의수탁자(乙)가 소유권이전등기를 위하여 지출하여야 할 취득세, 등록세 등을 명의신탁자(甲)로부터 제공받았다면, 당해 부동산의 매매대금 상당액 이외에 명의신탁자(甲)가 명의수탁자(乙)에게 지급한 취득세, 등록세 등의 취득비용도 특별한 사정이 없는 한 명의신탁자(甲)에게 부당이득으로 반환하여야 한다[2007다90432].

ⓓ 명의신탁자(甲)가 명의수탁자(乙)에 대하여 가지는 매매대금 상당의 부당이득반환 청구권에 기하여 유치권을 행사할 수 없다[2008다34828].

㉣ 매수대금의 실질적 부담자(명의신탁자 甲)의 지시에 따라 부동산의 소유명의를 이전하거나 그 처분대금을 반환하기로 약정하여도 이는 무효인 명의신탁약정을 전제로 하는 것이어서 역시 무효이다[2014다63315].

㉤ 매수대금을 부담한 명의신탁자(甲)와 매수인 명의를 빌려준 명의수탁자(乙) 및 제3자(丁) 사이의 새로운 명의신탁약정에 의하여 명의수탁자(乙)가 다시 명의신탁자(甲)가 지정하는 제3자(丁) 앞으로 소유권이전등기를 마쳐 주었다면, 제3자(丁)명의의 소유권이전등기는 무효이다[2006다73102].

㉥ 다만, 명의수탁자(乙)의 완전한 소유권 취득을 전제로 하여 사후적으로 명의신탁자(甲)와의 사이에 위에서 본 매수자금반환의무의 이행에 갈음하여 명의신탁된 부동산 자체를 양도하기로 합의하고 그에 기하여 명의신탁자(甲) 앞으로 소유권이전등기를 마쳐준 경우에는 그 소유권이전등기는 새로운 소유권 이전의 원인인 대물급부의 약정에 기한 것이므로 특별한 사정이 없는 한 유효하다[2014다30483].

③ 매도인(丙)이 악의인 경우의 법률관계

㉠ 매도인(丙)이 명의신탁을 알고 있었다면 매도인(丙)과 명의수탁자(乙) 사이의 매매계약은 무효가 되고, 명의수탁자(乙)에로의 물권변동은 무효로 된다. 따라서 부동산의 소유권은 매도인(丙)에게 귀속된다.

㉡ 따라서 매도인(丙)은 수탁자(乙)에게 소유권이전등기의 말소를 청구할 수 있고, 명의수탁자는 매도인에게 지급한 매매대금의 반환을 청구할 수 있다.

㉢ 한편, 신탁자(甲)는 수탁자(乙)에게 소유권이전등기를 청구할 수 없고, 매도인(丙)과의 사이도 아무런 법률관계가 없으므로 매도인(丙)에게 소유권이전등기를 청구할 수도 없다.

㉣ 만약 명의수탁자(乙)과 명의신탁 사실을 아는 매도인(丙)이 매매계약에 따른 법률효과를 직접 명의신탁자(甲)에게 귀속시킬 의도로 계약을 체결한 사정이 인정된다면, 甲과 乙의 명의신탁은 3자간 등기명의신탁으로 보아야 한다[2010다52799].

④ 경매에서의 계약명의신탁

㉠ 부동산경매절차에서 부동산을 매수하려는 사람이 매수대금을 자신이 부담하면서 타인의 명의로 매각허가결정을 받기로 함에 따라 그 타인이 경매절차에 참가하여 매각허가가 이루어진 경우에도 매도인의 선의인 계약명의신탁과 동일하다.

㉡ 즉, 그 경매절차의 매수인은 어디까지나 그 명의인(乙)이므로 경매목적부동산의 소유권은 그 명의인(乙)이 취득한다 할 것이고, 이 경우 매수대금을 부담한 사람과 이름을 빌려 준 사람 사이에는 명의신탁관계가 성립한다.

㉢ 다만, 경매절차에서의 소유자(丙)가 위와 같은 명의신탁약정 사실을 알고 있었더라도 수탁자(乙)가 소유권을 취득한다[2012다69197].

CHAPTER

05 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률

제 1 절 서 설

1. 의 의

1동의 건물을 구분하여 그 부분을 각각 별개로 소유하는 것을 말하며 건물의 구분된 부분은 독립한 소유권의 객체로 된다.

2. 입법목적

토지이용의 고도화, 입체화라는 사회적 요청 때문에 대규모의 공동주택, 특히 아파트가 일반화 되고 그 결과 민법 제215조만에 의해서는 공동주거에 따른 복잡한 법률관계를 합리적으로 규율할 수 없게 되자 1984년 집합건물법이 제정되어 민법 제215조는 그 존재의의를 상당부분 상실했다.

제 2 절 구분소유의 요건

1. 의 의

① 1동의 건물 중 구조상 구분된 여러 개의 부분이 독립한 건물로서 사용될 수 있을 때에는 그 각 부분은 이 법에서 정하는 바에 따라 각각 소유권의 목적으로 할 수 있으며(제1조), 이러한 전유부분인 건물부분을 목적으로 하는 소유권을 '구분소유권'이라 한다(제2조 제1호)

② 구분소유가 성립하기 위하여는 건물부분이 '구조상 · 이용상 독립성'을 갖추어야 하고, 건물의 특정부분을 구분하여 별개의 소유권의 객체로 하려는 소유자의 '구분행위'가 있어야 한다.

2. 구조상 · 이용상 독립성

① 1동의 건물에 대하여 구분소유가 성립하기 위해서는 객관적 · 물리적인 측면에서 1동의 건물이 존재하고, 구분된 건물부분이 구조상 · 이용상 독립성을 갖추어야 한다[2010다71578전합].

② 이용상 독립성이란 구분소유권의 대상이 되는 해당 건물부분이 그 자체만으로 독립하여 하나의 건물로서의 기능과 효용을 갖춘 것을 말한다.

③ 구분소유의 목적이 될 수 있는 구조상 및 이용상의 독립성을 갖추지 못한 건물의 일부에 구분소유권의 목적으로 등기되어 있었다 하더라도 그 자체로 무효이므로 이를 기초하여 경매절차가 진행되어 매각허가를 받고 매수대금을 납부하였다 하여도 매수인은 그 소유권을 취득할 수 없다[92다3151, 2009마1449].

3. 구분행위

① 구분행위는 건물의 물리적 형질에 변경을 가함이 없이 법률관념상 건물의 특정부분을 구분하여 별개의 소유권의 객체로 하려는 일종의 법률행위로서, 그 시기나 방식에 특별한 제한이 있는 것은 아니고 처분권자의 구분의사가 객관적으로 외부에 표시되면 인정된다[2010다71578전합].

② 구조상 및 이용상의 독립성을 갖추고 있더라도 소유자가 구분건물로 등기하지 않고 1동의 건물을 객체로 등기를 한 때에는 구분소유권이 성립하지 않는다.

4. 등기나 등록 여부 불문

구분건물이 물리적으로 완성되기 전에도 건축허가신청이나 분양계약 등을 통하여 장래 신축되는 건물을 구분건물로 하겠다는 구분의사가 객관적으로 표시되면 구분행위의 존재를 인정할 수 있고, 이후 1동의 건물 및 그 구분행위에 상응하는 구분건물이 객관적 · 물리적으로 완성되면 아직 그 건물이 집합건축물대장에 등록되거나 구분건물로서 등기부에 등기되지 않았더라도 그 시점에서 구분소유가 성립한다[2010다71578전합].

제 3 절 집합건물의 구성요소

1. 전유부분(專有部分)

'전유부분'이란 구분소유권의 목적인 건물부분을 말하고, 전유부분에 대한 구분소유권을 가지는 자를 '구분소유자'라 한다(제2조 제2호, 3호).

2. 공용부분(共用部分)

(1) 의 의

'공용부분'이란 전유부분 외의 건물부분(계단, 복도 등), 전유부분에 속하지 아니하는 건물의 부속물(승강기, 수도 · 가스 · 전기 · 소방설비, 수도탱크 등) 및 제3조 제2항 및 제3항에 따라 공용부분으로 된 부속의 건물을 말하고(제2조 제4호), 이는 구분소유권의 목적으로 할 수 없다(제3조 제1항).

(2) 공용부분의 종류

① 법정(구조상)공용부분

㉠ 여러 개의 전유부분으로 통하는 복도, 계단, 그 밖에 구조상 구분소유자 전원 또는 일부의 공용(共用)에 제공되는 건물부분을 말한다(제3조 제1항).

㉡ 법정(구조상)공용부분은 등기대상이 아니다.

② 규약상 공용부분

㉠ 전유부분과 구분점포인 건물부분과 부속의 건물은 규약 또는 공정증서로써 공용부분으로 정할 수 있다(제3조 제2항 제3항).

㉡ 규약상 공용부분은 공용부분이라는 취지를 등기(표제부만 둔다)하여야 한다(제3조 제4항).

3. 대지(垈地)

① 법정대지

> **제2조(정의)** 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
> 5. "건물의 대지"란 전유부분이 속하는 1동의 건물이 있는 토지 및 제4조에 따라 건물의 대지로 된 토지를 말한다.

'건물의 대지'라 함은 전유부분이 속하는 1동의 건물이 소재하는 토지를 말한다(제2조 제5호).

② 규약대지

> **제4조(규약에 따른 건물의 대지)** ① 통로, 주차장, 정원, 부속건물의 대지, 그 밖에 전유부분이 속하는 1동의 건물 및 그 건물이 있는 토지와 하나로 관리되거나 사용되는 토지는 규약으로써 건물의 대지로 할 수 있다.

③ 대지공유자의 분할청구금지

> **제8조(대지공유자의 분할청구 금지)** 대지 위에 구분소유권의 목적인 건물이 속하는 1동의 건물이 있을 때에는 그 대지의 공유자는 그 건물 사용에 필요한 범위의 대지에 대하여는 분할을 청구하지 못한다.

4. 대지사용권

(1) 의 의

> **제2조(정의)** 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
> 6. "대지사용권"이란 구분소유자가 전유부분을 소유하기 위하여 건물의 대지에 대하여 가지는 권리를 말한다.

(2) 전유부분과 대지사용권의 일체성

제20조(전유부분과 대지사용권의 일체성) ① 구분소유자의 대지사용권은 그가 가지는 전유부분의 처분에 따른다.

② 구분소유자는 그가 가지는 (다른규약이 없는한) 전유부분과 분리하여 대지사용권을 처분할 수 없다. 다만, 규약으로써 달리 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제2항 본문의 분리처분금지는 그 취지를 등기(대지권 등기)하지 아니하면 선의(善意)로 물권을 취득한 제3자에게 대항하지 못한다.

따라서 전유부분만에 관하여 설정된 저당권이나 가압류의 효력은, 특별한 사정이 없는 한, 당연히 종물 내지 종된 권리인 그 대지사용권에까지 미치고([2001다22604]), 그에 터잡아 진행된 경매절차에서 전유부분을 경락받은 자는 그 대지사용권도 함께 취득한다[2005다15048].

(4) 민법 제267조의 적용배제

제22조(「민법」 제267조의 적용 배제) 제20조 제2항 본문의 경우 대지사용권에 대하여는 「민법」 제267조(같은 법 제278조에서 준용하는 경우를 포함한다)를 적용하지 아니한다.

민법 제267조(지분포기 등의 경우의 귀속) 공유자가 그 지분을 포기하거나 상속인없이 사망한 때에는 그 지분은 다른 공유자에게 각 지분의 비율로 귀속한다.

제 4 절 공용부분

1. 공용부분 결정기준

건물의 어느 부분이 구분소유자의 전원 또는 일부의 공용에 제공되는지는 소유자들 사이에 특단의 합의가 없는 한 건물의 구조에 따른 객관적인 용도에 의하여 결정된다. 따라서 구분건물에 관하여 구분소유가 성립될 당시 객관적인 용도가 공용부분인 건물부분을 나중에 임의로 개조하는 등으로 이용 상황을 변경하거나 집합건축물대장에 전유부분으로 등록하고 소유권보존등기를 하였더라도 그로써 공용부분이 전유부분이 되어 어느 구분소유자의 전속적인 소유권의 객체가 되지는 않는다[2015다77212].

2. 공용부분의 귀속 및 사용권

제10조(공용부분의 귀속 등) ① 공용부분은 구분소유자 전원의 공유에 속한다. 다만, 일부의 구분소유자만이 공용하도록 제공되는 것임이 명백한 공용부분(이하 "일부공용부분"이라 한다)은 그들 구분소유자의 공유에 속한다.
제11조(공유자의 사용권) 각 공유자는 공용부분을 그 용도에 따라 사용할 수 있다.

① 공용부분을 무단점유 · 사용한 구분소유자는 특별한 사정이 없는 한 해당 공용부분을 점유 · 사용함으로써 얻은 이익을 다른 구분소유자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다.

② 그러나 다른 구분소유자는 공용부분을 독점적으로 무단점유 · 사용하는 구분소유자에게 공용부분의 보존행위로서 그 인도를 청구할 수 없다.

3. 공용부분의 지분(持分)

(1) 공유자의 지분권

제12조(공유자의 지분권) ① 각 공유자의 지분은 그가 가지는 전유부분의 면적 비율에 따른다.

(2) 전유부분과 공용부분에 대한 지분의 일체성

제13조(전유부분과 공용부분에 대한 지분의 일체성) ① 공용부분에 대한 공유자의 지분은 그가 가지는 전유부분의 처분에 따른다.
② 공유자는 그가 가지는 전유부분과 분리하여 공용부분에 대한 지분을 처분할 수 없다.
③ 공용부분에 관한 물권의 득실변경(得失變更)은 등기가 필요하지 아니하다.

4. 공용부분의 보존 · 관리 및 변경

① 공용부분의 보존행위

제16조(공용부분의 관리) ① 다만, 보존행위는 각 공유자가 할 수 있다.

② 공용부분의 관리행위

제16조(공용부분의 관리) ① 공용부분의 관리에 관한 사항은 제15조 제1항 본문 및 제15조의 2의 경우를 제외하고는 제38조 제1항에 따른 통상의 집회결의로써 결정한다.

③ 공용부분의 변경

제15조(공용부분의 변경) ① 공용부분의 변경에 관한 사항은 관리단집회에서 구분소유자의 3분의 2 이상 및 의결권의 3분의 2 이상의 결의로써 결정한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제38조 제1항에 따른 통상의 집회결의로써 결정할 수 있다.

1. 공용부분의 개량을 위한 것으로서 지나치게 많은 비용이 드는 것이 아닐 경우
2. 「관광진흥법」 제3조 제1항 제2호 나목에 따른 휴양 콘도미니엄업의 운영을 위한 휴양 콘도미니엄의 공용부분변경에 관한 사항인 경우

② 제1항의 경우에 공용부분의 변경이 다른 구분소유자의 권리에 특별한 영향을 미칠 때에는 그 구분소유자의 승낙을 받아야 한다.

제15조의2(권리변동 있는 공용부분의 변경) ① 제15조에도 불구하고 건물의 노후화 억제 또는 기능 향상 등을 위한 것으로 구분소유권 및 대지사용권의 범위나 내용에 변동을 일으키는 공용부분의 변경에 관한 사항은 관리단집회에서 구분소유자의 5분의 4 이상 및 의결권의 5분의 4 이상의 결의로써 결정한다.

5. 공용부분의 부담 · 수익

제17조(공용부분의 부담 · 수익) 각 공유자는 규약에 달리 정한 바가 없으면 그 지분의 비율에 따라 공용부분의 관리비용과 그 밖의 의무를 부담하며 공용부분에서 생기는 이익을 취득한다.

제18조(공용부분에 관하여 발생한 채권의 효력) 공유자가 공용부분에 관하여 다른 공유자에 대하여 가지는 채권은 그 특별승계인에 대하여도 행사할 수 있다.

① **관리비청구** : 관리단은 관리비징수에 관한 유효한 관리단규약 등이 존재하지 않더라도, 공용부분에 대한 관리비는 이를 그 부담의무자인 구분소유자에 대하여 청구할 수 있다[2009다22266,22273].

② **공용부분의 체납관리비** : 아파트의 특별승계인은 前입주자의 체납관리비 중 공용부분에 관하여는 이를 승계하여야 한다[2001다8677全合]. 그러나 전유부분에 관한 체납관리비는 승계하지 아니한다.

③ **연체료** : 관리비납부를 연체할 경우 부과되는 연체료는 위약벌의 일종으로서 공용부분관리비에 대한 연체료는 특별승계인에게 승계되는 공용부분관리비에 포함되지 않는다[2004다3598,3604].

④ **중첩적 채무인수** : 구분소유권이 순차로 양도된 경우 각 특별승계인들은 이전 구분소유권자들의 채무를 중첩적으로 인수한다고 봄이 상당하므로, 현재 구분소유권을 보유하고 있는 특별승계인뿐만 아니라 그 이전의 구분소유자들도 공용부분에 관한 종전 구분소유자들의 체납관리비채무를 부담한다[2006다50420].

6. 수선적립금

제17조의2(수선적립금) ① 제23조에 따른 관리단(이하 "관리단"이라 한다)은 규약에 달리 정한 바가 없으면 관리단집회 결의에 따라 건물이나 대지 또는 부속시설의 교체 및 보수에 관한 수선계획을 수립할 수 있다.

② 관리단은 규약에 달리 정한 바가 없으면 관리단집회의 결의에 따라 수선적립금을 징수하여 적립할 수 있다. 다만, 다른 법률에 따라 장기수선을 위한 계획이 수립되어 충당금 또는 적립금이 징수 · 적립된 경우에는 그러하지 아니하다.

7. 건물의 설치 · 보존상의 흠

제6조(건물의 설치 · 보존상의 흠 추정) 전유부분이 속하는 1동의 건물의 설치 또는 보존의 흠으로 인하여 다른 자에게 손해를 입힌 경우에는 그 흠은 공용부분에 존재하는 것으로 추정한다.

제 5 절 구분소유자의 의무와 책임

1. 구분소유자의 의무

제5조(구분소유자의 권리 · 의무 등) ① 구분소유자는 건물의 보존에 해로운 행위나 그 밖에 건물의 관리 및 사용에 관하여 구분소유자 공동의 이익에 어긋나는 행위를 하여서는 아니 된다(공동이익침해금지).

② 전유부분이 주거의 용도로 분양된 것인 경우에는 구분소유자는 정당한 사유 없이 그 부분을 주거 외의 용도로 사용하거나(용도외 사용금지) 그 내부 벽을 철거하거나 파손하여 증축 · 개축하는 행위를 하여서는 아니 된다(불법증개축 금지).

2. 의무위반자에 대한 조치

① 행위의 정지청구 등

제43조(공동의 이익에 어긋나는 행위의 정지청구 등) ① 구분소유자가 제5조 제1항의 행위를 한 경우 또는 그 행위를 할 우려가 있는 경우에는 관리인 또는 관리단집회의 결의로 지정된 구분소유자는 구분소유자 공동의 이익을 위하여 그 행위를 정지하거나 그 행위의 결과를 제거하거나 그 행위의 예방에 필요한 조치를 할 것을 청구할 수 있다.

② 제1항에 따른 소송의 제기는 관리단집회의 결의(과반수 결의)가 있어야 한다.

③ 점유자가 제5조 제4항에서 준용하는 같은 조 제1항에 규정된 행위를 한 경우 또는 그 행위를 할 우려가 있는 경우에도 제1항과 제2항을 준용한다.

이러한 행위정지의 청구는 재판외 또는 재판상으로 할 수 있다. 다만, 소송을 제기하기 위해서는 관리단집회의 결의(보통결의)가 있어야 한다.

② 사용금지의 청구

제44조(사용금지의 청구) ① 제43조 제1항의 경우에 제5조 제1항에 규정된 행위로 구분소유자의 공동생활상의 장해가 현저하여 제43조 제1항에 규정된 청구로는 그 장해를 제거하여 공용부분의 이용 확보나 구분소유자의 공동생활 유지를 도모함이 매우 곤란할 때에는 관리인 또는 관리단집회의 결의로 지정된 구분소유자는 관리단집회의 결의에 근거하여 소(訴)로써 적당한 기간 동안 해당 구분소유자의 전유부분 사용금지를 청구할 수 있다.
② 제1항의 결의는 구분소유자의 4분의 3 이상 및 의결권의 4분의 3 이상으로 결정한다.
③ 제1항의 결의를 할 때에는 미리 해당 구분소유자에게 변명할 기회를 주어야 한다.

③ 구분소유권의 경매

제45조(구분소유권의 경매) ① 구분소유자가 제5조 제1항 및 제2항을 위반하거나 규약에서 정한 의무를 현저히 위반한 결과 공동생활을 유지하기 매우 곤란하게 된 경우에는 관리인 또는 관리단집회의 결의로 지정된 구분소유자는 해당 구분소유자의 전유부분 및 대지사용권의 경매를 명할 것을 법원에 청구할 수 있다.
② 제1항의 청구는 구분소유자의 4분의 3 이상 및 의결권의 4분의 3 이상의 관리단집회 결의가 있어야 한다.
③ 제2항의 결의를 할 때에는 미리 해당 구분소유자에게 변명할 기회를 주어야 한다.
④ 제1항의 청구에 따라 경매를 명한 재판이 확정되었을 때에는 그 청구를 한 자는 경매를 신청할 수 있다. 다만, 그 재판확정일부터 6개월이 지나면 그러하지 아니하다.
⑤ 제1항의 해당 구분소유자는 제4항 본문의 신청에 의한 경매에서 경락인이 되지 못한다.

제 6 절 담보책임

1. 의 의

제9조(담보책임) ① 제1조 또는 제1조의2의 건물을 건축하여 분양한 자(이하 "분양자"라 한다)와 분양자와의 계약에 따라 건물을 건축한 자로서 대통령령으로 정하는 자(이하 "시공자"라 한다)는 구분소유자에 대하여 담보책임을 진다. 이 경우 그 담보책임에 관하여는 「민법」 제667조 및 제668조를 준용한다.

2. 하자담보책임의 부담자

제9조(담보책임) ① 제1조 또는 제1조의2의 건물을 건축하여 분양한 자(이하 "분양자"라 한다)와 분양자와의 계약에 따라 건물을 건축한 자로서 대통령령으로 정하는 자(이하 "시공자"라 한다)는 구분소유자에 대하여 담보책임을 진다.

3. 하자담보추급권자

① 집합건물법 제9조에 의한 하자담보추급권은 집합건물의 수분양자가 집합건물을 양도한 경우 특별한 사정이 없는 한 현재 구분소유자에게 귀속한다[2001다47733].

② 입주자대표회의나 관리단은 구분소유자들에게서 그 권리를 양수하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 하자담보추급권을 가진다고 할 수 없다[2011다80531].

4. 담보책임의 존속기간

① 제척기간

제9조의2(담보책임의 존속기간) ① 제9조에 따른 담보책임에 관한 구분소유자의 권리는 다음 각 호의 기간 내에 행사하여야 한다.

1. 「건축법」 제2조 제1항 제7호에 따른 건물의 주요구조부 및 지반공사의 하자 : 10년
2. 제1호에 규정된 하자 외의 하자 : 하자의 중대성, 내구연한, 교체가능성 등을 고려하여 5년의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간

② 기산점

제9조의2(담보책임의 존속기간) ② 제1항의 기간은 다음 각 호의 날부터 기산한다.

1. 전유부분 : 구분소유자에게 인도한 날
2. 공용부분 : 「주택법」 제29조에 따른 사용검사일(집합건물 전부에 대하여 임시 사용승인을 받은 경우에는 그 임시 사용승인일을 말하고, 「주택법」 제29조 제1항 단서에 따라 분할 사용검사나 동별 사용검사를 받은 경우에는 분할 사용검사일 또는 동별 사용검사일을 말한다) 또는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인일

㉠ 하자담보책임기간은 재판상 또는 재판 외의 권리행사기간인 제척기간에 해당한다[2009다82060].

㉡ 임대 후 분양전환된 집합건물의 경우에도 분양전환 시점이 아닌 임대에 의하여 집합건물을 인도받은 시점부터 하자담보책임의 제척기간이 진행한다고 할 것이다[2011다66610].

제 7 절 관리단 및 관리단의 기관

1. 관리단(管理團)

① 관리단의 당연설립

> **제23조(관리단의 당연 설립 등)** ① 건물에 대하여 구분소유관계가 성립되면 구분소유자 전원을 구성원으로 하여 건물과 그 대지 및 부속시설의 관리에 관한 사업의 시행을 목적으로 하는 관리단이 설립된다.

수분양자로서 분양대금을 완납하였음에도 분양자측의 사정으로 소유권이전등기를 경료받지 못한 수분양자도 구분소유자에 준하는 것으로 보아 관리단의 구성원이 되어 의결권을 행사할 수 있다[2004마515].

② 관리단의 의무

> **제23조의2(관리단의 의무)** 관리단은 건물의 관리 및 사용에 관한 공동이익을 위하여 필요한 구분소유자의 권리와 의무를 선량한 관리자의 주의로 행사하거나 이행하여야 한다.

③ 관리단의 채무에 대한 구분소유자의 책임

> **제27조(관리단의 채무에 대한 구분소유자의 책임)** ① 관리단이 그의 재산으로 채무를 전부 변제할 수 없는 경우에는 구분소유자는 제12조의 지분비율에 따라 관리단의 채무를 변제할 책임을 진다. 다만, 규약으로써 그 부담비율을 달리 정할 수 있다.

2. 관리인(管理人)

① 관리인의 선임 · 해임

> **제24조(관리인의 선임 등)** ① 구분소유자가 10인 이상일 때에는 관리단을 대표하고 관리단의 사무를 집행할 관리인을 선임하여야 한다.
> ② 관리인은 구분소유자일 필요가 없으며, 그 임기는 2년의 범위에서 규약으로 정한다.
> ③ 관리인은 관리단집회의 결의로 선임되거나 해임된다. 다만, 규약으로 제26조의2에 따른 관리위원회의 결의로 선임되거나 해임되도록 정한 경우에는 그에 따른다.
> ④ 관리인에게 부정한 행위나 그 밖에 그 직무를 수행하기에 적합하지 아니한 사정이 있을 때에는 각 구분소유자는 관리인의 해임을 법원에 청구할 수 있다.

② 임시관리인

제24조의2(임시관리인의 선임 등) ① 구분소유자, 그의 승낙을 받아 전유부분을 점유하는 자, 분양자 등 이해관계인은 제24조제3항에 따라 선임된 관리인이 없는 경우에는 법원에 임시관리인의 선임을 청구할 수 있다.

② 임시관리인은 선임된 날부터 6개월 이내에 제24조제3항에 따른 관리인 선임을 위하여 관리단집회 또는 관리위원회를 소집하여야 한다.

③ 임시관리인의 임기는 선임된 날부터 제24조제3항에 따라 관리인이 선임될 때까지로 하되, 같은 조 제2항에 따라 규약으로 정한 임기를 초과할 수 없다.

③ 관리인의 권한과 의무

제25조(관리인의 권한과 의무) ① 관리인은 다음 각 호의 행위를 할 권한과 의무를 가진다.

1. 공용부분의 보존행위

   1의2. 공용부분의 관리 및 변경에 관한 관리단집회 결의를 집행하는 행위

2. 공용부분의 관리비용 등 관리단의 사무 집행을 위한 비용과 분담금을 각 구분소유자에게 청구 · 수령하는 행위 및 그 금원을 관리하는 행위

3. 관리단의 사업 시행과 관련하여 관리단을 대표하여 하는 재판상 또는 재판 외의 행위

   3의2. 소음 · 진동 · 악취 등을 유발하여 공동생활의 평온을 해치는 행위의 중지 요청 또는 분쟁 조정절차 권고 등 필요한 조치를 하는 행위

4. 그 밖에 규약에 정하여진 행위

② 관리인의 대표권은 제한할 수 있다. 다만, 이로써 선의의 제3자에게 대항할 수 없다.

④ 관리인의 보고의무 등

제26조(관리인의 보고의무 등) ① 관리인은 대통령령으로 정하는 바에 따라 매년 1회 이상 구분소유자 및 그의 승낙을 받아 전유부분을 점유하는 자에게 그 사무에 관한 보고를 하여야 한다.

⑤ 회계감사

제26조의2(회계감사) ① 전유부분이 150개 이상으로서 대통령령으로 정하는 건물의 관리인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 감사인(이하 이 조에서 "감사인"이라 한다)의 회계감사를 매년 1회 이상 받아야 한다. 다만, 관리단집회에서 구분소유자의 3분의 2 이상 및 의결권의 3분의 2 이상이 회계감사를 받지 아니하기로 결의한 연도에는 그러하지 아니하다.

3. 관리위원회(管理委員會)

① 관리위원회의 설치 및 기능

제26조의3(관리위원회의 설치 및 기능) ① 관리단에는 규약으로 정하는 바에 따라 관리위원회를 둘 수 있다.
② 관리위원회는 이 법 또는 규약으로 정한 관리인의 사무 집행을 감독한다.
③ 제1항에 따라 관리위원회를 둔 경우 관리인은 보존행위 등의 행위를 하려면 관리위원회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 규약으로 달리 정한 사항은 그러하지 아니하다.

② 관리위원회의 구성 및 운영

제26조의4(관리위원회의 구성 및 운영) ① 관리위원회의 위원은 구분소유자 중에서 관리단집회의 결의에 의하여 선출한다. 다만, 규약으로 관리단집회의 결의에 관하여 달리 정한 경우에는 그에 따른다.
② 관리인은 규약에 달리 정한 바가 없으면 관리위원회의 위원이 될 수 없다.
③ 관리위원회 위원의 임기는 2년의 범위에서 규약으로 정한다.

제 8 절 규약 및 집회

1. 규약(規約)

(1) 규약의 설정 · 변경 · 폐지

제29조(규약의 설정 · 변경 · 폐지) ① 규약의 설정 · 변경 및 폐지는 관리단집회에서 구분소유자의 4분의 3 이상 및 의결권의 4분의 3 이상의 찬성을 얻어서 한다.

(2) 규약의 보관 및 열람

제30조(규약의 보관 및 열람) ① 규약은 관리인 또는 구분소유자나 그 대리인으로서 건물을 사용하고 있는 자 중 1인이 보관하여야 한다.
② 제1항에 따라 규약을 보관할 구분소유자나 그 대리인은 규약에 다른 규정이 없으면 관리단집회의 결의로써 정한다.
③ 이해관계인은 제1항에 따라 규약을 보관하는 자에게 규약의 열람을 청구하거나 자기 비용으로 등본의 발급을 청구할 수 있다.

2. 관리단집회(管理團集會)

(1) 집회의 권한

제31조(집회의 권한) 관리단의 사무는 이 법 또는 규약으로 관리인에게 위임한 사항 외에는 관리단집회의 결의에 따라 수행한다.

(2) 집회의 종류

① 정기관리단집회(定期管理團集會)

제32조(정기관리단집회) 관리인은 매년 회계연도 종료 후 3개월 이내에 정기관리단집회를 소집하여야 한다.

② 임시관리단집회(臨時管理團集會)

제33조(임시관리단집회) ① 관리인은 필요하다고 인정할 때에는 관리단집회를 소집할 수 있다.
② 구분소유자의 5분의 1 이상이 회의의 목적 사항을 구체적으로 밝혀 관리단집회의 소집을 청구하면 관리인은 관리단집회를 소집하여야 한다. 이 정수(定數)는 규약으로 감경할 수 있다.
③ 제2항의 청구가 있은 후 1주일 내에 관리인이 청구일부터 2주일 이내의 날을 관리단집회일로 하는 소집통지 절차를 밟지 아니하면 소집을 청구한 구분소유자는 법원의 허가를 받아 관리단집회를 소집할 수 있다.
④ 관리인이 없는 경우에는 구분소유자의 5분의 1 이상은 관리단집회를 소집할 수 있다. 이 정수는 규약으로 감경할 수 있다.

(3) 집회소집통지

제34조(집회소집통지) ① 관리단집회를 소집하려면 관리단집회일 1주일 전에 회의의 목적 사항을 구체적으로 밝혀 각 구분소유자에게 통지하여야 한다. 다만, 이 기간은 규약으로 달리 정할 수 있다.
② 전유부분을 여럿이 공유하는 경우에 제1항의 통지는 제37조제2항에 따라 정하여진 의결권을 행사할 자(그가 없을 때에는 공유자 중 1인)에게 통지하여야 한다.

제35조(소집절차의 생략) 관리단집회는 구분소유자 전원이 동의하면 소집절차를 거치지 아니하고 소집할 수 있다.

(4) 결의방법

① 결의사항

관리단집회는 원칙적으로 집회소집절차에 따라 통지한 사항에 관하여만 결의할 수 있다. 다만, 구분소유자 전원의 동의로 소집절차를 거치지 아니하고 소집된 관리단집회는 그러하지 아니하다.

② 의결권

> **제37조(의결권)** ① 각 구분소유자의 의결권은 규약에 특별한 규정이 없으면 제12조에 규정된 지분비율에 따른다.

③ 전유부분이 공유일 경우

㉠ **전유부분을 여럿이 공유하는 경우에는 공유자는 관리단집회에서 의결권을 행사할 1인을 정한다.**

㉡ 전유부분의 공유자는 서로 협의하여 공유자 중 1인을 관리단집회에서 의결권을 행사할 자로 정하여야 하고, 협의가 이루어지지 않을 경우 공유물의 관리에 관한 민법 제265조에 따라 전유부분 지분의 과반수로써 의결권 행사자를 정하여야 한다(또는 공유자 중 전유부분 지분의 과반수를 가진 자가 의결권 행사자가 된다)[2007마1734].

㉢ 지분이 동등하여 의결권행사자를 정하지 못할 경우에는 그 전유부분의 공유자는 의결권을 행사할 수 없으며, 의결권행사자가 아닌 공유자들이 지분비율로 개별적으로 의결권을 행사할 수도 없다[2007마1734].

④ 의결권행사방법

의결권은 서면이나 전자적 방법으로 또는 대리인을 통하여 행사할 수 있다.

(5) 규약 및 집회의 결의의 효력

관리단집회에서 적법하게 결의된 사항은 그 결의에 반대한 구분소유자에 대하여도 효력을 미친다[94다49687].

제 9 절 재건축(再建築) 및 복구(復舊)

1. 재건축

(1) 재건축의 결의

① 재건축결의나 재건축결의의 내용을 변경함에 있어서는 관리단집회에서 구분소유자 및 의결권의 4/5 이상의 결의에 따른다.

② 재건축결의시 서면결의가 가능하고, 그와 같은 서면결의를 함에 있어서는 관리단집회가 소집 · 개최될 필요가 없음은 당연하다고 할 것이다[2005다68769, 68776].

③ 하나의 단지 내에 있는 여러 동의 건물 전부를 일괄하여 재건축하는 경우, 재건축결의는 개개의 각 건물마다 있어야 한다.

④ 집합건물법상 주거용 집합건물을 철거하고 상가용 집합건물을 신축하는 것과 같이 건물의 용도를 변경하는 형태의 재건축결의도 허용된다[2006다32217].

(2) 재건축절차

① 재건축불참자에 대한 서면 촉구

> **제48조(구분소유권 등의 매도청구 등)** ① 재건축의 결의가 있으면 집회를 소집한 자는 지체 없이 그 결의에 찬성하지 아니한 구분소유자(그의 승계인을 포함한다)에 대하여 그 결의내용에 따른 재건축에 참가할 것인지 여부를 회답할 것을 서면으로 촉구하여야 한다.

② 참가거절 간주

> **제48조(구분소유권 등의 매도청구 등)** ② 제1항의 촉구를 받은 구분소유자는 촉구를 받은 날부터 2개월 이내에 회답하여야 한다.
> ③ 제2항의 기간 내에 회답하지 아니한 경우 그 구분소유자는 재건축에 참가하지 아니하겠다는 뜻을 회답한 것으로 본다.

③ 구분소유권 등의 매도청구

> **제48조(구분소유권 등의 매도청구 등)** ④ 제2항의 기간이 지나면 재건축결의에 찬성한 각 구분소유자, 재건축결의내용에 따른 재건축에 참가할 뜻을 회답한 각 구분소유자(그의 승계인을 포함한다) 또는 이들 전원의 합의에 따라 구분소유권과 대지사용권을 매수하도록 지정된 자(이하 "매수지정자"라 한다)는 제2항의 기간 만료일부터 2개월 이내에 재건축에 참가하지 아니하겠다는 뜻을 회답한 구분소유자(그의 승계인을 포함한다)에게 구분소유권과 대지사용권을 시가로 매도할 것을 청구할 수 있다. 재건축결의가 있은 후에 이 구분소유자로부터 대지사용권만을 취득한 자의 대지사용권에 대하여도 또한 같다.

2. 공용부분의 복구(復舊)

(1) 건물가격의 2분의 1 이하에 상당하는 건물부분이 멸실된 경우

> **제50조(건물이 일부 멸실된 경우의 복구)** ① 건물가격의 2분의 1 이하에 상당하는 건물 부분이 멸실되었을 때에는 각 구분소유자는 멸실한 공용부분과 자기의 전유부분을 복구할 수 있다. 다만, 공용부분의 복구에 착수하기 전에 제47조 제1항의 결의나 공용부분의 복구에 대한 결의가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
> ② 제1항에 따라 공용부분을 복구한 자는 다른 구분소유자에게 제12조의 지분비율에 따라 복구에 든 비용의 상환을 청구할 수 있다.

(2) 건물가격의 2분의 1을 초과하는 건물부분이 멸실된 경우

제50조(건물이 일부 멸실된 경우의 복구) ④ 건물이 일부 멸실된 경우로서 제1항 본문의 경우를 제외한 경우(복구비용이 1/2을 초과한 경우)에 관리단집회는 구분소유자의 5분의 4 이상 및 의결권의 5분의 4 이상으로 멸실한 공용부분을 복구할 것을 결의할 수 있다.

참고학습 특별정족수

통상 의결정족수 (과반수)	① 공용부분의 관리에 관한 사항 ② 공용부분의 개량을 위한 것으로 과다한 비용이 들지 않는 경우 ③ 관리인의 선임 및 해임 ④ 휴양콘도미니엄의 공용부분의 변경
1/5 이상	임시관리단집회 소집청구
2/3 이상	공용부분의 변경에 관한 사항
3/4 이상	① 규약의 설정변경폐지 ② 구분소유자의 전유부분의 사용금지청구 ③ 구분소유권의 경매청구 ④ 전유부분의 점유자에 대한 인도청구
4/5 이상	① 권리변동을 내용으로 하는 공용부분의 변경 ② 재건축 결의, 재건축 결의사항 변경 ③ 건물가액의 1/2 초과 멸실의 경우 공용부분의 복구
전원	① 관리단집회 소집절차의 생략 ② 소집통지시 통지하지 않은 사항에 대한 의결